

adw. Marta Tomkiewicz-Januszewska

KONSTRUKCJA APELACJI KARNEJ

WARSZAWA 2023



IZBA ADWOKACKA
W WARSZAWIE



AUDEMUS IURA
NOSTRA DEFENDERE

KONSTRUKCJA APELACJI KARNEJ

adw. Marta Tomkiewicz-Januszewska

KONSTRUKCJA APELACJI KARNEJ

WARSZAWA 2023

IZBA ADWOKACKA
W WARSZAWIE



AUDEMUS IURA
NOSTRA DEFENDERE

Wydawca:
Izba Adwokacka w Warszawie
Al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa
ora.warszawa@adwokatura.pl
www.ora-warszawa.com.pl

Copyright Izba Adwokacka w Warszawie, 2023

Tytuł:
Konstrukcja apelacji karnej

Autorka:
adw. Marta Tomkiewicz-Januszewska

Projekt graficzny i skład tekstu:
Justyna Kramarz – Studio Grafpa
www.*grafpa*.pl

Projekt okładki:
Justyna Kramarz

Zezwalamy na udostępnienie okładki książki w Internecie

ISBN 978-83-967277-0-1

Słowo wstępne od autorki

Prac naukowych lub publicystycznych z zakresu prawa karnego, przygotowanych przez wybitnych praktyków i przedstawicieli doktryny prawa karnego, na rynku wydawniczym jest wiele. Niniejsza publikacja jest o tyle specyficzna, że opracowana została w oparciu o notatki jej autorki z zajęć repetytoryjnych dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, przygotowujących do egzaminu zawodowego. Jest zatem tym, co studenci określiliby mianem „*skryptu przedegzaminacyjnego*”.

Z całą pewnością nie jest to opracowanie stricte naukowe, choć jego autorka prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu prawa karnego, nie tylko dla aplikantów adwokackich, ale także na uczelniach wyższych. Publikacja ma wspomóc w nauce przedegzaminacyjnej w szczególności tych aplikantów adwokackich, którzy nie zajmują się prawem karnym w swojej praktyce zawodowej. To zatem raczej zbiór podstawowych informacji na temat zasad konstruowania zarzutów, ich treści i wniosków apelacyjnych, aniżeli praca naukowa kompleksowo omawiająca – nierzadko rodzące szereg problemów praktycznych – zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego.

By w możliwie jak najbardziej przystępnej i skondensowanej formie przedstawić podstawowy zakres wiedzy, opracowanie w wielu fragmentach skonstruowane zostało w formie pytań i odpowiedzi. Tam, gdzie wydaje się to wskazane, autorka posługuje się praktycznymi przykładami, także negatywnymi, aby pokazać skutki najczęściej popełnianych błędów.

Karnistą/ką nie chce i nie musi być każdy, co zrozumiałe. Każdy jednak z przyszłych adwokatów musi zdać egzamin zawodowy, który obejmuje 5 działów wiedzy prawniczej (prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne i etyka adwokacka). Sam egzamin jest bardzo wymagający, a ogrom wiedzy jaką trzeba przyswoić jest przytłaczający. Okazuje się, że w ferworze wielomiesięcznych przygotowań nie pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby zapoznać się z orzecznictwem, co powoduje, że często zarzuty apelacyjne merytorycznie ukierunkowane są w zupełnie odmienną stronę aniżeli podąża utrwalona linia orzecznicza. Błędy tego

rodzaju wydatnie wpływają na ocenę końcową pracy, o ile nie przesądzają czasem o samym wyniku egzaminu.

Starając się zatem znaleźć rozwiązanie powyższych problemów, poza omówieniem podstawowych zasad konstruowania zarzutów i wniosków apelacji, w niniejszej publikacji autorka zebrała najistotniejsze tezy orzecznicze Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w Polsce w odniesieniu do poszczególnych omawianych zagadnień. Moim zamierzeniem było ułatwienie aplikantom przygotowania się do egzaminu zawodowego. Wszystkie zawarte w publikacji orzeczenia zacytowane zostały w kluczowych fragmentach, przy czym są to wierne cytaty z uzasadnień danych rozstrzygnięć, nie zaś przekopiowane tezy z internetowych programów prawniczych. Niektóre orzeczenia przytoczone zostały w obszernych fragmentach, co jest zabiegiem celowym. Nie chciałam bowiem skracać merytorycznych treści wtedy, gdy coś wydawało mi się interesujące i przydatne do zgłębienia danego zagadnienia na poziomie choć podstawowym. Dodatkowo na podstawowym poziomie omówione zostały także wybrane przez autorkę merytoryczne zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego, po to aby unikać najczęściej pojawiających się błędów w tym zakresie.

Wyrażając nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się przydatna w przygotowaniach do egzaminu zawodowego, w tym miejscu życzę wszystkim zdającym egzamin zawodowy oraz rozpoczynającym samodzielną praktykę **POWODZENIA!**

Spis treści

Słowo wstępne od autorki	5
Wykaz literatury	11
Wykaz skrótów	12
Rozdział 1. Wprowadzenie	13
Rozdział 2. O jakich wymogach formalnych należy pamiętać, konstruując petitum apelacji?	15
Ad. 2.1. Czy apelacja wniesiona jest do właściwego sądu?	15
Ad. 2.2. Czy apelacja wniesiona jest w terminie?	16
Ad. 2.3. Czy apelacja wniesiona została przez osobę uprawnioną? ...	19
Ad. 2.4. Czy właściwie przywołano odpowiednie podstawy prawne? .	22
Ad. 2.5. Czy załączono wymaganą przepisami Kodeksu postępowania karnego liczbę odpisów apelacji?	24
Rozdział 3. Kierunek i zakres zaskarżenia.	27
Ad. 3.1. Kierunek zaskarżenia	27
Ad. 3.2. Zakres zaskarżenia.	29
Rozdział 4. Dodatkowe uwagi, będące wynikiem błędów w pracach egzaminacyjnych	39
Rozdział 5 Podsumowanie wymogów formalnych i przykładowe petitum apelacji.	41
Rozdział 6. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze	45
Ad. 6.1. Gradacja „ważności” zarzutów:	45
Ad. 6.2. Właściwa konstrukcja zarzutów z art. 439 § 1 k.p.k. i z art. 438 k.p.k.	47
Ad. 6.2.1. Właściwa konstrukcja zarzutu bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 § 1 k.p.k.)	47
Ad. 6.2.2. Właściwa konstrukcja zarzutów z art. 438 k.p.k.	50

Ad. 6.2.2.1. Konstrukcja zarzutu obrazy prawa materialnego. . .	52
Ad. 6.2.2.2. Konstrukcja zarzutu obrazy prawa procesowego oraz zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych:	54
Ad. 6.2.2.3. Obraza prawa procesowego a błąd w ustaleniach faktycznych	56
Ad. 6.2.2.4. Konstrukcja zarzutu rażąco niewspółmiernej kary (uzupełniona o uwagi co do merytorycznych podstaw formułowania zarzutów z art. 438 pkt 4 k.p.k.)	61
Ad. 6.3. Bezwzględne przyczyny odwoławcze z art. 439 § 1 k.p.k. . . .	68
Ad. 6.3.1. W wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. – art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.	69
Ad. 6.3.2. Sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie – art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.	75
Ad. 6.3.3. Sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego – art. 439 § 1 pkt 3 k.p.k.	81
Ad. 6.3.4. Sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu – art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.	82
Ad. 6.3.5. Orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie – art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.	87
Ad. 6.3.6. Orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu – art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k.	89
Ad. 6.3.7. Zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie – art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.	92
Ad. 6.3.8. Orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone – art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.	100

Ad. 6.3.9. Zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11 k.p.k. – art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.;	108
Ad. 6.3.10. Oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k. lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy – art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.;	145
Ad. 6.3.11. Sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa – art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.	152
 Rozdział 7. Zasadność sformułowania zarzutu obrazy prawa materialnego; czym są tzw. zarzuty „mieszane”?	
Ad. 7.1. Zarzut obrazy z art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.	157
Ad. 7.2. Obraza prawa materialnego z art. 438 pkt 1 k.p.k. a obraza prawa materialnego z art. 438 pkt 1a k.p.k.	169
Ad. 7.3. Jakie błędy procesowe – zgodnie ze stanowiskiem judykatury – nie stanowią obrazy prawa materialnego?:	175
Ad. 7.4. Niedopuszczalność konstruowania tzw. zarzutów „mieszanych” ...	179
 Rozdział 8 Wnioski apelacji	
Ad. 8.1. Prawidłowa konstrukcja wniosku apelacji przy uwzględnieniu obecnego brzmienia art. 437 § 1 i 2 k.p.k.;	189
Ad. 8.2. Wniosek apelacji w przypadku wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej	207
Ad. 8.3. Powołanie nowych faktów lub dowodów w apelacji	210
Ad. 8.4. Ponowienie w apelacji wniosków dowodowych, które podlegały oddaleniu na etapie postępowania przed Sądem I instancji	217
 Rozdział 9. Najczęstsze zarzuty oraz zagadnienia apelacyjne w oparciu o zasady wypracowane przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne	
Ad. 9.1. Czy zasady procesowe mogą być podstawą zarzutu apelacyjnego?	219

Ad. 9.2. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 5 § 2 k.p.k. i czy prawidłowe jest łączenie tego zarzutu z art. 7 k.p.k. albo z art. 410 k.p.k.	221
Ad. 9.3. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k.?	226
Ad. 9.4. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 6 k.p.k.?	237
Ad. 9.5. Czy w apelacjach karnych można formułować zarzuty obrazy prawa cywilnego?	250
Ad. 9.6. Czy w apelacji zasadne jest formułowanie zarzutu obrazy art. 424 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.k.?	256
Ad. 9.7. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 410 k.p.k.?	260
Ad. 9.8. Czy właściwe jest formułowanie w apelacji zarzutu obrazy art. 167 k.p.k.?	266
Ad. 9.9. Postanowienie o oddaleniu wniosków dowodowych jako kazus na egzaminie adwokackim?	270
Ad. 9.10. W jaki sposób w apelacji kwestionujemy zamiar sprawczy?	275
Ad. 9.11. W jaki sposób w apelacji kwestionujemy nieskorzystanie przez sąd z możliwości zastosowania fakultatywnej instytucji prawa karnego?	284
Ad. 9.12. Czy art. 53 k.k. może być podstawą zarzutu apelacyjnego?	287
Ad. 9.13. Czy art. 115 § 2 k.k. może być podstawą zarzutu apelacyjnego?	290
Ad. 9.14. Formułowanie zarzutu obrazy art. 193 § 1 k.p.k. a zarzutu obrazy art. 201 k.p.k.?	295
Ad. 9.15. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu i wyjście poza granice aktu oskarżenia?	305
Ad. 9.16. Brak kompletu znamion w opisie czynu przypisanego oskarżonemu a apelacja tylko do co kary ze strony oskarżyciela posiłkowego	318
Rozdział 10. Jak czytać akta egzaminacyjne na egzaminie zawodowym?	323

Wykaz literatury

- Eichstaedt K.*, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 89 k.p.k., opubl. LEX/el 2022
- Gajowniczek – Pruszyńska K., Tomkiewicz M.*, Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów, C. H. Beck, Warszawa 2021
- Kapiński Z.*, Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2021
- Kurowski M.*, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 6 k.p.k., Lex/el 2022
- Lipiński K.*, Łączenie i mieszanie zarzutów apelacji karnej, *Palestra* 1/2020, s. 40-53
- Świecki D.*, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 438 k.p.k., Lex/el 2022
- Zabłocki S.*, [w:] Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Tom IV, Warszawa 2021

Wykaz skrótów

1. Akty prawne

k.k.	ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny
k.k.s.	ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy
k.k.w.	ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
Konstytucja RP ...	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.
k.p.c.	ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
k.p.k.	ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego
k.p.w.	ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
PrAdw	ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o advokaturze

2. Organy i publikatory

Dz.U.	Dziennik Ustaw
NSA	Naczelny Sąd Administracyjny
OSNKW	Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa
OSNPG	Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo Pro- kuratury Generalnej
Pal.	Palestra
PiP	Państwo i Prawo
Prok. i Pr.	Prokuratura i Prawo
RP	Rzeczpospolita Polska
SA	Sąd Apelacyjny
SN	Sąd Najwyższy
TK	Trybunał Konstytucyjny
WSA	Wojewódzki Sąd Administracyjny
ETPC	Europejski Trybunał Praw Człowieka

Rozdział 1.

Wprowadzenie

Prawidłowe skonstruowanie apelacji w postępowaniu karnym nie jest zadaniem łatwym. Jeśli jednak wystarczająco dobrze znamy przepisy prawa karnego procesowego i materialnego, a także pamiętamy o pewnych podstawowych zasadach związanych z konstruowaniem zarzutów oraz wniosków apelacji, zadanie to przestanie być tak bardzo skomplikowane.

Zaakcentowania wymaga w szczególności podstawowa zasada, że skoro w apelacji kwestionujemy naruszenie jakichś nakazów czy zakazów, wynikających z k.p.k. czy reguł wynikających z prawa karnego materialnego, to brak dobrej znajomości tych przepisów (a zatem tego, jak sąd powinien postąpić właściwie, a czego mu zrobić nie wolno), czyni wręcz niemożliwym prawidłowe skonstruowanie zarzutów apelacji.

WNIOSEK – aby sporządzić prawidłową apelację, trzeba dobrze orientować się w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego. Przedmiotem każdego zarzutu jest bowiem twierdzenie, że sąd naruszył określony w Kodeksie postępowania karnego bądź Kodeksie karnym zakaz albo nakaz określonego działania.

Bez znajomości zatem np. art. 186 § 1 zd. 2 k.p.k. nie sformułujemy zarzutu obrazy tego przepisu, jeśli sąd ujawni na rozprawie zeznania złożone przez osobę, która skorzystała z uprawnienia z art. 182 § 1 k.p.k. (prawo do odmowy złożenia zeznań, przysługujące osobie najbliższej dla oskarżonego).

Rozdział 2.

O jakich wymogach formalnych należy pamiętać, konstruując petitum apelacji?

1. czy apelacja wniesiona jest do właściwego sądu;
2. czy apelacja wniesiona jest w terminie;
3. czy apelacja wniesiona została przez osobę uprawnioną;
4. czy właściwie przywołano odpowiednie podstawy prawne (w odniesieniu do samego wniesienia środka odwoławczego, konstruowanych zarzutów oraz formułowanych wniosków);
5. czy załączono wymaganą przepisami Kodeksu postępowania karnego liczbę odpisów apelacji;

Podkreślenia wymaga, że **wszystkie ww. kwestie podlegają ocenie na egzaminie zawodowym, a błędy akurat w tym zakresie są stosunkowo łatwe do uniknięcia.**

Ad. 2.1. Czy apelacja wniesiona jest do właściwego sądu?

Apelację wnosimy do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji.

Jeśli zatem wyrok, wydany został przez Sąd Rejonowy jako sąd I instancji, to w apelacji wskazujemy: „*Sąd Okręgowy w ... za pośrednictwem Sądu Rejonowego w...*”. Natomiast, jeśli w I instancji orzekł Sąd Okręgowy, wówczas wskazujemy: „*Sąd Apelacyjny w... za pośrednictwem Sądu Okręgowego w...*”.

W praktyce kopertę, zawierającą środek zaskarżenia, adresujemy do sądu I instancji, który po sprawdzeniu formalnych warunków wniesionego środka odwoławczego (czy wniesiony został w terminie, przez umocowany podmiot itp.), przekaże apelację wraz z aktami do Sądu II instancji.

Zaznaczenia jednocześnie wymaga, że z art. 125 k.p.k. wynika, że pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora, organu Policji albo innego organu postępowania przygotowawczego uważa się

za wniesione z zachowaniem terminu. Mając jednak na uwadze cel egzaminu jakim jest weryfikacja wiedzy zdających, wydaje się uzasadnionym przyjęcie założenia, że zasada ta nie obowiązuje na egzaminie zawodowym. Wniesienie apelacji do niewłaściwego sądu będzie bowiem błędem pracy, który ze znacznym prawdopodobieństwem wpłynie na obniżenie oceny, choć w praktyce działanie apelującego bezsprzecznie pozostawałoby pod ochroną art. 125 k.p.k.

Ad. 2.2. Czy apelacja wniesiona jest w terminie?

Termin na wniesienie apelacji – zgodnie z art. 445 § 1 k.p.k. – wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku sądu I instancji wraz z uzasadnieniem uprawnionemu podmiotowi (np. obrońcy oskarżonego bądź bezpośrednio oskarżonemu, jeśli na etapie wydawania wyroku występował w sprawie bez obrońcy). W warunkach egzaminacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na wytyczne zadania egzaminacyjnego, w których z reguły wskazywane jest w jakim dniu doręczono uprawnionemu podmiotowi odpis wyroku wraz z uzasadnieniem. Może mieć to znaczenie wtedy, kiedy data egzaminu jest znacząco różna niż data doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, wynikająca z treści zadania egzaminacyjnego.

ALE! Pamiętajmy także o WYJĄTKACH z zakresu postępowania nakazowego i postępowania przyspieszonego¹ – art. 517h § 1 k.p.k. w zw. z art. 517h § 3 k.p.k., art. 506 § 1 k.p.k.

Art. 517h k.p.k.:

§ 1.

Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku może być złożony na piśmie w terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku,

¹ Na marginesie zaakcentowania wymaga również odmienna regulacja w sprawach o wykroczenia – w art. 105 k.p.w., ustawodawca wskazał bowiem, że: § 1 Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej; § 1a. W wypadku, gdy uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia (...).

a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie wyroku – od daty jego doręczenia. Wniosek można również złożyć ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia (...).

§ 3.

Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem (...).

Art. 506 k.p.k.:

§ 1

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku (...).

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 429 § 1 k.p.k., prezes sądu I instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy. Co więcej, nawet gdyby Prezes sądu I instancji nie dostrzegł, że środek wniesiony został po terminie albo przez osobę nieuprawnioną i przyjął apelację obarczoną takimi błędami, to – zgodnie z art. 430 § 1 k.p.k. – Sąd odwoławczy pozostawi bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 429 § 1 k.p.k. albo jeżeli przyjęcie tego środka nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu. Niezależnie zatem od praktycznych skutków niewniesienia środka odwoławczego w terminie albo przez osobę nieuprawnioną, w warunkach egzaminacyjnych błędy w tym zakresie z całą pewnością wpłyną na obniżenie oceny pracy.

W tym miejscu przypomnieć należy, że zgodnie z art. 123 k.p.k.

§ 1.

Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin.

§ 2.

Jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który odpowiada początkowi terminu; jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, koniec terminu przypada na ostatni dzień tego miesiąca.

§ 3.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy lub na sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przykład I: jeśli doręczono nam wyrok wraz z uzasadnieniem we wtorek 3 sierpnia 2021 r., to termin 7-dniowy i 14-dniowy upłynie również we wtorek (dokładnie o północy z wtorku na środę), tyle że 7-dniowy w dniu 10 sierpnia 2021 r., zaś 14-dniowy w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Przykład II: gdyby doręczono nam wyrok z uzasadnieniem w sobotę 7 sierpnia 2021 r., wówczas termin 14-dniowy upływałby (stosownie do treści art. 123 § 3 *in fine* k.p.k.) w poniedziałek 23 sierpnia 2021 r. (albowiem jest to następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).

Na marginesie warto odnotować, że w wyniku nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r., która weszła w życie 5 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1694), do art. 123 § 3 k.p.k. – obok dni wolnych od pracy – dodano sobotę, zrównując ten dzień w skutkach procesowych z dniem „*uznawanym przez ustawę za dzień wolny od pracy*”. Nieaktualne pozostają zatem wszelkie wcześniejsze wątpliwości praktyczne w tym zakresie².

Przydatne orzecznictwo:

- *Przyzwolenie na uzupełnienie przez stronę apelacji w postaci rozszerzenia zakresu zaskarżenia i podniesienia nowych zarzutów po upływie terminu określonego art. 445 § 1 k.p.k., byłoby swoistym przedłużeniem terminu do jej wniesienia (zob. post SN z 10 grudnia 2003 r., V KK 195/03, OSNKW 2004, Nr 3, poz. 25; zob. też wyrok SA w Krakowie*

² Przed ww. zmianą przepisów stanowisko judykatury w odniesieniu do soboty wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt IV KK 50/19), zgodnie z którym podkreślono, że *jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia. Rzecz jednak w tym, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) a więc także w rozumieniu art. 123 k.p.k.*

z dnia 10 listopada 2004 r., II AKa 225/04) – wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2019 r., sygn. akt II KK 178/18

- *Zatem jeżeli termin do wniesienia zażalenia dla strony mija w dniu późniejszym niż dla pełnomocnika lub obrońcy, ten ostatni może skutecznie wnieść zażalenie w tym dłuższym terminie. Wynika to nie tylko z zasygnalizowanej wcześniej „jedności” sprawy stojącej u podstaw decyzji procesowej i środka odwoławczego, ale także z faktu, iż dopiero po uzyskaniu orzeczenia i zapoznaniu się z nim strona może podjąć decyzję o wniesieniu środka odwoławczego – postanowienie Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III KZ 79/15*
- (...) *treść przepisu art. 123 § 3 k.p.k. stanowi, że jeśli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia. Nie jest więc tak, jak to podnosi oskarżony, że licząc termin do wniesienia środka odwoławczego, z terminu tego należy eliminować takie dni wolne od pracy, jak soboty i niedziele. Tylko wtedy, jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, to czynność można wykonać następnego dnia. W pozostałych przypadkach, jeżeli w 7 – dniowym terminie mieszczą się soboty i niedziele, to je również uwzględnia się przy obliczaniu terminu. Tym samym więc, samego przekonania oskarżonego, iż do czasu, w jakim ma złożyć wniosek, nie zalicza się sobót i niedziel oraz, że termin obejmuje tylko dni robocze, nie można uznać za okoliczność usprawiedliwiającą uchybienie – postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt II AKz 456/15*

Ad. 2.3. Czy apelacja wniesiona została przez osobę uprawnioną?

Kwestię należytego umocowania należy rozpatrywać na kilku niezależnych płaszczyznach, pamiętając o podstawowej zasadzie, wynikającej z art. 425 § 1 k.p.k.³

³ Art. 425 § 1 k.p.k. stanowi, że od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy.

Po pierwsze, w **warunkach egzaminacyjnych należy pamiętać, by zadanie „podpisać” takimi fikcyjnymi danymi, jakie wprost wynikają z zadania egzaminacyjnego**. Pełna i skrupulatnie przestrzegana anonimizacja danych osobowych, obowiązująca podczas egzaminu zawodowego, wyklucza możliwość posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem w treści sporządzanej apelacji. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na treść wytycznych egzaminacyjnych, gdzie wskazywane są fikcyjne dane osobowe adwokata, którymi zdający powinien się posłużyć, sporządzając apelację (np. adw. Jan Zetowski czy adw. Katarzyna Nowak). Nie należy również podpisywać sporządzonego środka odwoławczego własnoręcznie⁴.

Po drugie, w **warunkach egzaminacyjnych należy zwrócić także szczególną uwagę na to, czy z zadania egzaminacyjnego wynika, że obrońca (bądź pełnomocnik) występował na etapie postępowania przed sądem I instancji, czy też umocowany został już po wydaniu wyroku (i składał wnioszek o uzasadnienie), czy wreszcie – ma on dopiero załączyć upoważnienie do obrony (pełnomocnictwo) wraz z wniesieniem środka odwoławczego**. Jeśli z akt zadania egzaminacyjnego wynika, że obrońca (bądź pełnomocnik) złożył już upoważnienie do obrony (albo odpowiednio pełnomocnictwo), to wówczas należy pamiętać, by w *petitum* apelacji odwołać się do tego dokumentu („*upoważnienie do obrony/pełnomocnictwo, w aktach*”). Jeśli natomiast obrońca (pełnomocnik) umocowany został na dalszym etapie postępowania i upoważnienie do obrony (pełnomocnictwo) przedkłada wraz z apelacją, należy pamiętać o załączeniu dokumentu, potwierdzającego owo umocowanie („*upoważnienie do obrony/pełnomocnictwo, w załączeniu*”) i dodatkowo wymienić ten dokument w załącznikach do apelacji.

Po trzecie, w ***petitum* apelacji należy precyzyjnie wskazać kto ten środek odwoławczy wnosi**, tj. „*Działając jako obrońca oskarżonego X (upoważnienie do obrony w aktach sprawy/w załączeniu), zaskarżam wyrok.../ „Działając jako pełnomocnik X (pełnomocnictwo w aktach sprawy/w załączeniu), zaskarżam wyrok...*”.

⁴ Wystarczające jest wpisanie elektronicznie w miejscu, gdzie powinien znajdować się podpis autora apelacji formuły: „*W tym miejscu odręczny podpis adw. Jana Kowalskiego*”.

Na marginesie zwracam uwagę, że w procesie karnym niewłaściwe jest posługiwanie się przez obrońcę (nad wyraz często używaną przez zdających) formułą „*reprezentujący oskarżonego*”, „*zastępując oskarżonego*” czy „*działający w jego imieniu i na jego rzecz*”. Przypomnieć należy, że w procesie karnym obrońca nie zastępuje oskarżonego, albowiem w swoich decyzjach procesowych jest samodzielny i niejako odrębny od oskarżonego (oczywiście, przy zachowaniu reguły działania na korzyść oskarżonego i w zgodzie z zasadami deontologii zawodowej). Możliwa jest bowiem sytuacja, w której oskarżony ma odmienne stanowisko procesowe od swojego obrońcy (np. oskarżony wnosi o „*łagodne skazanie*”, zaś obrońca o uniewinnienie), z czym nie mielibyśmy do czynienia np. na gruncie procesu cywilnego, gdzie pełnomocnik – działając w imieniu i na rzecz mocodawcy – prezentuje z mocodawcą jedno stanowisko.

Dlatego przy konstruowaniu apelacji jako obrońca, sugerowane jest posługiwanie się ww. formułą „***Działając jako obrońca oskarżonego X (upoważnienie do obrony w aktach sprawy/w załączeniu), zaskarżam wyrok...***”, która wyklucza ww. wątpliwości.

Przydatne orzecznictwo:

- Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., I KZP 10/10, OSNKW 2010, z. 10, poz. 84 *rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców. Akceptując ten pogląd prawny, stwierdzić zatem należy, że M. M., matka małoletniego N. Ż. z uwagi na uregulowanie art. 98 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie może działać jako osoba wykonująca prawa osoby pokrzywdzonej, a zatem i nie może reprezentować tej strony w procesie karnym. W tej sytuacji czynność procesową w postaci wniesienia kasacji przez pełnomocnika ustanowionego przez osobę, która nie może wykonywać praw pokrzywdzonego należy ocenić jako bezskuteczną, albowiem kasacja została wniesiona przez osobę nieuprawnioną (por. wyrok SN z dnia 1 grudnia 2010 r., III KK 315/09, LEX nr 686665; art. 520§ 1 k.p.k.), co musi skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania w oparciu o przepis art. 531 § 1 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k.). Podkreślić przy*

tym należy, że to, iż jej apelację także rozpoznał Sąd odwoławczy, nie zwalnia Sądu Najwyższego od oceny statusu osoby wnoszącej kasację (...) – postanowienie Sądu Najwyższego z 18 października 2011 r., sygn. akt V KK 209/11

- *Wśród braków pisma procesowego powodujących wezwanie osoby, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku, wymieniony został brak polegający na niezłożeniu upoważnienia do podjęcia czynności procesowej. Niespełnienie wymagań związanych z wniesieniem pisma – w tym przypadku brak upoważnienia do podjęcia czynności – zawsze powoduje konieczność zastosowania omawianego przepisu – postanowienie Sądu Najwyższego z 8 października 2002 r., sygn. akt IV KKN 317/98*

Ad. 2.4. Czy właściwie przywołano odpowiednie podstawy prawne?

W kontekście podstaw prawnych wskazywanych w *petitum* apelacji, należy w szczególności pamiętać o właściwych przepisach odnoszących się odpowiednio do:

- A) podstawy prawnej wnoszonego środka odwoławczego;
- B) podstaw prawnych zarzutów apelacji;
- C) podstaw prawnych wniosków apelacji:

ad. A. Podstawę prawną wniesienia apelacji stanowi: **art. 444 § 1 k.p.k. oraz art. 425 § 1 i 2 k.p.k.** W konsekwencji, w *petitum* wskazujemy „Na podstawie art. 444 § 1 k.p.k. w zw. z art. 425 § 1 i 2 k.p.k., zaskarżam wyrok...”.

ad. B. Podstawę prawną zarzutów apelacyjnych może stanowić co do zasady: **art. 427 § 2 k.p.k. w związku z art. 438 (pkt 1–4) k.p.k. lub art. 439 § 1 k.p.k.** W konsekwencji, w *petitum* wskazujemy: „Na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 (pkt 1–4) k.p.k., zaskarżonemu wyrokowi zarzucam obrazę art. ...”/ Na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 (pkt...) k.p.k., zaskarżonemu wyrokowi zarzucam obrazę art. ...”. To, jaki dokładnie zarzut należy w danych okolicznościach sformułować, omówione zostanie w dalszej

części niniejszego opracowania, w podrozdziale zatytułowanym „Zasady konstruowania zarzutów apelacyjnych”.

Na marginesie, zwracam uwagę na używanie właściwej terminologii. Po pierwsze, Kodeks postępowania karnego posługuje się w art. 438 k.p.k. pojęciem „*obraza przepisów*” – odmiennie zatem aniżeli Kodeks postępowania cywilnego, gdzie mowa jest o „*naruszeniu przepisów*”. Na potrzeby egzaminu warto o tym pamiętać, wskazując w *petitum* apelacji: „*Na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 (pkt 1–4) k.p.k., zaskarżonemu wyrokowi zarzucam obrazę art. ...*”.

Po drugie, w apelacji **zarzuty kierujemy wobec rozstrzygnięcia sądu, nie zaś wobec sądu czy sędziego personalnie⁵, a nasze zarzuty odnosimy bezpośrednio do wyroku, nie zaś aktu oskarżenia**. W konsekwencji, nieprawidłowe jest często pojawiające się w pracach egzaminacyjnych sformułowanie: „*zarzucam sądowi obrazę art...*” (powinno być „*ww. wyrokowi zarzucam obrazę art...*”) czy też „*zarzucam obrazę art. 7 k.p.k. w odniesieniu do pierwszego czynu z aktu oskarżenia*”. Wreszcie, należy pamiętać także o precyzyjnym określeniu w *petitum* apelacji, jaki wyrok podlega zaskarżeniu – „*(...) zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego w ..., ... Wydział Karny z dnia ..., wydany w sprawie o sygn. akt ..., którego odpis wraz z uzasadnieniem doręczony został obrońcy w dniu...*”.

Ad. C. Podstawę prawną wniosków apelacyjnych stanowi co do zasady: **art. 427 § 1 k.p.k. oraz art. 437 § 1 i 2 k.k.** W konsekwencji, w *petitum* wskazujemy: „*Mając na uwadze powyższe zarzuty, na podstawie art. 427 § 1 k.p.k. w zw. z art. 437 § 1 i 2 k.p.k., wnoszę o...*”.

Kwestia powołania w apelacji nowych faktów lub dowodów oraz ponowienia wniosków, które podlegały oddaleniu na etapie postępowania przed Sądem I instancji szerzej omówiona została w dalszej części pracy (zob. podrozdział 8.3. i 8.4.).

⁵ Dla jasności wyводу zaznaczenia wymaga, że omawiane w tym miejscu uwagi nie odnoszą się do specyficznych ze swej istoty zarzutów naruszenia obiektywizmu bądź obrazy art. 41 k.p.k. w odniesieniu do konkretnego sędziego, w których to przypadkach w oczywisty sposób zarzutu skierowane byłyby personalnie do osoby sędziego bądź ławnika.

Ad. 2.5. Czy załączono wymaganą przepisami Kodeksu postępowania karnego liczbę odpisów apelacji?

Z **art. 446 § 2 k.p.k.** wynika, że *do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis*. Pamiętać należy, że w postępowaniu karnym, po wniesieniu aktu oskarżenia, stronami postępowania są: oskarżony, oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy (albo oskarżyciel prywatny w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego). Jeśli z akt zadania egzaminacyjnego wynika, że w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego występował pokrzywdzony, ale nie złożył oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, to nie jest stroną postępowania sądowego i tym samym, nie załączamy dla niego dodatkowego odpisu apelacji.

Należy także pamiętać o treści **art. 140 k.p.k.**, zgodnie z którym odpisy, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom. W praktyce oznacza to, że jeśli oskarżyciel posiłkowy reprezentowany jest przez pełnomocnika, wówczas należy załączyć jeden dodatkowy odpis dla pełnomocnika, zgodnie z ww. art. 140 k.p.k.

Przykład I: jeśli w sprawie zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Rejonowego występował: oskarżyciel publiczny, oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, to – wnosząc apelację jako obrońca – należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza dwa odpisy apelacji (dla oskarżyciela publicznego i oskarżyciela posiłkowego). Jeśli natomiast w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego występował tylko oskarżony i oskarżyciel publiczny, należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza jeden odpis apelacji.

Przykład II: jeśli w sprawie zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Rejonowego występował: oskarżyciel publiczny, oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, reprezentowany przez pełnomocnika, to – wnosząc apelację jako obrońca – należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza trzy odpisy apelacji (jeden dla oskarżyciela publicznego, jeden dla oskarżyciela posiłkowego i jeden dla jego pełnomocnika, stosowanie do art. 140 k.p.k.). Jeśli natomiast

w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego występował tylko oskarżony i oskarżyciel publiczny, należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza jeden odpis apelacji.

Przykład III: jeśli w sprawie zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Okręgowego występował: oskarżyciel publiczny, oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, to – wnosząc apelację jako obrońca – należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza trzy odpisy apelacji (po jednym dla oskarżyciela publicznego i oskarżyciela posiłkowego jako stron przeciwnych oraz jeden dodatkowy, o jakim mowa w ww. art. 446 § 2 zd. 2 k.p.k.). Jeśli natomiast w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego występował tylko oskarżony i oskarżyciel publiczny, należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza dwa odpisy apelacji (dla oskarżyciela publicznego i jeden dodatkowy, o jakim mowa w ww. art. 446 § 2 zd. 2 k.p.k.).

Przykład IV: jeśli w sprawie zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Okręgowego występował: oskarżyciel publiczny, oskarżony i oskarżyciel posiłkowy, reprezentowany przez pełnomocnika, to – wnosząc apelację jako obrońca – należy w załącznikach do apelacji wskazać, że zdający załącza cztery odpisy apelacji (jeden dla oskarżyciela publicznego, jeden dla oskarżyciela posiłkowego, jeden dla jego pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, stosowanie do art. 140 k.p.k. oraz jeden dodatkowy, o jakim mowa w ww. art. 446 § 2 zd. 2 k.p.k.).

Zaznaczenia również wymaga, że apelacja sporządzona przez profesjonalistę powinna zawierać zarzuty. Dalsza część publikacji poświęcona została temu właśnie zagadnieniu.

Rozdział 3.

Kierunek i zakres zaskarżenia

W każdej apelacji, niezależnie od tego, czy jest ona sporządzana na potrzeby egzaminu zawodowego, czy przygotowana w praktyce zawodowej, istotne jest prawidłowe określenie kierunku i zakresu zaskarżenia wyroku. Szczególnego znaczenia nabiera prawidłowe określenie zakresu zaskarżenia, a błędy w odniesieniu do tej kwestii – szczególnie w warunkach egzaminacyjnych – mogą być bardzo daleko idące w skutkach.

Ad. 3.1. Kierunek zaskarżenia

Stosownie do art. 425 § 3 i 4 k.p.k., (§3) *odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela publicznego.* (§ 4). *Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść oskarżonego.*

Kierunek zaskarżenia to zatem wskazanie przez apelującego czy zaskarża wyrok „na korzyść oskarżonego” czy też „na niekorzyść oskarżonego”. Pamiętać trzeba, że oskarżyciel publiczny, wobec treści art. 425 § 4 k.p.k., może wnieść środek odwoławczy tak na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, a oskarżyciel posiłkowy – na niekorzyść, to w odniesieniu do oskarżonego obrońca wnieść środek zaskarżenia tylko na korzyść; wynika to z treści art. 86 § 1 k.p.k., zgodnie z którym obrońca może podejmować czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.

W świetle brzmienia wyżej zacytowanej normy i zasad deontologii zawodowej, nie jest dopuszczalne wniesienie apelacji przez obrońcę „na niekorzyść” własnego klienta. Skonstruowanie zarzutów na niekorzyść oskarżonego prowadziłyby zatem do oceny negatywnej tak przygotowanego środka odwoławczego.

W praktyce niewskazanie przez obrońcę działania na korzyść oskarżonego raczej nie byłoby problemem (szczególnie, że sąd odwoławczy kierunek

apelacji jest w stanie „wyczytać” z treści sformułowanych w środku odwoławczym zarzutów). Tym niemniej na potrzeby egzaminu zawodowego należy pamiętać, by wskazywać w *petitum* apelacji obrońcy: „zaskarżam wyrok (...) w całości/w części na korzyść oskarżonego”. Brak tego wskazania może zostać uznany przez część egzaminatorów za brak określenia tego elementu w sporządzonej apelacji.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) zgodnie z art. 86 § 1 k.p.k. obrońca może przedsięwziąć czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Oznacza to, że jest niedopuszczalny z mocy ustawy i nie podlega rozpoznaniu wniesiony przez obrońcę zwykły środek odwoławczy, względnie nadzwyczajny środek zaskarżenia, werbalnie deklarujący zaskarżenie orzeczenia na korzyść oskarżonego, to o innym w istocie kierunku. Konsekwencje procesowe czynności podejmowanych przez obrońcę oskarżonego z naruszeniem zakazu wynikającego a contrario z art. 86 § 1 k.p.k., muszą być przy tym oceniane z uwzględnieniem układu procesowego, w jakim zostały podjęte (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1997 r., IV KKN 326/96, OSNKW 1997, z. 7–8, poz. 64) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 7 października 2020 r., sygn. akt IV KS 24/20**
- (...) ze względu na treść art. 425 § 3 k.p.k., nie było w ogóle możliwe zaskarżenie przez obrońcę D. R. orzeczenia w części uchylającej tymczasowe aresztowanie wobec ww. oskarżonego – ze względu na oczywisty brak *gravamen*. Jeśli jednak zdaniem obrońcy „nie było żadnych podstaw do przedłużenia tymczasowego aresztowania oskarżonego w okolicznościach niniejszej sprawy” i „postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania nie powinno zostać w ogóle wydane”, to przypomnieć wypada, iż racjonalny ustawodawca wszak przewidział w art. 552 § 4 k.p.k., odrębny tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Jak powszechnie przyjmuje się w literaturze i orzecznictwie, dla orzekania w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia – w ogóle nie jest niezbędne, by decyzja o zatrzymaniu (tymczasowym aresztowaniu) była zaskarżona (*vide* uzasadnienie

uchwały SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 5/06, OSNKW 2006, z. 6, poz. 55) – postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 17 czerwca 2020 r., sygn. akt II AKz 327/20

- *Nie jest natomiast dopuszczalne skarżenie przez oskarżonego czy jego obrońcę rozstrzygnięć dotyczących współoskarżonych i to jeszcze na ich niekorzyść – postanowienie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt IV KK 416/15, LEX nr 2069262*
- *Domaganie się określenia czasu trwania środka karnego w minimalnej wysokości (1 rok), w sytuacji gdy w wyroku okres obowiązywania tego środka nie został wcale określony (co do okresów obowiązywania środków karnych zobacz art. 43§1 k.k., art. 42§4 k.k.), jest zgodne z kierunkiem zaskarżenia (na korzyść skazanego), albowiem brak określenia w wyroku czasu trwania środka karnego sprawia, iż środek ten obowiązuje bez żadnych ograniczeń czasowych – wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2014 r., sygn. akt II KK 125/14*
- *(...) zmierzanie przez obrońcę do usunięcia takiego błędu orzeczenia, który wywiera jednoznacznie korzystne skutki dla interesów procesowych oskarżonego, nie jest dopuszczalne – postanowienie Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt II KK 193/12*

Ad. 3.2. Zakres zaskarżenia

Stosownie do treści art. 433 § 1 k.p.k., sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku odwoławczym zostały wskazane zarzuty stawiane rozstrzygnięciu – również w granicach podniesionych zarzutów, uwzględniając treść art. 447 § 1–3, a w zakresie szerszym – w wypadkach wskazanych w art. 435, art. 439 § 1, art. 440 i art. 455 k.p.k. Powyższe oznacza zatem, że **zasadą jest, że sąd II instancji rozpoznaje apelację w granicach zaskarżenia oraz w granicach formułowanych zarzutów**. Wyjątkowo, kontrola sądu odwoławczego „wyjdzie” poza te granice, jeśli zaistnieją szczególne okoliczności, o jakich mowa w art. 435 k.p.k., art. 439 § 1 k.p.k., art. 440 k.p.k. i art. 455 k.p.k.

W konsekwencji, będzie istotnym błędem, jeśli **zdający nieprawidłowo określi zakres zaskarżenia i poza zakresem tego zaskarżenia pozostawi**

np. jeden czyn bądź kwestię winy oskarżonego za ten czyn, a sąd odwoławczy nie dostrzeże w danej sprawie żadnego z ww. czterech szczególnych przypadków (o jakich mowa w art. 433 § 1 *in fine* k.p.k.). W takiej bowiem sytuacji sąd odwoławczy – nie widząc podstaw do wyjścia poza granice zaskarżenia – nie zbada sytuacji oskarżonego i w ogóle nie dokona kontroli odwoławczej w tym (pominiętym) zakresie.

Prawidłowe określenie granic zaskarżenia, szczególnie w warunkach egzaminacyjnych, nabiera zatem istotnego znaczenia, podobnie jak dostrzeżenie właściwych uchybień wyroku i prawidłowe sformułowanie wniosków apelacji. Wszystkie te elementy podlegają ocenie przez egzaminatorów, także w odniesieniu do ich wzajemnej spójności i z doświadczenia mogą stwierdzić, że zakres zaskarżenia stwarza zdającym znaczne problemy.

Art. 447 k.p.k. wskazuje że: (§ 1) Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku; (§ 2) Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych; (§ 3) Apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za zwróconą odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku.

Wskazanie granic zaskarżenia w poniższych dwóch przykładach przedstawia się następująco:

Przykład I: *zapada wyrok, w którym oskarżonemu przypisane zostało sprawstwo tylko jednego czynu, np. z art. 177 § 2 k.k. Oskarżony nie przyznawał się do winy.*

Odp.: Skoro zatem kwestionujemy przypisaną oskarżonemu winę, to stosownie do treści art. 447 § 1 k.p.k., nasz zakres zaskarżenia w apelacji powinien być określony jako odnoszący się do całości rozstrzygnięcia – tj. „*zaskarżam wyrok (...) w całości (...)*”.

Na marginesie rozważań warto wskazać, że **zaskarżenie wyroku w całości dla sądu odwoławczego oznacza, że kwestionujemy tak winę, jak i wszystkie**

pozostałe skutki skazania. Skoro bowiem twierdzimy, że brak jest zawinienia po stronie oskarżonego, to tym samym brak jest również podstaw, by orzekać wobec niego jakąkolwiek karę, środki karne czy kompensacyjne. Te są bowiem naturalnym skutkiem wydania wyroku, uznającego winę. Zupełnie wystarczające jest zatem w omawianej sytuacji wskazanie „*zaskarżam wyrok w całości*”, bez potrzeby wskazywania dodatkowych określeń, odnoszących się do orzekanych – jako konsekwencja wydania wyroku skazującego – kar, środków karnych, środków kompensacyjnych itd.

***Przykład II:** zapada wyrok, w którym oskarżonemu przypisane zostało sprawstwo tylko jednego czynu, np. z art. 177 § 2 k.k. Oskarżony przyznawał się do winy. Kwestionujemy jednak orzeczony środek karny w wymiarze 6 lat zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów, który jako obrońca uważamy za nieadekwatny do stopnia winy i okoliczności. Uważamy bowiem, że jest to rażąco surowy wymiar tego środka.*

Odp.: Skarżymy zatem wyrok „w części orzeczenia o środku karnym”/ „w części co do środka karnego”.

Zaznaczyć należy, że w odniesieniu do powyższych przykładów nie ma potrzeby szerszego opisywania zakresu zaskarżenia aniżeli używanie formuły „*zaskarżam w całości/w części co do orzeczonej kary czy środka karnego itp.*”. W szczególności nie ma potrzeby pisania „*zaskarżam wyrok w całości co do winy*”, skoro ze sformułowaniem „*w całości*” ustawodawca wprost łączy skutki, o których mowa w art. 447 § 1 k.p.k.

Na kanwie tego drugiego przykładu, podkreślić należy, że **dla sądu odwoławczego użycie przez apelującego sformułowania „zaskarżam wyrok w części (...)” jest jednoznaczne z niekwestionowaniem winy za sam czyn, co do którego te środki karne/kompensacyjne itd. zostały orzeczone.** Innymi słowy, jeśli sąd odwoławczy nie dostrzeże w danej sprawie żadnego z ww. czterech szczególnych przypadków, o jakich mowa w art. 433 § 1 *in fine* k.p.k., to tym samym – nie widząc podstaw do wyjścia poza granice zaskarżenia – nie będzie czynił przedmiotem kontroli odwoławczej winy

oskarżonego, skupiając się wyłącznie na objętej zakresie zaskarżenia karze/środkach karnych etc.

Należy zatem pamiętać, że **sformułowanie „w części” odnosi się do kary/środków karnych/środków kompensacyjnych, a nie do jednostek redakcyjnych wyroku (!)**, tj. punktów sentencji wyroku. Ta pozornie banalna myśl umyka często zdającym i w konsekwencji, staje się źródłem najczęstszych błędów o daleko idących skutkach, szczególnie wtedy gdy w wyroku, podlegającym zaskarżeniu, sąd uznał winę oskarżonego za więcej niż jeden czyn. Problemy, jakie mogą wynikać z nieuwzględnienie powyższych uwag, w najprostszy sposób zobrazują następujące przykłady:

Przykład III: zapada wyrok, w którym oskarżonemu przypisane zostało sprawstwo trzech czynów, np. (1). art. 177 § 1 k.k., (2). art. 280 § 1 k.k. i (3). art. 284 § 1 k.k. Oskarżony przyznawał się do winy co do 1 czynu i nie kwestionuje orzeczonej kary oraz środków karnych za ten czyn. Kwestionuje natomiast zawinienie w odniesieniu do drugiego czynu, zaś w kwestii czynu trzeciego wprawdzie oskarżony przyznał się do winy, jednak uważa, że orzeczona kara jest rażąco surowa.

Odp.: Prawidłowy zakres zaskarżenia w apelacji obrońcy powinien zostać sformułowany następująco: „**w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 2 wyroku, zaskarżam to rozstrzygnięcie w całości, zaś w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 3 wyroku, zaskarżam to rozstrzygnięcie w części orzeczenia o karze**”. Dla sądu odwoławczego taki zakres zaskarżenia oznacza, że:

- Pierwszego przypisanego czynu oskarżony nie kwestionuje w ogóle i o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 433 § 1 in fine k.p.k. (tj. rozpoznanie sprawy przez sąd z urzędu poza granicami apelacji), sąd nie będzie odnosił się w wyroku II instancji w ogóle do tego czynu, zaś wyrok w tym zakresie uprawomocni się;
- Oskarżony kwestionuje tak winę, jak i wszystkie inne rozstrzygnięcia odnoszące się do czynu z pkt 2 wyroku;
- Oskarżony nie kwestionuje winy i ustaleń faktycznych, stanowiących podstawę jej ustalenia za czyn z pkt 3 wyroku, negując jednak wysokość kary, jaka zapadła w tym stanie faktycznym.

Gdybyśmy zapomnieli o tym, że zakres zaskarżenia nie odnosi się do jednostek redakcyjnych wyroku, ale co do danego czynu i związanym z nim rozstrzygnięć w płaszczyźnie winy/kary/środków i określilibyśmy zakres zaskarżenia błędnie – np. zaskarżam wyrok w części co pkt 2 i 3 wyroku, jak niestety często zdarza się w pracach egzaminacyjnych – to o ile nie miałyby to znaczenia dla czynów z pkt 1 i 3 (czyn z pkt 3 i tak należałoby zaskarżyć „w części”, skoro kwestionujemy jedynie karę, a nie zawinienie, a czyn z pkt 1 nie jest przez nas kwestionowany, więc nie możemy pogorszyć swojej sytuacji), to miałyby to daleko idące skutki dla czynu z pkt 2 wyroku. W przypadku bowiem czynu z pkt 2 wyroku, określenie zakresu zaskarżenia „w części”, pomijałoby żądanie, by sąd odwoławczy zweryfikował winę oskarżonego za tenże przypisany czyn. Innymi słowy, skoro ze sformułowania „w części” wywodzimy, że nie kwestionujemy samego przypisania winy (a także ustaleń faktycznych sądu w tym zakresie), to – używając sformułowania „zaskarżam wyrok w części co do pkt 2 (...)” twierdzimy, że kwestionujemy wyłącznie karę lub środki karne, nie zaś winę jako taką. W konsekwencji, jeśli sąd odwoławczy nie dopatrzy się z urzędu okoliczności, o których mowa w art. 433 § 1 *in fine* k.p.k. i nie rozpoznana apelacji poza wskazanymi przez nas granicami zaskarżenia, to w najgorszym scenariuszu pozbawimy oskarżonego II instancji co do weryfikacji jego zawinienia. W warunkach egzaminacyjnych natomiast możemy narazić się nawet na negatywną ocenę całej pracy, jeśli egzaminujący uzna, że takie działanie nie jest działaniem w interesie i na korzyść własnego klienta w tym znaczeniu, że nie realizuje jego interesu procesowego. Pozbawia ono bowiem oskarżonego szansy na skorzystanie przez niego z konstytucyjnego prawa do rozpoznania jego sprawy przez sądy dwóch instancji.

Skutki błędów w zakresie określenia zakresu zaskarżenia celnie ujął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26 lutego 2018 r. (sygn. akt II AKa 445/17), stwierdzając że – *z treści art. 447 k.p.k. wynika obowiązek wskazania zakresu zaskarżenia – tj. czy orzeczenie jest skarżone w całości, bo kwestionuje winę (§ 1 art. 447), czy też jest zwrócone przeciwko rozstrzygnięciu o karze i środkach karnych (§ 2 art. 447). Unormowanie powyższe wynikające z art. 447 k.p.k. wskazuje zatem, że częściowe zaskarżenie wyroku co do kary skutkuje tzw. horyzontalną prawomocnością wyroku, a tym samym rozstrzygnięcie*

co do winy co do zasady nie podlega kontroli odwoławczej. Rolą sądu odwoławczego w sytuacji, gdy w sprawie stronę reprezentuje obrońca nie jest totalna ocena wyroku, a jedynie te rozstrzygnięcia, które są kontestowane przez skarżącego.

Przykład IV: zapada wyrok, w którym oskarżonemu przypisane zostało sprawstwo trzech czynów, np. (1). art. 177 § 1 k.k., (2). art. 280 § 1 k.k. i (3). art. 284 § 1 k.k. Oskarżony nie przyznawał się do winy co do pierwszego czynu i drugiego, zaś w odniesieniu do czynu 3 wprawdzie przyznał się do winy, jednak uważa, że orzeczony obowiązek naprawienia szkody w części jest rażąco wygórowany.

Odp.: Prawidłowy zakres zaskarżenia w apelacji obrońcy powinien zostać sformułowany następująco: „***w odniesieniu do czynów przypisanych w pkt 1 i 2 wyroku, zaskarżam te rozstrzygnięcia w całości, zaś w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 3 wyroku, zaskarżam to rozstrzygnięcie w części orzeczenia o środku kompensacyjnym***”. Dla sądu odwoławczego taki zakres zaskarżenia oznacza, że:

- W odniesieniu do czynów z pkt 1 i 2 wyroku, oskarżony kwestionuje tak winę, jak i wszystkie inne rozstrzygnięcia odnoszące się do tych czynów;
- Oskarżony nie kwestionuje winy i ustaleń faktycznych stanowiących podstawę jej ustalenia za czyn z pkt 3 wyroku, negując jednak wysokość środka kompensacyjnego, jaki został orzeczony w tej sprawie.

Gdybyśmy zapomnieli o tym, że zakres zaskarżenia nie odnosi się do jednostek redakcyjnych wyroku, ale co do danego czynu i związanych z nim rozstrzygnięć w płaszczyźnie winy/kary/środków i określilibyśmy zakres zaskarżenia błędnie – np. zaskarżam wyrok w części co do pkt 1–3 wyroku, to miałyby to daleko idące skutki dla czynów przypisanych w pkt 1 i 2 wyroku. W przypadku bowiem tych czynów, określenie zakresu zaskarżenia „w części”, pomijałoby żądanie, by sąd odwoławczy zweryfikował winę oskarżonego za te przypisane czyny. Innymi słowy, o ile sąd odwoławczy nie rozpoznałby z urzędu apelacji poza wskazanymi przez nas granicami zaskarżenia, to badałby tylko to, czy sąd I instancji orzekł wobec oskarżonego karę adekwatną

do zawnienia i okoliczności sprawy. Nie badałby natomiast tego, czy oskarżony rzeczywiście ponosi winę za przypisane wyrokiem czyny.

W konsekwencji, w przypadku większej liczby czynów przypisanych zaskarżonym wyrokiem (a tak z reguły skonstruowane są zadania egzaminacyjne), należy pamiętać o określeniu zakresu zaskarżenia odrębnie dla każdego z przypisanych wyrokiem czynów (np. w formule „w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 2 wyroku, zaskarżam to rozstrzygnięcie w całości, zaś w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 3 wyroku, zaskarżam to rozstrzygnięcie w części orzeczenia o karze/o środku karnym”). Określenie „w całości/w części” odnosi się bowiem odpowiednio do „winy/kary/środków karnych/środków kompensacyjnych”, nie zaś do jednostek redakcyjnych przyjętych przez sąd w zaskarżonym wyroku (jednostek redakcyjnych, czyli punktów sentencji wyroku).

Przydatne orzecznictwo:

- Przyzwolenie na uzupełnienie przez stronę apelacji w postaci rozszerzenia zakresu zaskarżenia i podniesienia nowych zarzutów po upływie terminu określonego art. 445 § 1 k.p.k., byłoby swoistym przedłużeniem terminu do jej wniesienia (zob. post SN z 10 grudnia 2003 r., V KK 195/03, OSNKW 2004, Nr 3, poz. 25; zob. też wyrok SA w Krakowie z dnia 10 listopada 2004 r., II AKa 225/04). W konsekwencji Sąd Okręgowy, choć ze względu na kierunek i zakres zaskarżenia obowiązany był dokonać całościowej kontroli wyroku Sądu Rejonowego, to jednak wynikający z art. 457 § 3 k.p.k. obowiązek odniesienia się w uzasadnieniu do zarzutów i wniosków apelacji wiązał go wyłącznie w zakresie zarzutów i wniosków zawartych w apelacjach wniesionych w terminie, nie wiązał zaś w zakresie zarzutów zgłoszonych po upływie terminu (...) – **wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2019 r., sygn. akt II KK 178/18**
- (...) przepis art. 433 § 1 k.p.k. stanowi, że sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku odwoławczym zostały wskazane zarzuty stawiane rozstrzygnięciu – również w granicach podniesionych zarzutów, uwzględniając treść art. 447 § 1–3, a w zakresie szerszym w wypadkach wskazanych w art. 435, art. 439 art. 440

i art. 455 k.p.k. (...). W realiach rozważanej sprawy, wbrew stanowisku skarżącego, istniała możliwość zmiany zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec skazanego środka karnego przewidzianego w art. 43a § 2 k.k. bez potrzeby wykraczania poza granice zaskarżenia i podniesiony zarzut. Zgodnie z art. 434 § 1 k.p.k. sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego jedynie: – wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, oraz – w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia, oraz – w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym, chyba że środek odwoławczy nie pochodzi od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika i nie podniesiono w nim zarzutów albo ustawa nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie od podniesionych zarzutów. W rozważanej sprawie spełnione zostały wszystkie przesłanki umożliwiające orzekanie reformatoryjne. Po pierwsze, prokurator wniósł środek odwoławczy na niekorzyść oskarżonego. Po drugie, orzekanie reformatoryjne mogło nastąpić w granicach zaskarżenia. Prokurator zaskarżył wyrok Sądu pierwszej instancji „w części dotyczącej środków karnych”, jednak z treści zarzutu wynika, że dotyczył on jedynie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z art. 42 § 2 k.k. Z przywoływanego wcześniej art. 433 § 1 k.p.k. wynika wszakże, że przy określaniu granic zaskarżenia uwzględniać należy treść art. 447 § 1–3 k.p.k. Z punktu widzenia omawianej sprawy istotne znaczenie ma art. 447 § 3 k.p.k., który stanowi, że apelację co do środka karnego uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych. Po trzecie, spełniona została także ostatnia przesłanka, tj. stwierdzenie uchybień podniesionych w środku odwoławczym (zarzut obrazy art. 42 § 2 k.k. okazał się trafny) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II KK 422/17**

- (...) należy mieć w polu uwagi regulację z art. 447 § 2 k.p.k., zgodnie z którą apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych. Zwrot „całość rozstrzygnięcia o karze” odnosi się do także do rozstrzygnięcia o karze łącznej. Jeżeli zatem przedmiotem zaskarżenia jest wymiar kary łącznej w wyroku skazującym, to zgodnie z art. 447 § 2 k.p.k. zakresem zaskarżenia objęte są

także rozstrzygnięcia o karach jednostkowych. Zważywszy dodatkowo, że niewątpliwie intencją autora apelacji było doprowadzenie do obniżenia orzeczonej kary łącznej, co – z uwagi na zastosowanie przy jej orzekaniu zasady pełnej absorpcji – byłoby możliwe jedynie w drodze złagodzenia jednej lub obu kar jednostkowych, przyjąć należało, iż zarzut odwoławczy obejmuje nie tylko karę łączną, lecz również kary jednostkowe pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu w punktach 64 i 65 zaskarżonego wyroku – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa 233/17

- (...) częściowe zaskarżenie wyroku co do kary skutkuje tzw. horyzontalną prawomocnością wyroku, a tym samym rozstrzygnięcie co do winy co do zasady nie podlega kontroli odwoławczej. Rolą Sądu Odwoławczego w sytuacji, gdy w sprawie stronę reprezentuje obrońca nie jest totalna ocena wyroku, a jedynie te rozstrzygnięcia, które są kontestowane przez skarżącego – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt II AKa 106/16**
- Nie jest natomiast dopuszczalne skarżenie przez oskarżonego czy jego obrońcę rozstrzygnięć dotyczących współoskarżonych i to jeszcze na ich niekorzyść – **postanowienie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt IV KK 416/15, LEX nr 2069262**
- Przepis art. 425 § 3 k.p.k. nie daje bowiem oskarżonemu podstaw do skarżenia wyroku w zakresie dot. innego uczestnika postępowania. Sąd Apelacyjny podziela pogląd (...), że interes prawny w zaskarżaniu odnosi się do danego odwołującego się podmiotu. Może on więc skarżyć te rozstrzygnięcia lub ustalenia, które jego dotyczą. To zatem ze skarżonego rozstrzygnięcia lub ustalenia ma bezpośrednio wynikać niekorzystny dla skarżącego skutek, aby można było mówić o istnieniu po jego stronie gravamen w jego zaskarżeniu. Oskarżony nie jest zatem uprawniony do zaskarżania rozstrzygnięć odnoszących się wprost do innego współoskarżonego – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 grudnia 2015 r., sygn. akt II AKa 156/15**
- (...) uzasadnienie stanowi integralną część środka zaskarżenia i może, a nawet powinno zawierać wyjaśnienie, rozbudowanie, doprecyzowanie treści podniesionych w zarzutach. Jest to stanowisko ograniczone do tych

sytuacji, w których w zarzucie środka odwoławczego zawarte są treści mogące budzić wątpliwości co do ich istoty, ale w powiązaniu z ich rozwinieciem w uzasadnieniu, wątpliwości te jednoznacznie rozwiewają – **wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2011 r., sygn. akt WA 22/11**

- Orzeczenie o karze obejmuje nie tylko jej rodzaj, czy wysokość, ale również środki związane z poddaniem sprawcy próbie takie jak warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności czy dozór kuratora. Do środków tych należy również obowiązek naprawienia szkody, który przez ustawodawcę zaliczony został do katalogu środków karnych (obecnie kompensacyjnych – uwaga autorki) – **wyrok Sądu Najwyższego z 17 maja 2006r., sygn. akt II KK 265/05**
- (...) zaskarżenie prawomocnego wyroku „co do kary” („co do orzeczenia o karze”) oznacza, iż środek zaskarżenia dotyczy wówczas każdego rozstrzygnięcia zawartego w wyroku, a odnoszącego się do tej kary lub kar, której kasacja dotyczy, czyli także do rozstrzygnięcia orzekającego określoną opłatę w sprawach karnych, w rozmiarze ustalonym w zależności od wysokości kary – **wyrok Sądu Najwyższego z 1 marca 2005 r., sygn. akt V KK 6/05; zob. także: wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2007 r., sygn. akt IV KK 322/07**
- Zaskarżenie wyroku chociażby do jednego ze skazań objętych orzeczeniem łącznym rozciąga się na wszystkie skazania objęte tym orzeczeniem, gdyż z uwagi na charakter wyroku taka apelacja stanowi przeszkodę uprawomocnienia się wyroku w pozostałej części – **wyrok Sądu Najwyższego z 2 kwietnia 1986 r., sygn. akt III KR 54/86, LEX nr 17757**
- We wszystkich wypadkach przestępstw przeciwko mieniu, w których rozmiar winy i co za tym idzie wysokość orzeczonej kary, a także kwalifikacja prawna czynu, zależą od wysokości zagarniętego mienia, kwestionowanie w rewizji (obecnie apelacji – uwaga autorki) oskarżonego ustaleń co do tej wartości mienia jest zwrócone przeciwko winie – **postanowienie Sądu Najwyższego z 13 września 1985 r., sygn. akt I KR 116/85**

Rozdział 4.

Dodatkowe uwagi, będące wynikiem błędów w pracach egzaminacyjnych:

- „koszty” – rzadko kiedy formułowane w apelacjach egzaminacyjnych wnioski o zwrot kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru/zwrot wydatków z tytułu ustanowienia w sprawie pełnomocnika z wyboru są skonstruowane prawidłowo. Zagadnienie zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru i zwrotu wydatków z tytułu ustanowienia w sprawie pełnomocnika nie sprowadza się w mojej ocenie do sformułowania prostego wniosku o zasądzenie tychże kosztów z odwołaniem np. do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłaty za czynności adwokackie, jak często formułowany jest w pracach i w praktyce sądowych. Uważam bowiem, że w przypadku ustanowienia zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika z wyboru, niezbędnym elementem wniosku „kosztowego” jest wykazanie faktu rzeczywistego poniesienia przez stronę tychże środków⁶. Często formułowane zatem w pracach wnioski o zwrot kosztów, według „norm przepisanych”, wydają się błędne, albowiem rozporządzenie odnosi się wyłącznie do stawek, jakie związane są z pełnieniem funkcji obrońcy albo pełnomocnika z urzędu. Nie ma w niniejszej publikacji miejsca na szczegółowe omówienie tej problematyki. Istotne znaczenie ma jednak to, że brak zawarcia w pracy egzaminacyjnej wniosku „kosztowego” nie stanowi błędu pracy, albowiem wniosek ten nie dotyczy istoty odpowiedzialności karnej oskarżonego i może on zostać złożony na późniejszym etapie postępowania odwoławczego. **Sugeruję zatem zdającym nieformułowanie tego rodzaju wniosków bez pewności ich prawidłowego skonstruowania, ponieważ ich brak w pracy nie będzie potraktowany jako błąd. Natomiast wadliwe sformułowanie**

⁶ W art. 616 § 1 pkt 2 k.p.k. ustawodawca wprost odwołuje się do „wydatków stron”, poczynionych w związku z ustanowieniem jednego obrońcy lub pełnomocnika.

takiego dodatkowego wniosku zostanie dostrzeżone przez egzaminatorów i może zostać ocenione jako błąd pracy.

- *Należy pamiętać, że w postępowaniu karnym, niezależnie od tego, czy wnosząc apelację występujemy jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, czy też jako obrońca – **nigdy nie wnosimy opłaty skarbowej** od przedkładanego do akt pełnomocnictwa/upoważnienia do obrony/reprezentacji. Zgodnie z pkt IV pkt 2a załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546), zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w sprawach karnych, karno-skarbowych, dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia jest zwolnione od konieczności wnoszenia opłaty skarbowej.*

Rozdział 5.

Podsumowanie wymogów formalnych i przykładowe *petitum* apelacji:

1. Do sporządzenia prawidłowej apelacji konieczna jest dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego;
2. Dokładnie czytamy wytyczne zadania egzaminacyjnego, aby prawidłowo określić datę wniesienia środka odwoławczego, a także sąd do którego wnosimy apelację;
3. Sprawdzamy, jakimi danymi, zgodnie z treścią zadania egzaminacyjnego, mamy „podpisać” apelację oraz to, czy nasze upoważnienie do obrony/pełnomocnictwo do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego przedłożone zostało już do akt, czy też mamy je przedłożyć wraz z apelacją;
4. Pamiętamy o: (1) art. 444 § 1 k.p.k. oraz art. 425 § 1 i 2 k.p.k. – jako podstawach prawnych wniesionego środka odwoławczego, (2) art. 427 § 2 k.p.k. w związku z art. 438 (pkt 1–4) k.p.k. bądź art. 439 § 1 k.p.k. – jako podstawie prawnej formułowanych zarzutów apelacyjnych oraz (3) art. 427 § 1 k.p.k. w związku z art. 437 § 1 i 2 k.p.k. – jako podstawie prawnej formułowanych wniosków apelacji;
5. Zaskarżamy wyrok, a zarzuty formułujemy wobec określonego rozstrzygnięcia, nie zaś sądu jako takiego;
6. Niezależnie od tego, że działania obrońcy muszą być działaniami w interesie i na korzyść oskarżonego, w egzaminacyjnej apelacji obrońcy wskazujemy, że środek odwoławczy wnosimy „na korzyść oskarżonego”;
7. W kontekście liczby załączanych do apelacji odpisów, ustalamy kto jest po stronie przeciwnej (np. czy tylko oskarżyciel publiczny, czy także oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik), aby złożyć właściwą liczbę, zgodnie z art. 446 § 2 k.p.k. i art. 140 k.p.k.;
8. Pamiętamy, że sformułowanie „w części” odnosi się do kary/środków karnych/środków kompensacyjnych, a nie do jednostek redakcyjnych wyroku, a w przypadku większej liczby przypisanych oskarżonemu

przestępstw – zakres zaskarżenia określamy oddzielnie dla każdego z przypisanych czynów;

9. Nie jest wskazane formułowanie w apelacji wniosków o koszty, chyba że mamy pewność ich prawidłowego skonstruowania;
10. W postępowaniu karnym nigdy nie wnosimy opłaty skarbowej od przedkładanego do akt pełnomocnictwa/upoważnienia do obrony/reprezentacji;

Przykładowa komparycja oraz *petitum* apelacji:

Warszawa, r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie
II Wydział Karny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie
V Wydział Karny
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

adw. Anna Nowak
Kancelaria Adwokacka
ul. Kwiatowa 6
01-090 Warszawa,
obrońca oskarżonego
.....

sygn. akt: V K

APELACJA

od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, V Wydział Karny
z r. (sygn. akt V K),
który wraz z uzasadnieniem doręczony został obrońcy w dniu

Jako ustanowiony w sprawie obrońca oskarżonego (upoważnienie do obrony w aktach sprawy), na podstawie art. 444 § 1 k.p.k. w zw. z art. 425 § 1 i 2 k.p.k., zaskarżam wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, V Wydział Karny z dnia r., wydany w sprawie o sygn. akt V K, **w całości na korzyść oskarżonego**

I. Na podstawie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 2 k.p.k., ww. wyrokowi zarzucam obrazę przepisów postępowania karnego, mającą wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj.:

a. art., **poprzez**, **podczas** gdy
....., co doprowadziło do

b. itd.

II. Mając na uwadze powyższe zarzuty, w oparciu o art. 427 § 1 k.p.k. wnoszę, aby Sąd Odwoławczy, działając na zasadzie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., zmieniał zaskarżone rozstrzygnięcie i uniewinnił oskarżonego od wszystkich zarzucanych mu czynów.

Uzasadnienie

.....

-podpis adw. Anny Nowak-

Załączniki: - dwa odpisy apelacji (*przy założeniu braku oskarżyciela posiłkowego – jeden dla oskarżyciela publicznego i jeden dodatkowy do akt Sądu Apelacyjnego*).

Rozdział 6.

Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze

Ad. 6.1. Gradacja „ważności” zarzutów:

Względne przyczyny odwoławcze wymienione zostały w art. 438 k.p.k., zaś bezwzględne w art. 439 k.p.k. Te ostatnie są najpoważniejszymi błędami, jakimi może być obarczony wyrok sądu i stąd też ich skutki są najdalej idące. W dalszej części niniejszego opracowania omówione zostaną zarówno względne, jak i bezwzględne przyczyny odwoławcze, po to, aby unikać często pojawiających się błędów merytorycznych i konstrukcyjnych, z jakimi spotykam się w sprawdzanych pracach egzaminacyjnych.

Dla porządku wskazać należy, że na egzaminie zawodowym kluczowe znaczenie ma oczywiście dostrzeżenie właściwych zarzutów przez zdających. Kwestia kolejności ich sformułowania w *petitum* apelacji nie przesądzi o zdaniu bądź nie egzaminu, a wręcz może się zdarzyć, że dla części egzaminatorów nie będzie stanowiła większego problemu. Tym niemniej, warto pamiętać o omawianej w tym miejscu kwestii, szczególnie jeśli zdający ma ambicję napisania wysoko ocenianej pracy.

Pytanie: Jaka powinna być właściwa kolejność zarzutów w *petitum* apelacji karnej, przy założeniu, że prawidłowe są różne zarzuty – zarówno z art. 438 k.p.k., jak i z art. 439 k.p.k. (z zastrzeżeniem, że zarzuty te nie mają tzw. „charakteru mieszanego”, o czym szerzej w podrozdziale 7.4.)?

Odpowiedź: W takiej sytuacji wskazanym byłoby sformułowanie w pierwszej kolejności zarzutów wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Uchybienia te są bowiem na tyle doniosłe, że skutkują uchynieniem wyroku i – w zależności od okoliczności – umorzeniem postępowania albo przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Co więcej,

w orzeczeniach sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, w których podzielono poglądy apelujących co do zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, sądy poprzestają na wywodzie odnoszącym się do art. 439 k.p.k. i wynikających stąd skutkach procesowych, nie odnosząc się do pozostałych zarzutów podniesionych w apelacjach.

W warunkach egzaminacyjnych, kiedy podnosimy zarzuty z art. 439 k.p.k., sugerowane jest jednak niepomijanie innych, mniej doniosłych zarzutów z art. 438 k.p.k. W warunkach egzaminu zawodowego takie działanie może bowiem skończyć się uzyskaniem oceny niedostatecznej. Nierzadko bowiem formułowane w pracach egzaminacyjnych zarzuty bezwzględnej przyczyny odwoławczej bywają wadliwe merytorycznie. Nie wskazanie w pracy egzaminacyjnej innych zarzutów, wobec przekonania o zasadności sformułowanego zarzutu z art. 439 § 1 k.p.k., może w skrajnych przypadkach doprowadzić do tego, że poza błędnym zarzutem z art. 439 § 1 k.p.k. w pracy nie będzie innych zarzutów, podlegających ocenie. **Sugeruję zatem, aby mimo formułowania zarzutów z art. 439 § 1 k.p.k., na egzaminie zawodowym skorzystać z formuły „niezależnie od dostrzeżenia ww. bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. ..., zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucam nadto obrazę...”** i wskazywać wszystkie odnalezione w kasusie egzaminacyjnym, kluczowe oraz mające znaczenie dla rozstrzygnięcia uchybienia Sądu I instancji z art. 438 k.p.k.

Z powyższego wynika również, że **w przypadku jednoczesnego wystąpienia zarzutów z art. 439 k.p.k. oraz z art. 438 k.p.k., zarzuty z art. 439 k.p.k. powinny zostać sformułowane w *petitum* apelacji w pierwszej kolejności.** Dopiero później zarzuty z art. 438 k.p.k., przy czym **wprowadzona przez ustawodawcę kolejność punktów w art. 438 k.p.k. nie jest przypadkowa.** Pomijając w tym miejscu zagadnienie tzw. zarzutów „mieszanych” (zob. podrozdział 7.4.), najpierw formułujemy zarzuty obrazu prawa materialnego, potem procesowego i błędu w ustaleniach faktycznych, a dopiero w ostatniej kolejności (tak, jak wynika z art. 438 k.p.k.) zarzuty odnoszące się do niewspółmierności orzeczonej kary, środków karnych lub nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przypadku lub innego środka.

Ad. 6.2. Właściwa konstrukcja zarzutów z art. 439 § 1 k.p.k. i z art. 438 k.p.k.

Zanim przejdziemy do zasad odnoszących się do merytorycznego formułowania zarzutów apelacji, konieczne jest poczynienie uwag, dotyczących różnicy w samej konstrukcji zarzutów z art. 439 § 1 k.p.k. oraz z art. 438 pkt 1/1a k.p.k. i art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. Z mojego doświadczenia egzaminacyjnego wynika bowiem, że w tym zakresie prace zawierają powtarzalne błędy (np. sformułowanie zarzutu obrazy „*art. 7 k.p.k., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie*”). Aby zatem uniknąć prostych do wyeliminowania błędów, poniżej przedstawione zostaną uwagi dotyczące samej konstrukcji zarzutów z art. 439 § 1 k.p.k. oraz z art. 438 k.p.k., aby dopiero w kolejnej części niniejszej publikacji odpowiedzieć na pytanie, kiedy merytorycznie należy sformułować zarzuty określone wyżej wskazanymi przepisami.

Ad. 6.2.1. Właściwa konstrukcja zarzutu bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 § 1 k.p.k.)

Prawidłowo skonstruowany zarzut bezwzględnej przyczyny odwoławczej odnosi się do naruszenia przez sąd zakazu lub nakazu, wynikającego z prawa karnego procesowego, np. wbrew nakazowi w sprawie o zabójstwo w I instancji orzekł Sąd Rejonowy zamiast Sądu Okręgowego albo sąd skazał oskarżonego ponownie za ten sam czyn. Ustawodawca postrzega bezwzględnej przyczyny odwoławcze jako najistotniejsze uchybienia, jakimi może być obarczone sądowe rozstrzygnięcie. Mają one tak istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, że **błędne jest wykazanie z punktu widzenia konstrukcji zarzutu wpływu tej obrazy na treść rozstrzygnięcia** (tak też m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt II KK 99/11).

W praktyce dostrzec można różne sposoby konstruowania zarzutów bezwzględnej przyczyny odwoławczej – albo poprzez wskazanie **konkretnego przepisu prawa karnego procesowego, który został naruszony, co doprowadziło do zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej**

(zob. przykład III poniżej)⁷, **albo poprzez wskazanie konkretnej przyczyny z art. 439 § 1 k.p.k., zawierającej w sobie precyzyjnie określone uchybienie (np. sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu bądź, że orzeczono karę nieznaną ustawie) i opisanie w zarzucie zaistniałego uchybienia** (zob. przykład V-VI poniżej).

Z oczywistych względów w odniesieniu do bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. niewystarczające byłoby wskazanie w zarzucie obrazu tego przepisu. Jest to bowiem przepis odsyłający w swojej treści do art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11 k.p.k., co wiąże się z koniecznością wskazania w zarzucie konkretnego przepisu z art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11 k.p.k., który został naruszony i co skutkuje bezwzględną przyczyną odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. W przypadku przedawnienia czynu przypisanego oskarżonemu wyrokiem sądu I instancji, prawidłowe będzie zatem wskazanie w zarzucie obrazu art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., co doprowadziło do wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. (nie zaś obrazu art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.).

Dla praktyków oczywiście najistotniejsze znaczenie ma dostrzeżenie samego uchybienia. Skoro brak jest definicji ustawowej zarzutu odwoławczego, to słusznym wydaje się pogląd, że kwestia konstrukcji zarzutu bezwzględnej przyczyny odwoławczej pozostawiona została do uznania skarżącego pod warunkiem, że prawidłowo dostrzeżenie i opisz dostrzeżone uchybienie.

Poniżej przedstawione zostaną przykładowe konstrukcje zarzuty bezwzględnej przyczyny odwoławczej:

Przykład I: obrazu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., polegająca na skazaniu oskarżonego za czyn z art. 278 § 1 k.k. w sytuacji braku zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej za popełnienie

⁷ Przeciwnicy tego rozwiązania podnoszą, że taka konstrukcja zarzutu może osłabiać jego znaczenie „na pierwszy rzut oka”, sugerując że apelujący dostrzega mniej rażące uchybienia tj. obrazę prawa procesowego, nie zaś najistotniejszą wadę jaką obarczone może być orzeczenie w postaci bezwzględnej przyczyny odwoławczej.

tegoż przestępstwa, co stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia, określoną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

Przykład II: obrazą art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., poprzez skazanie oskarżonego za czyn opisany w punkcie I wyroku, zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 KK, w sytuacji gdy za czyn ten oskarżony został już prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) o sygn. akt (...), co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.

Przykład III: obrazą art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k., polegająca na wydaniu orzeczenia przez Sąd Rejonowy w sprawie, która według właściwości rzeczowej podlegała rozpoznaniu w I instancji przez Sąd Okręgowy, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.

Przykład IV: obrazą art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k., polegająca na skazaniu oskarżonego za czyn z art. 278 § 1 k.k. w sytuacji braku zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej za popełnienie tegoż przestępstwa, co miało wpływ na treść rozstrzygnięcia, albowiem bez takowego błędu nie doszłoby do wydania wyroku skazującego, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną powyżej, co w konsekwencji co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

Przykład V: obrazą art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., poprzez skazanie oskarżonego z naruszeniem zasady *res iudicata*, tj. za czyn opisany w punkcie I wyroku, zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 KK, w sytuacji gdy za czyn ten oskarżony został już prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...) o sygn. akt (...), co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.

Przykład VI: obrazą art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k., polegająca na wydaniu orzeczenia przez Sąd Rejonowy w sprawie, wbrew treści art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k., tj. przez Sąd Rejonowy, w sytuacji gdy właściwym rzeczowo w I instancji był Sąd Okręgowy.

Przydatne orzecznictwo:

- Stwierdzenie jednej z przyczyn zaliczonych przez ustawodawcę do katalogu bezwzględnych przesłanek uchylenia orzeczenia nie tylko nie zobowiązuje, ale nawet nie zezwala na badanie możliwości wpływu tej wadliwości na treść tego orzeczenia (art. 439 § 1 in principio k.p.k.). Przy uchybieniach zaliczonych przez ustawodawcę do tak skonstruowanego katalogu możliwość takiego wpływu jest zakładana z mocy samego prawa – **wyrok Sądu Najwyższego z 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt II KK 99/11**

Ad. 6.2.2. Właściwa konstrukcja zarzutów z art. 438 k.p.k.

Omawiane w tym miejscu zagadnienie wynika wprost ze sformułowania poszczególnych przepisów art. 438 k.p.k., zgodnie z którym:

Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:

- 1) *obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu;*
 - 1a) *obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;*
- 2) *obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;*
- 3) *błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;*
- 4) *rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.*

Należy zwrócić uwagę na to, że w art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. ustawodawca wprost odwołał się do wpływu, jaki obraza mogła mieć na treść orzeczenia (fragmenty podkreślone przez autorkę). Nieco inaczej kształtuje się jednak ta sytuacja w odniesieniu do zarzutów z art. 438 pkt 1 k.p.k. i art. 438 pkt 1a k.p.k., co wymaga dodatkowe komentarza.

Sformułowanie ww. przepisów determinuje elementy konstrukcji zarzutów dotyczących poszczególnych sfer prawa karnego. Obraza prawa materialnego jest bowiem, również zdaniem ustawodawcy, tak poważnym zarzutem, że jej zaistnienie musiało mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Mając jednocześnie na uwadze obecne brzmienie art. 438 pkt 1 k.p.k. w porównaniu do art. 438 pkt 1a k.p.k., z całą pewnością nie ma potrzeby wskazywania w treści formułowanego zarzutu w oparciu o art. 438 pkt 1 k.p.k. owego wpływu, odmiennie niż w przypadku obrazy prawa procesowego czy błędu w ustaleniach faktycznych. **Inaczej kształtuje się jednak ta sytuacja w odniesieniu do zarzutu z art. 438 pkt 1a k.p.k., albowiem w tym zakresie ustawodawca wprost wskazał, że skarżący musi nie tylko wykazać, że doszło do obrazy prawa materialnego, ale także to, że na skutek tejże obrazy „orzeczenie nie odpowiada prawu”.**

Jak wskazuje D. Świecki, *gdy podstawą zarzutu odwoławczego jest art. 438 pkt 1a, to należy w zarzucie wykazać, że obraza przepisu prawa materialnego w innym wypadku niż dotyczący kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu powoduje, że to rozstrzygnięcie nie odpowiada prawu. Dopiero spełnienie tego warunku prowadzi do skuteczności zarzutu. W art. 438 pkt 1a zakłada się bowiem, że pomimo stwierdzonego uchybienia dotknięte nim rozstrzygnięcie może odpowiadać prawu, co w konsekwencji wyklucza możliwość zmiany tego orzeczenia. Dlatego też skarżący już w zarzucie powinien wykazać, że z powodu tego uchybienia orzeczenie jednak prawu nie odpowiada. Chodzi tu o wpływ stwierdzonego uchybienia na sytuację prawną oskarżonego lub innej strony prywatnej, tj. oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego (zob. uwagi do art. 438 pkt 1a). Zatem ten zarzut powinien składać się z dwóch elementów⁸.*

W konsekwencji, obecna redakcja przepisu art. 438 pkt 1a k.p.k. wiąże się w praktyce z koniecznością wykazania wpływu na treść orzeczenia, tj. tego, że orzeczenie nie odpowiada prawu (co logicznie wynika z wprowadzonego do tego przepisu sformułowania „*chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu*”).

⁸ D. Świecki, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 438 k.p.k., Lex/el 2022, teza 4.

Konstrukcyjnie zarzut obrazy prawa materialnego z art. 438 pkt 1 k.p.k. powinien zatem składać się w zasadzie z dwóch członów, zaś zarzut obrazy prawa procesowego (i błędu w ustaleniach faktycznych) oraz zarzut z art. 438 pkt 1a k.p.k. – z trzech (dodatkowo bowiem należy przy art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. wykazać wpływ dostrzeżonej obrazy na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia, zaś przy art. 438 pkt 1a k.p.k. – to, że orzeczenie nie odpowiada prawu).

Ad. 6.2.2.1. Konstrukcja zarzutu obrazy prawa materialnego:

- **(1) sposób obrazy prawa materialnego + (2) na czym dokładnie ta obraza miałyby polegać ***

Zanim przejdziemy do praktycznych przykładów, warto poczynić jedną dodatkową uwagę, która będzie przydatna do omówienia zagadnienia tzw. zarzutów „mieszanych”, przedstawionego w dalszej części niniejszej publikacji (zob. podrozdział 7.4 niniejszej publikacji). **Co chcemy przekazać sądowi odwoławczemu, formułując zarzut obrazy prawa materialnego? Innymi słowy – co myśli sąd odwoławczy, kiedy analizuje tego rodzaju zarzut? Myśli, że apelujący nie kwestionuje ustalonego stanu faktycznego (!).** Tylko bowiem wówczas kiedy nie kwestionujemy ustalonego przez sąd stanu faktycznego, możliwe i zasadne jest formułowanie w apelacji zarzutów obrazy prawa materialnego. Ostatnia uwaga odnosi się do przepisów części szczególnej k.k. (jeśli natomiast doszło do obrazy przepisów części ogólnej k.k. – np. sąd orzekł karę grzywny, przekraczając ustawowe granice wymiaru tej kary – wówczas w oczywisty sposób nie ma mowy o czynieniu jakichś ustaleń faktycznych przez sąd).

Jeśli natomiast kwestionujecie ustalenia faktyczne (formułując zarzuty w oparciu o art. 438 pkt 2 k.p.k. czy też art. 438 pkt 3 k.p.k.), a obraza prawa materialnego jest wyłącznie konsekwencją powyższego, to wówczas zarzut obrazy prawa materialnego nie jest merytorycznie prawidłowy. **Zarzut obrazy prawa materialnego dla sądu odwoławczego oznacza zatem, że apelujący nie kwestionuje ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd I instancji.** Uważa natomiast, że albo sąd nieprawidłowo odkodował określoną normę

prawną (dokonał jej błędnej wykładni), albo nieprawidłowo zastosował prawo materialne (tj. dokonał wadliwej subsumpcji prawidłowo dokonanych ustaleń faktycznych pod prawidłowo odkodowaną normę prawną). Stąd też **sposób obrazu prawa materialnego to albo błędna wykładnia, albo nieprawidłowe zastosowanie** (które obejmuje także nieprawidłowe niezastosowanie jakiejś normy prawnej, która powinna w danym – prawidłowo ustalonym – stanie faktycznym zostać zastosowana).

W konsekwencji powyższego (i tego właśnie dotyczy wyżej zaznaczona *), niejako dodatkowym elementem konstrukcyjnym zarzutu obrazu prawa materialnego jest często sformułowanie „*przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym*”⁹.

(!) Sugeruję wpisywanie tego sformułowania („*przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym*”) do zarzutów materialnych, uwzględnianych w pracy egzaminacyjnej, albowiem dzięki takiemu działaniu egzaminowany sam skontroluje swój pogląd, czy rzeczywiście zarzut materialny jest poprawny i czy jednocześnie nie kwestionuje w swojej apelacji, w innym zarzucie (np. procesowym) tych samych kwestii, do których odnosi się zarzut z art. 438 pkt 1 albo 1a k.p.k.

Przykład I: obraza art. 280 § 2 k.k., poprzez jego błędną wykładnię (1), polegającą na wadliwym, bo stojącym w sprzeczności z utrwalonymi poglądami orzecznictwa oraz doktryny prawa karnego uznaniu, przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym (*), że poduszka jest przedmiotem podobnie niebezpiecznym do broni palnej lub noża w rozumieniu ww. przepisu (2).

Przykład II: obraza art. 226 § 1 k.k., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie (1), w sytuacji gdy, przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym (*), przypisany oskarżonemu czyn w zakresie ustawowych znamion

⁹ Jak również do tego elementu zarzutu z art. 438 pkt 1a k.p.k., który odnosi się do tego, że wydane orzeczenie nie odpowiada prawu (zob. uwagi pkt 6.2.2 niniejszej publikacji).

nie był kompletny (2), albowiem brak było znamienia działania „*podczas i w związku*” z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariusza.

Pamiętaj! Jeśli naszym zdaniem sąd I instancji błędnie/dowolnie ustalił, że np. oskarżony użył noża i wobec tego kwestionujemy to ustalenie (np. twierdząc, że świadek nie mówił w tym zakresie prawdy albo że nie ma żadnego dowodu potwierdzającego takie ustalenie), to wówczas negujemy sposób oceny dowodów i w apelacji podnosimy zarzut obrazy prawa procesowego (np. poprzez zarzut obrazy art. 7 k.p.k.). Twierdzimy tym samym, że gdyby sąd prawidłowo ocenił materiał dowodowy, to poczyniłby odmienne ustalenia faktyczne i w konsekwencji – nie zastosowałby prawa materialnego, uznając oskarżonego za niewinnego. Obraza prawa materialnego w powyższym przykładzie jest zatem, naszym zdaniem, wyłącznie konsekwencją błędu popełnionego przez sąd wcześniej, bo na etapie oceny materiału dowodowego i czynienia w oparciu o tę ocenę ustaleń faktycznych w sprawie. Natomiast sformułowanie w powyższej sytuacji zarzutu materialnego byłoby oczywiście błędne.

Ad. 6.2.2.2. Konstrukcja zarzutu obrazy prawa procesowego oraz zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych:

- (1) co się wydarzyło/co zrobił sąd + (2) jak prawidłowo być powinno + (3) jaki jest tego skutek/jaki może mieć to wpływ na treść orzeczenia

Pamiętaj! W odniesieniu do obrazy prawa karnego procesowego, odmiennie niż przy obrazie prawa materialnego, nie wskazujemy w zarzucie sposobu obrazy prawa procesowego. Jest to niestety często spotykany błąd w pracach egzaminacyjnych, dlatego zwracam na to szczególną uwagę. Błędne jest zatem umieszczanie w zarzucie obrazy prawa procesowego sformułowania „*poprzez jego błędne zastosowanie*” (!).

Przykład I: obraza art. 7 k.p.k., polegająca na dowolnej ocenie dowodu w postaci wyjaśnień współoskarżonego Jana Kowalskiego i wadliwe uznanie

tego dowodu za wiarygodny (1), podczas gdy wyjaśnienia te, stanowiąc dowód z pomówienia, są w istocie niespójne, niekonsekwentne i nielogiczne, zaś sam współoskarżony Jan Kowalski zainteresowany był wynikiem sprawy w kierunku umniejszenia własnej odpowiedzialności (2), co doprowadziło do błędnego ustalenia (wyłącznie w oparciu o ww. dowód), że oskarżony Paweł Nowak 23 kwietnia 2021 r. uderzył pokrzywdzonego kijem w głowę (3).

Przykład II: obraza art. 174 k.p.k., poprzez dokonanie ustaleń faktycznych wyłącznie w oparciu o treść notatki służbowej funkcjonariusza Jana Kowalskiego (1), podczas gdy zgodnie z dyspozycją ww. przepisu nie można zastępować zeznań świadków treścią notatek służbowych i innych zapisów, nieutrwalonych w procesowej formie protokołu z czynności przesłuchania (2), co skutkuje błędnym, bo całkowicie procesowo dowolnym ustaleniem, że oskarżony miał przyznać się do popełnienia przypisanego mu zaskarżonym wyrokiem czynu (3).

Zaakcentowania wymaga, że **ww. trzeci człon konstrukcji zarzutu obrazy prawa procesowego w realiach zadania egzaminacyjnego powinien być jak najbardziej skonkretyzowany**. Nie jest prawidłowe wpisywanie ogólnych treści takich jak „co doprowadziło do błędnego skazania oskarżonego” bądź „co skutkowało niesłusznym uznaniem oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu”. Oczywiście jest bowiem, że skoro – zdaniem apelującego – sąd złamał istotny zakaz lub nakaz wynikający z przepisów prawa procesowego, to doszło do niesłusznego skazania czy błędnego uznania winy oskarżonego. Sugeruję wskazywać możliwie jak najbardziej skonkretyzowane ustalenie, które zdaniem zdającego zostało poczynione błędnie wskutek obrazy prawa procesowego bądź błędnego ustalenia innego faktu istotnego z punktu widzenia wydanego rozstrzygnięcia (np. błędne ustalenie, że oskarżony był w jakimś miejscu/coś zrobił/zachował się w określony sposób/miał określony stan świadomości itp.).

Z moich egzaminacyjnych obserwacji wynika, że zdający nierzadko formułują wadliwy zarzut obrazy art. 5 § 2 k.p.k. W większość przypadków, biorąc pod uwagę opis zarzutu apelacyjnego oraz jego uzasadnienie, zdający ma w rzeczywistości na myśli obrazę art. 7 k.p.k. Decyduje się jednak na

sformułowanie zarzutu obrazy art. 5 § 2 k.p.k., co najczęściej świadczy o nieznanomości orzecznictwa, wydanego na tle tego przepisu. Zgodnie bowiem z ugruntowanym stanowiskiem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, zasadniczo zarzut obrazy art. 5 § 2 k.p.k. jest uzasadniony, gdy sąd podzieli się swoimi wątpliwościami w uzasadnieniu i następnie rozstrzygnie je na niekorzyść oskarżonego. Nie mają zatem znaczenia wątpliwości strony, tylko sądu, który dodatkowo powinien je wyartykułować¹⁰. W dalszej części niniejszej publikacji, poświęconej najczęściej formułowanym zarzutom apelacyjnym, kwestia ta zostanie omówiona szerzej (zob. podrozdział 9.2.).

Konstruując zarzut obrazy prawa procesowego albo błędu w ustaleniach faktycznych, w pewnych okolicznościach można wskazać art. 5 § 2 k.p.k. jako ww. trzeci człon tegoż zarzutu (np. *„co doprowadziło do wadliwego niedostrzeżenia wątpliwości, które zgodnie z art. 5 § 2 k.p.k. powinny zostać rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego”*). Innymi słowy, jeśli w naszej apelacji twierdzimy, że gdyby sąd należycie ocenił materiał dowodowy, to miałby wątpliwości, które musiałby rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego, wówczas jako trzeci element konstrukcyjny zarzutu (możliwy wpływ na treść rozstrzygnięcia) dopuszczalne byłoby odwołanie się do skutku w postaci obrazy art. 5 § 2 k.p.k.

Ad. 6.2.2.3. Obraza prawa procesowego a błąd w ustaleniach faktycznych

Tak jak wskazano powyżej, konstrukcyjnie nie ma większej różnicy pomiędzy zarzutem obrazy prawa procesowego a zarzutem błędu w ustaleniach faktycznych. W obu przypadkach prawidłowo skonstruowany zarzut powinien

¹⁰ Dla porządku zaznaczenia wymaga, że orzecznictwo w szczególnych okolicznościach dopuszcza również możliwość formułowania zarzutu obrazy art. 5 § 2 k.p.k., kiedy sąd orzekający wątpliwości nie miał, choć powinien w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy (*„(...) zarzut naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. dotyczyć może tylko takich sytuacji, gdy sąd orzekający powyższe nie dające się usunąć wątpliwości i rozstrzygnie je na niekorzyść oskarżonego bądź, gdy takie wątpliwości, na gruncie zgromadzonego materiału dowodowego, powinien powziąć. Adresatem norm wynikających z przepisu art. 5 § 2 k.p.k. są organa orzekające, a nie strony postępowania”* – tak też Sąd Najwyższy w postanowieniu z 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt 78/14).

zawierać trzy elementy – wskazanie: (1) co zrobił sąd + (2) jak powinno być prawidłowo + (3) jaki może mieć to wpływ na treść zapadłego rozstrzygnięcia.

Różnica natomiast sprowadza się do tego, kiedy należy sformułować zarzut obrazy prawa procesowego, a kiedy błędu w ustaleniach faktycznych. W pracach egzaminacyjnych nierzadko zarzut z art. 438 pkt 3 k.p.k. to w rzeczywistości zarzuty obrazy prawa procesowego, tyle że bez wskazania konkretnego przepisu Kodeksu postępowania karnego, którego obrazy dopuścił się sąd. Zdający np. zamiast sformułować zarzut obrazy art. 7 k.p.k. w odniesieniu do zeznań świadka Jana Kowalskiego, formułując zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, polegający na błędnym uznaniu zeznań świadka Jana Kowalskiego (bądź poszczególnych elementów/okoliczności, wynikających z tych zeznań) za wiarygodne i przydatne do czynienia dalszych istotnych ustaleń w sprawie. Oczywiście najważniejszym z punktu widzenia efektu jest dostrzeżenie samego uchybienia. Dla znacznej części egzaminatorów, w tym autorki niniejszej publikacji, przyjęcie jednak takiej konstrukcji zarzutu sugeruje, że zdający nie potrafi wskazać konkretnego naruszonego przepisu Kodeksu postępowania karnego, choć słusznie dostrzega sam problem.

Obecnie granica pomiędzy omawianymi zarzutami mocno się zatarła. W apelacjach obrońcy i pełnomocnicy zamiennie posługują się oboma zarzutami. W warunkach egzaminacyjnych sugeruję jednak formułowanie zarzutu obrazy prawa procesowego zamiast błędu w ustaleniach faktycznych, choćby po to, by uniknąć zarzutu ze strony egzaminatora, że zdający nie potrafi wskazać konkretnych nakazów lub zakazów z Kodeksu postępowania karnego, które sąd miałby obrazić, dochodząc do określonego ustalenia.

Pamiętajmy, że sąd I instancji ocenia materiał dowodowy i dopiero wynikiem tej oceny jest dokonanie określonych ustaleń faktycznych. **Błędne ustalenie faktyczne jest zatem najczęściej skutkiem błędu popełnionego przez sąd na płaszczyźnie oceny materiału dowodowego.** Innymi słowy, jeśli sąd błędnie uznał świadka lub dokument za dowód wiarygodny, to naturalną konsekwencją będzie poczynienie przez sąd błędnych ustaleń faktycznych w oparciu o te błędnie ocenione dowody.

W pracach egzaminacyjnych nierzadko spotykam się z **niepoprawną praktyką dublowania zarzutów z art. 438 pkt 2 k.p.k. oraz z art. 438 pkt 3 k.p.k.** Zdający formułują prawidłowe zarzuty obrazy prawa procesowego, by

następnie sformułować odrębny zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, który merytorycznie i co do treści jest tożsamy ze sformułowanymi w pracy zarzutami obrazy prawa procesowego. Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 lutego 2018 r. (sygn. akt II AKa 7/18), *błędne ustalenia faktyczne są konsekwencją wadliwych wniosków wywiedzionych z właściwie ocenionych dowodów lub pominięcia wynikających z tych dowodów okoliczności. Nie jest więc wewnętrznie spójne zarzucanie jednocześnie dowolnej oceny dowodów i błędu w ustaleniach faktycznych co do tego samego rozstrzygnięcia*. Praktyka formułowania zatem ww. dwóch odrębnych zarzutów co do tej samej kwestii, jest nieprawidłowa i wiąże się z reguły ze wskazaniem w opisie oceny dokonanej przez egzaminatora, że zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych są w istocie zbędne, albowiem są wyłącznie powtórzeniem co do meritum zarzutów obrazy prawa procesowego.

Prawidłowe jest natomiast wskazanie błędu w ustaleniach faktycznych jako trzeciego członu konstrukcyjnego zarzutu obrazy prawa procesowego. Skoro bowiem błędne ustalenie faktyczne jest najczęściej skutkiem błędu popełnionego przez sąd na płaszczyźnie oceny materiału dowodowego, a prawidłowa konstrukcja zarzutu z art. 438 pkt 2 k.p.k. wymaga określenia wpływu uchybienia na treść rozstrzygnięcia, to – zamiast dublować zarzuty z art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. – właściwe byłoby umieszczenie owego dostrzeżonego błędu w ustaleniach faktycznych jako wpływu obrazy konkretnego przepisu prawa karnego procesowego na treść wydanego wyroku.

Dla zainteresowanych – dawniej zarzut z art. 438 pkt 3 k.p.k. „zarezerwowany” był dla tzw. „samoistnych błędów w ustaleniach faktycznych”, czyli takich, których źródła nie można było jednoznacznie wskazać. Dla przykładu – świadek uznany w uzasadnieniu wyroku przez sąd za wiarygodne źródło dowodowe twierdził, że oskarżony był ubrany w zielony płaszcz. Tymczasem sąd w ustalonym stanie faktycznym stwierdzał, że oskarżony był ubrany w płaszcz koloru czerwonego. W takiej sytuacji nie było jasne w oparciu o jaki dowód sąd ustalił kolor płaszcza jako czerwony, skoro tylko jeden świadek mówił o kolorze i to zielonym, zaś sąd uznał to źródło dowodowe za w pełni wiarygodne. Inaczej byłoby, gdyby sąd uznał świadka za wiarygodnego, ale wskazał, że świadek najpewniej pomylił kolor płaszcza i w tym

zakresie sąd nie dał wiary świadkowi. Wówczas zasadnym – dla zakwestionowania tego ustalenia koloru płaszcza przyjętego przez sąd – byłoby sformułowanie zarzutu z art. 7 k.p.k. W takiej sytuacji wiemy dokładnie, co doprowadziło sąd do określonego (naszym zdaniem wadliwego) ustalenia. W przypadku zaś błędów „samoistnych” tej wiedzy nie mieliśmy i w takiej sytuacji co do zasady właściwy był zarzut z art. 438 pkt 3 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) tzw. błąd braku ustaleń faktycznych w jakimś zakresie należy traktować jako naruszenie przepisów prawa procesowego, nie zaś uchybienie, które należy kwalifikować w ramach podstawy z art. 438 pkt 3 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 lipca 2022 r., sygn. akt II AKa 91/22**
- *Apelacja jest skonstruowana nie w pełni prawidłowo, bo te same kwestie raz podnosi w ramach zarzutów obrazy prawa procesowego, a następnie powtarza pod postacią zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych. Przypomnieć więc trzeba, że zasadniczo winno stawiać się zarzut główny, tzw. pierwotny, a jego dalsze konsekwencje winny być wykazywane w uzasadnieniu środka odwoławczego. Dla przykładu wskazać można, że zarzut obrazy art. 7 k.p.k. wyprzedza zarzut dokonania błędu w ustaleniach faktycznych; wybór wiarygodnych źródeł dowodowych determinuje w istocie dalsze ustalenia. Odnosnie do naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. przypomnieć trzeba, że chodzi tu o wątpliwości sądu, a nie strony. Jeśli więc sąd nie powziął wątpliwości, nie wyraził ich, to nie mógł ich rozstrzygnąć ani na korzyść, ani na niekorzyść oskarżonego. Zarzut winien dotyczyć bądź to obrazy art. 7 k.p.k., bądź błędu w ustaleniach faktycznych pod postacią błędu dowolności – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24 września 2019 r., sygn. akt II AKa 83/19, LEX nr 2978581***
- (...) zarzut obrazy przepisów prawa procesowego z art. 438 pkt 2 k.p.k. może być skuteczny tylko wówczas gdy naruszenie danego przepisu prawa mogło mieć wpływ na kształt zaskarżonego orzeczenia – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2019 r., sygn. akt II AKa 159/18**
- W aspekcie przyczyn odwoławczych określonych w art. 438 pkt 2 k.p.k. w środku odwoławczym mogą być podnoszone także zarzuty niezgodności

przebiegu postępowania z wymogami prawa procesowego, i to zarówno te błędy, które polegają na zaniechaniu wypełnienia konkretnych nakazów przepisów prawa procesowego (*errores in omittendo*), jak i te które sprowadzają się do działania sprzecznego z konkretnymi przepisami procedury (*errores in faciendo*). Przepisy procedury statuuja też fundamentalne metody oceny dowodów, z zatem takie naruszenie tych zasad, które mogło mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, może stanowić podstawę zarzutu środka odwoławczego. Należy pamiętać o tym, że wpływ danego uchybienia na treść orzeczenia zależy ściśle od realiów konkretnej sprawy (*vide*: „Kodeks postępowania karnego – Komentarz” pod. red. Z. Gostyńskiego wyd. ABC W-wa 1998 tom II, str. 460–461 tezy 13, 15) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 10 stycznia 2019 r., sygn. akt II AKa 91/18**

- Tymczasem jest oczywiste, że uchybieniem o charakterze pierwotnym może być wyłącznie obraza przepisu prawa procesowego, zaś błąd w ustaleniach faktycznych jest natomiast implikacją naruszenia art. 7 k.p.k. Kwestionowane przez obrońcę ustalenia faktyczne przedmiotowej sprawy, są przecież konsekwencją uznania przez sąd I instancji za prawdziwe określonej treści dowodów, stąd przede wszystkim zasadnicza jest kwestia odpowiedzi na pytanie, czy sąd ten sprostął zasadzie określonej w art. 7 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 lipca 2018 r., sygn. akt II AKa 92/18**
- (...) błędne ustalenia faktyczne są konsekwencją wadliwych wniosków wywiedzionych z właściwie ocenionych dowodów lub pominięcia wynikających z tych dowodów okoliczności. Nie jest więc wewnętrznie spójne zarzucanie jednocześnie dowolnej oceny dowodów i błędu w ustaleniach faktycznych co do tego samego rozstrzygnięcia – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 14 lutego 2018 r., sygn. akt II AKa 7/18**
- O istotnym wpływie obrazy przepisów postępowania na treść orzeczenia można mówić dopiero wtedy, gdy zasadnie wykaże się, iż kwestionowane rozstrzygnięcie byłoby w istotny sposób odmienne od tego, które w sprawie zapadło (*vide postan.* SN z 18 marca 2003 r., IV KKN 332/00, LEX nr 77447) – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28 czerwca 2012 r., sygn. akt II AKa 137/12**

- *Nie ustosunkowanie się formalne do jednego z wniosków dowodowych może wprawdzie stanowić uchybienie wymogom art. 170 § 3 k.p.k., jednakże naruszenie to nie uzasadnia automatycznie wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Dzieje się tak bowiem tylko wówczas, gdy obraza przepisów postępowania mogła mieć wpływ na treść orzeczenia, co jednoznacznie wynika z treści art. 438 pkt 2 k.p.k. Każda obraza przepisów postępowania, jak podkreśla się w piśmiennictwie, wymaga indywidualnej oceny okoliczności konkretnego wypadku – wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 2003 r., sygn. akt SNO 54/03*

Ad. 6.2.2.4. Konstrukcja zarzutu rażąco niewspółmiernej kary (uzupełniona o uwagi co do merytorycznych podstaw formułowania zarzutów z art. 438 pkt 4 k.p.k.)

W art. 438 pkt 4 k.p.k. ustawodawca wskazał, że orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka. Powyższa redakcja przepisu oznacza, że **zarzut konstruowany w oparciu o art. 438 pkt 4 k.p.k. odnosi się do dwóch różnych rodzajowo sytuacji**. Z jednej strony do sytuacji rażącej niewspółmierności kary, środka karnego lub nawiązki. Z drugiej zaś – do niesłusznego zastosowania lub niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka (np. środka kompensacyjnego¹¹).

Pamiętać należy, że zarzut niewspółmierności orzeczonej kary/środka karnego lub nawiązki wymaga odniesienia orzeczonej kary/środka karnego lub nawiązki do kary/środka karnego lub nawiązki, jaka powinna zostać

¹¹ Zgodnie z art. 56 k.k., przepisy art. 53 k.k., art. 54 § 1 k.k. oraz art. 55 k.k. stosuje się odpowiednio do orzekania innych środków przewidzianych w tym kodeksie, z wyjątkiem obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z powyższej regulacji wprost wynika zatem, że do środków kompensacyjnych nie stosujemy m.in. sądowych dyrektyw wymiaru kary (art. 53 § 1 k.k.). Jednocześnie, skoro kwestia niewspółmierności związana jest z sądowymi dyrektywami kary (bo w oparciu o stopień wykorzystania elementów składających się na te dyrektywy twierdzimy o rażącej surowości lub łagodności kary), to tym samym logicznie przyjąć należałoby, że w odniesieniu do środka kompensacyjnego nie możemy stosować kryterium niewspółmierności z art. 438 pkt 4 k.p.k.

orzeczona przy uwzględnieniu zasad sądowego wymiaru kary z art. 53 k.k. **Istotą zarzutu rażąco niewspółmiernej (tj. rażąco surowej lub rażąco łagodnej) kary/środka karnego lub nawiązki jest ich zobiektywizowanie, poprzez odniesienie do kary/środka karnego lub nawiązki, jakie powinny zostać orzeczone w okolicznościach danej sprawy, przy prawidłowym zastosowaniu zasad wynikających z art. 53 k.k. oraz reguł wypracowanych w tej kwestii przez judykaturę.** Sąd Najwyższy oraz sądy powszechne wielokrotnie podkreślały bowiem, że **o nadmiernej surowości bądź łagodności kary/środka karnego lub nawiązki nie decyduje ich nominalny wymiar.** Mogłoby się bowiem okazać, że np. kara 6 lat pozbawienia wolności – która wydaje się być z założenia karą surową, skoro dotyczy wieloletniego pozbawienia człowieka wolności – w okolicznościach danej sprawy jest karą rażąco łagodną, nieuwzględniającą wszystkich występujących w sprawie okoliczności obciążających sprawcę. Z kolei kara 6 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 148 § 1 k.k. (przy czym dolna granica ustawowego zagrożenia za zabójstwo to 8 lat pozbawienia wolności) w okolicznościach danej sprawy jest karą nadmiernie surową – sąd wprawdzie zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary, np. w oparciu o art. 31 § 2 k.k., jednak nie uwzględnił w wystarczającym stopniu szeregu okoliczności łagodzących odpowiedzialność karną oskarżonego.

Należy również pamiętać, że zarzut z art. 438 pkt 4 k.p.k. odnosi się wyłącznie do niewspółmierności orzeczonych środków karnych/kar/nawiązki, nie zaś zasadności ich orzeczenia. Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 23 listopada 2016 r., *kara może być uznana za rażąco niewspółmierną z powodu niewłaściwego wyboru jej rodzaju, jej nadmiernej wysokości, albo z powodu nieorzeczenia warunkowego zawieszenia jej wykonania*¹².

Natomiast w przypadku kiedy sąd w wyroku orzekł karę, której wymiar nie jest przewidziany przepisami Kodeksu karnego (np. 6 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.) albo orzekł w wyroku o przypadku przedmiotów, które nie stanowiły własności oskarżonego, mimo że przypisane sprawcy przestępstwo nie przewidywało takiej możliwości (*vide*: art. 44 § 7 k.k.), to obrońca powinien sformułować w apelacji zarzut

¹² Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 23 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 222/16.

obraży prawa materialnego na podstawie art. 438 pkt 1a k.p.k., nie zaś zarzut z art. 438 pkt 4 k.p.k. Podobnie, jeśli Sąd nie orzekł o obowiązku naprawienia szkody w całości lub w części, mimo wniosku oskarżyciela posiłkowego w tym przedmiocie, to pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego powinien sformułować w apelacji, na podstawie art. 438 pkt 1a k.p.k., zarzut obraży prawa materialnego, tj. art. 46 § 1 k.k., nie zaś zarzut z art. 438 pkt 4 k.p.k.

Natomiast gdyby sąd orzekł zbyt wygórowaną kwotę np. tytułem zadośćuczynienia (z perspektywy obrońcy) bądź zbyt małą kwotę zadośćuczynienia (z perspektywy oskarżyciela posiłkowego) – w stosunku do faktycznie doznanej przez oskarżyciela posiłkowego krzywdy – wówczas zasadnym byłoby sformułowanie zarzutu błędnego ustalenia faktycznego co do rozmiaru zasądzonego środka kompensacyjnego.

Przykład I: Zaskarżonemu wyrokowi, na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 4 k.p.k., zarzucam rażąco niewspółmierność wymierzonej oskarżonemu kary łącznej w wymiarze 4 lat pozbawienia wolności, co jest wynikiem wadliwego zastosowania zasad zbliżonych do zasady kumulacji poszczególnych kar jednostkowych, w sytuacji zaistnienia okoliczności przemawiających za zastosowaniem wobec oskarżonego zasad pełnej absorpcji.

Przykład II: Zaskarżonemu wyrokowi, na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 4 k.p.k., zarzucam rażąco łagodność wymierzonej oskarżonemu kary ograniczenia wolności, w sytuacji gdy czyn przez niego popełniony i okoliczności jego popełnienia, a także postawa oskarżonego w toku procesu, wprost wskazują, że dla osiągnięcia celów kary wymagany jest proces resocjalizacji w warunkach izolacji.

Przykład III: Zaskarżonemu wyrokowi, na zasadzie art. 427 § 2 k.p.k. w zw. z art. 438 pkt 4 k.p.k., zarzucam rażąco niewspółmierność orzeczonej kary w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności, wynikającą z nieuwzględniania w odpowiednim stopniu faktu przyznania się przez oskarżonego do winy oraz opisanie przebiegu zdarzeń, umożliwiającego Sądowi poczynienie dokładnych ustaleń stanu faktycznego, a nadto faktu przeproszenia pokrzywdzonych i wyrażenia żalu oraz okazania skruchy, co w konsekwencji doprowadziło

do wyraźnej dysproporcji pomiędzy charakterem kar orzeczonych a karami, które powinny zostać orzeczone przy zastosowaniu dyrektyw wymiaru kary oraz zasad ukształtowanych przez judykaturę.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) z rażącą niewspółmiernością kary mamy do czynienia wówczas kiedy zachodzi nienadająca się do zaakceptowania dysproporcja pomiędzy karą wymierzoną a karą, która powinna w danych warunkach zostać wymierzona aby była karą sprawiedliwą, zasłużoną dla sprawcy przestępstwa przypisanego mu w wyroku – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 grudnia 2021 r., sygn. akt II AKa 260/21**
- W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że rażąca niewspółmierność kary występuje wtedy, gdy kara orzeczona nie uwzględnia w należyty sposób stopnia społecznej szkodliwości przypisywanego czynu oraz nie realizuje wystarczająco celu kary, ze szczególnym uwzględnieniem celów zapobiegawczych i wychowawczych. Pojęcie niewspółmierności rażącej oznacza znaczną, wyraźną i oczywistą, a więc niedającą się zaakceptować dysproporcję między karą wymierzoną a karą sprawiedliwą (zasłużoną). Przesłanka rażącej niewspółmierności kary jest spełniona tylko wtedy, gdy na podstawie ustalonych okoliczności sprawy, które powinny mieć decydujące znaczenie dla wymiaru kary, można przyjąć, że występuje wyraźna różnica między karą wymierzoną a karą, która powinna zostać wymierzona w wyniku prawidłowego zastosowania dyrektyw wymiaru kary oraz zasad ukształtowanych przez orzecznictwo – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 października 2021 r., sygn. akt II AKa 251/20**
- (...) podstawą zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary jest wykazanie, że w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek, który powoduje, że nawet najniższa kara przewidziana w ustawie musi być uznana za karę rażąco surową. Wystąpienie takiego szczególnego wypadku powinno znajdować wsparcie w okolicznościach nietypowych samego zdarzenia albo takich cechach sprawcy, które charakteryzują go w sposób wyjątkowo pozytywny i powodują, że zasługuje on na wymierzenie kary poniżej minimum ustawowego. Ocena co do tego, że

w odniesieniu do konkretnego sprawcy zachodzi podstawa do skorzystania z dobrodziejstwa przewidzianego w art. 60 § 2 k.k., należy oczywiście do sądu i jest oceną swobodną, ale nie dowolną. Decydując się na orzeczenie kary z nadzwyczajnym jej złagodzeniem, sąd ma więc obowiązek przedstawić argumenty uzasadniające przekonanie, że w realiach rozpoznawanej sprawy zaistniały przesłanki do takiego postąpienia. Nie może też budzić wątpliwości, że wypadki szczególnie uzasadnione, o jakich mowa w przepisie art. 60 § 2 k.k., istotnie różnią się od wypadków zwykłych, co do których obowiązują standardowe dyrektywy wymiaru kary. Te ostatnie bowiem pozwalają na wykorzystanie możliwości istniejących w ramach ustawowych granic zagrożenia karą. Natomiast zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary bez jednoczesnego wykazania, że istotnie przemawiały za tym okoliczności o charakterze szczególnym, w pełni uzasadnia przekonanie, że kara wymierzona w takich warunkach jest karą rażąco niewspółmierną (vide wyrok SN z dnia 4 lutego 2020, sygn. III KK 113/2019) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II AKa 112/20**

- O rażącej niewspółmierności kary w rozumieniu art. 438 pkt 4 k.p.k. nie można bowiem mówić w sytuacji, gdy Sąd wymierzając karę uwzględnił wszystkie okoliczności wiążące się z poszczególnymi ustawowymi dyrektywami i wskaźnikami jej wymiaru. Nie można zasadnie dowodzić rażącej niewspółmierności kary także wówczas, gdy granice swobodnego uznania sędziowskiego będące wyrazem zasady sądowego wymiaru kary nie zostały przekroczone (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 kwietnia 1996 r. II AKa 85/96, publ. KZS 1996/4/42; wyroki Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 1996 r. II AKr 463/95, publ. OSA 1996/7-8/27 i z dnia 22 czerwca 1995 r. II AKr 178/95, publ. Prok. i Pr. 1996/2-3/25 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1973 r. III KR 254/73, publ. OSNPG 1974/3-4/51) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 listopada 2020 r., sygn. akt II AKa 217/18**
- W świetle ugruntowanego orzecznictwa sądowego za represję rażąco niewspółmierną uznaje się taką karę, która – pomijając dyrektywy wymiaru kary – w sposób istotny lub wręcz drastyczny odbiega od tej,

jaką należałoby wymierzyć przy uwzględnieniu okoliczności przedmiotowych charakteryzujących czyn przypisany sprawcy oraz podmiotowych, związanych z jego osobą. Na gruncie art. 438 pkt 4 k.p.k. nie chodzi bowiem o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, że karę dotychczas wymierzoną można byłoby określić – również w odbiorze zewnętrznym – jako rażąco niewspółmierną, tzn. niewspółmierną w stopniu nie pozwalającym na jej akceptację. W realiach tej sprawy, nie ulega wątpliwości, że karę 25 lat pozbawienia wolności wymierzoną K. M. nie sposób ocenić jako karę niewspółmiernie rażąco łagodną – **postanowienie Sądu Najwyższego z 26 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 382/19**

- Należy podkreślić, że podstawę do orzeczenia kary stanowi przestępstwo, a miarę kary jego społeczna szkodliwość. Dyrektywa współmierności kary do stopnia społecznej szkodliwości czynu sprawcy odgrywa decydującą rolę przy wyrokowaniu, a zatem to właśnie stopień społecznej szkodliwości czynu ma zatem kształtować orzeczenie o karze. Zgodnie z art. 115 § 2 k.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiar wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych obowiązków a także postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (vide: uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 lipca 2002 r. II AKa 340/02) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 31 października 2019 r., sygn. akt II AKa 153/19**
- Nie może być przecież mowy o rażącym naruszeniu art. 53 k.k. Zarzut dotyczący wymierzenia kary nieodpowiadającej dyrektywom sądowego wymiaru kary może bowiem stanowić tylko względną przyczynę odwoławczą określoną w art. 438 pkt 4 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 17 maja 2017 r., sygn. akt IV KK 155/17**
- (...) rażąca niewspółmierność kary, o jakiej mowa w art. 438 pkt 4 k.p.k., zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą wymierzoną przez sąd pierwszej instancji a karą, jaką należałoby wymierzyć

w instancji odwoławczej w następstwie prawidłowego zastosowania w sprawie dyrektyw wymiaru kary przewidzianych w art. 53 k.k. oraz zasad ukształtowanych przez orzecznictwo Sądu Najwyższego (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1973 r., III KR 254/73, OSNPG 1974, nr 3–4, poz. 51 i aprobatę tego stanowiska: M. Cieślak, Z. Doda, Przegląd orzecznictwa, Palestra 1975, z. 3, s. 64). Nie chodzi zatem o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną nazwać można byłoby – również w potocznym znaczeniu tego słowa – „rażąco” niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu niedającym się wręcz zaakceptować (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 1994 r., II KRN 189/94, OSN Prok. i Pr. 1995, Nr 5, poz. 18). O rażącej niewspółmierności kary wymierzonej oskarżonemu P. P. w powyższym znaczeniu niewątpliwie nie może być mowy. W ocenie Sądu Apelacyjnego kara ta jest współmierna do stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu i spełnia zadania w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele indywidualno-prewencyjne. Jest wynikiem trafnej oceny okoliczności przedmiotowych i podmiotowych sprawy i jako spełniająca wymogi określone dyrektywami przepisu art. 53 § 1 i 2 k.k., uznana być musi za karę prawidłowo wyważoną. Wymierzona oskarżonemu kara nie przekracza stopnia jego zawinienia i jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości jego czynu, który był wysoki. Jej wymiar uwzględnia wszystkie okoliczności mające wpływ na wymiar kar, zarówno obciążające, jak i przemawiające na korzyść oskarżonego – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 października 2017 r., sygn. akt II AKa 318/17**

- Kara może być uznana za rażąco niewspółmierną z powodu niewłaściwego wyboru jej rodzaju, jej nadmiernej wysokości, albo z powodu nieorzeczenia warunkowego zawieszenia jej wykonania (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II AKa 81/15, LEX nr 1393146) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 23 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 222/16**
- Podkreślenia wymaga, że nie chodzi tu o każdą ewentualną różnicę w ocenach co do wymiaru kary, ale o różnicę ocen tak zasadniczej natury, iż karę dotychczas wymierzoną można byłoby nazwać – również

w potocznym znaczeniu tego słowa – „rażąco” niewspółmierną, to jest niewspółmierną w stopniu nie dającym się wręcz zaakceptować – wyrok Sadu Najwyższego z 18 października 2016 r., sygn. akt SNO 43/16

Ad. 6.3. Bezwzględne przyczyny odwoławcze z art. 439 § 1 k.p.k.

Skoro omówione zostały już zasady odnoszące się do poprawnego konstruowania zarzutów z art. 439 § 1 k.p.k. i z art. 438 k.p.k., to warto przedstawić podstawowe reguły merytorycznego ich formułowania. W niniejszej części opracowania oraz w rozdziale 7 postaram się odpowiedzieć na pytanie – kiedy merytorycznie prawidłowe będzie sformułowanie zarzutu z art. 439 § 1 k.p.k., a kiedy z określonego punktu art. 438 k.p.k.?

Bezwzględne przyczyny odwoławcze, jak wskazane zostało powyżej, to najbardziej doniosłe uchybienia, jakie mogą wystąpić w procesie karnym. Ich pojawienie się nie może być pominięte, czy sanowane w drodze zmiany rozstrzygnięcia przez Sąd Odwoławczy, albowiem art. 439 § 1 k.p.k. wprost wskazuje, że niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia – sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyła zaskarżone orzeczenie. W praktyce wymiaru sprawiedliwości bezwzględne przyczyny odwoławcze występują raczej dość rzadko, co wynika z doniosłości i wagi tych najistotniejszych uchybień.

Z mojego doświadczenia wynika, że z reguły podczas egzaminów adwokackich pojawia się przynajmniej jedna bezwzględna przyczyna odwoławcza. Wielokrotnie zdarzało się, że jej dostrzeżenie i właściwe opisanie przesądzało o zdaniu egzaminu. Jednocześnie **zdarzało się, że egzaminowani nie tylko nie dostrzegali właściwych przyczyn z art. 439 § 1 k.p.k., ale nadto wskazywali bezwzględne przyczyny odwoławcze tam, gdzie ich nie było lub mylili poszczególne bezwzględne przyczyny odwoławcze, np. zamieniając stosując pojęcia braku skargi uprawnionego oskarżyciela z brakiem wniosku o ściganie.** Co więcej, nierzadko argumentacja zdających podążała w przeciwnym kierunku do utrwalonej linii orzeczniczej sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, co – nawet w przypadku prawidłowego dostrzeżenia

wszystkich innych uchybień zadania egzaminacyjnego – istotnie wpływało na obniżenie oceny pracy z uzasadnieniem odnoszącym się do nieznamomości orzecznictwa na tle konkretnych bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Z tego względu zdecydowałam się omówić w niezbędnym zakresie zagadnienie bezwzględnych przyczyn odwoławczych, po to, aby przygotowujący się do egzaminu zapoznali się z podstawowymi tezami orzecznictwymi i uniknęli na egzaminie prezentowania całkowicie błędnych wywodów prawnych.

Oczywistym jest, że w publikacji tego rodzaju jak niniejsza nie ma możliwości dogłębnego omówienia problematyki bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Postaram się jednak w prosty sposób wyjaśnić jak orzecznictwo oraz doktryna rozumie poszczególne przyczyny z art. 439 § 1 k.p.k. (w tym – mając na uwadze art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. – także te z art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11 k.p.k.) po to, by pomóc uniknąć zdającym popełnienia zbyt często pojawiających się błędów w tym zakresie.

Aby ułatwić pełniejsze zrozumienie omawianej materii, przedstawienie każdej z bezwzględnych przyczyn odwoławczych uzupełnione zostanie przydatnym orzecznictwem. Zapoznanie się z zebranymi poniżej tezami orzecznictwymi powinno być wystarczające na potrzeby egzaminu zawodowego.

Ad. 6.3.1. W wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. – art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.;

Powtarzając za Sądem Apelacyjnym w Krakowie¹³, osobą nieuprawnioną do orzekania w rozumieniu ww. przepisu jest osoba, która nie ma w ogóle uprawnień do orzekania, natomiast osobą niezdolną do orzekania z tego przepisu jest osoba, która wprawdzie posiada uprawnienia do orzekania, jednak ze względu na chwilowe lub trwałe zakłócenia psychiczne spowodowane chorobą psychiczną, stanem odurzenia alkoholowego, narkotycznego czy innego stanu chorobowego, nie jest zdolna orzekać świadomie i zgodnie z wymogami prawa. Wykazanie takiego stanu powinno opierać się na dowodach, a nie tylko na subiektywnym przekonaniu osoby zainteresowanej

¹³ Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 maja 2014 r., sygn. akt II AKo 34/14.

wynikiem procesu. Przytoczone poniżej orzeczenia ukazują, jakie sytuacje procesowe uznane zostały przez sądy za odpowiadające znaczeniu art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- *Trafnie w kwestii tej wypowiedział się w sposób kategoryczny Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 marca 1988 r., II KR 36/88 (OSNKW 1988, z. 7–8, poz. 58), gdy stwierdził „zgodnie z art. 30 pkt 7 k.p.k. (z 1969 r. – obecnie art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. – uwaga SN), udział sędziego w wydaniu każdego orzeczenia, które zostało następnie uchylone, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, powoduje wyłączenie go od udziału w sprawie w razie jej ponownego rozpoznania, i to niezależnie od przyczyn, jakie legły u podstaw wydanego orzeczenia”, zasadnie przy tym konkludując, że „skutki takie będą rodziły wszystkie sytuacje, gdy sędzia wypowiadał się merytorycznie w sprawie w zakresie winy, lecz także niewątpliwym jest, że takie same skutki rodzić musi udział w wydaniu orzeczenia o umorzeniu postępowania – na skutek stwierdzenia ujemnych lub braku dodatnich przesłanek procesowych, gdyż po prostu powołany przepis nie wprowadza żadnych w tym zakresie ograniczeń” – wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2021 r., sygn. akt V KK 439/19*
- (...) *aplikant adwokacki jako substytut obrońcy czy pełnomocnika jest także uczestnikiem postępowania, w związku z działaniem którego może mieć zastosowanie wyłączenie sędziego w trybie art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k., chociaż działa on na podstawie instrukcji udzielającego substytucji i w granicach jego pierwotnego umocowania. Sąd Najwyższy stwierdza, że sędzia nie jest wyłączony z mocy ustawy w rozumieniu art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k. od rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym, gdy w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w charakterze substytutu pełnomocnika pokrzywdzonego incydentalnie (jednorazowo) wziął udział w rozprawie – na której nie podjęto innych czynności poza stwierdzeniem stawiennictwa i odebraniem oświadczenia co do występowania przez pokrzywdzonego w roli oskarżyciela posiłkowego – adwokat będący synem tego sędziego. Pojęcie „udziału” sędziego w sprawie, w rozumieniu przesłanek wyłączenia z art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k.,*

oznacza wystąpienie sędziego w sprawie, której rozpoznanie nastąpiło w całości albo choćby w części z udziałem osób wskazanych w art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k., tzn. co najmniej rozpoczęło się, albo rozpoczęte trwało, ew. nastąpiło podjęcie przez te osoby innych czynności, w tym zwłaszcza procesowych równoznacznych z zajęciem stanowiska w sprawie, złożeniem oświadczeń procesowych co do rozpoznawanych kwestii dotyczących sprawy, aktywnego albo nawet biernego zajęcia stanowiska co do rozpoznawanego oskarżenia – **postanowienie Sądu Najwyższego z 3 września 2020 r., sygn. akt V KO 57/20**

- Ławnik ta bowiem, biorąc udział w wydaniu wyroku skazującego M. K. (1) w sprawie XVI K 49/18 za tożsamy rozbój na osobie S. N., jaki zarzucano B. S., zapoznała się dokładnie z tym samym materiałem dowodowym, stanowiącym podstawę oskarżenia i skazania M. K. (1) i uznając, że stanowi on podstawę do przyjęcia popełnienia przez skazanego i osób z nim uczestniczących w popełnieniu tego czynu, w tym B. S., już w wyroku z dnia 1 marca 2018 r., przestępstwa rozboju z art. 280 § 2 k.k., przesądziła, iż materiał ten daje podstawy do przyjęcia, iż czterech sprawców, a więc nie tylko, M. K. (1), ale i P. S., M. S. i B. S., w sposób dokładnie opisany w treści zarzucanego czynu, dopuścili się przestępstwa rozboju kwalifikowanego z art. 280 § 2 k.k., którego przedmiotem miał być telefon komórkowy marki (...) o wartości 800 zł należący do J. R. Tymczasem ławnik ta, dosłownie kilka miesięcy później, ponownie orzekała w sprawie dotyczącej tego samego rozboju na podstawie dokładnie tych samych dowodów, wydając wspólnie z pozostałych składem orzekającym zaskarżony wyrok, mając już przecież wyrobione przekonanie, że ten właśnie materiał dowodowy nakazuje przyjąć zasadność zarzucanego oskarżonemu B. S. przestępstwa rozboju na osobie S. N. w sposób, w jaki to zaproponował prokurator w akcie oskarżenia, a więc i w sposób, w jaki to przyjęto w treści wyroku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie XVI K 49/18. Powyższe więc prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż w przypadku tego ławnika zaistniała uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności w tej sprawie w rozumieniu art. 41 § 1 k.p.k., skoro w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie (por. uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 9/07, OSNKW 2007/5/39; wyrok SN z dnia

29 sierpnia 2006 r., V KK 107/05, OSNKW 2006, z. 10, poz. 96; wyrok SN z dnia 2 czerwca 2011 r., III KK 328/10, LEX nr 860618; wyrok SN z dnia 8 lutego 2011 r.) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt II AKa 47/19**

- (...) bezwzględną podstawą odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. jest sytuacja, gdy w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. Z oczywistych względów należało rozstrzygnąć, czy w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w P. uczestniczyła w wydaniu orzeczenia „osoba uprawniona do orzekania”. W orzecznictwie sądowym, a także w literaturze prawniczej zalicza się do tego rodzaju uchybienia między innymi brak uprawnień do orzekania w danym sądzie. Uznaje się za udział w orzekaniu osoby nieuprawnionej sytuacje, gdy w składzie sądu wyższego orzekał sędzia sądu niższego bez właściwej delegacji. Innymi słowy, w przypadku osoby nieuprawnionej do orzekania chodzi nie tylko o osobę niemającą w ogóle uprawnień do orzekania, ale jest nią także osoba niemająca uprawnień do orzekania w danej sprawie, czy w danym sądzie. W praktyce może dochodzić również do zbiegu dwóch bezwzględnych podstaw odwoławczych – w omawianym przypadku – udziału w orzekaniu osoby nieuprawnionej oraz nienależytej obsady sądu w ujęciu art. 439 § 1 pkt 2 in principio k.p.k. W orzecznictwie sądowym przyjmowano, że nienależytą obsadą jest m.in. udział w składzie sądu wyższego rzędu sędziego sądu niższego bez delegacji lub sędziego, na którego delegowanie na obszarze właściwości danego sądu okręgowego lub apelacyjnego prezes tego sądu nie uzyskał zgody kolegium sądu, o jakiej mowa w art. 77 § 8–9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, j.t., z późn. zm. – dalej jako u.s.p.). Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych nie pozostawiało w tej materii żadnych wątpliwości, akcentując wyjątkowy charakter przepisów regulujących delegowanie sędziego oraz związany z tym wymóg dokonywania ich ściślejszej wykładni. Stwierdzenie to dotyczyło również sposobu określenia czasu pełnienia obowiązków sędziego w sądzie wskazanym w decyzji o delegowaniu. Podkreślano, że czynności orzecznicze podejmowane w sprawie

przez sędziego delegowanego muszą mieścić się w ramach tego aktu, który winien obejmować nie tylko dni prowadzenia spraw lub udziału w nich tego sędziego, ale również dni, w których w takich sprawach wydawane (ogłaszane) są orzeczenia. Te ostatnie czynności stanowią wszak immanentną część postępowania sądowego i brak jest podstaw do kształtowania w ich ramach odmiennych wymogów w zakresie składu sądu i jego należytej obsady (...) Przepis art. 47b § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, j.t., z późn. zm.) stanowi ustawową i samoistną podstawę prawną do podejmowania przez delegowanego sędziego czynności w sprawie, aż do ich zakończenia. Treść tego przepisu prowadzi do wniosku, że udzielenie delegacji sędziemu sądu niższego do orzekania w sądzie wyższego rzędu, która to delegacja dotyczy konkretnej sprawy i konkretnego terminu jej rozpoznania, wywiera skutki prawne nie tylko na określony w treści delegacji termin rozprawy, lecz także na wszystkie pozostałe terminy, w których sprawa ta będzie się odbywać. W rezultacie należy przyjąć, że delegacja sędziego obowiązuje od daty w niej wskazanej do czasu merytorycznego zakończenia sprawy, łącznie z terminem ogłoszenia wyroku, którego odroczenie nastąpiło w trybie art. 411 § 1 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r., sygn. akt II KK 257/18**

- Mając na uwadze treść art. 159 § 1 pkt 3 u.s.p. i art. 23 o strażach gminnych, nie ma wątpliwości, że H. W. nie mógł być jednocześnie ławnikiem i strażnikiem miejskim, gdyż łączenie stanowiska związanego ze ściganiem przestępstw i wykroczeń z funkcją ławnika prowadziło do złamania zasady incompatibilitas, o której mowa w pierwszym z powołanych przepisów. Założeniem wdrożenia ustawowego zakazu łączenia stanowisk było wyeliminowanie takiego stanu rzeczy, w którym wymiar sprawiedliwości sprawowałyby jednostki zajmujące się zawodowo wykonywaniem ochrony prawnej, oraz przeciwdziałanie sytuacjom, w których osoby objęte treścią przepisu mogłyby znać sprawę z racji wykonywanego zawodu lub być związane stosunkiem podległości z osobami decydującymi o sprawie – **wyrok Sądu Najwyższego z 9 października 2018 r., sygn. akt III KO 110/18**
- Nie budzi wszak wątpliwości, że użyte na gruncie art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. określenie „osoba” swoim zakresem znaczeniowym obejmuje również

ławników (tak trafnie m.in. J. Grajewski, S. Steinborn, *Komentarz aktualizowany do art. 425–673 Kodeksu postępowania karnego*, L.K. Paprzycki (red.), komentarz do art. 439, teza 11) – **wyrok Sądu Najwyższego z 9 października 2018 r., sygn. akt III KO 105/18**

- (...) uchybieniem mieszczącym się w treści art. 439 § 1 k.p.k. jest li tylko sytuacja, w której w rozpoznaniu sprawy bierze udział sędzia podlegający wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.). Nie chodzi zatem o uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego (art. 41 § 1 k.p.k.), ale o sytuację, w której sędzia orzekający w danej sprawie podlega wyłączeniu z mocy prawa (art. 40 § 1 k.p.k.) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 29 marca 2018 r., sygn. akt V KZ 15/18**
- Samo stwierdzenie faktu orzekania na etapie apelacyjnym z udziałem osoby podlegającej wyłączeniu z mocy prawa w oparciu o art. 40 § 1 pkt 6 k.p.k. było wprawdzie wystarczające do uchylenia zaskarżonego orzeczenia (art. 439 § 1 pkt 1 in fine k.p.k.), niemniej nie obligowało instytucji kasacyjnej do rezygnacji z próby odgadnięcia, dlaczego Sąd odwoławczy dopuścił się tak poważnego pogwałcenia prawa procesowego – **wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt IV KK 318/15**
- Osobą nieuprawnioną do orzekania z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. jest osoba, która nie ma w ogóle uprawnień do orzekania, natomiast osobą niezdolną do orzekania z tego przepisu jest osoba, która wprawdzie posiada uprawnienia do orzekania, jednak ze względu na chwilowe lub trwałe zakłócenia psychiczne spowodowane chorobą psychiczną, stanem odurzenia alkoholowego, narkotycznego czy innego stanu chorobowego, nie jest zdolna orzekać świadomie i zgodnie z wymogami prawa. Wykazanie takiego stanu powinno opierać się na dowodach, a nie tylko na subiektywnym przekonaniu osoby zainteresowanej wynikiem procesu – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 maja 2014 r., sygn. akt II AKo 34/14, LEX nr 1514944**
- Z samego brzmienia przepisu art. 439 § 1 k.p.k. (in princ.) wynika, że wskazuje się w nim enumeratywnie na uchybienia obciążające nie określonej czynności procesową lecz „zaskarżone orzeczenie”, a więc wydane przez sąd w obsadzie wymienionej w tym orzeczeniu. Nie należy do jego składu, co oczywiste, sąd wezwany (art. 396 § 1 i 2 k.p.k.), a więc

dokonujący na zlecenie sądu orzekającego określonych czynności w postępowaniu dowodowym. Nienależyta obsada sądu wezwanego, a tym bardziej przeprowadzenie czynności dowodowej bez nakazanego ustawą udziału sądu wezwanego (art. 177 § 1a k.p.k.), nie oznacza zaistnienia uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. (por. wyrok SN z dnia 11 sierpnia 1999 r., V KKN 229/99, OSNKW 1999, z. 9–10, poz. 60) – postanowienie Sądu Najwyższego z 2 marca 2009 r., sygn. akt V KK 319/08

Ad. 6.3.2. Sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie – art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.;

Sytuacja nienależycie obsadzonego sądu to w szczególności przypadek, kiedy skład sądu nie odpowiada warunkom określonym w art. 28–30 k.p.k. Omawiając tę przyczynę odwoławczą nie sposób pominąć w szczególności bezprecedensowej **uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., wydanej w składzie trzech połączonych Izb – Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego¹⁴**, w której Sąd Najwyższy wskazał kryteria oceny wystąpienia przesłanki składu sądu nienależycie obsadzonego w odniesieniu do konkretnych sytuacji procesowych, związanych ze sposobem powołania sędziego (zasadnicze tezy orzeczenia zacytowane zostały poniżej). Wpisując się w obecną sytuację związana z kryzysem praworządności w Polsce, Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r. sygn. akt Kpt 1/20, uznał za niedopuszczalne stosowanie art. 439 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30) w rozumieniu przyjętym w ww. uchwale.

Natomiast nieobecność jednego z członków składu orzekającego na całej rozprawie jest konsekwencją obowiązującej na gruncie Kodeksu postępowania karnego zasady niezmienności składu przez cały toczący się proces karny. Innymi słowy, w procesie karnym (odmiennie niż w postępowaniu

¹⁴ Uchwała Sądu Najwyższego pełny skład Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20.

cywilnym) niezależnie od tego, ile rozpraw głównych odbyło się w danej sprawie, na każdej z nich skład sądu musi być dokładnie taki sam. Powyższa zasada dotyczy tak sędziów zawodowych, jak i ławników. W warunkach egzaminacyjnych sugeruję sprawdzenie wszystkich protokołów z rozprawy głównej, załączonych do zadania egzaminacyjnego, w celu zweryfikowania, czy skład sądu na każdym terminie rozprawy oraz na ogłoszeniu wyroku był dokładnie taki sam. Gdyby zaś okazało się, że choćby na jednym z terminów rozprawy – bez względu na to, jak doniosłe czynności procesowe miałyby się wówczas odbyć – skład sądu uległ zmianie, zasadne jest wskazanie, że doszło do wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.¹⁵

Przydatne orzecznictwo:

- *Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. może zachodzić także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3) (...) warunkiem uznania takiej wadliwości nie może być jednak sam fakt powołania sędziego do pełnienia urzędu na podstawie wniosku złożonego przez KRS w nowym, kwestionowanym konstytucyjnie składzie. Trzeba, aby wadliwość ta w realiach konkretnej sprawy prowadziła do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie*

¹⁵ Na marginesie wskazać można na odmienne uregulowanie omawianej kwestii w sprawach o wykroczenia. Zgodnie bowiem z art. 80 k.p.w., rozprawę przerwana lub odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, choćby skład sądu uległ zmianie, chyba że sąd po wysłuchaniu stron obecnych postanowi inaczej. **W postępowaniu w sprawach o wykroczenia możliwa jest zatem zmiana składu orzekającego w toku postępowania**, która – odmiennie aniżeli na gruncie k.p.k. – nie będzie stanowiła bezwzględnej przyczyny odwoławczej.

praw człowieka i podstawowych wolności – postanowienie Sądu Najwyższego z 18 listopada 2020 r., sygn. akt IV KK 290/20

- *Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) tymczasowo uregulować kwestie sporne i do czasu rozstrzygnięcia sprawy o sygn. Kpt 1/20: I. wstrzymać wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych: 1) ukształtowania składu Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, z późn. zm.) oraz art. 187 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) trybu przedstawiania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, uregulowanego ustawą, o której mowa w pkt 1 oraz art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 3) wykonywania prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do powoływania sędziów zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 1 oraz art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 4) kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego przez osobę powołaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami tej ustawy oraz art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, II. wstrzymać stosowanie, od dnia jej wydania, uchwały składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. W szczególności oznacza to, że: 1) niedopuszczalne jest stosowanie art. 439 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30) oraz art. 379 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) w rozumieniu przyjętym w przedmiotowej uchwale, 2) kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego na urząd przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt I.1, w trybie uregulowanym tą ustawą, nie*

może być ograniczana, 3) orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali sędziowie wskazani w pkt 2, mają moc obowiązującą – **postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2020 r., sygn. akt Kpt 1/20, nr OTK-A 2020/15**

- 1. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.
- 2. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezależności i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
- 3. Wykładnia art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. oraz art. 379 pkt 4 k.p.c. przyjęta w punktach 1 i 2 niniejszej uchwały nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu.
- 4. Punkt 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do orzeczeń wydanych z udziałem sędziów Izby Dyscyplinarnej utworzonej w Sądzie Najwyższym na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym bez względu na datę wydania tych orzeczeń – **uchwała Sądu Najwyższego pełny skład Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I-4110-1/20**

- (...) Sąd Okręgowy, który wydał wyrok w postępowaniu odwoławczym, był nienależycie obsadzony. Stanowi to uchybienie, mające charakter bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., co nakłada na Sąd Najwyższy obowiązek uchylenia zaskarżonego orzeczenia, dotkniętego tym uchybieniem, bez konieczności badania wpływu dostrzeżonego uchybienia na treść tego orzeczenia – **wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r., sygn. akt IV KK 362/17**
- Bezwzględna przyczyna odwoławcza polegająca na tym, że sąd był nienależycie obsadzony zachodzi wówczas, gdy skład sądu orzekającego w konkretnej sprawie jest różny od tego, który przewidziany jest w ustawie jako wyłączny do rozpoznawania określonej kategorii spraw, w sądzie danego szczebla (...) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt II AKa 128/18**
- Uchybienie o jakim mowa art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. powstaje wtedy, gdy sędzia nie ma w ogóle delegacji do orzekania w danym sądzie, jak i wtedy, gdy jego delegacja nie spełnia ustawowych wymogów warunkujących ważność i skuteczność aktu delegowania. Informacja o delegacji sędziego B.P. – S. została prawidłowo podana w komparycji wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 24 maja 2017 r. Stwierdzić przy tym należy, że nie ma obowiązku dołączania do akt każdej sprawy dokumentu – delegacji sędziego, wymóg ten nie wynika ani z przepisów u.s.p. ani k.p.k. Wystarczającym jest kiedy fakt delegacji wynika z odpowiedniej informacji zamieszczonej w komparycji rozstrzygnięcia, co stanowi ukształtowaną i stałą praktykę sądów – **postanowienie Sądu Najwyższego z 8 marca 2018 r., sygn. akt IV KK 12/18**
- (...) uchybienie, które polegało na udziale w składzie orzekającym sądu wyższego rzędu sędziego sądu niższego rzędu bez uprawniającej do tego delegacji, stanowi nienależytą obsadę sądu, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. (zob. np. uchwała SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 28/01, OSNKW 2002, z. 1–2, poz. 3, a także wyroki SN: z dnia 1 października 2002 r., V KK 114/02, LEX nr 55231; z dnia 24 października 2007 r., III KK 210/07, LEX nr 322847; z dnia 17 maja 2011 r., III KK 104/11, LEX nr 795788; z dnia 12 lutego 2016 r., III KK 397/15, LEX nr 2019555, czy z dnia 23 maja 2017 r., III KO 19/17,

LEX nr 2294386 – wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r., sygn. akt III KO 20/17

- *Jednoosobowe, sprzeczne z treścią przepisu art. 29 § 1 k.p.k., rozpoznanie przez Sąd Okręgowy w K. apelacji obrońcy G. Ś., w sytuacji gdy postępowanie przed Sądem Rejonowym w K. toczyło się w trybie zwyczajnym, należy traktować jako nienależytą obsadę sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 19 sierpnia 2009 r. sygn. akt V KK 144/09, z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV KK 32/12, LEX nr 1163352, z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt IV KK 250/12, LEX nr 1220929, z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. akt V KK 289/13, z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt IV KK 28/15). Stwierdzenie tego rodzaju uchybienia, stanowiącego bezwzględną przyczyną odwoławczą (nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.), obliguje Sąd Najwyższy do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym – **wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2016 r., sygn. akt IV KK 124/16***
- *Nieobecność członka składu orzekającego sądu na całej rozprawie, w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 in fine k.p.k., nie obejmuje czynności podejmowanych przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy (...) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt V KK 30/16***
- *Każdy z członków składu orzekającego musi być obecny we wszystkich fazach rozprawy głównej, od wywołania sprawy do ogłoszenia wyroku i jego ustnego uzasadnienia (wraz z pouczeniem o przysługującym stronom prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia). W przypadku, gdyby którykolwiek z członków składu orzekającego nie był obecny na całej rozprawie, sąd odwoławczy – stosownie do treści art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. – uchyła zaskarżone orzeczenie (niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia). Nie ulega przy tym wątpliwości, że ww. przepis odnosi się do „członków składu orzekającego”, którzy wydali „zaskarżone orzeczenie” – **wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 6 lutego 2014 r., sygn. akt VIII Ka 790/13***
- *(...) gdyby w jakiejś incydentalnej kwestii zapadło nawet postanowienie przez sąd nienależycie obsadzony, np. o odroczeniu rozprawy,*

o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o ukaraniu świadka grzywną, ale pozostałe czynności procesowe, które doprowadziły do wydania orzeczenia kończącego postępowanie, zostały wykonane przez sąd „należycie obsadzony”, to absurdem byłoby przyjęcie, że to kończące orzeczenie miałoby podlegać uchyleniu na podstawie art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., tylko dlatego, że przy podejmowaniu decyzji w jakiejś incydentalnej kwestii sąd był „nienależycie obsadzony” – wyrok Sądu Najwyższego z 1 sierpnia 2007 r., sygn. akt IV KK 150/07

Ad. 6.3.3. Sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego – art. 439 § 1 pkt 3 k.p.k.;

Sądem szczególnym w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 3 k.p.k. są: sądy administracyjne (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) oraz sądy wojskowe, wymienione w art. 652 k.p.k. (wojskowy sąd garnizonowy i wojskowy sąd okręgowy oraz orzekający w zakresie sądownictwa wojskowego – Sąd Najwyższy). Z kolei w art. 653–655 k.p.k. wskazana została przez ustawodawcę właściwość rzeczowa każdego z ww. sądów. W przypadku zatem, gdyby w sprawie przestępstwa, popełnionego np. przez majora Wojska Polskiego w służbie czynnej, w pierwszej instancji orzekał Sąd Rejonowy w W. (a nie Wojskowy Sąd Okręgowy), wówczas doszłoby do zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 3 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- *Rozpoznanie sprawy przez niewłaściwy wydział właściwego sądu nie stanowi uchybienia określonego w treści art. 439 § 1 pkt 3 lub 4 k.p.k., a w przypadku sporów kwestię tę – jako leżącą w sferze wewnętrznej organizacji danego sądu – rozstrzyga prezes sądu na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (...). Nie stanowi też uchybienia prawu przekazanie sprawy do innego wydziału tego samego sądu, przez skład orzekający w formie postanowienia, zwłaszcza gdy czynność*

ta podejmowana jest na rozprawie. Jednakże wydane postanowienie przez sąd w takim przypadku nie jest postanowieniem objętym regulacją zawartą w art. 200 i 201 k.p.c. i nie jest zaskarżalne na podstawie art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c. Forma przekazania sprawy bowiem nie zmienia istoty tej czynności, mającej charakter organizacyjno-administracyjny i dotyczącej funkcjonowania sądu w ramach jego wewnętrznych struktur (podobnie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, z. 1, poz. 5) – wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt SNO 7/14

- (...) orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o przestępstwa popełnione w czasie pełnienia tej służby. Tym samym sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego jakim jest przecież sąd wojskowy, co stanowi bezwzględny powód odwoławczy o jakim mowa w art. 439 § 1 pkt 3 k.p.k. – wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r., sygn. akt IV KK 160/03

Ad. 6.3.4. Sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu – art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.;

Właściwość rzeczowa sądów karnych omówiona została w art. 24 i 25 k.p.k. Zgodnie z drugim z przytoczonych przepisów, co do zasady sądy okręgowe powołane są do rozpoznania w I instancji spraw:

- *wszystkich zbrodni, określonych w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych*
 - *przy czym zbrodnią, zgodnie z art. 7 § 2 k.k. jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą – np. zabójstwo z art. 148 § 1 k.k., albowiem dolna granica ustawowego zagrożenia to nie mniej niż 8 lat pozbawienia wolności albo rozbój kwalifikowany z art. 280 § 2 k.k., albowiem ustawodawca przewidział, że w przypadku uznania sprawcy za winnego sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż 3 lata.*
- *występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a*

§ 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego – przy czym:

- ww. rozdział XVI to wszystkie określone w art. 117 – 126c k.k. przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
- ww. rozdział XVII to wszystkie określone w art. 127–139 przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
- pozostałe ww. przestępstwa z Kodeksu karnego to zdaniem ustawodawcy na tyle poważne czyny przestępne, że mimo iż nie stanowią one zbrodni, to powinny być rozpoznawane od samego początku procesu przez sądy wyższej instancji aniżeli sądy rejonowe
- przypomnieć w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 7 § 3 k.k., występkiem jest czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (np. art. 155 k.k., albowiem ten kto powoduje nieumyślnie śmierć człowieka polega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 czy też udział w bójce lub pobiciu z art. 158 § 1 k.k., który to czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3).
- należy zwrócić uwagę na ww. przepis art. 294 k.k. – kradzież z art. 278 § 1 k.k. należy co do zasady do właściwości sądu rejonowego, jednakże gdy przedmiotem kradzieży jest mienie znacznej wartości, wówczas właściwym rzeczowo w I instancji jest sąd okręgowy. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do przestępstw: przywłaszczenia z art. 284 § 1 i 2 k.k., oszustwa z art. 286 § 1 k.k. oraz oszustwa komputerowego z art. 287 § 1 k.k.;
- występkę, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego
 - np. występki, wynikający z art. 43 w zw. z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, polegający na używaniu przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenie dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej.

Natomiast do rozpoznania w I instancji innych, niewymienionych powyżej spraw, właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy.

Jeśli zatem w sprawie rozboju kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.) w I instancji orzekłby sąd rejonowy, wyrok taki obarczony byłby bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. Podobnie byłoby, gdyby sąd rejonowy orzekł w sprawie udziału w bójce (albo pobiciu), której skutkiem jest śmierć człowieka (art. 158 § 3 k.k.). Podkreślenia jednocześnie wymaga, że **powyższa zasada odnosi się wyłącznie do sytuacji orzekania sądu niższego rzędu w sprawie, w której właściwym rzeczowo w I instancji jest sąd wyższego rzędu. Nie ma natomiast zastosowania w przypadku, w którym sąd wyższego rzędu orzekłby w sprawie, w której właściwym byłby sąd niższego rzędu.**

Komentarza wymaga również sytuacja ewentualnej zmiany kwalifikacji czynu po otwarciu przewodu sądowego, wynikała z przeprowadzonego postępowania dowodowego. Procesowo zdarza się, że na skutek oceny dowodów sąd zmienia w wyroku zarówno opis zarzuczonego czynu, jak i kwalifikację prawną tegoż czynu. Gdyby wynikiem takiego procesu myślowego była zmiana, która przesądza o właściwości innego sądu, tj. sądu wyższego rzędu, wówczas sąd powinien wydać postanowienie o stwierdzeniu swojej niewłaściwości i sprawę według tejże właściwości przekazać do rozpoznania sądowi właściwemu rzeczowo do rozpoznania sprawy w I instancji.

Tak mogłoby być np. w sytuacji, w której w akcie oskarżenia zarzucony jest rozbój z art. 280 § 1 k.k., zaś w wyniku przesłuchania świadków sąd uznaje, że oskarżony posługiwał się nożem, co uzasadniałby kwalifikację prawną z art. 280 § 2 k.k. (zamiast z art. 280 § 1 k.k.). Podobnie, gdyby w sprawie oskarżenia o przywłaszczenie kwoty 180.000 zł, np. na skutek opinii biegłego z zakresu rachunkowości, sąd ustalił, że ww. kwota to jednak 210.000 zł, co zgodnie z art. 115 § 5 k.k. stanowi mienie znacznej wartości. W obu ww. przypadkach nieprzekazanie spraw do sądu okręgowego i orzekanie przez sąd rejonowy prowadziłoby do sytuacji, w której sąd niższego rzędu orzekł w sprawach zastrzeżonych przez Kodeks postępowania karnego do właściwości sądu wyższego rzędu jako sądu I instancji. Mielibyśmy wówczas do czynienia z wystąpieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- *Naruszenie właściwości rzeczowej i funkcjonalnej stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. jedynie wówczas, gdy orzekał „sąd niższego rzędu” w sprawie należącej do „sądu wyższego rzędu” – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 26 maja 2020 r., sygn. akt II AKz 295/20***
- *Sąd okręgowy wykroczył poza zakres badania właściwości rzeczowej dopuszczalny na etapie wstępnej kontroli aktu oskarżenia. Sąd okręgowy ma prawo przekazać sprawę sądowi rejonowemu przed rozprawą główną tylko w razie stwierdzenia swej niewłaściwości w oparciu o niewątpliwe okoliczności czynu, lecz nie wtedy, gdy wymaga to oceny dowodów. Ostrożności przy tej decyzji należy oczekiwać zwłaszcza od sądu wyższego rzędu, bo jego pogląd zwiąże sąd niższego rzędu, któremu sprawa będzie przekazana. Gdyby ta decyzja była błędna, jej skutki mogą kreować bezwzględną przesłankę odwoławczą (art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.). Dlatego w przypadkach wątpliwych celowe jest poinformować strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu, a nie stwierdzać niewłaściwości jeszcze przed rozpoznaniem sprawy – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 września 2017 r., sygn. akt II AKz 385/17, LEX nr 2541062***
- *(...) w układzie procesowym, w którym doszło już do rozpoznania spraw w jednym postępowaniu, a tylko co do niektórych z nich sąd rejonowy okazał się niewłaściwy rzeczowo, to nie ma potrzeby ponownego rozpoznania wszystkich spraw przez sąd wyższego rzędu, skoro bezwzględną przyczyną odwoławczą dotknięty jest wyrok tylko w przedmiotowej części, a nie w całości – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 maja 2016 r., sygn. akt V KK 65/16***
- *Rozpoznanie sprawy przez niewłaściwy wydział właściwego sądu nie stanowi uchybienia określonego w treści art. 439 § 1 pkt 3 lub 4 k.p.k., a w przypadku sporów kwestię tę – jako leżącą w sferze wewnętrznej organizacji danego sądu – rozstrzyga prezes sądu na podstawie § 55 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (...). Nie stanowi też uchybienia prawu przekazanie sprawy do innego wydziału tego samego sądu,*

przez skład orzekający w formie postanowienia, zwłaszcza gdy czynność ta podejmowana jest na rozprawie. Jednakże wydane postanowienie przez sąd w takim przypadku nie jest postanowieniem objętym regulacją zawartą w art. 200 i 201 k.p.c. i nie jest zaskarżalne na podstawie art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c. Forma przekazania sprawy bowiem nie zmienia istoty tej czynności, mającej charakter organizacyjno-administracyjny i dotyczącej funkcjonowania sądu w ramach jego wewnętrznych struktur (podobnie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1994 r., III CZP 87/94, OSNC 1995, z. 1, poz. 5) – **wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt SNO 7/14**

- (...) sama kwalifikacja prawna czynu nie jest wiążąca dla sądu, a przy kontroli wstępnej aktu oskarżenia, należy zawsze rozważyć zasadność wskazywanej przez oskarżyciela publiczności rzeczowej sądu od strony opisu zarzucanego czynu i wskazanych w nim okoliczności, w tym wypadku także kwot wynikających z poszczególnych zachowań zarzucanych oskarżonej, aby nie okazało się następnie w toku rozpoznawania sprawy, że dany sąd jest rzeczowo niewłaściwy do jej rozpoznania – **postanowienie Sądu Najwyższego z 21 lutego 2013 r., sygn. akt II KK 11/13**
- W wypadku gdy sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu, uchylenie zaskarżonego orzeczenia jest, niezależnie od wpływu uchybienia na treść orzeczenia – w myśl art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k. – konieczne – **wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2011 r., sygn. akt II KK 165/11**
- Sąd okręgowy, rozpoznając apelację od wyroku sądu rejonowego wydanego z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej, wobec stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej powinien uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu w pierwszej instancji. Takie rozstrzygnięcie sądu odwoławczego co do właściwości rzeczowej wiąże sąd okręgowy rozpoznający sprawę w pierwszej instancji – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 grudnia 1970 r., sygn. akt IV KZ 127/70, LEX nr 1633241**

Ad. 6.3.5. Orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie – art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.;

Orzeczenie kary, środka karnego, środka kompensacyjnego lub środka zabezpieczającego nieznanego ustawie **odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której orzeczone środki bądź kara są zupełnie nieznane polskiemu prawu, a zatem rodzajowo w ogóle nie funkcjonującą w polskim prawie karnym**. Przykładem takiej kary byłoby np. orzeczenie kary śmierci albo kary chłosty. Jak wskazał natomiast Sąd Najwyższy, *nie stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k. zarówno orzeczenie kary nieprzewidzianej za dane przestępstwo, jak i nieprzewidzianej w danym rozmiarze. „Karą nieznaną ustawie” nie jest kara orzeczona powyżej górnej granicy danego rodzaju kary, a w konsekwencji nie stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej np. orzeczenie kary ograniczenia wolności w wymiarze 3 lat, kary pozbawienia wolności w wymiarze tygodnia lub lat 17, mimo ewidentnej obrazy odpowiednio art. 34 § 1 i art. 37¹⁶*. Tego rodzaju wadliwe ukształtowanie kary stanowiłoby natomiast rażącą obrazę ww. przepisów prawa karnego materialnego i wymagało sformułowania zarzutów z art. 438 pkt 1a k.p.k., nie zaś zarzutu bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- Idzie więc wyłącznie o kary w ogóle nieprzewidziane przez Kodeks karny (S. Śliwiński, *Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne*, Warszawa 1948, s. 464, podawał za przykład karę deportacji, wbicia na pal, rozerwania koźmi, napiętnowania; inni autorzy wskazywali także na karę chłosty, aresztu domowego, a od momentu wyeliminowania jej z polskiego systemu prawnego także na karę śmierci), nie zaś o wymiar kary lub środka karnego powyżej lub poniżej ustawowych granic. Poza wszelkim sporem, nie stanowi więc bezwzględnej przyczyny

¹⁶ Wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2008 r., sygn. akt II KK 92/07.

odwoławczej zarówno orzeczenie kary nieprzewidzianej za dane przestępstwo, jak i nieprzewidzianej w danym rozmiarze. Co więcej, w piśmiennictwie przeważa też pogląd, iż „karą nieznaną ustawie” nie jest kara orzeczona powyżej górnej granicy danego rodzaju kary, a w konsekwencji nie stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej np. orzeczenie kary ograniczenia wolności w wymiarze 3 lat, kary pozbawienia wolności w wymiarze tygodnia lub lat 17, mimo ewidentnej obrazy odpowiednio art. 34 § 1 i art. 37 – **wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2008 r., sygn. akt II KK 92/07, LEX nr**

- Bezwzględna przyczyna odwoławcza opisana w art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k. zaistnieje wówczas, gdy orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznanie ustawie, a więc w ogóle ustawą nieprzewidziane – **postanowienie Sądu Najwyższego z 20 września 2017 r., sygn. akt III KK 287/17**
- (...) wymieniona bezwzględna przyczyna odwoławcza nie występuje w sytuacji, gdy orzeczono karę rodzajowo dopuszczalną przez ustawę karną, a jedynie orzeczoną w wymiarze sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa (...). W polskim prawie karnym nie jest dopuszczalne określenie wymiaru orzekanej kary pozbawienia wolności w postaci niedookreślonej, tj. przedziału czasowego, czyli okresu od-do, w jakim kara ma się mieścić, a wymagane jest konkretne wskazanie jej wymiaru jednostkowego w latach i miesiącach, stosownie do przepisu art. 37 k.k. Ujęcie wymiaru kary pozbawienia wolności jako „od 3 lat do 3 lat i 8 miesięcy” uniemożliwia wykonanie tej kary, gdyż przy jej wprowadzaniu do wykonania nie byłoby możliwe dokładne określenie jej daty końcowej, czy momentu, od którego skazany mógłby ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, a wyznaczenie tych granic czasowych jest w toku postępowania wykonawczego niezbędne – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt II AKa 210/17**
- Zaaprobowanie rozstrzygnięcia o karze, która na etapie wyrokowania przez Sąd ad quem nie była przewidziana w obowiązującej ustawie, prowadzi do wniosku, że Sąd drugiej instancji dopuścił się uchybienia o randze bezwzględnej przesłanki odwoławczej, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt SDI 53/16**

- *Sformułowanie o środku karnym, zamiast o środku kompensacyjnym, należy więc uznać za omyłkę pisarską nie zaś za orzeczenie środka karnego nieznanego ustawie w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 30 września 2016 r., sygn. akt IV KK 294/16***
- *Orzeczenie tego środka do czynów popełnionych przed dniem 26 września 2005 r. nie znajdowało więc podstawy prawnej i w konsekwencji stanowiło orzeczenie o środku nieznanym ustawie karnej. Następstwa takiego stanu rzeczy nie ograniczają się jedynie do stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, jak to przyjęły oba sądy orzekające w przedmiocie wniosku obrońcy o wznowienie postępowania. Jak bowiem trafnie wywiódł Sąd Najwyższy w powołanym wyżej wyroku z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 399/12: „Orzeczenie kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego niemieszczącego się w katalogu kar lub środków zamieszczonym w ustawie będącej podstawą orzekania lub w ustawie, która przy uwzględnieniu art. 4 k.k. powinna być podstawą orzekania, oznacza orzeczenie kary lub środka nieznanego ustawie, co stanowi bezwzględną przyczyną odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.” – **wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt III KK 187/14***
- *W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się, że karą nieznaną ustawie jest kara nieprzewidziana w obowiązującej ustawie (por. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 listopada 1970 r., OSNKW 1971, Nr 2, poz. 17), czy dalej idąc, nieznaną polskiemu systemowi prawnemu, a więc rodzajowo niefunkcjonującą w polskim prawie karnym (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 1989 r., OSNKW 1990, nr 7–12, poz. 32). Będą nimi np. kara chłosty, kara śmierci itp. – **wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2013 r., sygn. akt SDI 47/13***

Ad. 6.3.6. Orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu – art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k.;

Omawiana przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. odnosi się do przypadków, w których wydane orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób

biorących udział w jego wydaniu. Z przytoczonego poniżej orzecznictwa wynika, że w przypadku kolegiального składu sądu – orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów, zaś przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne z uzasadnieniem (tzw. *votum separatum*), a nadto, że każde orzeczenie powinno zostać podpisane przez każdą z osób biorących udział w jego wydaniu. Warto odnotować, że powyższe uwagi dotyczą orzeczenia, a zatem sentencji tegoż orzeczenia, nie zaś jego uzasadnienia.

Na marginesie zaakcentowania wymaga, że w zakresie naruszenia zasady większości głosów – stanowiącej bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. – z uwagi na tajemnicę narady sędziowskiej, o jakiej mowa w art. 108 § 1 k.p.k., w praktyce występowałyby istotne trudności w wykazaniu jej faktycznego wystąpienia¹⁷.

Przydatne orzecznictwo:

- *Zaniechanie podpisania wyroku przez sędziego orzekającego w sprawie w składzie jednoosobowym stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. Uchybienie to w aktualnym stanie prawnym, nie może być w żaden sposób konwalidowane – skutkuje uchyleniem dotkniętego nim orzeczenia (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 28 lutego 2013 r., IV KK 36/13; z dnia 2 lutego 2012 r., IV KK 18/12, LEX nr 1119558; z dnia 4 listopada 2010 r., III KK 145/10, LEX nr 653504; z dnia 9 grudnia 2010 r., III KK 285/10, LEX nr 686811) – wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r., sygn. akt V KK 207/20*
- (...) wspomniany przepis mówi o sytuacji, gdy nie uzasadnienie, ale orzeczenie nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu. Kwestia ta nie nasuwa wątpliwości, wobec czego tylko na marginesie można odnotować, że Sąd Najwyższy od dawna wskazywał, iż niepodpisanie przez sędziego uzasadnienia orzeczenia nie może

¹⁷ Wobec treści art. 108 § 1 k.p.k., sytuacja naruszenia zasady większości głosów byłaby możliwa w zasadzie wyłącznie w sytuacji, gdyby doszło do zgłoszenia *votum separatum* co do istoty sprawy i jednoczesnego wydania orzeczenia, zgodnego z *votum separatum*. Wówczas bowiem jasnym byłoby, kto personalnie zgłosił zdanie odrębne i czy w tej sytuacji zachowana została zasada większości opowiadających się „za” treścią wydanego orzeczenia.

być traktowane jako bezwzględna przyczyna uchylecia orzeczenia (zob. np. wyrok 7 sędziów z dnia 13 lutego 1973 r., V KRN 576/72, OSNKW 1973, z. 11, poz. 136) – wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2018 r., sygn. akt IV KK 246/17

- *Niepodpisanie wyroku przez wszystkie osoby biorące udział w wydaniu tego orzeczenia jest uchybieniem, którego konwalidowania nie przewidują obowiązujące przepisy, nie niweluje go podpisanie uzasadnienia orzeczenia przez wszystkich sędziów uczestniczących w jego wydaniu. Treść art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. obliguje do uchylecia orzeczenia dotkniętego wyżej opisanym uchybieniem – wyrok Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt V KK 44/17*
- *W sytuacji, gdy orzeczenie nie zostanie podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu, stanowi to tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą (art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k.). Brak podpisu członka składu orzekającego pod sporządzonym orzeczeniem nie może zostać uzupełniony po jego ogłoszeniu (por. postanowienie SN z 19 stycznia 2012 r., I KZP 19/11, OSNKW 2012, Nr 1, poz. 3). Jednocześnie przyjęcie, że uchybienie to jest bezwzględną przyczyną odwoławczą, powoduje również, że nie może ono zostać konwalidowane, nawet jeśli rzeczywiście nie miało żadnego wpływu na merytoryczną treść orzeczenia (por. wyrok SN z 2 lutego 2012 r., IV KK 18/12, KZS 2012, z. 5, poz. 27) – wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2017 r., sygn. akt IV KO 97/16*
- *W prawie cywilnym nie ma legalnej definicji podpisu, choć kodeks cywilny tym pojęciem się posługuje (art. 78 § 1 k.c.), a w obowiązującym ustawodawstwie nie ma wyraźnego wskazania, jaka ma być treść podpisu i w jaki sposób ma być on wykonany. Jednak ze stanowiska judykatury i piśmiennictwa wynika, iż podpis może być skrócony, nie musi być czytelny, zatem pominięcie w nim pewnych liter nie musi świadczyć o podpisaniu się innym nazwiskiem, a jedynie o skorzystaniu z dopuszczalnej i stosowanej praktyki złożenia własnoręcznego podpisu w sposób skrócony, za pomocą techniki oddającej indywidualne cechy piszącego. Pomijanie pewnych liter, zwłaszcza samej końcówki nazwiska jest, w praktyce obrotu prawnego powszechne. Wymaga się jednak, by napisany znak ręczny – przy całej tolerancji, co do kształtu własnoręcznego podpisu – stwarzał dla*

osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz, że uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. W konsekwencji minimum wymagań koniecznych do uznania znaku pisańskiego za podpis jest to, by wyrażał, co najmniej nazwisko, umożliwiał identyfikację autora, przynajmniej według takich kryteriów, jak cechy indywidualne i powtarzalne (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1993 r., III CZP 146/93, OSNC 1994, Nr 5, poz. 94; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 78/09, nie publ.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2007 r., II CSK 124/07, OSNC 2008, Nr 9, poz. 102) – **wyrok Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt II CSK 518/15**

- Podpisanie orzeczenia to złożenie pod nim odręcznie znaku graficznego o cechach wyróżniających się pod względem złożoności i czytelności. Również tzw. parafta, z tego punktu widzenia jest uznawana za podpis, tylko złożony w formie skrótowej. Istotna jest własnoręczność tak złożonego znaku graficznego. Dlatego nie jest podpisem napisanie nazwiska pismem maszynowym. Najważniejsze przy ustaleniu, czy złożony własnoręcznie znak graficzny stanowi podpis jest tylko to, by podpisujący nadawał mu charakter podpisu (*animus signandi*). Wskazuje się, że jakkolwiek podpis nie musi być czytelny, to powinien odzwierciedlać cechy charakterystyczne dla osoby, która go składa, by w ten sposób ułatwić orientację w rozpoznaniu osoby – **wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 r., sygn. akt IV KK 327/13**
- Oryginały postanowień sądów obydwu instancji zostały podpisane przez sędziów, którzy te orzeczenia wydali. Natomiast odpisy tychże orzeczeń (podobnie jak kopie, czy kserokopie), nie muszą być podpisane przez sędziów. Wystarczy wówczas pieczęć odpowiedniego sądu potwierdzająca zgodność takiego dokumentu z oryginałem – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lutego 2014 r., sygn. akt V KO 8/14**

Ad. 6.3.7. Zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie – art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.;

Zgodnie z utrwalonym od lat stanowiskiem orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca

jego wykonanie, odnosi się do *sprzeczności wewnętrznej, która musi być istotna, zasadnicza, a jej konsekwencją jest nie utrudnienie (możliwe do usunięcia w trybie art. 13 § 1 k.k.w.), lecz uniemożliwienie jego wykonania*. Sprzeczność taka nie może być wywodzona z rozbieżności pomiędzy sentencją wyroku, a jego uzasadnieniem¹⁸. Jak z kolei wyjaśnione zostało w wyroku z 25 stycznia 2017 r., art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. dotyczy skrajnie sprzecznych rozstrzygnięć zawartych w wyroku, a więc takich które tyczą jednej osoby i tego samego czynu ale *powodują przeciwstawne konsekwencje prawne, tak że wykonanie jednego rozstrzygnięcia powoduje unicestwienie drugiego, prowadząc do sprzeczności logicznej*¹⁹.

Przykładem ww. sprzeczności byłoby uznanie oskarżonego jednocześnie za winnego i niewinnego popełnienia tego samego przestępstwa w ramach tego samego orzeczenia albo orzeczenie w jednym punkcie sentencji kary 100 stawek grzywny po 10 zł, przy jednoczesnym orzeczeniu 200 stawek grzywny po 10 zł w innym punkcie tego samego orzeczenia za ten sam czyn.

Podkreślenia wymaga, że **nie każda sprzeczność w samej treści orzeczenia automatycznie stanowić będzie bezwzględną przyczynę odwoławczą**. Jeśli sprzeczność wyłącznie utrudniałaby wykonanie orzeczenia, nawet znacznie, to ustawodawca przewidział w tym zakresie szczególny tryb, ułatwiający rozwiązanie takiej sytuacji na etapie postępowania wykonawczego. Stosownie do **art. 13 § 1 zd. 1 Kodeksu karnego wykonawczego**, organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.

W omawianym kontekście nie sposób również pominąć stanowiska, wyrażonego w uchwale Składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt I KZP 2/18), zgodnie z którym *w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.) może zostać usunięte uchybienie w wyroku, które polega na rozbieżnym – w zapisie cyfrowym i słownym – rozstrzygnięciu o karze (innym środku reakcji prawnokarnej)*. Omyłka pisarska może być uznana za oczywistą, jeżeli po dokonaniu przez sąd analizy treści

¹⁸ Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2021 r., sygn. akt III KK 192/20.

¹⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2017 r., sygn. akt V KK 396/16.

wyroku, przy uwzględnieniu kwalifikacji prawnej przypisanego przestępstwa, podstaw skazania i wymiaru kary, zostanie ustalone, że tylko jeden z rozbieżnych sposobów wyrażenia kary (innego środka reakcji prawnokarnej) odzwierciedla wymiar kary (innego środka reakcji prawnokarnej), który był możliwy do orzeczenia na podstawie wskazanych przepisów prawa. Jeżeli analiza treści wyroku takiej pewności nie daje, sprzeczność w opisie rozstrzygnięcia o karze może być usunięta tylko w trybie wniesienia właściwego środka zaskarżenia. W przypadku, gdy publikacja wyroku została zapisana w formacie audio lub audio i video (art. 147 § 2b k.p.k.), to odtworzenie zapisu pozwoli na bezsporne ustalenie, którą karę ogłoszono, a zatem, która kara została orzeczona²⁰.

Zaznaczyć również należy, że bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. odnosi się wyłącznie do sprzeczności w treści orzeczenia Sądu, tj. jego sentencji – nie zaś sprzeczności zachodzącej pomiędzy sentencją orzeczenia a jego uzasadnieniem, czy też jego ogłoszeniem. Tego rodzaju bowiem sytuacje powinny być natomiast rozpatrywane w kategorii zaistnienia względnych przyczyn odwoławczych z art. 438 pkt 2 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- *Sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie odnosi się do sprzeczności wewnętrznej, która musi być istotna, zasadnicza, a jej konsekwencją jest nie utrudnienie (możliwe do usunięcia w trybie art. 13 § 1 k.k.w.), lecz uniemożliwienie jego wykonania. Sprzeczność taka nie może być wywodzona z rozbieżności pomiędzy sentencją wyroku, a jego uzasadnieniem (zob. np. wyrok SN z 5 marca 1984 r., I KR 6/84, OSNKW 1984/11-12, poz. 128; postanowienie SN z 15 września 2010 r., II KK 42/10, OSNKW 2010/11, poz. 101) – postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2021 r., sygn. akt III KK 192/20*

²⁰ Zaakcentowania dodatkowo wymaga, że w uzasadnieniu przytoczonej poniżej (zob. „Przydatne orzecznictwo”) uchwały Składu 7 Sędziów z 28 czerwca 2018 r. sygn. akt. I KZP 2/18, Sąd Najwyższy wskazał m.in., że treść uzasadnienia nie jest pomocna przy rozstrzyganiu rozbieżności zawartych w sentencji orzeczenia w kontekście możliwości sprostowania orzeczenia („(...) o istnieniu lub braku warunków do sprostowania w treści wyroku rozbieżnego – opisanego cyfrą i słowem – rozstrzygnięcia o karze, decyduje tylko treść samego wyroku, a nie treść innych dokumentów procesowych, w tym uzasadnienia wyroku (...”).

- (...) *sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. to także taki stan, gdy co najmniej dwa jego poszczególne rozstrzygnięcia (niezależnie od tego czy prawidłowe i poprawnie sformułowane) pozostają do siebie w takiej relacji, że ich obu naraz nie da się wykonać. Jeżeli więc nawet wyrok zawiera rozstrzygnięcie, które z powodu jego nieprawidłowości albo niepoprawności w jego sformułowaniu nie nadaje się do wykonania, to taka wadliwość wyroku nie stanowi jeszcze bezwzględnej przesłanki odwoławczej, albowiem nie wynika ze sprzeczności zawartej w tym orzeczeniu. Art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. dotyczy zatem skrajnie sprzecznych rozstrzygnięć zawartych w wyroku, a więc takich które tyczą jednej osoby i tego samego czynu, ale powodują przeciwstawne konsekwencje prawne, tak że wykonanie jednego rozstrzygnięcia powoduje unicestwienie drugiego, prowadząc do sprzeczności logicznej* – **postanowienie Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2021 r., sygn. akt V KK 14/21**
- Skazując bowiem oskarżonego S. J. za czyn z art. 178a § 1 k.k., Sąd Rejonowy wymierzył mu „środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowych na okres 5 (trzech) lat”. Oczywiście jest, że wskazane rozstrzygnięcie, zawarte w pkt 2 wyroku nakazowego zawiera *sprzeczność uniemożliwiającą jego prawidłowe wykonanie. Powoduje bowiem niemożliwe do rozszyfrowania wątpliwości, czy w rzeczywistości zamiarem Sądu meriti było wymierzenie oskarżonemu środka karnego na okres trzech czy pięciu lat. Uchybienie to nie daje tym samym także podstaw do jego naprawy w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2006 r., sygn. akt V KK 482/05)* – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2020 r., sygn. akt III KK 296/20**
- *Sprzeczność uniemożliwiająca wykonanie orzeczenia to wada, której nie da się naprawić poprzez określenie w uzasadnieniu sposobu prawidłowego jego rozumienia* – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 października 2020 r., sygn. akt IV KK 426/19**
- *Bezwzględną przyczyną odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. nie jest każda sprzeczność w treści orzeczenia, lecz tylko taka, która in concreto prowadzi do niemożliwości wykonania go. Nie jest taką*

sprzecznością zamieszczenie w zaskarżonym postanowieniu dwóch odmiennych oznaczeń określających okres udzielonego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 15 lipca 2020 r., sygn. akt II AKz w 476/20, LEX nr 3169371**

- (...) nie może pozostawiać żadnych wątpliwości, że o istnieniu lub braku warunków do sprostowania w treści wyroku rozbieżnego – opisanego cyfrą i słowem – rozstrzygnięcia o karze, decyduje tylko treść samego wyroku, a nie treść innych dokumentów procesowych, w tym uzasadnienia wyroku. To w wyroku skazującym sporządzanym na piśmie (art. 412 k.p.k.) następuje rozstrzygnięcie o karze (art. 413 § 2 pkt 2 k.p.k.), a więc dokonuje się, niezwłocznie po naradzie i ukończeniu głosowania, zapisu na piśmie orzeczonej kary. Sporządzony na piśmie wyrok jest w istocie przygotowaniem jego projektu, albowiem dokument ten staje się wyrokiem od strony prawnej dopiero z chwilą jego ogłoszenia, po uprzednim podpisaniu przez wszystkich członków składu orzekającego (...). Uzasadnienie wyroku to przecież dokument odrębny od samego wyroku, sporządzany po ogłoszeniu wyroku i z reguły dopiero na wniossek, a więc nie zawsze. Z zasady więc nie może stanowić podstawy do wyjaśniania rozbieżności zawartych w wyroku w zakresie orzeczenia o karze. Ponadto, pisemne motywy rozstrzygnięcia wyjaśniać mają to rozstrzygnięcie, a nie je dopiero ustalać lub opisywać, w szczególności, który z dwóch różnych zapisów określa rzeczywisty wymiar kary. Nie można zatem przez treść uzasadnienia rozstrzygać rozbieżności w treści wyroku. Uzasadnienie wyroku ma przecież charakter jedynie sprawozdawczy. Powyższe wspiera argument, iż w razie zachodzącej sprzeczności między treścią wyroku a jego uzasadnieniem, wiążąca jest treść orzeczenia, które będzie podlegać wykonaniu, zwłaszcza, że to przecież wyrok został ogłoszony publicznie – **uchwała Składu 7 Sędziów z 28 czerwca 2018 r. sygn. akt. I KZP 2/18**
- Sąd Rejonowy, orzekając wobec skazanego karę grzywny, posługując się zapisem cyfrowym i słownym, odmiennie w każdym z nich określił wysokość kwotową jednej stawki dziennej. W zapisie cyfrowym wskazał, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 40 zł, zaś w zapisie słownym

wysokość tej stawki określił na kwotę dziesięć zł. W tej sytuacji istnieje rozbieżność co do rzeczywistej wysokości orzeczonej kary grzywny. Tego rodzaju sytuacja wprost wskazuje na naruszenie przez Sąd Rejonowy art. 413 § 2 pkt 2 k.p.k. w stopniu przesądzającym o wystąpieniu wskazanej powyżej bezwzględnej przyczyny odwoławczej, co w konsekwencji prowadzić musi do uchylenia zaskarżonego orzeczenia – **wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2017 r., sygn. akt III KK 511/17**

- Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że zaskarżony wyrok obciążony jest bezwzględną przyczyną odwoławczą w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. W treści tego orzeczenia zachodzi sprzeczność uniemożliwiająca jego wykonanie. Sąd Rejonowy, orzekając wobec skazanego karę ograniczenia wolności, posługując się zapisem cyfrowym i słownym, odmiennie w każdym z nich określił godzinowy wymiar nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. W zapisie cyfrowym przyjął, iż wymiar ten wynosi 20 godzin w stosunku miesięcznym, zaś w zapisie słownym wymiar ten określony został na 30 godzin. Tego rodzaju sytuacja wprost wskazuje na naruszenie przez Sąd Rejonowy art. 413 § 2 pkt 2 k.p.k. w stopniu przesądzającym o wystąpieniu wskazanej powyżej bezwzględnej przyczyny odwoławczej, co w konsekwencji prowadzić musi do uchylenia zaskarżonego orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów. Należy zauważyć, że Sąd Najwyższy podkreślał w dotychczasowym orzecznictwie, że rozbieżność w cyfrowym i słownym zapisie wymiaru kary nie tylko narusza wynikający z art. 413 § 2 pkt 2 k.p.k. obowiązek redagowania orzeczenia w sposób jednoznaczny i zrozumiały, ale przede wszystkim odzwierciedla wewnętrzną sprzeczność wyroku uniemożliwiającą jego wykonanie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. akt V KK 389/15, LEX nr 1959501) – **wyrok Sądu Najwyższego z 23 maja 2017 r., sygn. akt III KK 186/17**
- Art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. dotyczy skrajnie sprzecznych rozstrzygnięć zawartych w wyroku, a więc takich które dotyczą jednej osoby i tego samego czynu ale powodują przeciwstawne konsekwencje prawne, tak że wykonanie jednego rozstrzygnięcia powoduje unicestwienie drugiego, prowadząc do sprzeczności logicznej. Przykładami takich rozstrzygnięć są; skazanie

i uniewinnienie oskarżonego za ten sam czyn w ramach tego samego wyroku, czy skazanie za ten sam czyn na różne kary – wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2017 r., sygn. akt V KK 396/16

- (...) omyłka „pisarska” oznacza więc błąd związany z napisaniem orzeczenia lub zarządzenia, pomyłkę związaną z samym sporządzeniem orzeczenia lub zarządzenia (a nie błąd mający swoje źródło w zdarzeniach z wcześniejszych etapów postępowania, w tym także etapu podejmowania sędziowskich decyzji, który poprzedza sporządzenie orzeczenia lub zarządzenia na piśmie). Za „pisarską” może zatem zostać uznana jedynie taka omyłka, która ma charakter niejako techniczny i związana jest li tylko z utrwalaniem w pisemnej formie wcześniej podjętych sędziowskich decyzji. W tym miejscu wywodu po raz wtóry zasygnalizować należy, że konieczność stwierdzenia „pisarskiego” charakteru omyłki nie pozwala na dokonywanie w trybie określonym w art. 105 § 2–4 k.p.k. korektury tych błędów co do personaliów oskarżonego, które powstały już na wcześniejszym etapie postępowania, a w fazie „pisania” orzeczenia jedynie zostały zmaterIALIZEDOWANE, choćby inne względy (funkcjonalne) przemawiały za ich potraktowaniem na równi z omyłkami mającymi charakter pisarski. W końcu wypada przypomnieć, że „oczywisty” oznacza „niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny”, a przymiot ten może być odnoszony jedynie do czegoś, „co jest oczywiste, nie budzi żadnych wątpliwości” (...) podanie w komparycji lub w sentencji wyroku personaliów innych niż te, które nosi w istocie osoba, która była oskarżona w danej sprawie, może być skorygowane w trybie określonym w art. 105 k.p.k. jedynie wówczas, gdy istota rozbieżności ma czysto pisarski (błąd co do oznaczenia tożsamości), a nie merytoryczny (błąd co do ustalenia tożsamości) charakter. To, czy korekta omyłki co do personaliów jest dopuszczalna w trybie określonym w art. 105 k.p.k., ocenić należy na tle niepowtarzalnych okoliczności konkretnej sprawy – **uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 Sędziów z 28 marca 2012 r., sygn. akt I KZP 24/11**
- W przywołanym w kasacji art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. za określone tam uchybienie uznaje się jedynie sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie. Musi to być zatem, gdy chodzi

o wyrok, sprzeczność między poszczególnymi jego rozstrzygnięciami, i to nie każda, lecz tylko taka, która powoduje, że niemożliwe staje się jego wykonanie. Przepis ten nie obejmuje zatem ani sytuacji, gdy sprzeczność w treści wyroku utrudnia jedynie jego wykonanie, ale go nie uniemożliwia, ani sprzeczności zachodzącej między samym wyrokiem, a więc jego treścią (dyspozytywną częścią) a jego uzasadnieniem, jako że uzasadnienie to nie stanowi integralnego elementu treści wyroku. W tej pierwszej sytuacji, stosownie do art. 13 § 1 k.k.w., możliwe jest wystąpienie do sądu, który wydał orzeczenie, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do jego wykonania, a w drugiej mamy do czynienia z rażącą obrazą prawa materialnego lub procesowego, która miała istotny wpływ na treść wyroku w rozumieniu art. 523 § 1 w zw. z art. 438 pkt 1 lub 2 k.p.k., ale nie z uchybieniem, o jakim mowa w art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 15 września 2010 r., sygn. akt II KK 42/10**

- (...) nie stanowi jednak uchybienia, o którym mowa w art. 104 § 1 pkt 5 k.p.s.w. (sprzeczność w treści orzeczenia uniemożliwiająca jego wykonanie), ograniczenie się przez sąd w wyroku do orzeczenia jedynie odnośnie do samego rodzaju kary lub środka karnego, bez wskazania rozmiaru (wysokości, okresu) zastosowanego środka reakcji karnej, gdyż niemożność wykonania takiego rozstrzygnięcia nie wynika z wymaganej przez wskazany przepis sprzeczności w treści orzeczenia, lecz z braku wszystkich niezbędnych elementów rozstrzygnięcia w kwestii kary lub środka karnego; jest więc ona wynikiem innego niż w tym przepisie rażącego naruszenia prawa, które to uchybienie należy oceniać od strony art. 438 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w. Trzeba też zauważyć, że również na gruncie, podobnego jak w art. 104 § 1 pkt 5 k.p.s.w., rozwiązania przyjętego w art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k., w doktrynie procesu karnego wskazuje się, iż nie stanowi bezwzględnego powodu uchylenia orzeczenia samo orzeczenie kary w sposób uniemożliwiający jej wykonanie, jeżeli nie wynika ono z wewnętrznej sprzeczności orzeczenia, upatrując wtedy powodu do uchylenia orzeczenia zwłaszcza w obrazie prawa materialnego – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 lutego 2010 r., sygn. akt V KK 301/09**

Ad. 6.3.8. Orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone – art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.;

Z bezwzględną przyczyną odwoławczą w postaci *res iudicata* (powaga rzeczy osądzonej) będziemy mieli do czynienia wówczas, kiedy sąd wydał orzeczenie, mimo że zapadło już w innym postępowaniu prawomocne orzeczenie dotyczące tego samego przedmiotu sprawy tej samej osoby. Jak wskazał Sąd Najwyższy w jednym ze swoich judykatów, omawiana w tym miejscu bezwzględna przyczyna odwoławcza *ma miejsce wówczas, gdy **uprzednio prawomocnie zostało zakończone postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby**, nowe postępowanie pokrywa się zaś z przedmiotem postępowania w sprawie już zakończonej, a także gdy jego przedmiot jest częścią przedmiotu osądzonego w sprawie już zakończonej*²¹.

Nie będzie zatem naruszeniem powagi rzeczy osądzonej przypadek, gdy sąd np. uzna Jana Kowalskiego za winnego przestępstwa kradzieży 20 komputerów, za które to przestępstwo inny sąd uznał winę Jana Nowaka. Podobnie, nie będzie naruszeniem powagi rzeczy osądzonej przypadek, gdy sąd uzna Jana Nowaka za winnego kradzieży 20 komputerów, a inny sąd skaze tego samego Jana Kowalskiego za kradzież 20 drukarek, a także nie będzie naruszeniem powagi rzeczy osądzonej przypadek, gdy sąd uzna Jana Nowaka za winnego kradzieży 20 komputerów w 2018 roku, zaś inny sąd – za kradzież również 20 komputerów, ale w roku 2020.

Sąd Najwyższy w utrwalonym od lat orzecznictwie podkreśla bowiem, że *przepis art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. odnosi się do tego samego czynu i to tej samej osoby, albowiem warunkiem przyjęcia stanu prawomocności materialnej jest tożsamość czynu, a nie tylko wzajemne podobieństwo, identyczna kwalifikacja prawna, czy pomieszczenie zachowań w tożsamym przedziale czasowym*²².

Przesłankę „*innego prawomocnie ukończonego postępowania*” należy rozumieć w ten sposób, że w obrocie prawnym istnieje inne prawomocne rozstrzygnięcie o winie i odpowiedzialności karnej tej samej osoby za ten sam czyn przestępny.

²¹ Wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2011 r., sygn. akt IV KK 197/11.

²² Postanowienie Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt V KS 5/18.

Należy również pamiętać, że **art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. dotyczy wyłącznie *res iudicata* (powagi rzeczy prawomocnie osądzonej), nie zaś *lis pendens* (zawiśłości sporu)**. Ten drugi przypadek polega na naruszeniu zakazu równoległego prowadzenia postępowań karnych, dotyczących tego samego przedmiotu procesu, w stosunku do tej samej osoby. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji procesowej, zasadne byłoby złożenie w toku postępowania wniosku o umorzenie postępowania później wszczętego w oparciu o art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

Zaznaczenia wymaga również kwestia, która pojawiła się na adwokackim egzaminie zawodowym w 2018 roku. Pamiętać należy, że ***prawomocne skazanie za czyn ciągły (art. 12 k.k.) stoi na przeszkodzie, ze względu na treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., ponownemu postępowaniu o później ujawnione zachowania, będące elementami tego czynu, które nie były przedmiotem wcześniejszego osądzenia, niezależnie od tego, jak ma się społeczna szkodliwość nowo ujawnionych fragmentów czynu ciągłego do społecznej szkodliwości zachowań uprzednio w ramach tego czynu osądzonych***. Innymi słowy, gdyby oskarżony skazany został w warunkach art. 12 § 1 k.k.²³, a następnie ten sam oskarżony miałby być sądzony niejako za wycinek powyższego skazania, np. a przestępstwo oszustwa, które miałoby zostać popełnione w ww. okresie od 1.01.2018 r. do 1.10.2021 r. (np. w dniu 15.05.2019 r.) – to niezależnie od tego, że w dacie pierwotnego skazania ten nowy czyn mógł nie być w ogóle znany organom ścigania i niezależnie od jego społecznej szkodliwości (np. mogłoby to być największe oszustwo popełnione przez tego oskarżonego/skazanego pod względem rozmiaru szkody) – to o ile czyn ten był elementem czynu już osądzonego (tj. spełniał przesłanki art. 12 § 1 k.k.) i jednocześnie nie został wraz z tym czynem wcześniej osądzony, sąd musiałby takie nowe postępowanie umorzyć, ze względu na powagę rzeczy osądzonej²⁴.

²³ A zatem sąd przypisał sprawstwo jakiegoś czynu z Kodeksu karnego, uwzględniając w kwalifikacji prawnej art. 12 k.k., np. „uznaje oskarżonego za winnego popełnienia, w okresie od 1.01.2018 r. do 1.10.2021 r., przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. zw. z art. 12 k.k.”.

²⁴ „(...) Sąd Najwyższy wyraża pogląd, iż prawomocne skazanie za czyn ciągły (art. 12 k.k.) stoi na przeszkodzie, ze względu na treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., ponownemu postępowaniu o później ujawnione zachowania, będące elementami tego czynu, które nie były przedmiotem wcześniejszego osądzenia, niezależnie od tego, jak ma się społeczna szkodliwość nowo ujawnionych fragmentów czynu ciągłego do społecznej szkodliwości zachowań uprzednio w ramach tego czynu osądzonych” – zob. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 21 listopada 2001 r., sygn. akt I KZP 29/01.

Przydatne orzecznictwo:

- Wprawdzie w orzecznictwie podkreśla się, że „w przypadku przestępstw niealimentacji, które należą do kategorii tzw. przestępstw zbiorowych, sformułowana w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. przeszkoda procesowa w postaci *rei iudicatae* może zachodzić wyłącznie wówczas, gdy okresy uporczywego uchylania się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych, ustalone w kolejno rozpoznawanych sprawach, są identyczne i pokrywają się ze sobą lub gdy okres określony w sprawie następnej został w całości objęty skazaniem w sprawie rozpoznawanej poprzednio, prawomocnie już zakończonej” (...), jednak – jak pokazują realia rozpoznawanej sprawy – niepokrywanie się lub nieobejmowanie badanych okresów nie w każdym przypadku będzie stanowiło przeszkodę do stwierdzenia tożsamości podmiotowo-przedmiotowej w porównywanych sprawach. Powinno ono bowiem dotyczyć takich wycinków czasowych, które mogłyby być potraktowane jako odrębny czyn zabroniony w świetle dyspozycji art. 209 § 1 k.k., w której pojęcie czynu, wyznaczającego przedmiot procesu, musi być rozumiane w sposób swoisty, uwzględniający wieloczynowy charakter tego występkę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2004 r., V KK 272/04, OSNwSK 2004/1/2111, LEX nr 163223; zob. też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r., V KKN 504/00, OSNKW 2001/7-8/57, LEX nr 47616) – **wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2021 r., sygn. akt V KK 601/21**
- (...) w wypadku gdy wobec tej samej osoby zapadły dwa prawomocne wyroki łączne, obejmujące te same skazania, które objęte były tym węzłem w wyroku, który uprawomocnił się wcześniej, drugi z tych wyroków dotknięty jest w tym zakresie rażącym naruszeniem prawa, zaliczanym do tzw. bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia, przewidzianym w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. określanym jako naruszenie powagi rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.). Taka sytuacja stanowi ujemną przesłankę procesową, przewidzianą w przepisie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., w zakresie wydania kolejnego orzeczenia w tym przedmiocie w przypadku, gdy w orzeczeniu wydawanym później miało dojść do rozstrzygnięcia tego, czy dokładnie te same skazania za czyny jednostkowe spełniają warunki do objęcia ich węzłem kary łącznej w wyroku łącznym (por. wyrok SN

z 30 listopada 2011 r., II KK 149/11, OSNKW 2011/12, poz. 113). Powaga rzeczy osądzonej zachodzi również wówczas, gdy w wyroku łącznym wymierzono karę łączną obejmującą kary jednostkowe orzeczone wobec skazanego, wobec którego zapadł uprzednio prawomocny wyrok łączny, który pochłonął kary jednostkowe z tych samych wyroków podlegających połączeniu (por. wyrok SN z dnia 21 maja 2008 r., V KK 147/08, OSNwSK 2008, poz. 1135) – **wyrok Sądu Najwyższego z 30 listopada 2021 r., sygn. akt III KK 373/21**

- Uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. odnoszące się do powagi rzeczy osądzonej (*res iudicata*) dotyczy bowiem tylko takiej sytuacji, gdy mimo ujemnej przesłanki procesowej, sąd wydał orzeczenie, chociaż zapadło już prawomocne orzeczenie dotyczące tej samej sprawy w innym postępowaniu – **wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt III KA 1/20**
- (...) zachowanie oskarżonego należało potraktować jako fragment czynu ciągłego, a prawomocne skazanie za czyn ciągły rodzi powagę rzeczy osądzonej, co wykluczało przypisanie kolejnych, takich samych jednostkowych zachowań z okresu przyjętego w prawomocnym wyroku – **wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2018 r., sygn. akt V KK 268/18**
- (...) bezwzględna przyczyna odwoławcza, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. zachodzi w sytuacji, gdy w innym lub kontynuowanym postępowaniu prawomocnym orzeczeniem rozstrzygnięta została kwestia odpowiedzialności karnej (zob. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2009 r., III KK 159/09, zob. też uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2002 r., I KZP 27/02, OSNKW 2002, z. 11–12, poz. 96). W tej sytuacji koniecznym stało się uchylenie wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy temu organowi celem pozostawienia przyjętej po terminie apelacji bez rozpoznania (art. 430 § 1 k.p.k.). Brak było bowiem podstaw prawnych jedynie do umorzenia postępowania odwoławczego przez Sąd Najwyższy, tak jak nie ma ich Sąd odwoławczy. Przepis art. 17 § 1 k.p.k. nakazuje, w razie zrealizowania się ujętych w nim przesłanek, umorzyć „postępowanie karne”, a więc całe postępowanie, a nie jego określone stadium – **wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2018 r., sygn. akt IV KK 368/17**

- (...) warunkiem przyjęcia stanu prawomocności materialnej jest tożsamość czynu, a nie tylko wzajemne podobieństwo, identyczna kwalifikacja prawna, czy pomieszczenie zachowań w tożsamym przedziale czasowym – **postanowienie Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt V KS 5/18**
- W tożsamej pod względem prawnym sprawie Sąd Najwyższy stwierdził – „Jeżeli wobec skazanego zapadły dwa prawomocne wyroki łączne, w których węzłem kary łącznej objęto tylko te same skazania, to drugi z tych wyroków dotknięty jest bezwzględną przyczyną odwoławczą przewidzianą w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k., określaną jako powaga rzeczy osądzonej. Tego stanu prawnego nie zmienia dyspozycja art. 575 § 1 k.p.k., przewidującego, że jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego wydania poprzedni wyrok łączny traci moc” (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25 maja 2016 r., IV KO 29/16, Lex nr 2044496; z dnia 3 grudnia 2014 r., II KK 246/14, Lex nr 1583222; z dnia 30 listopada 2011 r., II KK 149/11, Lex nr 1099359) – **wyrok Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt IV KK 481/17**
- Wydanie wyroku skazującego, pomimo że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone, jest uchybieniem stanowiącym bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia, wymienioną w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. Zgodnie bowiem z treścią art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza wówczas, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone, albo wcześniej wszczęte toczy się. Zakaz ten służy wyeliminowaniu tego rodzaju nieprawidłowej sytuacji, gdy równolegle i niezależnie od siebie toczą się dwa postępowania o ten sam przedmiot – **wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2017 r., sygn. akt II KK 255/17**
- W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że w przypadku przestępstw niealimentacji, które należą do kategorii tzw. przestępstw zbiorowych, sformułowana w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. przeszkoda procesowa w postaci rei iudicatae może zachodzić wyłącznie wówczas, gdy okresy (...) uchyłania się od obowiązku świadczeń alimentacyjnych, ustalone

w kolejno rozpoznawanych sprawach, są identyczne i pokrywają się ze sobą, lub gdy okres określony w sprawie następnej został w całości objęty skazaniem w sprawie rozpoznawanej poprzednio, prawomocnie już zakończonej (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25 października 2016 r., IV KK 338/16, KZS 2016, Nr 12, poz. 17; z dnia 26 września 2007 r., III KK 260/07, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 2052; z dnia 17 listopada 2004 r., V KK 272/04, Lex Nr 163223) – **wyrok Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 2017 r., sygn. akt II KK 222/17**

- (...) negatywna przesłanka *lis pendens* stanowiąca względny powód odwoławczy, formułuje zakaz równoległego prowadzenia postępowań karnych dotyczących tego samego przedmiotu procesu, w stosunku do tej samej osoby, podyktowany względami ekonomiki procesowej. Jednak zakaz ten ustaje z chwilą, gdy w jednym z tych postępowań zapadnie prawomocny wyrok kończący postępowanie w sprawie. Wówczas zaczyna funkcjonować negatywna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy osądzonej (*res iudicata*), która rodzi zakaz *ne bis in idem*, czyli zakaz zarówno ponownego wszczynania, jak i kontynuowania postępowania o ten sam czyn tej samej osoby, co do którego zapadło prawomocne orzeczenie. Przesłankę *res iudicata*, zaliczaną do tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych (art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.) tworzą zawsze prawomocne orzeczenia merytoryczne, a także formalne, o ile oparte są na ujemnej przesłance bezwzględnej. Ma to na celu zapewnienie stabilności prawa i orzeczeń organów procesowych w postępowaniu karnym, a także służy realizacji wspomnianej zasady *ne bis in idem*, stanowiącej gwarancję, że nikt nie będzie pociągany więcej niż raz do odpowiedzialności karnej za ten samy czyn zabroniony pod groźbą kary (zob. także postanowienie SN z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt III KK 169/14, Lex nr 1565774; wyrok SN z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt V KK 407/13, Lex nr 1439399) – **wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2016 r., sygn. akt III KK 491/15**
- (...) zakaz wynikający z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. (*rei iudicatae*) ma miejsce wówczas, gdy uprzednio prawomocnie zostało zakończone postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby, nowe postępowanie pokrywa się zaś z przedmiotem postępowania w sprawie już zakończonej, a także

gdy jego przedmiot jest częścią przedmiotu osądzonego w sprawie już zakończonej (zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2008 r., IV KK 118/08 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1974 r., PiP 1976, nr 1–2, poz. 269). Istota zakazu podwójnej karalności sprowadza się do dyrektywy, w myśl której „ten sam czyn” („jeden czyn”, „to samo przestępstwo”) może być tylko raz ukarane. Funkcja zasady *res iudicata* oznacza stabilność wydanych rozstrzygnięć – chodzi o niedopuszczalność ich zmian, choćby pojawiły się nowe okoliczności mogące świadczyć, że orzeczenie mogłoby być inne – **wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2011 r., sygn. akt IV KK 197/11**

- Skoro zaistnienie owej negatywnej przesłanki procesowej implikowało bezwzględną niemożność prowadzenia dalszego postępowania karnego – w tym zakresie – (co jednoznacznie wynika z brzmienia art. 17 § 1 k.p.k. – „nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza”) to nawet równoczesne (formalne) wystąpienie w sprawie innej bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. konieczności tego rodzaju następstw procesowych żadną miarą nie podważa. W sytuacji zbiegu tego rodzaju bezwzględnych przyczyn odwoławczych, pierwszeństwo zastosowania będzie miała ta określona w pkt 8 art. 439 § 1 k.p.k., jako powodująca dla procesu nieodwracalne, a przez to zdecydowanie dalej idące, skutki. Stanowi je wszak – co raz jeszcze należy zaakcentować – niemożność dalszego prowadzenia postępowania karnego, a tym samym nakaz jego umorzenia – **postanowienie Sądu Najwyższego z 31 maja 2011 r., sygn. akt V KK 412/10**
- (...) od dnia 1 maja 2004 r. orzeczenie kończące postępowanie karne w innym państwie Unii Europejskiej (bo tylko te związane są postanowieniami Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen) stoi na przeszkodzie ściganiu karnemu w Polsce za ten sam czyn (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2006 r., IV KO 22/05, OSNKW 2006, z. 7–8, poz. 75). Nie ma przy tym znaczenia, czy owo orzeczenie wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zapadło przed datą polskiej akcesji do Unii, czy też po tej dacie. Istotne jest jedynie to, czy sąd polski orzekał po dniu 1 maja 2004 r., albowiem od tego dnia na przeszkodzie ściganiu w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. stoi orzeczenie

wydane w innym państwie członkowskim – wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2011 r., sygn. akt III KK 365/10

- (...) przepis art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. odnosi się nie tylko do tego samego czynu, ale także do tej samej osoby, tymczasem już z treści zarzutu wynika, że ukarana zostać miała inna niż Ł. W. osoba. W przypadku kolizji drogowej istnieje przy tym możliwość uznania więcej niż jednej osoby za winną naruszenia przepisów o ruchu drogowym i spowodowania kolizji – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt IV KK 172/10**
- (...) można sformułować następujący pogląd prawny: w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego do uchybienia określonego w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. dochodzi, gdy oparte na pojednaniu orzeczenie o umorzeniu postępowania, o którym mowa w art. 492 § 1 k.p.k., odnosi się do prawomocnie już wcześniej rozstrzygniętej w innym lub tym samym postępowaniu kwestii odpowiedzialności karnej tej samej osoby co do tego samego czynu – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2009 r., sygn. akt III KK 159/09**
- Prawomocne orzeczenie w przedmiocie odpowiedzialności za zarzucane sprawcy przestępstwa pozostające w ciągu, spowoduje taki skutek, że w ewentualnym późniejszym postępowaniu nie będzie już prawnej możliwości uwzględnienia tych czynów w konstrukcji czynu ciągłego, nawet gdy orzekający w tym późniejszym postępowaniu sąd dojdzie do wniosku, że czyny te, wraz z innymi czynami zarzuconymi sprawcy w nowym postępowaniu, składałyby się na czyn ciągły w rozumieniu art. 12 k.k. Dziać się tak będzie nie dlatego, że sąd w nowym postępowaniu jest związany ocenami dokonanymi w chronologicznie pierwszym postępowaniu, bowiem związania takiego – jak to już zostało wyjaśnione – brak. W nowym postępowaniu sąd dokonać musi ocen w zgoła odmiennej sytuacji procesowej, w której wiąże go powaga rzeczy osądzonej w zakresie czynów, co do których uprzednio prawomocnie orzeczono i z tego powodu ewentualna budowa konstrukcji czynu ciągłego może następować jedynie w oparciu o te elementy zachowania sprawcy, które jeszcze osądzone nie zostały – **uchwała Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2007 r., sygn. akt I KZP 15/07**

- (...) rozpoznanie przez sąd rejonowy zażalenia pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do określonej osoby o określone czyny w sytuacji, gdy uprzednio sąd ten rozpoznał już wcześniej zażalenie podejrzanego na to orzeczenie i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, oznacza orzekanie w sprawie, w której postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone i stanowi tym samym naruszenie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 26 listopada 2002 r., sygn. akt III KZ 47/02**
- Prawomocne osądzenie fragmentu zachowania sprawy składającego się na czyn ciągły, stwarza mianowicie powagę rzeczy osądzonej co do dalszych jego zachowań, które w razie ich wcześniejszego ujawnienia, weszłyby w skład czynu ciągłego. (...) prawomocne skazanie za czyn ciągły (art. 12 k.k.) stoi na przeszkodzie, ze względu na treść art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., ponownemu postępowaniu o później ujawnione zachowania, będące elementami tego czynu, które nie były przedmiotem wcześniejszego osądzenia, niezależnie od tego, jak ma się społeczna szkodliwość nowo ujawnionych fragmentów czynu ciągłego do społecznej szkodliwości zachowań uprzednio w ramach tego czynu osądzonych – **uchwała Sądu Najwyższego z 21 listopada 2001 r., sygn. akt I KZP 29/01**

Ad. 6.3.9. Zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11 k.p.k. – art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.;

Zgodnie z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. orzeczenie podlega uchyleniu, jeżeli rozstrzygnięcie wydane zostało, pomimo zaistnienia negatywnych przesłanek procesowych, określonych w art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. (śmierć oskarżonego), art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. (przedawnienie karalności), art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k. (orzekanie wobec osoby niepodlegającej orzecznictwu sądów polskich), art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. (brak skargi uprawnionego oskarżyciela), art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. (brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie), art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (wystąpienie innej okoliczności wyłączającej ściganie). Powyższe przesłanki stanowią formalnoprawne przeszkody do wydania orzeczenia.

Z mojego egzaminacyjnego doświadczenia wynika, że w odniesieniu do powyżej wymienionych negatywnych przeszkód procesowych najczęściej problemów zdającym sprawia z jednej strony liczenie okresu przedawnienia karalności, przypisanego oskarżonemu czynu oraz stwierdzenie co jest inną okolicznością wyłączającą ściganie, o jakiej mowa w art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Z drugiej zaś egzaminowani często mylą przesłanki braku skargi uprawnionego oskarżyciela i braku wniosku o ściganie. Tym zagadnieniom zatem poświęcam najczęściej uwagi w niniejszym podrozdziale.



O ile ustalenie wystąpienia przesłanki śmierci oskarżonego w toku postępowania karnego czy niepodlegania orzecznictwu sądów polskich nie sprawiają większych problemów, to jednak dla porządku poniżej przytoczenia wymaga kilka orzeczeń, przedstawiających stanowisko orzecznictwa w tym zakresie.

Przydane orzecznictwo do art. 17 § 1 pkt 5 i 8 k.p.k.

- (...) *brak podlegania orzecznictwu polskich sądów karnych może wynikać z przymiotów samego sprawcy (związane jest to z całą sferą immunitetów), jak i z faktu, że sprawca dopuścił się czynu, co do którego orzekanie nie następuje przed sądami karnymi (por. P. Hofmański, E. Sadzik, J. Zgryzek: Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, t. I, 2007, s. 159). Natomiast T. G. zauważa, że ujemnej przesłanki procesowej z art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k. nie należy mylić z podległością sprawy sądom karnym. Jest to bowiem jedynie zagadnienie zakresu właściwości sądów w ramach ich jurysdykcji. Jeżeli zatem sprawa nie podlega orzecznictwu sądów karnych (taka sytuacja istniała np. w odniesieniu do wykroczeń w okresie przed nowelizacją, która weszła w życie 17 października 2001 r.), następuje stwierdzenie braku właściwości i przekazanie sprawy organowi właściwemu (...)* – **postanowienie Sądu Najwyższego z 3 września 2020 r., sygn. akt III KO 73/20**
- *Niepodleganie sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych (art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k.) to procesowa przeszkoda związana z kwestią jurysdykcji sądów i tzw. immunitetów materialnych. Podnosi się, że niepodleganie sprawcy orzecznictwu polskich sądów karnych może wynikać zarówno*

z przymiotów samego sprawcy, jak i faktu, że dopuścił się czynu co do którego orzekanie nie następuje przed sądami karnymi (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1995 r., WR 149/95) – postanowienie Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV KK 107/18

- *Nie ulega wątpliwości, że śmierć oskarżonego stanowi bezwzględną przesłankę procesową, skutkującą – z woli ustawodawcy wyrażonej w art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. – niedopuszczalnością postępowania karnego. Jej stwierdzenie wymusza bądź to niweczowanie procesu wobec sprawcy, który zmarł, bądź też umorzenie toczącego się postępowania wobec takiej osoby. Proces umarza się zatem w każdym jego stadium, w którym przesłanka ta zaistnieje, także po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem. Stąd też wydanie wyroku skazującego wobec oskarżonego mimo jego śmierci w toku procesu, stanowi zawsze bezwzględną podstawę do uchylenia tego orzeczenia, wskazaną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. Zaistnieje ona także mimo braku wiedzy sądu o samym fakcie śmierci oskarżonego. Śmierć oskarżonego – jak wspomniano – należy do negatywnych i ściśle procesowych przesłanek, a stanowiący o jej konsekwencjach przepis art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k., jest w swej treści i jednoznaczny i bezwzględny. Powinien być zatem stosowany niezależnie od powodów zaistnienia tego uchybienia – wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2013 r., sygn. akt III KK 147/13*



Przechodząc natomiast do krótkiego omówienia **przesłanki z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.** nie sposób nie przywołać podręcznikowych wręcz przykładów tego rodzaju przeszkód formalnych wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego jakimi będą, abolicja czy amnestia. Z analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych (przytoczonego poniżej) wynika natomiast, że taką okolicznością jest również m.in.:

- *nierokujący nadziei na poprawę stan zdrowia oskarżonego, który nie tylko czasowo uniemożliwia mu prowadzenie wobec niego postępowania, ile wręcz wyklucza możliwość prowadzenia postępowania w przyszłości²⁵;*

²⁵ Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 października 2021 r., sygn. akt II KK 430/21.

- *wniesienie kasacji na niekorzyść i ujawnienie się w toku postępowania kasacyjnego jednej ze wskazanych w art. 529 k.p.k. okoliczności*²⁶;
- *złożenia wniosku w trybie przepisów rozdziału 58 k.p.k., dotyczącego roszczeń o innym charakterze, niż wymienione w art. 552 k.p.k.*²⁷;
- *stwierdzenie współukaranego czynu następczego/uprzedniego*²⁸ – zob. także uchwałę Sądu Najwyższego z 16 czerwca 1964 r., sygn. akt VI KO 57/63, gdzie wyjaśnione zostało pojęcie współukaranych czynów uprzednich i następczych;
- *objęcie osoby przekazanej w wyniku europejskiego nakazu aresztowania ściganiem za przestępstwo, które nie stanowiło podstawy przekazania*²⁹;
- *brak zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej*³⁰.

Omawiając art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. nie sposób nie wspomnieć również o zagadnieniu **ułaskawienia przed prawomocnym wydaniem wyroku**. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 30 marca 2016 r. (sygn. akt X Ka 57/16) uznał ułaskawienie przez Prezydenta przed zapadnięciem prawomocnego wyroku za możliwe i uzasadniające umorzenie postępowania karnego wobec oskarżonego na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. W rozpoznawanej kasacji od ww. wyroku Sąd Najwyższy wykluczył jednakże taką możliwość, wskazując że *zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych (...). Wydanie prawomocnego wyroku skazującego stanowi więc warunek sine qua non zastosowania prawa łaski*³¹.

Przydane orzecznictwo do art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.

- (...) *„inną okolicznością wyłączającą ściganie może być nierokujący nadziei na poprawę stan zdrowia oskarżonego, który nie tylko czasowo*

²⁶ Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lutego 2020 r., sygn. akt III KK 62/19.

²⁷ Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKz 362/19.

²⁸ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 listopada 2014 r., sygn. akt II AKa 203/14.

²⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2013 r., sygn. akt IV KK 67/13.

³⁰ Wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 2009 r., sygn. akt V KK 141/09.

³¹ Uchwała Sądu Najwyższego w Składzie 7 Sędziów z 31 maja 2017 r., sygn. akt I KZP 4/17.

uniemożliwia mu prowadzenie wobec niego postępowania, ile wręcz wyklucza możliwość prowadzenia w przyszłości” (zob. T. Grzegorzcyk: *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, Warszawa 2014, tom I, s. 152–153; M. Kurowski (w.): *Kodeks postępowania karnego. Komentarz* pod red. D. Świeckiego, Warszawa 2015, tom I, s. 140) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 19 października 2021 r., sygn. akt II KK 430/21**

- (...) gdy w dacie wnoszenia kasacji na niekorzyść była on obiektywnie dopuszczalną, natomiast dopiero po jej wpływie do Sądu Najwyższego zmaterializowała się okoliczność uniemożliwiająca – stosownie do treści art. 529a *contrario k.p.k.* – jej rozpoznanie. Jedyłą możliwą wówczas do wydania decyzją procesową jest umorzenie postępowania kasacyjnego. Podstawę ku temu będzie stanowił przepis art. 17 § 1 pkt 11 *k.p.k.* stosowany w związku z art. 429 § 1 *in fine k.p.k.*, ponieważ kasacja taka dopiero z momentem powstaniem tego rodzaju okoliczności staje się niedopuszczalną z mocy ustawy z uwagi na treść art. 529 *k.p.k.* odczytywanego właśnie *a contrario* (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z 20 czerwca 2006 r., II KK 295/05; z dnia 16 marca 2011 r., IV KK 17/11; z dnia 10 stycznia 2012 r., SDI 31/11; z dnia 8 października 2013 r., III KK 44/13; z dnia 5 lutego 2019 r., III KK 582/17) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lutego 2020 r., sygn. akt III KK 62/19**
- (...) w przypadku złożenia wniosku w trybie przepisów rozdziału 58 *k.p.k.*, dotyczącego roszczeń o innym charakterze, niż wymienione w art. 552 *k.p.k.*, sąd właściwy w sprawach karnych powinien umorzyć postępowanie na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 *k.p.k.*, co definitywnie zamyka postępowanie prowadzone na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego. W dalszej kolejności powinien jednak podjąć działania zmierzające do nadania dalszego biegu wnioskowi, nie wykluczając ewentualnego wezwania wnioskodawcy do sprecyzowania jego żądań. Czynnością następczą, po umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 *k.p.k.* powinno być przekazanie wniosku właściwemu sądowi cywilnemu. Może to nastąpić na podstawie zarządzenia o przekazaniu sprawy innemu wydziałowi, jeśli właściwy rzeczowo jest ten sam sąd, do którego sprawa wpłynęła (odpowiednio stosowany § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych),

ewentualnie wyznaczenia tego wydziału przez prezesa sądu (§ 55 ust. 2 rozporządzenia), względnie na podstawie postanowienia w przedmiocie właściwości. Wtórny zagadnieniem jest natomiast to, czy sąd właściwy do rozpoznawania spraw karnych (w praktyce wydział karny) ma to uczynić samodzielnie, np. w tym samym postanowieniu, którym umarza postępowanie, czy też poprzestać na przekazaniu sprawy wydziałowi cywilnemu. Zagadnienie to w realiach sprawy nie ma praktycznego znaczenia, bowiem wartość dochodzonych przez wnioskodawcę roszczeń przekracza 75 tys. zł, więc sąd okręgowy pozostaje właściwy rzeczowo także w sprawie cywilnej. Nie można natomiast, hipotetycznie, wykluczyć sytuacji, w której już na etapie wydawania postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.c. dojdzie do jednoczesnego rozstrzygnięcia w przedmiocie właściwości, skoro obowiązek jej badania z urzędu wprost wynika z art. 35 k.p.k. – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKz 362/19**

- Skoro zatem okoliczność ta należy do kategorii objętej dyspozycją art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., to nie sposób uznać ją za „inną okoliczność wyłączającą ściganie” w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Ten charakter mają bowiem przeszkody prawne spoza katalogu zamieszczonego w art. 17 § 1 pkt 1–10 k.p.k., wynikające z ustawy albo umów międzynarodowych takie, jak abolicja, konsumpcja skargi publicznej, list żelazny, czy też ograniczenia wynikające z zakresu przekazania osoby przekazanej w wykonaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania – **postanowienie Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt V KK 7/19**
- Nie ma racji skarżący, że decyzja o umorzeniu postępowania powinna być wstrzymana w oczekiwaniu na ewentualne ustalenia faktyczne co do meritum sprawy. Byłoby to nawet niedopuszczalne. Obligatoryjność umorzenia postępowania z art. 17 § 1 k.k. wyraża powinność organu procesowego niezwłocznego wykonania dyspozycji, ujawni on istnienie opisanych w tym przepisie okoliczności, a nie później. Podobnie kieruje się na posiedzenie sprawę przed rozprawą główną, gdy ujawni się okoliczności uzasadniające umorzenie (art. 339 § 3 pkt 1 w zw. z art. 17 § 1 pkt 2–11 k.p.k.) – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 3 grudnia 2018 r., sygn. akt II AKz 591/18, LEX nr 2691998**

- *Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych). Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (...) trzeba stwierdzić, że zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Postępowanie, które zostało wszczęte wniesieniem aktu oskarżenia przez właściwy organ procesowy, niezależnie od stopnia jego zawansowania, toczy się z udziałem stron do jego prawomocnego zakończenia. Dopiero w sytuacji, gdy efektem prowadzonego postępowania będzie wydanie prawomocnego wyroku przesądzającego kwestie winy (skazującego), powstaje możliwość wydania aktu łaski dostosowanego do prawnokarnej zawartości tego wyroku. Wydanie prawomocnego wyroku skazującego stanowi więc warunek sine qua non zastosowania prawa łaski – **uchwała Sądu Najwyższego w Składzie 7 Sędziów z 31 maja 2017 r., sygn. akt I KZP 4/17.***
- (...) przez współukarane czyny uprzednie, lub następne rozumie się takie działania poprzedzające główny czyn przestępczy lub następujące po nim, które oceniane z osobna mogłyby być uznane za odrębne przestępstwa, jednakże przy całościowej ocenie zdarzenia należy je uznać za skwitowane przez wymierzenie kary za przestępstwo główne – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 maja 2017 r., sygn. akt II AKa 47/17**
- (...) przez „inne okoliczności wyłączające ściganie” w ujęciu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. rozumie się przeszkody natury prawnej, wynikające z norm Kodeksu postępowania karnego oraz przepisów innych ustaw lub umów międzynarodowych; wszelkie natomiast stany mające charakter przeszkód faktycznych uniemożliwiających prowadzenie postępowania stanowią podstawę do zawieszenia tego postępowania w oparciu o art. 22 § 1 k.p.k. Jeżeli więc oskarżony nie może brać udziału w procesie z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody (zob. postanowienie SN z dnia 2 października 2007 r., II KK 17/07; postanowienie SA w Łodzi z dnia

15 lipca 2009 z., II AKz 471/09, Prok. i Pr. – wkl. 2010/12/14; postanowienie SA w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2014 z. II AKz 151/14, Biul. SAKa 2014/2/17) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt II KK 313/15**

- Skorzystanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prawa łaski przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego skutkuje jego umorzeniem na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. – **wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 marca 2016 r., sygn. akt X Ka 57/16, za LEX: <https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/522362733/1/x-ka-57-16-ulaskawienie-przed-wydaniem-prawomocnego-wyroku-wyroku-sadu-okregowego-w-warszawie?keyword=X%20Ka%2057~2F16%20&cm=SREST>**
- Przepisy postępowania karnego nie zawierają wyraźnej regulacji sposobu postąpienia w razie stwierdzenia współukaranego czynu następczego. Skoro konstrukcja czynów współukaranych jest zbieżna z wystąpieniem ujemnej przesłanki procesowej jako „innej okoliczności wyłączającej ściganie”, wskazanej w art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., przemawia to za wydaniem w tej sytuacji orzeczenia umarzającego, zgodnie z art. 414 § 1 k.p.k. Konsekwencją tego jest orzeczenie nowych kar łącznych – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 listopada 2014 r., sygn. akt II AKa 203/14, LEX nr 1711349**
- Zgodnie z zasadą specjalności osoby przekazanej w wyniku wykonania ENA nie można ścigać za przestępstwo, które nie stanowiło podstawy przekazania – **wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2013 r., sygn. akt IV KK 67/13, LEX nr 1504584**
- Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, jako jedną z postaci pomijalnego zbiegu przestępstw, przyjmuje się tzw. współukarane przestępstwo uprzednie, za które można uznać taki czyn, który stanowi środek prowadzący do dalszego celu, stanowiącego także przestępstwo (por. wyrok SN z dnia 10 stycznia 2003 r. WA 69/02 – OSNKW 2003, z. 3–4, poz. 40 i cyt. tam literaturę). W realiach niniejszej sprawy oczywiste jest, że dokonany przez Mariusza G. fałsz materialny dokumentów rzeczoznawcy, stanowił środek do celu, jakim było wyłudzenie kredytu. Tego rodzaju sytuacja stanowi inną okoliczność wyłączającą ściganie

w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w sprawie zaistniało zatem uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2009 r., sygn. akt IV KK 98/09**

- Brak zgody państwa wydającego na pociągnięcie oskarżonego do odpowiedzialności karnej, stanowi przeszkodę w ściganiu i jest tym samym „inną okolicznością wyłączającą ściganie” w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., którą stosownie do treści art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. kwalifikować należy jako tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą. Pogląd taki, sformułowany w piśmiennictwie (por. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, t. III, s. 404; J. Gajewski, L. Paprzycki, M. Płachta: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003, s. 575; T. Grzegorczyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 115), zyskał akceptację również w judykaturze (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2006 r., V KK 193/06, LEX nr 196965 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., IV KK 179/08, LEX nr 438417) – **wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 2009 r., sygn. akt V KK 141/09**
- Abolicja bowiem jest tzw. ujemną przesłanką procesową, która wyłącza możliwość prowadzenia procesu karnego – **wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 1983 r., sygn. akt V KRN 197/83**
- Przez współukarane czyny uprzednie lub następne rozumie się zazwyczaj w teorii takie działania poprzedzające główny czyn przestępny lub po nim następujące, które, oceniane z osobna, mogłyby być uznane za odrębne przestępstwa, jednakże przy całościowej ocenie zdarzenia uznać je należy za skwitowane przez wymierzenie kary za przestępstwo główne. Przy współukaranym czynie uprzednim chodzi w większości wypadków o sytuację, w których pewne przygotowawcze działanie sprawcy godzi w to samo w istocie dobro prawne, w jakie godzi czyn główny. Mówiąc o współukaranym czynie następnym, mamy na myśli wypadki, w których sprawca czynu głównego ponownie atakuje dobro naruszone przez czyn główny w sposób wyczerpujący znamiona odrębnego przestępstwa. Opisywanych wyżej konstrukcji prawnych („czyny współukarane”) nie należy jednak rozszerzać na wypadki, w których odrębne przedmiotowe działania sprawcy, każde o znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa,

godzą w różne dobra prawne. Konstrukcje te prowadzą z konieczności do jednolitej oceny odrębnych czynów w myśl zasady przewidzianej w art. 36 k.k., który to przepis odnosi się przecież do wypadku, gdy jeden czyn podpada pod kilka przepisów ustawy. Przytoczone wyżej względy przemawiają przeciwko przyjęciu konstrukcji jedności przestępstwa (art. 36 k.k.), a za utrzymaniem ustalonej praktyki, według której zabór broni i jej następne nielegalne przechowywanie stanowią dwa odrębne przestępstwa w zbiegu realnym (art. 31–34) – **uchwała Sądu Najwyższego – połączone izby – Izba Karna oraz Wojskowa z 26 czerwca 1963 r., sygn. akt VI KO 57/63**



Przesłanka z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. sprawia zdającym problem wtedy, kiedy nie wiedzą w jaki sposób liczone jest przedawnienie w postępowaniu karnym. W niniejszym podrozdziale skupimy się zatem na tym zagadnieniu.

Terminy przedawnienia przestępstw reguluje art. 101 k.k. Znajomość tego przepisu w powiązaniu ze zrozumieniem różnicy pomiędzy występkami a zbrodniami, a także czynami ściganymi z oskarżenia publicznego a prywatnego, jest niezbędna do prawidłowego **obliczenia okresu ustania karalności zarzuconego/przypisanego oskarżonemu przestępstwa**. Przypomnienia wymagają zatem następujące kwestie:

- A) zgodnie z art. 7 § 2 k.k., **zbrodnią** jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Oznacza to, że jeśli ustawodawca w części szczególnej Kodeksu karnego wskazał, że dolna granica ustawowego zagrożenia wynosi 3 lata albo co najmniej trzy lata lub więcej – wówczas mamy do czynienia ze zbrodnią (np. zabójstwo z art. 148 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawiania wolności od 8 lat; rozbój kwalifikowany z art. 280 § 2 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż 3 lata itp.).
- B) zgodnie z art. 7 § 3 k.k., **występkiem** jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Mając zatem na uwadze ww. art. 7

§ 2 k.k., występками będą wszystkie czyny, których dolna granica ustawowego zagrożenia jest mniejsza niż 3 lata (np. rozbój w typie podstawowym z art. 280 § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat; nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat itp.).

- C) w Kodeksie karnym mamy tylko 4 czyny ścigane z oskarżenia prywatnego, co ustawodawca wprost zaznacza w treści przepisu penalizującego określone zachowanie – art. 212 k.k. (zniesławienie, gdzie wskazano ten tryb ścigania w § 4), art. 216 k.k. (znieważenie, gdzie wskazano ten tryb ścigania w § 5), art. 217 k.k. (naruszenie nietykalności cielesnej, gdzie wskazano ten tryb ścigania w § 3) oraz art. 157 § 2 k.k. (lekkie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, gdzie wskazano ten tryb ścigania w § 4). **Pozostałe przestępstwa, przewidziane przepisami części szczególnej Kodeksu karnego ścigane są z oskarżenia publicznego**, przy czym – co jest częstym źródłem konfuzji egzaminowanych – **tryb wnioskowy jest rodzajem trybu publicznoskargowego (!)**. Po złożeniu wymaganego przez ustawodawcę wniosku przez pokrzywdzonego, sprawa toczy się normalnie w trybie publicznoskargowym i tryb ten w żadnym razie nie jest trybem prywatnoskargowym!

Po przypomnieniu powyższych kwestii, na przykładach przećwiczmy liczenie okresu przedawnienia.

Przykład I: Czyn z art. 286 § 1 k.k. miał zostać popełniony 13 stycznia 1993 r. – wskaż datę przedawnienia karalności tego przestępstwa, przy założeniu, że:

- A) w dniu 1 czerwca 2007 roku wydano postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w ww. sprawie;
- B) dotychczas postępowanie nie zostało wszczęte;

W pierwszej kolejności należy ustalić, który z punktów art. 101 § 1 k.k. ma zastosowanie do czynu z art. 286 § 1 k.k. W tym celu należy sprawdzić

zagrożenie karne, przewidziane przez ustawodawcę za czyn z art. 286 § 1 k.k. Oszustwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, co oznacza, że jest to występki zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat (bo górna granica ustawowego zagrożenia za czyn z art. 286 § 1 k.k. wynosi 8 lat). Zastosowanie znajdzie zatem art. 101 § 1 pkt 2a k.k. – karalność przestępstwa oszustwa ustaje po 15 latach od daty jego popełnienia. Przy czym dodatkowo pamiętać należy:

- *o treści art. 101 § 3 k.k. – zatem gdyby czyn miał zostać popełniony np. pomiędzy 1 stycznia 1990 r. a 12 lutego 1990 r., wówczas owe 15 lat przedawnienia liczone jest od daty 12 lutego 1990 r.;*
- *o treści art. 102 k.k., zgodnie z którym jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101 k.k., wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 k.k. ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. W naszym przykładzie oznacza to, że jeśli w okresie owych 15 lat przedawnienia oszustwa zostałyby wszczęte postępowanie karne o ten czyn (niekoniecznie przeciwko osobie), wówczas okres przedawnienia ulega przedłużeniu o dodatkowe 10 lat.*

Odpowiedź I:

Ad. A) W naszym przykładzie czyn z art. 286 § 1 k.k. miał zostać popełniony 13 stycznia 1993 r., przy czym w dniu 1 czerwca 2007 r. wydano postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w ww. sprawie. Zgodnie z ww. analizą, przestępstwo oszustwa popełnione 13 stycznia 1993 r. przedawniłoby się po 15 latach, tj. w dniu 13 stycznia 2008 r. Skoro w dniu 1 czerwca 2007 r. wszczęte zostało postępowanie karne, to stosownie do art. 102 k.k., czyn ten przedawni się o północy z 13 stycznia 2018 r. na 14 stycznia 2018 r.

Ad. B) Gdyby do 13 stycznia 2008 r. nie zostało wszczęte postępowanie karne, wówczas przestępstwo uległoby przedawnieniu o północy z 13 stycznia 2008 r. na 14 stycznia 2008 r.

Przykład II: Czyn z art. 148 § 1 k.k. miał zostać popełniony 13 stycznia 1986 r. – wskaż datę przedawnienia karalności tego przestępstwa, przy założeniu, że:

- A) w dniu 1 czerwca 2005 r. wydano postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w ww. sprawie;
- B) dotychczas postępowanie nie zostało wszczęte;

Zabójstwo z art. 148 § 1 k.k. zagrożone jest karą pobawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Ww. zagrożenie karne powoduje, że zastosowanie znajdzie zatem art. 101 § 1 pkt 1 k.k. – karalność przestępstwa zabójstwa ustaje po 30 latach od daty jego popełnienia.

Odpowiedź II:

Ad. A) W naszym przykładzie czyn z art. 148 § 1 k.k. miał zostać popełniony 13 stycznia 1986 r., przy czym w dniu 1 czerwca 2005 r. wydano postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w ww. sprawie. Zgodnie z ww. analizą, przestępstwo zabójstwa popełnione 13 stycznia 1986 r. przedawniłoby się po 30 latach, tj. w dniu 13 stycznia 2016 r. Skoro w dniu 1 czerwca 2005 r. wszczęte zostało postępowanie karne, to stosownie do art. 102 k.k., czyn ten przedawni się o północy z 13 stycznia 2026 r. na 14 stycznia 2026 r.

Ad. B) Gdyby do 13 stycznia 2026 r. nie zostało wszczęte postępowanie karne, wówczas przestępstwo uległoby przedawnieniu o północy z 13 stycznia 2016 r. na 14 stycznia 2016 r.

Przykład III: Czyn z art. 280 § 2 k.k. miał zostać popełniony 13 czerwca 2002 r. – wskaż datę przedawnienia karalności tego przestępstwa, przy założeniu, że:

- A) w dniu 15 czerwca 2020 r. wydano postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w ww. sprawie;
- B) dotychczas postępowanie nie zostało wszczęte;

Rozbój kwalifikowany z art. 280 § 2 k.k. zagrożony jest karą pobawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Zgodnie z art. 7 § 2 k.k. czyn ten jest zatem zbrodnią, albowiem dolna granica ustawowego za ten czyn wynosi co najmniej 3 lata. Powyższe przesądza zatem o zastosowaniu do tego czynu

art. 101 § 1 pkt 2 k.k., zgodnie z którym karalność innej zbrodni aniżeli zabójstwo ustaje po upływie 20 lat od jej popełnienia.

Odpowiedź III:

Ad. A) W naszym przykładzie czyn z art. 280 § 2 k.k. miał zostać popełniony 13 czerwca 2002 r., przy czym w dniu 15 czerwca 2020 r. wydano postanowienie o wszczęciu postępowania karnego w ww. sprawie. Zgodnie z ww. analizą, przestępstwo rozboju kwalifikowanego popełnione 13 czerwca 2002 r. przedawniłoby się po 20 latach, tj. w dniu 13 czerwca 2022 r. Skoro w dniu 15 czerwca 2020 r. wszczęte zostało postępowanie karne, to stosownie do art. 102 k.k., czyn ten przedawni się o północy z 13 stycznia 2032 r. na 14 stycznia 2032 r.

Ad. B) Gdyby do 13 czerwca 2022 r. nie zostało wszczęte postępowanie karne, wówczas przestępstwo uległoby przedawnieniu o północy z 13 czerwca 2022 r. na 14 czerwca 2022 r.

Przykład IV: Czyn z art. 212 § 1 k.k. miał zostać popełniony 13 grudnia 2017 r. – wskaż datę przedawnienia karalności tego przestępstwa, przy założeniu, że:

- A) w dniu 15 czerwca 2020 r. oskarżyciel prywatny złożył prywatny akt oskarżenia do sądu, mimo że od początku wiedział kto jest sprawcą przestępstwa;
- B) w dniu 15 czerwca 2020 r. oskarżyciel prywatny złożył prywatny akt oskarżenia do sądu, albowiem dopiero po dwóch latach dowiedział się kto jest sprawcą przestępstwa na jego szkodę;

Przestępstwo zniesławienia zagrożone jest karą grzywny albo karą ograniczenia wolności i zgodnie z art. 212 § 4 k.k., ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Powyższe przesądza zatem o zastosowaniu do tego czynu art. 101 § 2 k.k., zgodnie z którym karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego

popęlnienia. W przypadku wszczęcia postępowania karnego o czyn ścigany z oskarżenia prywatnoskargowego zastosowanie znajdzie także art. 102 *in fine*, tj. nastąpi przedłużenie okresu przedawnienia o okres 5 lat, albowiem jest to inny występki aniżeli ten, do którego zastosowanie znajdzie art. 101 § 1 k.k.

Odpowiedź IV:

Ad. A) W naszym przykładzie czyn z art. 212 § 1 k.k. miał zostać popełniony 13 grudnia 2017 r., przy czym w dniu 15 czerwca 2020 r. oskarżyciel prywatny złożył akt oskarżenia w sądzie. Zgodnie z ww. analizą, w przypadku w którym oskarżyciel znał sprawcę, wówczas zgodnie z art. 101 § 2 k.k., okres przedawnienia karalności wynosi 1 rok. Oznacza to, że pokrzywdzony czynem prywatnoskargowym ma rok na zainicjowanie sprawy (najczęściej złożenie prywatnego aktu oskarżenia w sądzie). W opisywanym stanie faktycznym oskarżyciel prywatny wniósł akt oskarżenia dopiero w dniu 15 czerwca 2020 r., a zatem jeśli postępowanie karne nie zostało wszczęte przez oskarżyciela publicznego (np. w trybie art. 60 k.p.k.) to znaczy, że czyn ten przedawnił się o północy z 13 grudnia 2018 r. na 14 grudnia 2018 r.

Ad. B) Gdyby oskarżyciel prywatny nie wiedział, kto jest sprawcą przestępstwa prywatnoskargowego, popełnionego na jego szkodę (np. w internecie), wówczas – zgodnie z art. 101 § 2 – okres przedawnienia karalności tego czynu wynosi trzy lata. Złożenie zatem prywatnego aktu oskarżenia w sądzie w dniu 15 czerwca 2020 roku mieściłoby się w ww. okresie 3 lat od daty czynu (tj. 13 grudnia 2017 r.).

Omawiając negatywną przesłankę procesową z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. nie sposób nie wspomnieć o kwestii **zawieszenia biegu terminu przedawnienia karalności czynów oraz wykonania kary, wprowadzonego tzw. „ustawą covidową”**³². Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15 z.zr¹ ust. 1 ww. ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego

³² Art. 15z.zr¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095)

z powodu COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Ustawodawca określił jednocześnie w art. 15 zzz¹ ust. 2 ustawy, że okresy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia 14 marca 2020 r. – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, oraz od dnia 20 marca 2020 r. – w przypadku stanu epidemii. Zaakcentowania jednocześnie wymaga, że w okresie od 31.3.2020 r. do 15.5.2020 r. obowiązywał (uchylony 16 maja 2020 r.) art. 15 zzz ust. 6 ww. ustawy, który wprowadzał zawieszenie biegu terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19. Uchylony art. 15 zzz ust. 6 ustawy skutkował tym, że w praktyce w czasie jego obowiązywania należało do okresu przedawnienia ww. czynów doliczyć okres równy okresowi obowiązywania tego przepisu (tj. okres od 31 marca 2020 r. do 16 maja 2020 r., łącznie 45 dni), albowiem w tym czasie bieg terminów przedawnienia w ww. zakresie był zawieszony. Natomiast obecnie obowiązujący art. 15 zzz¹ ustawy covidowej poszerza granice zawieszenia biegu terminów przedawnienia, rodząc w praktyce wymiaru sprawiedliwości istotne spory, w tym te związane ze zgodnością z Konstytucją wprowadzonej regulacji. Ramy niniejszej publikacji nie pozwalają na szersze omówienie tej kwestii. Zainteresowanych tą problematyką odsyłam do orzeczeń Sądu Najwyższego wskazanych w przypisie³³.

Przydatne orzecznictwo do art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.:

- *W orzecznictwie sądowym zasadnie przyjmuje się bowiem stanowisko, że w przypadku zbiegu w postępowaniu odwoławczym negatywnych*

³³ W orzecznictwie zarysowały się odmienne stanowiska Sądu Najwyższego w kwestii tego, czy zawieszenie biegu terminów przedawnienia wprowadzone art. 15 zzz¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych odnosi się także do czynów popełnionych przed 31 marca 2020 r., czy też tylko do czynów popełnionych po tej dacie – zob. wyrok Sądu Najwyższego z 3 marca 2022 r., sygn. akt IV KK 726/21, wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2022 r., sygn. akt II KK 34/22 i przeciwny pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z 11 czerwca 2021 r., sygn. akt III KK 173/21.

*przesłanek: z pkt 1 § 1 art. 17 k.p.k. („czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia”) oraz przesłanki z pkt 6 § 1 tego art. 17 k.p.k. („nastąpiło przedawnienie karalności”) priorytet będzie miała ta przesłanka wskazana w pkt 1 § 1 tegoż przepisu – **postanowienie Sądu Najwyższego z 2 marca 2021 r., sygn. akt II KK 56/21***

- *Sąd Najwyższy wielokrotnie też podkreślał, że w przypadku zbiegu negatywnych przesłanek procesowych, określonych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. oraz art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., sąd powinien umorzyć postępowanie z uwagi na niedopuszczalność jego dalszego prowadzenia. Zasada ta nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy zbieg tych przesłanek zostanie stwierdzony dopiero po przeprowadzeniu dowodów i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych sprawy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 27/10, OSNKW 2011, z. 1, poz. 5). Wówczas umorzenie z powodu przedawnienia karalności jest dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy nie ma od razu podstaw do uniewinnienia oskarżonego z braku czynu lub braku znamion czynu albo braku winy. Wskazuje się, że umorzenie z racji przedawnienia wchodzi też zawsze w rachubę, gdyby kwestie istnienia czynu, jego znamion i odpowiedzialności wymagały dalszego dowodzenia, gdyż postępowaniu w tej materii stoi na przeszkodzie przedawnienie karalności (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2002 r., IV KKN 264/99; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2002 r., V KKN 484/00) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt IV KK 334/19***
- *Przedawnienie karalności powoduje, że nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie postępowania karnego; w takiej sytuacji postępowania karnego nie wszczyna się, a postępowanie wszczęte powinno zostać umorzone bez względu na stadium postępowania (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 29 lipca 2020 r., sygn. akt V KK 143/20***
- *Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia okresów przedawnienia karalności decydujące znaczenie ma czyn przypisany w wyroku, a nie czyn zarzucany w akcie oskarżenia (por. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 4 lipca 2001 r., V KKN 346/99, Jurysta 2002, nr 2–3, s. 48, z dnia 9 listopada 2011 r., IV KK 338/11, LEX nr 1044060) – **wyrok Sądu Najwyższego z 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt IV KK 456/18***

- (...) wniosek prokuratora złożony na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. został skierowany do Sądu już po nastąpieniu przedawnienia karalności czynów zarzuconych oskarżonemu. Oczywiście jest zatem, że dotknięty taką wadą wniosek nie powinien zostać uwzględniony, zaś postępowanie karne przeciwko oskarżonemu, wobec zaistnienia negatywnej przeszkody procesowej określonej w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., powinno zostać umorzone. Dlatego przyznać należy racje skarżącemu, że wydany w sprawie wyrok skazujący dotknięty jest bezwzględną przyczyną odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV KK 151/18**
- Od strony proceduralnej przedawnienie karalności powoduje, że nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie postępowania karnego; w takiej sytuacji postępowania karnego nie wszczyna się, a postępowanie wszczęte powinno zostać umorzone bez względu na stadium postępowania (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). Warto zaznaczyć, że terminy przedawnienia zalicza się do terminów stanowczych o charakterze materialnoprawnym. (...) wszczęcie postępowania (również in rem) w okresie, o którym mowa w art. 101 k.k., powoduje, że karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 k.k. ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Zarazem jednak, stosownie do dyspozycji art. 2 wskazanej noweli, zmiany tej nie stosuje się, gdy termin przedawnienia już upłynął (zob. wyr. SN z 14 października 2016 r., III KK 366/16). Innymi słowy: jeżeli do 2 marca 2016 r. upłynął już termin przedawnienia karalności z art. 101 k.k. i gdy w tym czasie nie wszczęto postępowania przeciwko osobie (według poprzedniego brzmienia art. 102 k.k. wydłużenie terminów przedawnienia karalności miało miejsce, gdy nastąpiło wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobie – in personam), obowiązkiem organu procesowego było stwierdzić wystąpienie negatywnej przesłanki procesowej przewidzianej w art. 17 § 1 pkt 6 i postąpić, jak przepis ten w swej początkowej części wymaga – **wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2018 r., sygn. akt II KK 77/18**
- (...) z punktu widzenia biegu okresów przedawnienia karalności decyduje to, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił, a więc

opis czynu przypisanego, a nie to, o jakie przestępstwo został oskarżony. Ma to w niniejszej sprawie o tyle znaczenie, że skazanemu zarzucono co prawda popełnienie czynu, którego miał dokonać w okresie do 25 listopada 2003 r., ale ostatecznie Sąd Okręgowy przypisał mu działanie „w okresie co najmniej do 9 kwietnia 2001 r.” – **wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 2016 r., sygn. akt IV KK 300/16**

- (...) skoro w odniesieniu do skazanego przyjęto konstrukcję jednego czynu z art. 12 k.k., to czyn ten może mieć tylko jeden termin przedawnienia. Poszczególne zachowania opisane w czynie ciągłym, co do którego zastosowano kumulatywną kwalifikację, nawet jeśli pozwalają na ich „naturalne” wyodrębnienie oraz gdy wypełniają w całości znamiona poszczególnych czynów zabronionych, nie mogą być analizowane w kontekście terminów przedawnienia w oderwaniu od treści art. 11 § 3 k.k. oraz art. 101 k.k. (czytaj: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., V KK 235/09, OSNKW 2010, z. 6, s. 50). W myśl art. 11 § 3 k.k., karę za przestępstwo kumulatywnie kwalifikowane wymierza się na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. To jeśli czyn stanowiący substrat postępowania, wypełnia w istocie znamiona określone w trzech przepisach ustawy przy czym dwa z nich z art. 233 § 6 k.k. i art. 272 k.k., typizują przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, termin przedawnienia ich karalności wynosi 5 lat (art. 101 § 1 pkt 4 k.k.), zaś trzeci czyn – z art. 270 § 1 k.k. opisuje typ przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5 (art. 101 § 1 pkt 3 k.k.), a termin przedawnienia wynosi 10 lat, to jasnym staje się, że wbrew wywodom skarżącego, termin przedawnienia w odniesieniu do P. M. jeszcze nie upłynął. W tym wypadku fałszerstwo materialne przedawnia się z upływem 10 lat, zaś zgodnie z art. 102 k.k. ulega ono dalszemu przedłużeniu o kolejne 10 lat, co oznacza, iż w odniesieniu do skazanemu termin przedawnienia upłynie najpóźniej 10 grudnia 2024 r. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r., sygn. akt II KK 131/15**
- W wypadku zaistnienia ujemnej przesłanki procesowej w postaci przedawnienia karalności (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.), po uchyleniu wyroku ponowne rozpoznanie sprawy nie jest dopuszczalne. Dlatego też Sąd Najwyższy na

podstawie art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. uchylił zaskarżony wyrok, zaś w oparciu o art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. umorzył postępowanie – wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2012 r., sygn. akt IV KK 224/12

- *Stanowiące negatywną przesłankę procesową przedawnienie karalności podlega badaniu przez sąd odwoławczy niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, jako że jej nieuwzględnienie powoduje wystąpienie uchybienia należącego do bezwzględnych przyczyn odwoławczych – art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. – wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt III KK 38/12*
- *(...) nie ulega bowiem wątpliwości, że z punktu widzenia biegu okresu przedawnienia decydujące znaczenie ma to, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił – a więc czyn przypisany, nie zaś to jaki czyn mu zarzucono (...) – wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt III KK 356/11*



Brak skargi uprawnionego oskarżyciela, o jakim mowa w art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., to nic innego jak brak aktu oskarżenia. Najczęstsze przypadki wystąpienia przesłanki z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w praktyce dotyczą subsydiarnego aktu oskarżenia i prywatnego aktu oskarżenia. W odniesieniu do „**niesubsydiarnego**” trybu **publicznoskargowego** sytuacja jest bowiem o tyle prostsza, że akt oskarżenia z reguły wnoszony jest przez profesjonalny podmiot, który ustawowo powołany jest do ścigania i z tego tytułu powszechnie wnosi akty oskarżenia do sądu. Z brakiem skargi oskarżyciela publicznego będziemy mieć zatem do czynienia wyjątkowo – albo wówczas, kiedy akt ten wnoszony jest przez nie-prokuratorowski podmiot (np. Urząd Celny, organ kontroli skarbowej itp.), albo kiedy sąd uzna oskarżonego za winnego czynu innego aniżeli zarzucony w akcie oskarżenia (zob. także rozdział 10, poświęcony metodyce czytania akt egzaminacyjnych oraz podrozdział 9.15, poświęcony zagadnieniu wyjścia poza granice aktu oskarżenia).

W odniesieniu natomiast do **subsydiarnego aktu oskarżenia**, zarówno doktryna prawa karnego, jak i orzecznictwo wskazuje, że z brakiem skargi uprawnionego oskarżyciela w tym trybie mamy do czynienia, jeśli:

1. Nie dochowano terminu miesięcznego do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, przy czym istotne znaczenie ma to, że **termin ten liczony jest od daty doręczenia postanowienia prokuratora nadzrędnego pokrzywdzonemu, a nie jego pełnomocnikowi (!)**. Termin powyższy ma charakter prekluzyjny, a w konsekwencji – uchybienie w tym zakresie nie podlega konwalidacji w toku toczącego się postępowania sądowego. W przypadku dostrzeżenia przekroczenia terminu miesięcznego do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia w sądzie, postępowanie sądowe powinno zostać umorzone w oparciu o art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. W przypadku zaś wydania wyroku, mimo ww. uchybienia, wyrok obarczony byłby bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.;
2. Nie zachodzą warunki, o jakich mowa w art. 55 § 1 k.p.k., tj. **brak jest dwóch tożsamyh decyzji procesowych oskarżyciela publicznego** – dwóch decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania bądź dwóch decyzji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego. W przypadku gdyby oskarżyciel wniósł do sądu subsydiarny akt oskarżenia, a w sprawie najpierw wydano postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, a następnie (po uchyleniu tej decyzji przez sąd i wszczęciu postępowania) oskarżyciel wydałby postanowienie o umorzeniu dochodzenia, pokrzywdzony powinien złożyć zażalenie do sądu na postanowienie w przedmiocie umorzenia tegoż postępowania. Gdyby zaś złożył zażalenie do prokuratora nadzrędnego i ten podtrzymał decyzję oskarżyciela publicznego, postępowanie jurysdykcyjne wywołane wniesionym do sądu subsydiarnym aktem oskarżenia obarczone byłby nieusuwalnym brakiem wyczerpania drogi, wymaganej art. 55 § 1 k.p.k. Postępowanie sądowe powinno zostać umorzone w oparciu o art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. W przypadku zaś wydania wyroku, mimo ww. braku, wyrok obarczony byłby bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

W kontekście obecnie wymaganej przesłanki tożsamości decyzji oskarżyciela publicznego o zaniechaniu ścigania, konieczne jest wskazanie, że **ustawą z 7 lipca 2022 r. (o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która ogłoszona została w Dzienniku**

Ustaw 13 grudnia 2022 r., Dz. U. 2022, poz. 2600), ustawodawca **nowelizował art. 55 § 1 k.p.k. oraz 300 § 2 k.p.k.** Przepisy te, w nowym brzmieniu, wchodzą w życie z upływem 3 miesięcy od jego ogłoszenia (art. 33 ww. ustawy nowelizującej). Art. 55 § 1 k.p.k. po zmianie brzmień będzie: *Pokrzywdzony, o którym mowa w art. 330 § 2 zdanie trzecie, w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, może wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 3a i art. 396a nie stosuje się.* Natomiast z treści obecnego brzmienia art. 330 § 2 k.p.k. ustawodawca usunął słowo „ponownie”, **zmieniając tym samym warunki otwarcia pokrzywdzonemu drogi do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.**

Powyższa zmiana oznacza bowiem, że po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia ww. noweli w Dzienniku Ustaw (od 14 marca 2023 roku), **pokrzywdzony nie będzie musiał wykazywać tożsamości decyzji odmawiających wszczęcia postępowania albo umarzających postępowanie przygotowawcze, skoro ustawodawca usunął z ww. przepisów sformułowania „ponownie”/”w razie powtórnego wydania” w odniesieniu do decyzji oskarżyciela publicznego o zaniechaniu ścigania.** Po wejściu w życie omawianej nowelizacji aktualność straci zatem przytoczona poniżej teza orzecznicza z postanowienia Sądu Najwyższego z 2 września 2020 r. (sygn. akt V KK 355/19).

3. Zachowania musi być **tożsamość czynu, do którego odnoszą się poszczególne decyzje procesowe oskarżyciela publicznego, wymagane art. 55 § 1 k.p.k.** Gdyby okazało się, że pierwsze postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego odnosi się do innego czynu, aniżeli drugie postanowienie w przedmiocie umorzenia albo zarzut aktu oskarżenia nie odnosi się do tego czynu, który był przedmiotem dwóch decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania, wówczas nie ma mowy o tożsamości czynu, wymaganej art. 55 § 1 k.p.k. W przypadku dostrzeżenia ww. rozbieżności, postępowanie sądowe powinno zostać umorzone w oparciu o art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.

W przypadku zaś wydania wyroku, mimo braku ww. tożsamości czynów, wyrok obarczony byłby bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.;

4. **Uprawnienie do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia ma jedynie pokrzywdzony w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k.** Oznacza to, że jeśli czyn zarzucony subsydiarnym aktem oskarżenia nie dotyczy bezpośrednio sfery dóbr prawnych pokrzywdzonego (tj. czyn zarzucony nie narusza bezpośrednio lub nie zagraża dobrom prawnym pokrzywdzonego), to wówczas pokrzywdzony nie może wnieść aktu oskarżenia do sądu. Nie jest bowiem pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. Podobnie jest w przypadku wszystkich **przestępstw formalnych**, tj. takich, do których ustawowych znamion nie należy skutek (np. nielegalne przekroczenie granicy, nielegalne posiadanie broni etc.) albo przestępstw, które polegają na naruszeniu abstrakcyjnie rozumianych dóbr (np. fałszerstwo materialne) – **w przypadku tego rodzaju przestępstw z założenia brak jest w ogóle pokrzywdzonego (!), co a priori czyni niemożliwym wniesienie w tego rodzaju sprawach subsydiarnego aktu oskarżenia.** Gdyby zatem nasz klient oskarżony został subsydiarnym aktem oskarżenia o czyn z art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości albo o czyn z art. 270 § 1 k.k. postępowanie sądowe powinno zostać umorzone w oparciu o art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. W przypadku zaś wydania wyroku w odniesieniu do ww. kategorii czynów zabronionych, rozstrzygnięcie sądowe obarczone byłby bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.;

W odniesieniu natomiast do **czynów ściganych z oskarżenia prywatnego**, wobec znacznego odformalizowania tego typu skargi, przypadki braku skargi uprawnionego oskarżyciela nie są tak rozbudowane, jak w przypadku subsydiarnego aktu oskarżenia. Z orzecznictwa wynika bowiem, że z przypadkiem braku skargi uprawnionego oskarżyciela prywatnego mamy do czynienia, np.

1. gdy jeden z rodziców złoży prywatny takt oskarżenia przeciwko drugiemu rodzicowi, działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego³⁴.

³⁴ Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 1 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV 1 Ka 154/18.

2. w przypadku skazania oskarżonego za czyn ścigany z oskarżenia publicznego po przeprowadzeniu postępowania wszczętego wniesieniem prywatnego aktu oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego³⁵. Z takim przypadkiem mielibyśmy czynienia, gdyby np. w toku sprawy sądowej o czyn z art. 157 § 2 k.k. (czyn ścigany w trybie prywatnoskargowym), sąd po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej uznałby, że skoro rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwał dłużej niż 7 dni, to czyn ten wypełnia znamiona z art. 157 § 1 k.k. (czyn ścigany z oskarżenia publicznego) i skazał oskarżonego za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. W wyżej opisanym stanie faktycznym, sąd powinien umorzyć postępowanie karne w oparciu o art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. i sprawę przekazać oskarżycielowi publicznemu do ewentualnego prowadzenia w sprawie przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. Gdyby zaś wydał wyrok skazujący, jak w naszym przykładzie, wówczas rozstrzygnięcie to obarczone byłoby bezwzględną przyczyną odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

Poniżej przytoczone zostały orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w Polsce, z których wynikają stwierdzone w praktyce wymiaru sprawiedliwości przypadki wystąpienia braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Przydatne orzecznictwo do art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.

- *Decyzja prokuratora o przedłużeniu czasu trwania dochodzenia, jako poprzedzona obowiązkiem prokuratora zapoznania się z wykonanymi czynnościami i zebranymi dowodami, ma charakter nadzorczy, co oznacza, że w konsekwencji wymusza również zatwierdzenie przez prokuratora aktu oskarżenia sporządzonego przez finansowy organ postępowania przygotowawczego a następnie, wniesienie go do właściwego sądu. W układzie, gdy ten akt oskarżenia został wniesiony przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, to w sprawie tej zachodziła negatywna przesłanka procesowa w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.), co winno*

³⁵ Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r., sygn. akt IV KK 453/16.

było skutkować umorzeniem postępowania w tym zakresie przez sąd pierwszej instancji. Pomimo tego oskarżony został skazany za to przestępstwo (składające się z dwóch czynów opisanych w pkt 12 i 13), a wady tej nie dostrzegł – choć powinien – również sąd drugiej instancji, co stanowiło o obrazie art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. i w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. – **wyrok Sądu Najwyższego z 18 listopada 2021 r., sygn. akt V KK 350/21**

- (...) ujemna przesłanka określona w art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. wiąże się ściśle z zasadą skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.) i stanowi ujemną przesłankę procesową jedynie dla postępowania sądowego w pierwszej instancji (zob. T. Grzegorzcyk: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014, t. I, s. 147; M. Kurowski (w:) D. Świecki (red.): Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2017, t. I, s. 143). Przesądza o tym brzmienie art. 14 § 1 k.p.k., zgodnie z którym wszczęcie postępowania sądowego (...) następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu – **wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2021 r., sygn. akt II KK 545/21**
- Brak skargi uprawnionego oskarżyciela w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. (...) wchodzi w grę tylko w toku sądowego stadium procesu i tylko w odniesieniu do takiej osoby, która swoją skargą zainicjowała postępowanie główne, pomimo, że nie była osobą do tego uprawnioną lub orzeczono o czynie niezawartym w akcie oskarżenia. Dotyczy zatem dwóch rodzajów sytuacji: pierwszej – gdy osoba nie miała żadnej legitymacji do wystąpienia z oskarżeniem, drugiej – gdy czyn przypisany nie jest tożsamy z czynem zarzuconym (co oznacza, że orzeczono w przedmiocie przestępstwa, którego osądzenia w ogóle nie żądał oskarżyciel) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 14 października 2020 r., sygn. akt III KK 239/20, LEX nr 3182914**
- (...) nie został spełniony warunek „powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania” (art. 55 § 1 k.p.k.), który – zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą Sądu Najwyższego należy rozumieć, jako ponowne wydanie postanowienia tego samego rodzaju, jak poprzednie uchylone, czyli odpowiednio powtórne postanowienie o odmowie wszczęcia lub powtórne postanowienie o umorzeniu

*postępowania – postanowienie z 2 września 2020 r., sygn. akt V KK 355/19*³⁶

- *Skoro akt oskarżenia (i inne jego surogaty) uruchamia postępowanie sądowe, to od samego początku powinien zostać wniesiony przez podmiot uprawniony. Jeżeli tak się nie stało, to uruchomione postępowanie sądowe podlega umorzeniu, jako że od początku brak jest skutecznego impulsu procesowego, aby można było kontynuować procedowanie, a braku tego nie można usunąć. Jest to zatem odmienna sytuacja procesowa niż brak wniosku o ściganie, który to brak można konwalidować w każdym stadium procesu – postanowienie Sądu Najwyższego z 4 lutego 2020 r., sygn. akt III KK 365/19*
- *(...) pokrzywdzony może wnieść, w trybie art. 55 § 1 k.p.k., subsydiarny akt oskarżenia tylko co do tego czynu, w związku z którym prokurator ponownie odmówił wszczęcia lub umorzył postępowanie, a zatem skarga subsydiarna może obejmować zarzut popełnienia czynu, który zachowuje przymiot tożsamości z tym, którego oceny dotyczyły decyzje kończące postępowanie przygotowawcze. Z kolei jednak zakres prowadzenia tego postępowania zdeterminowany jest treścią złożonego zawiadomienia o przestępstwie. Tak więc, badając podstawy zezwalające na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia, zgodnie z art. 330 § 2 k.p.k., sąd w pierwszej kolejności powinien ustalić, w oparciu o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ścigania jakich czynów domagał się pokrzywdzony, a następnie na podstawie treści postanowienia o odmowie wszczęcia (umorzenia) postępowania przygotowawczego stwierdzić, czy postępowanie to zostało zakończone w zakresie całego zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzonego. Nie jest natomiast wystarczające poprzestanie na porównaniu kwalifikacji prawnych czynów objętych postanowieniem prokuratorskim i subsydiarnym aktem oskarżenia, czy jedynie zestawienie literalnej treści opisów tych czynów. Bezspornie bowiem istotą instytucji procesowej subsydiarnego aktu oskarżenia jest umożliwienie pokrzywdzonemu dochodzenia swych praw w postępowaniu sądowym w takim zakresie, w jakim uznawał on, że popełniono*

³⁶ Zob. pkt 2 na s. 109.

czyn zabroniony na jego szkodę i w jakim racji tych nie podzielił oskarżyciel publiczny (...) – wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2020 r., sygn. akt III KK 149/19

- *Skarga subsydiarna może jedynie obejmować zarzut popełnienia czynu, który zachowuje przymiot tożsamości z tym, którego oceny dotyczyły decyzje kończące postępowanie przygotowawcze. Kryteria tożsamości czynu wyznacza opis czynu, co do którego dwukrotnie zapadły decyzje o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 listopada 2019 r., sygn. akt II AKa 280/18*
- *W sytuacji bowiem, gdy przeciwną stroną wytoczonego procesu – jest drugi z rodziców małoletniego, co ma zastosowanie nie tylko w sprawach cywilnych ale i również w procesie karnym (patrz treść art. 51 § 2 kpk w zw. z art. 98 § 2 pkt 2 kro i w związku z art. 98 § 3 kro oraz w związku z art. 99 kro, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21.01.2014 r. sygn. SK 5/12, uchwała (7) Sądu Najwyższego – Izba Karna z 30.09.2010 r. I KZP 10/10, postanowienie SN z 20.06.2012 r. I KZP 9/12, postanowienie SN z 29.11.2017 r. IV KK 417/17, postanowienie SN z 22.11.2017 r. sygn. IV KK 147/17, postanowienie SN z 30.09.2015 r. sygn. I KZP 8/15 – opubl. w Lex) – to małoletniego nie może tam reprezentować ani ten ani drugi jego rodzic. Jest to sytuacja oczywista i zrozumiała – każdy z rodziców ma bowiem te same prawa i każdy z nich mógłby torpedować wszelkie działania drugiego z rodziców. Gdyby nie owo uregulowanie – to każdy wniosek (np. akt oskarżenia) wniesiony przez jednego rodzica imieniem małoletniego – swobodnie mógłby być cofnięty przez drugiego. To samo dotyczyłoby wniosków dowodowych, procesowych np. o ściganie, czy ustanowienia dla małoletniego pełnomocnika, i tym podobnych działań. Dlatego, w takiej sytuacji – wyłącznym reprezentantem interesów pokrzywdzonego małoletniego M. C. (3), a więc tu zarazem osobą władną do złożenia prywatnego aktu oskarżenia, czy do umocowania pełnomocników procesowych – jest ustanowiony przez Sąd kurator J. K. Poglądy opisane wyżej – są od dawna ugruntowane tak w orzecznictwie jak i w literaturze prawniczej (patrz D. Świecki, B. Augustyniak, K. Eichstaedt w Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany,*

opubl. W Lex/el 2019, a także K. Dudka, C. Kulesza, J. Matras – Kodeks postępowania karnego. Komentarz opubl. WKP, 2018). Jak już wyżej wskazano, kwestia zgodności z konstytucją, odnośnych przepisów k.r.o., była już potwierdzona w opisanym wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. O ile w sprawach prowadzonych z oskarżenia publicznego, kwestia reprezentacji małoletniego ma zdecydowanie mniejsze znaczenie, gdyż występuje tam – jako rzecznik interesu publicznego – prokurator, który najpierw prowadzi sprawę a następnie wnosi akt oskarżenia. Z urzędu reprezentuje on interesy wszystkich pokrzywdzonych, którzy sami do sprawy nie wstąpili. Może wprowadzić, pojawić się również tam problem odpowiedniej reprezentacji, np. gdy czyn ścigany jest na wniosek pokrzywdzonego albo gdy prokurator chce odstąpić od ścigania. Stąd nawet tam, dla małoletnich ustanawia się kuratorów. Jednak dużo większe reperkusje ma opisywana kwestia w postępowaniu prywatno-skargowym, gdzie właśnie pokrzywdzony jest inicjatorem całego procesu i bez jego woli, nie doszłoby do oskarżenia. Szczególnie istotne jest więc, czy uprawniona osoba – tę właśnie wolę pokrzywdzonego wyraża i czy jest to rzeczywista wola małoletniego, czy też jest on instrumentalnie wykorzystywany, np. do rozgrywek i konfliktów pomiędzy jego rodzicami. Tutaj prywatny akt oskarżenia – w rzeczywistości złożony został przez pełnomocnika M. C. (1)(seniora), który to nie miał, z opisanych względów, uprawnień do reprezentowania swojego małoletniego syna (również M. C. (3)) w procesie toczącym się przeciwko drugiemu z jego rodziców – oskarżonej M. C. (2). Oznacza to, że nie był on uprawnionym oskarżycielem, a aktu oskarżenia nie wniósł rzeczywiście małoletni. Dlatego na podstawie art. 439 § 1 pkt 9 kpk wobec stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej – braku skargi uprawnionego oskarżyciela zaskarżony wyrok należało w całości uchylić i postępowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 9 kpk – umorzyć – **wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 1 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV 1 Ka 154/18**

- Stosownie zaś do treści art. 155 § 1 k.k.s., wobec objęcia prowadzonego w sprawie dochodzenia nadzorem prokuratorskim, organem uprawnionym do wniesienia do sądu aktu oskarżenia był nie Urząd Celnny w K., lecz prokurator. W takim stanie rzeczy oczywiste jest wystąpienie

w sprawie negatywnej przesłanki procesowej, w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) Wystąpienie takiej wady postępowania musiało skutkować, zgodnie z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k., uchyleniem wyroku sądu pierwszej instancji i umorzeniem postępowania w zakresie opartym na wadliwej skardze. Nie jest bowiem możliwe traktowanie tej wady postępowania, jako braku formalnego aktu oskarżenia, gdyż nie chodzi tu o sytuację, gdy czynność dokonana jest przez organ uprawniony, a brak dotyczy wyłącznie podpisu osoby, lecz o sytuację, gdy czynność wniesienia aktu oskarżenia do sądu, a zatem akt inicjujący w ogóle prowadzenie sądowego postępowania karnego – dokonana jest przez organ nieuprawniony. W takim stanie rzeczy obowiązkiem Sądu Okręgowego w G. było zastosowanie unormowania z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 9 k.p.k., (uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania) – **wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2019 r., sygn. akt IV KK 484/17**

- Na podstawie art. 311 § 2 k.p.k. prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa, jednakże powierzenie to nie może obejmować czynności związanych z przedstawieniem zarzutów, zmianą lub uzupełnieniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz zamknięciem śledztwa (art. 311 § 3 k.p.k.). Zaznaczyć należy, że w śledztwie jedynym podmiotem uprawnionym do sporządzenia i wniesienia do sądu aktu oskarżenia jest prokurator (art. 331 § 1 k.p.k.). Trzeba stwierdzić, że brak skargi uprawnionego oskarżyciela zachodzi także w sytuacji, gdy w sprawie o czyn ścigany z urzędu, skargę złożył nieprokuratorski oskarżyciel publiczny poza zakresem swoich kompetencji oskarżycielskich. Oskarżyciele publiczni, niebędący prokuratorem, mogą występować w charakterze oskarżyciela publicznego jedynie w zakresie ustawowego upoważnienia (art. 45 § 2 k.p.k.). Nie ma bowiem możliwości, aby skargę wniósł do sądu organ, który jest uprawniony do prowadzenia dochodzenia i takowe prowadził, w sytuacji, gdy sprawa wymagała prowadzenia śledztwa – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lipca 2018 r., sygn. akt V KS 15/18**
- (...) zgodzić się też trzeba z – trafnym co do zasady – poglądem sądu odwoławczego, co do tego, że „o tożsamości przesądza czyn w jego ujęciu

historycznym”. Nie jest jednak tak, że opis zachowania zarzuconego lub przypisanego, zaprezentowany w rozstrzygnięciu organu procesowego nie ma istotnego znaczenia. Jest on kształtowany na podstawie uzyskiwanych materiałów procesowych. W granicach przewidzianych normami procesowymi podlega on też rzecz jasna ewentualnym modyfikacjom, ale w sposób jednoznaczny wytycza także ramy prowadzonego postępowania, może determinować właściwość organów procesowych i powodować inne konsekwencje, a wady lub braki w tym zakresie mogą prowadzić w krańcowych wypadkach nawet do przekonania, że nastąpiła dekompletacja znamion czynu zabronionego. Również z punktu widzenia realizacji uprawnień stron procesowych ramy postępowania sprecyzowane w postanowieniach o wszczęciu lub umorzeniu postępowania odgrywają istotną rolę – **wyrok Sądu Najwyższego z 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt II KK 445/17**

- (...) brak skargi uprawnionego oskarżyciela w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. wchodzi w grę tylko w toku sądowego stadium procesu i tylko w odniesieniu do takiej osoby, która swoją skargą zainicjowała postępowanie główne, działając jako m.in. oskarżyciel prywatny, pomimo, że nie była osobą do tego uprawnioną lub orzeczono o czynie nie zawartym w akcie oskarżenia (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2014 r., II KK 73/14, Lex Nr 1460977). Chodzi zatem o dwa rodzaje przypadków – pierwszy, gdy osoba nie miała żadnej legitymacji do wystąpienia z oskarżeniem (czyli także nie była uprawnionym oskarżycielem jako subsydiarny oskarżyciel posiłkowy, który w warunkach określonych w art. 55 k.p.k. wnosi akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia publicznego), i drugi, gdy czyn przypisany nie jest tożsamy z czynem zarzuconym (co oznacza, że orzeczono w przedmiocie przestępstwa, którego osądzenia w ogóle nie żądał oskarżyciel) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2017 r., sygn. akt II KK 393/17**
- (...) brak skargi uprawnionego oskarżyciela w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego, stanowiący ujemną przesłankę procesową z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., ma miejsce również wtedy, gdy autor oskarżenia wskazał wprawdzie siebie jako osobę pokrzywdzoną zachowaniem oskarżonego, ale sąd ustalił, że naruszone zostało dobro prawne nie

oskarżyciela prywatnego, tylko zgoła innego podmiotu – **wyrok Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2017 r., sygn. akt V KK 85/17**

- (...) prokurator w trybie art. 60 k.p.k. może objąć oskarżeniem tylko czyny ścigane z oskarżenia prywatnego. Skazanie więc oskarżonego za czyn ścigany z oskarżenia publicznego po przeprowadzeniu postępowania wszczętego wniesieniem prywatnego aktu oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego będzie zawsze stanowiło bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 maja 2017 r., sygn. akt IV KK 453/16**
- W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że nie dochodzi do wyjścia poza granice oskarżenia, jeśli sąd ustali, iż będące przedmiotem postępowania zdarzenie miało miejsce w innych ramach czasowych, niż sprecyzowane w skardze prokuratora. Warunkiem wprowadzenia zmian w tym zakresie jest jedynie to, aby sąd orzekał o tym samym zdarzeniu, które było przedmiotem oskarżenia. W tych warunkach zachowana zostaje tożsamość czynu zarzucanego i przypisanego. Granice oskarżenia są zachowane wtedy, gdy niezależnie od ilości dokonanych zmian wszystkie elementy nowego opisu czynu mieszczą się w ramach tego samego czynu w znaczeniu ontologicznym (zob. np. wyrok SN z dnia 30 października 2012 r., II KK 9/12, Lex nr 1226693). Tylko skazanie za czyn inny niż zarzucany, a więc stanowiący odmienne zdarzenie w tymże znaczeniu, byłoby naruszeniem zasady skargowości i stanowiłoby uchybienie procesowe o charakterze bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 § 1 pkt 8 w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.). – **postanowienie Sądu Najwyższego z 28 lutego 2017 r., sygn. akt III KO 75/16**
- Subsydiarny akt oskarżenia został tymczasem wniesiony w dniu 6 lutego 2014 r. (...), a zatem po wskazanym w art. 55 § 1 k.p.k. terminie, który ma charakter terminu prekluzyjnego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2015 r., V KZ 6/15, Lex nr 1682153; wyrok TK z dnia 25 września 2012 r. SK 28/10, OTK-A 2012, Nr 8, poz. 96 i z dnia 8 stycznia 2013 r. K 18/10 OTK-A 2013, Nr 1, poz. 2). W związku z powyższym skarga subsydiarna nie została skutecznie wniesiona, a zatem postępowanie sądowe zostało wszczęte i toczyło się przy braku skargi

uprawnionego oskarżyciela. Konsekwencją takiego uchybienia winno być uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia Sądu pierwszej instancji, ale tylko w układzie, gdyby umorzenie postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) było dla oskarżonego korzystniejsze, niż to orzeczenie, które obecnie zostało zaskarżone kasacją (art. 439 § 2 k.p.k.). Prowadząc taką ocenę Sąd Najwyższy uznał, że dla oskarżonego jest korzystniejsze orzeczeniem o umorzeniu postępowania karnego z powodu braku oczywistych podstaw oskarżenia (brak dowodów na popełnienie przestępstwa) niż umorzenie *stricto formalne*, tj. z powodu niewniesienia aktu oskarżenia – **wyrok Sądu Najwyższego z 29 lipca 2015 r., sygn. akt II KK 98/15**

- (...) wniesienie aktu oskarżenia w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia publicznego przez pokrzywdzonego, pomimo że nie zachodzą warunki przewidziane w art. 55 § 1 k.p.k. powoduje, że zachodzi ujemna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela – **wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2013 r., sygn. akt IV KK 42/13**
- (...) w sytuacji gdy prokurator, przychylając się do zażalenia pokrzywdzonego, uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego, bez przekazywania sprawy do sądu (art. 463 § 1 k.p.k.), a następnie, po odpowiednich uzupełnieniach, dojdzie powtórnie do wydania takiego samego postanowienia, pokrzywdzony nie uzyskuje uprawnienia do wystąpienia z własnym aktem oskarżenia, o jakim mowa w art. 55 § 1 k.p.k., ponieważ to ponowne postanowienie nie zostało wydane w wyniku uprzedniego uchylenia takiego postanowienia przez sąd, jak tego wymaga wskazany przepis. Postanowienie to, mimo że powtórne, podlega więc znów zaskarżeniu na zasadach ogólnych (art. 306 § 1 w zw. z art. 465 § 2 k.p.k.) i dopiero gdy zażalenie takie zostanie rozpoznane przez sąd, a ten uchylił postanowienie prokuratora przy ponownym wydaniu postanowienia tożsamego z uchylonym, pokrzywdzony nabędzie uprawnień określonych w art. 55 § 1 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2012 r., sygn. akt III KK 122/12**
- Jeżeli oskarżyciel posiłkowy nie był uprawniony do skierowania subsydiarnego aktu oskarżenia, o jakim mowa w art. 55 k.p.k., gdyż zarzucił

nim przestępstwo, w którym nie był pokrzywdzonym w rozumieniu przepisu art. 49 § 1 k.p.k., to taki akt oskarżenia nie stanowi skargi uprawnionej oskarżyciela w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. i zachodzi ujemna przesłanka procesowa. Jeżeli ujawniono te okoliczności w postępowaniu odwoławczym, to zaskarżony wyrok podlega uchyleniu na podstawie art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, a postępowanie należy w takim wypadku umorzyć – wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 września 2012 r., sygn. akt II AKa 203/12

- (...) oskarżyciel posiłkowy może wnieść subsydiarny akt oskarżenia o jakim mowa w art. 55 k.k. jedynie o czyny, w których był on pokrzywdzonym w rozumieniu przepisu art. 49 § 1 k.p.k., a nie takie, co do których dobro chronione prawem wprost ma wymiar ogólnospołeczny i nie dotyczy indywidualnie oraz bezpośrednio dóbr konkretnej osoby, co sprawia, że w takim zakresie nie jest on podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi, warunkującej wszczęcie postępowania przed właściwym sądem, co musi skutkować tym samym umorzeniem postępowania wobec wystąpienia negatywnej po temu okoliczności określonej w przepisie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 marca 2010 r., sygn. akt II AKz 107/10**
- (...) wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia w okolicznościach, gdy nie został spełniony warunek ponownego umorzenia śledztwa przez prokuratora, przesądzało ocenę o zaistnieniu przyczyny wyłączającej prowadzenie postępowania przed sądem, polegającej na braku skargi uprawnionej oskarżyciela. W takim wypadku, Sąd Okręgowy był wprost obowiązany – wobec treści art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., do umorzenia postępowania – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 października 2009 r., sygn. akt II AKz 672/09**



Z brakiem wniosku o ściganie bądź zezwolenia na ściganie mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy szczególny przepis wymaga złożenia takowego

wniosku lub uzyskania zezwolenia na ściganie od ustawowo umocowanego podmiotu, zaś w aktach brak tego rodzaju oświadczeń.

Najczęściej na egzaminach zawodowych pojawia się zagadnienie braku wniosku o ściganie, złożonego przez pokrzywdzonego. **O tym, czy dany czyn zabroniony ścigany jest wnioskowo czy też nie, zadecydował ustawodawca, wskazując precyzyjnie w przepisach części szczególnej Kodeksu karnego, w odniesieniu do jakich przestępstw taki wniosek powinien zostać złożony, by postępowanie mogło się toczyć.** Przykładem przestępstw ściganych wnioskowo jest m.in.: nieumyślne spowodowanie lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu osoby najbliższej (art. 157 § 5 k.k.), nieumyślne narażenie człowieka na niebezpieczeństwo (art. 160 § 5 k.k.), narażenie człowieka na zarażenie (art. 161 § 4 k.k.), spowodowanie wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k., w którym szkody doznała osoba najbliższa dla sprawcy (art. 177 § 3 k.k.), groźba karalna (art. 190 § 2 k.k.), kradzież popełniona na szkodę osoby najbliższej (art. 278 § 4 k.k.) itd. W każdym z ww. przypadków ustawodawca wprost wskazał na konieczność uzyskania wniosku, by móc pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej za przestępstwo, posługując się formułą „*ściganie odbywa się na wniosek*”. Należy przy tym pamiętać, że w obecnym stanie prawnym, stosownie do treści art. 12 § 1a k.p.k., uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela. Jeżeli natomiast powodem uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego ściganie na wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu.

Podkreślenia również wymaga, że ani ustawodawca, ani orzecznictwo nie wymaga jakiejś szczególnej formy wniosku. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2019 r., *wola ta może być zatem wyrażona zarówno na piśmie, jak i w trakcie składania zeznań w charakterze świadka. Istotne jest, aby z takiego dokumentu procesowego w sposób wyraźny wynikało żądanie pokrzywdzonego ścigania sprawcy (...). Podkreślenia wymaga, że samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie stanowi złożenia wniosku; wola ścigania musi bowiem zostać wyrażona wyraźnie*³⁷. Jednocześnie, nie budzi

³⁷ Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt II KK 6/19.

wątpliwości orzeczniczych, że fakt złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie stanowi złożenia wniosku.

W konsekwencji, **jeśli obrońca dostrzeże brak wymaganego przepisem szczególnym wniosku o ściganie, pochodzącego od pokrzywdzonego, powinien w pracy egzaminacyjnej sformułować zarzut obrazu art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.**, poprzez wydanie orzeczenia skazującego za czyn ścigany wnioskowo, pomimo braku złożenia przez pokrzywdzonego wymaganego wniosku o ściganie, co skutkuje zaistnieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o której mowa w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo do art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.:

- (...) wniosek o ściganie może być złożony na każdym etapie postępowania, o ile nie doszło do przedawnienia karalności danego przestępstwa – **wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2019 r., sygn. akt V KK 118/18**
- (...) brak wniosku o ściganie sprawia, że w przypadku popełnienia przez oskarżonego przestępstwa wyczerpującego znamiona zarówno przestępstwa ściganego z urzędu, jak i przestępstwa ściganego na wniosek, niedopuszczalne jest zamieszczenie w opisie przypisanego oskarżonemu czynu oraz w jego kwalifikacji prawnej jakichkolwiek elementów, wskazujących na popełnienie przestępstwa, do którego ścigania potrzebne było pozyskanie owego wniosku (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2002 r., II KKN 267/01, LEX nr 54399). Dotyczy to oczywiście również zamieszczenia w opisie czynu danych dotyczących jego skutków oraz osób pokrzywdzonych (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 45/05, OSNKW 2006/1/4) (...). przesłanka „braku wniosku o ściganie” ma charakter względny, a to oznacza, że do upływu okresu przedawnienia owy brak może być konwalidowany. Po drugie była konsekwencją tego, że rozstrzygnięcie w postaci umorzenia postępowania może dotyczyć wyłącznie całości czynu, a nie jego fragmentów. Konwalidacja uchybienia polegającego na bezpodstawnym przypisaniu osobie oskarżonej określonych fragmentów jej zachowania, składających się na jeden czyn zabroniony, sprowadza się natomiast do eliminacji związanych z nim elementów z opisu lub kwalifikacji prawnej tego czynu – **wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2019 r., sygn. akt IV KK 1/19**

- *Ustawa karnoprosesowa nie określa formy, w jakiej pokrzywdzony ma wyrazić wolę ścigania, to jest złożyć wniosek, o którym mowa w art. 12 § 1 k.p.k. Wola ta może być zatem wyrażona zarówno na piśmie, jak i w trakcie składania zeznań w charakterze świadka. Istotne jest, aby z takiego dokumentu procesowego w sposób wyraźny wynikało żądanie pokrzywdzonego ścigania sprawcy (...). Podkreślenia wymaga, że samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie stanowi złożenia wniosku; wola ścigania musi bowiem zostać wyrażona wyraźnie. Osoba uprawniona powinna zostać pouczona (art. 16 § 1 k.p.k.) o prawie złożenia wniosku, konsekwencjach jego złożenia określonych w art. 12 § 2 k.p.k. oraz o możliwości cofnięcia wniosku lub braku możliwości jego cofnięcia (art. 12 § 3 k.p.k.), tak, by u podstaw złożenia wniosku o ściganie legła swobodnie podjęta decyzja. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowane jest zapatrywanie, że wniosek o ściganie może być złożony na każdym etapie postępowania karnego, w tym również w postępowaniu odwoławczym toczącym się w związku z umorzeniem postępowania z powodu braku wniosku o ściganie (zob. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1970 r., VI KZP 43/68 (...)) – **wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt II KK 6/19***
- (...) *cofnięcie wniosku o ściganie (gdyby była prawnie skuteczna) – stanowi brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.), nie zaś brak skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.). Uprawnionym oskarżycielem w przypadku przestępstwa z art. 190 k.k. jest bowiem prokurator, gdyż przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia publicznego a prokurator wniósł w tym zakresie akt oskarżenia. Nie ma racji skarżący podnosząc, że cofnięcie wniosku o ściganie w realiach rozpoznawanej sprawy winno skutkować umorzeniem postępowania w zakresie zarzuconego oskarżonemu A. Ł. czynu z art. 190 k.k. Zgodnie bowiem z art. 12 § 3 k.p.k., na etapie postępowania jurysdykcyjnego wniosek o ściganie może być cofnięty za zgodą sądu do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej; przewód sądowy zaś rozpoczyna się od przedstawienia zarzutów oskarżenia przez oskarżyciela (art. 385 § 1 k.p.k.). Cofnięcie zatem wniosku przez pokrzywdzonego w toku rozprawy (...) nie wywołuje skutków prawnych*

o jakich mowa w zarzucie apelacji – wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II AKa 355/17

- *Złożenie wniosku o ściganie nie jest obwarowane koniecznością zachowania szczególnej formy. Jedynym wymogiem skutecznego złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie jest wyrażenie woli ścigania i ukarania sprawcy konkretnego przestępstwa – postanowienie Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2017 r., sygn. akt V KK 339/16*
- *Najdalej idący zarzut obrazy art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. jest efektem niepodzielenia trafnego stanowiska Sądu I instancji, że określony w tym przepisie brak zezwolenia jest usuwalny do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Możliwość konwalidacji tego braku wynika z art. 17 § 2 in fine k.p.k., który przewiduje, że w razie nieistnienia takiego zezwolenia sąd, rozstrzygający w przedmiocie procesu, podejmuje czynności zmierzające do wyjaśnienia, czy zezwolenie będzie wydane. Oznacza to również obowiązek oczekiwania przez ten sąd na rezultat postępowania wpadkowego zainicjowanego wnioskiem o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności, gdy – jak w tej sprawie – wniosek został złożony. Unormowanie określone w art. 17 § 2 k.p.k. świadczy o tym, że wskazana negatywna przesłanka dopuszczalności procesu głównego ma charakter względny, to znaczy, przeszkoda ta, uniemożliwiająca jego wszczęcie albo kontynuowanie, jest usuwalna – uchwała Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2017 r., sygn. akt SNO 55/16*
- *(...) negatywna przesłanka odwoławcza wymieniona w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. ma jedynie względny charakter, a w związku z tym wniosek o ściganie może zostać złożony aż do nastąpienia jego przedawnienia. Wniosek taki może zostać również złożony przez organ uprawniony do działania w imieniu następcy prawnego pokrzywdzonej spółki – wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2016 r., sygn. akt V KK 85/16*
- *Przestępstwo z art. 266 § 1 k.k. jest czynem tzw. bezwzględnie wnioskowym, to znaczy warunkiem wszczęcia albo kontynuowania postępowania jest, w myśl § 3 art. 266 k.k., wniosek pokrzywdzonego o ściganie. Brak wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej uniemożliwia postępowanie (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.). Prowadzenie go rodzi uchybienie*

wymienione w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 8 marca 2012 r., sygn. akt V KK 440/11, LEX nr 1674134**

- *Prywatnoscargowy akt oskarżenia dotyczy sędziego, zatem warunkiem dopuszczalności procesu jest uprzednie uchylenie immunitetu sędziowskiego. W sytuacji gdy ten warunek w sprawie nie został dotychczas spełniony, w grę wchodzi negatywna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k., obligująca sąd do umorzenia postępowania – **postanowienie Sądu Najwyższego z 22 lipca 2010 r., sygn. akt IV KO 83/10***

Ad. 6.3.10. Oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k. lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy – art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.;

Omawiana w tym miejscu bezwzględna przyczyna odwoławcza odnosi się do rzeczywistego naruszenia prawa oskarżonego do obrony. Dotyczy wyłącznie postępowania sądowego i jak wskazał w jednym z najnowszych judykatów Sąd Najwyższy – *musi być związana z sytuacją, gdy w czasie, kiedy obrońca nie może wykonywać z obiektywnych powodów swoich obowiązków, postępowanie sądowe jest prowadzone w sposób realny, efektywny, a zarazem zakładający możliwość podejmowania przez obrońcę czynności procesowych, przy czym nie chodzi o prowadzenie rozprawy (tego dotyczy część druga art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.)*³⁸.

Przesłanka ta nie znajdzie zastosowania w sytuacji, w których wprowadzie strona słusznie ocenia, że zachodziły przesłanki obrony obligatoryjnej, ale sąd obrońcy nie ustanowił. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 8 listopada 2017 r., z przesłanką z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy sąd, przed którym toczy się postępowanie, uzna, że oskarżony obrońcę mieć musi, a następnie prowadzi postępowanie nie wyznaczając obrońcy z urzędu, pomimo iż oskarżony sam obrońcy nie ustanowił. Dla stwierdzenia, że zachodzi omawiana tu bezwzględna przyczyna odwoławcza nie wystarczy zatem wykazać, iż w realiach rozpoznawanej

³⁸ Postanowienie Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2022 r., sygn. akt III KK 412/21.

sprawy zachodziły przesłanki obrony obligatoryjnej, o jakiej mowa w art. 79 § 2 k.p.k.³⁹, albowiem decydujące znaczenie w tym zakresie ma zatem ocena organu procesowego, a nie subiektywna ocena obrońcy czy stron postępowania⁴⁰.

W orzecznictwie podkreśla się także, że omawiana bezwzględna przyczyna odwoławcza zaistnieje w **sytuacji sprzeczności interesów oskarżonych, których obronę pełni ten sam obrońca**. Jest to bowiem przypadek, kiedy wprawdzie zapewniona jest obrona w znaczeniu formalnym, to jednak jest ona nieefektywna, albowiem obrona jednego z oskarżonych niechybnie łączy się z narażeniem interesów drugiego oskarżonego (np. dlatego, że obrońca nie złoży wniosku korzystnego dla jednego z bronionych oskarżonych, aby nie narażać w ten sposób interesów drugiego z nich). Z orzecznictwa wynika jednocześnie, że nie będzie odpowiadała bezwzględnej przyczynie odwoławczej sytuacja, w której jeden z dwóch/trzech obrońców, nawet przy obronie obligatoryjnej, w ogóle został pominięty przez sąd. W takim przypadku mamy do czynienia z obrazą art. 117 § 1 i 2 k.p.k. zw. z art. 6 k.p.k., nie zaś z bezwzględną przyczyną odwoławczą, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., polegająca na braku formalnej i merytorycznej obrony („oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy”), musi być związana z sytuacją, gdy w czasie, kiedy obrońca nie może wykonywać z obiektywnych powodów swoich obowiązków, postępowanie sądowe jest prowadzone w sposób realny, efektywny, a zarazem zakładający możliwość podejmowania przez obrońcę czynności procesowych, przy czym nie chodzi o prowadzenie rozprawy (tego dotyczy część druga art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2022 r., sygn. akt III KK 412/21**
- (...) bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., uzasadniająca wydanie orzeczenia o charakterze kasatoryjnym, zachodzi w sytuacji braku posiadania przez oskarżonego obrońcy w sytuacjach przewidzianych w tym przepisie, ale wyłącznie na etapie postępowania

³⁹ Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 listopada 2017 r., sygn. akt III KK 119/17.

⁴⁰ Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV KK 106/17.

sądowego, a nie przygotowawczego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 22 grudnia 2020 r., sygn. akt V KK 73/20**

- (...) okoliczność nieskuteczności zawiadomienia obrońcy o terminie rozprawy nie mieści się w katalogu bezwzględnych przyczyn odwoławczych, o których mowa w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. albowiem w ogóle obecność obrońcy na rozprawie odwoławczej nie miała charakteru obligatoryjnego. Natomiast niewątpliwie w niniejszej sprawie, wskutek wadliwego wskazania adresata zawiadomienia o terminie rozprawy odwoławczej, doszło do naruszenia przepisów postępowania, a mianowicie art. 117 § 1 k.p.k. i art. 6 k.p.k. Nie oznacza to jednak, że w toku procesu zaistniało uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., które polega na nieposiadaniu przez oskarżonego obrońcy w postępowaniu sądowym w wypadkach określonych w art. 79 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 28 października 2020 r., sygn. akt III KK 332/20**
- (...) bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. zachodzi wówczas, gdy oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k. lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy – **postanowienie Sądu Najwyższego z 1 października 2020 r., sygn. akt II KK 233/20**
- (...) za bezwzględną przyczynę odwoławczą wymienioną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. (brak obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 k.p.k. lub brak udziału obrońcy w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy) można uznać również sytuację, gdy oskarżony w postępowaniu sądowym ma wprowadzić formalnie obrońcę, ale z uwagi na zachodzącą sprzeczność interesów tego oskarżonego, i interesów innego oskarżonego reprezentowanego przez tego samego obrońcę, nie może on należycie spełniać swoich powinności. Procesowa kolizja interesów oskarżonych musi być realna, rzeczywista, a nie jedynie pozorna, potencjalna. (...) Racją unormowania zawartego w przepisie art. 85 § 2 k.p.k. jest wyłączenie możliwości kontynuacji obrony tych oskarżonych, co do których wystąpiła kolizja interesów oraz odsunięcie podejrzenia, że adwokat (radca prawny) mógłby wykorzystać dotychczas uzyskane informacje z naruszeniem interesów tego oskarżonego, którego

nie broniłby w dalszym postępowaniu (zob. wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2018 r., II KK 390/17, Lex nr 2487632; wyrok SN z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II KK 224/17, Lex nr 2427143) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2020 r., sygn. akt III KO 26/20**

- (...) nie skutkuje bezwzględną przyczyną odwoławczą sytuacja, w której obrońca obligatoryjny nie jest obecny na rozprawie, na której są podejmowane wyłącznie czynności o charakterze organizacyjnym, jak to miało miejsce w tej sprawie (por.m.in.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., III KO 68/13) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 marca 2020 r., sygn. akt III KO 96/19**
- (...) o ile trudno polemizować z poglądem, że późne zawiadomienie obrońców o terminie posiedzenia ograniczyło niewątpliwie ich prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym przedłużenia najostrzejszego środka zapobiegawczego, o tyle uprawnienie w tej materii nie było tożsame z obowiązkowym udziałem obrońcy w tym posiedzeniu. Tym samym nie mogło być mowy o zaistnieniu bezwzględnego uchybienia. Stwierdzić wypadało, że siłą rzeczy oczywiście nietrafna była towarzysząca zarzutowi z art. 439 k.p.k. teza o rażącym naruszeniu prawa procesowego, tj. art. 6 k.p.k., art. 117 § 2 k.p.k., art. 137 k.p.k., art. 249 § 5 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 marca 2020 r., sygn. akt IV KK 77/20**
- (...) przekonanie skazanego o nierzetelnym wykonywaniu przez obrońcę swoich zadań w procesie, np. przez brak dostatecznej znajomości akt sprawy, brak inicjatywy dowodowej z jego strony, nie jest równoznaczne z wystąpieniem bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. (zob. post. SN z 22 listopada 2012 r., V KO 60/12) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 maja 2018 r., sygn. akt IV KO 88/17**
- (...) kolizja interesów kilku oskarżonych, bronionych przez tego samego adwokata albo radcę prawnego, zachodzi wtedy, gdy dla obrony jednego z nich celowe byłoby dezawuowanie treści wyjaśnień innego, bronionego przez tego samego adwokata albo radcę prawnego, bo takie działanie podważałoby zaufanie tych oskarżonych co do rzetelności obrony. Dalej zauważyć należy, że za bezwzględną przyczynę odwoławczą (której zaistnienie zarzuca Skarżący w niniejszej sprawie) wymienioną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. (...) można faktycznie uznać sytuację, gdy oskarżony

w postępowaniu sądowym ma wprowadzić formalnie obrońcę, ale z uwagi na zachodzącą sprzeczność interesów tego oskarżonego i interesów innego oskarżonego reprezentowanego przez tego samego obrońcę, nie może on należycie spełniać swoich powinności – wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt II KK 390/17

- (...) istniejące uregulowania nie pozwalają uznać, iż przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność, choćby usprawiedliwioną, jednego z dwóch obrońców nastąpiło przy naruszeniu prawa oskarżonego do obrony, zwłaszcza w stopniu uzasadniającym zastosowanie art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt III KK 254/17**
- (...) zgodnie z przepisami art. 79 § 1 pkt 1 oraz § 3 k.p.k., oskarżony w postępowaniu karnym, jeżeli nie ma ukończonych 18 lat, musi mieć obrońcę, a udział takiego obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy. Z kolei z przepisu art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. wynika, że niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, zaskarżone orzeczenie bezwzględnie ulega uchyleniu, jeżeli obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy – **wyrok Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2018 r., sygn. akt V KK 485/17**
- (...) o istnieniu bezwzględnej przyczyny odwoławczej, o jakiej mowa w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. w nawiązaniu do art. 79 § 2 k.p.k. można mówić jedynie wtedy, gdy sąd, przed którym toczy się postępowanie uzna, że oskarżony obrońcę mieć musi, a następnie prowadzi postępowanie nie wyznaczając obrońcy z urzędu, pomimo iż oskarżony sam obrońcy nie ustanowił. Dla stwierdzenia, że zachodzi omawiana tu bezwzględna przyczyna odwoławcza nie wystarczy zatem wykazać, iż w realiach rozpoznawanej sprawy zachodziły przesłanki obrony obligatoryjnej, o jakiej mowa w art. 79 § 2 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 8 listopada 2017 r., sygn. akt III KK 119/17**
- Dla stwierdzenia, że ta bezwzględna przyczyna odwoławcza (z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. – uwaga autorki) wystąpiła, nie wystarczy wykazać, iż w realiach rozpatrywanej sprawy zachodziły przesłanki obrony obligatoryjnej, o jakiej mowa w art. 79 § 2 k.p.k. Obligatoryjność obrony

powstaje bowiem dopiero w wyniku sądowego uznania, że oskarżony musi mieć obrońcę. Decydujące znaczenie w tym zakresie ma zatem ocena organu procesowego, a nie subiektywna ocena obrońcy, czy stron postępowania. Skoro więc Sąd orzekający nie stwierdził okoliczności z art. 79 § 2 k.p.k., weryfikując przy tym kwestię zdolności oskarżonej do udziału w postępowaniu opiniami specjalistów, dokonując ich oceny, która w żadnej części nie była kwestionowana, to nie można mówić o obrazie art. 79 § 2 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV KK 106/17**

- (...) opisana sytuacja procesowa nie stanowiłaby uchybienia o randze bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. nawet wówczas, gdyby obrona oskarżonego miała charakter obligatoryjny. Wszak ustawodawca w dyspozycji cytowanego przepisu użył liczby pojedynczej „obrońca”, a przepis ten, jako statuujący wyjątek, wykładni rozszerzającej nie może podlegać. W razie obrony obligatoryjnej brak udziału w rozprawie odwoławczej jednego z ustanowionych obrońców, niezawiadomionego przez sąd o terminie rozprawy, jeżeli w rozprawie tej bierze udział inny obrońca, nie stanowi – z reguły – uchybienia o randze bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Takie uchybienie wystąpiłoby jedynie wówczas, gdyby w rozprawie nie brał udziału żaden z ustanowionych obrońców (podobne stanowisko – SN w wyroku z 14 listopada 2013 r., II KK 154/13, OSNKW 2014, nr 3, poz. 27). Wymienione wyżej uchybienie w postaci zaniechania zawiadamiania drugiego obrońcy z wyboru o czynnościach procesowych należy uznać za naruszenie przepisów postępowania, w tym przede wszystkim art. 6 k.p.k. w zw. z art. 77 k.p.k., art. 117 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 140 k.p.k., które mogło mieć wpływ na treść wyroku, a tym samym powoduje, że zaskarżony wyrok ostać się nie może. Całkowite „pominięcie” drugiego obrońcy w toku postępowania sądowego, w konsekwencji którego nie wziął on w ogóle udziału w rozprawie głównej, nie może być ocenione jako uchybienie, które nie mogło mieć istotnego wpływu na treść zaskarżonego wyroku. Skoro ustawodawca przewidział w ramach prawa do obrony możliwość ustanowienia trzech obrońców (art. 77 k.p.k.), to obowiązkiem organów procesowych jest je

respektować – **wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 12 maja 2016 r., sygn. akt XIII Ka 308/16**

- *Procesowa kolizja interesów oskarżonych musi być bowiem realna, rzeczywista a nie jedynie pozorna lub potencjalna (por. np. T. Grzegorzczak: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014, t. I, s. 383). Jak to ujmują inni autorzy, aby można było mówić o koniecznej ingerencji sądu (w trybie art. 85 § 2 k.p.k.) ze względu na sprzeczność interesów, obrona jednego ze współoskarżonych powinna „w sposób nieuchronny” narażać dobro innego oskarżonego, ma czynić jednoczesną obronę obu oskarżonych zadaniem „wręcz niemożliwym” (por. np. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2011, t. I, s. 588; K. Eichstaedt (w:) D. Świecki (red.): Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2013, t. I, s. 377). Również w orzecznictwie eksponuje się wskazany wyżej element realności, nie zaś jedynie pozorności kolizji – **postanowienie Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2015 r., sygn. akt II KK 80/14***
- *W art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. wyraźnie przecież zaznaczono, że chodzi o nieposiadanie obrońcy niezbędnego „w postępowaniu sądowym”. Zatem nawet brak obrońcy niezbędnego w postępowaniu przygotowawczym może być oceniany tylko pod kątem względnej przyczyny odwoławczej z art. 438 pkt 2 k.p.k., o ile oczywiście uchybienie to przeniknęło do postępowania sądowego i mogło mieć wpływ na treść orzeczenia. W tym przepisie chodzi więc o sądowe stadium procesu – **postanowienie Sądu Najwyższego z 6 lipca 2005 r., sygn. akt IV KO 8/05***
- *(...) podjęcie się przez adwokata obrony obojga oskarżonych, gdy obrona jednego z nich stoi w sprzeczności z obroną drugiego i dopuszczenie do takiej obrony przez Sąd, stanowi naruszenie podstawowego prawa oskarżonego w procesie karnym (art. 9 k.p.k. – obecnie art. 6 k.p.k. – uwaga autorki), gdyż z reguły taka sytuacja ma wpływ na treść wyroku. obrońca nie może spełnić należycie swojego obowiązku z korzyścią dla oskarżonych, gdy obrona jednego wymaga podważania zaufania do twierdzeń drugiego, nawet tylko z pewnej fazy postępowania i przez to prowadzi do postawienia go w niekorzystnej sytuacji procesowej – **wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 1980 r., sygn. akt II KR 210/80***

- (...) *sprzeczność zachodziłaby wtedy, gdyby obrona jednego z oskarżonych w sposób nieuchronny narażała dobro drugiego z nich, inaczej mówiąc, gdyby wyjaśnienia jednego z oskarżonych czy też dowody przez niego powołane oraz ich ocena godziły w interes drugiego, wskutek czego powstałaby kolizja interesów, prowadząca w takiej sytuacji do unicestwienia roli obrońcy w procesie karnym. Stanowiłoby to niewątpliwie pogwałcenie uprawnień oskarżonego przewidzianych w art. 9 k.p.k. (obecnie art. 6 k.p.k., uwaga autorki) – wyrok Sądu Najwyższego z 26 października 1971 r., sygn. akt V KRN 375/71*

Ad. 6.3.11. Sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa – art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku ustawodawca w art. 374 § 1 k.p.k. wymagał co do zasady obecności oskarżonego na rozprawie głównej. Przepis ten zmieniony został przez art. 1 pkt 120 lit. a) ustawy z dnia 27 września 2013 r. (Dz.U.2013.1247), zmieniającej Kodeks postępowania karnego z dniem 1 lipca 2015 r. Od tej daty art. 374 § 1 k.p.k. wprowadza prawo oskarżonego do udziału w rozprawie, chyba że przewodniczący lub sąd uzna jego obecność za obowiązkową. Warto odnotować, że art. 374 § 1 zd. 1 k.p.k. częściowo został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt K 46/15 (Dz.U.2020.1458) z dniem 26 sierpnia 2020 r. W orzeczeniu tym Trybunał wskazał, że ww. przepis traci moc w zakresie, w jakim nie przewiduje obowiązkowej obecności podejrzanego na rozprawie w sprawie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających.

Art. 1 pkt 120 lit. b) ww. ustawy nowelizującej dodał do treści art. 374 k.p.k. również art. **374 § 1a k.p.k.**, zgodnie z którym w sprawach o zbrodnie udział oskarżonego w czynnościach, o jakich mowa w art. 385 k.p.k. (tj. otwarcie przewodu sądowego, tj. przedstawienia zarzutów aktu oskarżenia) i art. 386 k.p.k. (tj. złożenie wyjaśnień przez oskarżonego) jest obowiązkowa.

Jak wskazuje D. Świecki⁴¹, „przepis art. 374 § 1 i 1a realizuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z 9.03.2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.Urz. UE L 65, s. 1), w której zobowiązuje się państwa członkowskie do zapewnienia oskarżonemu prawa do obecności na rozprawie, a także przewiduje, że rozprawa, której wynikiem może być orzeczenie w przedmiocie winy lub niewinności oskarżonego, może odbywać się pod jego nieobecność, pod warunkiem, że oskarżonego powiadomiono we właściwym czasie o rozprawie i konsekwencjach niestawiennictwa (art. 8 ust. 1 i 2 lit. a). Co do tego warunku, to jest on realizowany w art. 117 § 1 i art. 350 § 2 pkt 2 przez wprowadzenie obowiązku zawiadomienia oskarżonego o czasie i miejscu rozprawy, w art. 338 § 1a – przez pouczenie go o treści art. 374, i w art. 353 § 4 – przez pouczenie oskarżonego o treści art. 419 § 1, tj. o możliwości wydania wyroku pod jego nieobecność. Artykuł 374 § 1 zmienia charakter uchybienia związanego z nieprawidłowym rozpoznaniem sprawy pod nieobecność oskarżonego. **Wprowadzenie zasady, że udział oskarżonego w rozprawie nie jest obowiązkowy, powoduje, że uchybienie w tym zakresie nie ma już rangi bezwzględnej przyczyny odwoławczej (art. 439 § 1 pkt 11). Obecnie jest to względna przyczyna odwoławcza z art. 438 pkt 2 związana z naruszeniem art. 117 § 1 i 2 co do zawiadamiania o czasie i miejscu rozprawy (art. 117 § 1) i nieprzeprowadzania rozprawy pod nieobecność oskarżonego w warunkach określonych w art. 117 § 2, które w konsekwencji prowadzi do pozbawienia go prawa do udziału w rozprawie głównej (art. 374 § 1). To uchybienie procesowe dla skuteczności zarzutu odwoławczego wymaga również wykazania możliwego wpływu na treść orzeczenia**”.

W konsekwencji od 1 lipca 2015 r. obowiązkowy udział oskarżonego w rozprawie jest wyjątkiem od zasady nieobligatoryjnego udziału oskarżonego w rozprawie. Ustawodawca przewiduje zaledwie nieliczne sytuacje procesowe, w których udział oskarżonego jest obligatoryjny, w tym:

⁴¹ D. Świecki, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 374 k.p.k., Lex/el 2022, teza 1.

- *wszystkie sytuacje, w których przewodniczący lub sąd wyda stosowne zarządzenie, uznając obecność oskarżonego za obowiązkową;*
- *w sprawach, w których zarzucono oskarżonemu popełnienie zbrodni w trakcie czynności przedstawienia zarzutu aktu oskarżenia oraz przesłuchania oskarżonego na rozprawie głównej;*
- *na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania;*
- *na rozprawie w sprawie wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających (art. 380 k.p.k.);*

Po ww. nowelizacji k.p.k. wyłącznie niezawiadomienie oskarżonego o terminie rozprawy, w której jego udział – mocą ww. przepisów Kodeksu postępowania karnego – jest obligatoryjny bądź niezapewnienie udziału oskarżonego, którego udział jest obligatoryjny, stanowić będzie bezwzględną przyczynę odwoławczą. Natomiast w przypadku błędnego zawiadomienia oskarżonego o terminie rozprawy, w której jego udział jest wyłącznie jego prawem, takie uchybienie stanowić będzie względną przyczynę odwoławczą z art. 438 pkt 2 k.p.k.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) rozpoznanie sprawy pod nieobecność oskarżonego, jako uchybienie o charakterze bezwzględnej przyczyny odwoławczej, odnosi się do tych sytuacji, w których ustawa przewiduje obowiązkowy udział oskarżonego w czynności procesowej. Taka sytuacja w niniejszej sprawie jednak nie wystąpiła, albowiem rzeczony obowiązek – w przypadku rozpoznania sprawy na rozprawie głównej w postępowaniu zwyczajnym – dotyczy wyłącznie spraw o zbrodnie i tylko co do czynności otwarcia przewodu sądowego oraz przesłuchania oskarżonego, na co jednoznacznie wskazuje brzmienie art. 374 § 1a k.p.k. Na mocy zaś art. 374 § 1 zd. 2 k.p.k., przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżonego za obowiązkową – **postanowienie Sądu Najwyższego z 26 października 2021 r., sygn. akt II KK 287/21**
- Stosownie do treści art. 117 § 3 k.p.k. w razie niestawiennictwa strony, obrońcy lub pełnomocnika, których stawiennictwo jest obowiązkowe,

czynności procesowej nie przeprowadza się. W tej sytuacji przeprowadzenie posiedzenia skutkującego uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność nawet prawidłowo o niej powiadomionego oskarżonego, w przypadku uprzedniego uznania jego udziału w nim za obowiązkowy było niedopuszczalne. Skutkuje wystąpieniem uchybienia określonego w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k., o charakterze bezwzględnej przyczyny odwoławczej powodując, że niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia zaskarżone orzeczenie uchyla się – **wyrok Sądu Najwyższego z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt III KK 144/21**

- Stosownie do treści art. 354 pkt 2 k.p.k. w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających powinni, co do zasady, uczestniczyć: prokurator, obrońca i podejrzany. Udział podejrzanego w tym forum rozpoznania sprawy jest obligatoryjny, chyba że z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewskazane, przy czym nawet wtedy Sąd może uznać udział podejrzanego za konieczny (...) wykluczone jest rozpoznanie sprawy w tym trybie pod nieobecność któregośkolwiek z wymienionych w treści art. 354 pkt 2 k.p.k. podmiotów, z wyjątkiem wskazanej już wcześniej sytuacji. Procedowanie pod nieobecność podejrzanego stanowi natomiast uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 r., II K 139/05; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2015 r., V KK 337/14) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 3 lutego 2021 r., sygn. akt IV KK 582/19**
- (...) o naruszenia tego przepisu i zaistnienia bezwzględnej podstawy odwoławczej w nim skodyfikowanej dojdź może tylko wtedy, gdy – *verba legis* – obecność oskarżonego na rozprawie jest obowiązkowa. Obecność oskarżonego na rozprawie jest zaś obowiązkowa wówczas, gdy wyraźnie wynika to ustawy postępowania karnego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 27 listopada 2020 r., sygn. akt II KK 214/20**
- (...) zaistnienie bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. może być w toczącym się postępowaniu konwalidowane, jeżeli Sąd następnie powtórzy wszystkie czynności procesowe,

które zostały dokonane pod nieobecność oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa (...). Usunięcie uchybienia stanowiącego bezwzględną przyczynę odwoławczą jest skuteczne, gdy powtórzenie wadliwej czynności procesowej odbędzie się z zachowaniem wszystkich wymagań ustawowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, które uprzednio zostały obrażone. Podkreślenia wymaga, że w przypadku powtarzania odpowiedniego fragmentu rozprawy, celem usunięcia uchybienia stanowiącego bezwzględną przyczynę odwoławczą w postaci orzekania na rozprawie pod nieobecność obrońcy obligatoryjnego albo oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa, ponownie przeprowadzane są jedynie czynności dowodowe, zaś powtórzeniu nie podlegają żadne poprzednio wydane decyzje procesowe – **wyrok Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2018 r., sygn. akt V KK 405/17**

- Posiedzenie sądu w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego stanowi zatem czynność, na której „rozpoznano sprawę” i rozstrzygnięto w przedmiocie wymienionej kwestii. Jeżeli oskarżony nie brał udziału w tym posiedzeniu doszło do naruszenia przysługującego mu prawa do obrony. Uchybienie to przesądza, że postępowanie prowadzone było nierzetelnie. Bezwzględny charakter uchybienia powoduje, że zaskarżone orzeczenie podlega uchyleniu niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia (art. 439 § 1 KPK) – **postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7 marca 2018 r., sygn. akt II AKz 142/18**
- (...) art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. nie uległ zmianie w wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej k.p.k., nadal wymienia on nieobecność oskarżonego (podczas czynności, gdy była ona obowiązkowa) jako jedną z bezwzględnych przesłanek odwoławczych. Bezsprzecznie jednak, przepis ten nie ma samodzielnego bytu, gdyż musi zostać wypełniony treścią przez normy określające sytuacje, w których obecność oskarżonego podczas rozpoznawania jego sprawy jest obowiązkowa – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 lipca 2015 r., sygn. akt III KK 375/14**

Rozdział 7.

Zasadność sformułowania zarzutu obrazy prawa materialnego; czym są tzw. zarzuty „mieszane”?

Ad. 7.1. Zarzut obrazy z art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.

Obraza prawa materialnego, zgodnie z utrwalonym jednolitym orzecnictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych *polega na jego wadliwym zastosowaniu lub niezastosowaniu, w orzeczeniu, które oparte jest na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie można więc mówić o naruszeniu przepisów prawa materialnego w sytuacji, gdy wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę*⁴².

Z powyższego wynika **koncepcja tzw. „pierwotnego uchybienia”**, która **związana jest z koniecznością poszukiwania przez apelującego, gdzie dokładnie i na jakim etapie rozważań sądu wystąpił błąd, rozumiany jako naruszenie nakazu lub zakazu, wynikającego z Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego albo też innych przepisów, jakie sąd ma obowiązek stosować (lub nie stosować). Czy zatem błąd ten zaistniał w płaszczyźnie oceny materiału dowodowego, co uzasadniałoby formułowanie zarzutów z art. 438 pkt 2 albo 3 k.p.k., czy też później – w płaszczyźnie subsumpcji, czyli przyporządkowania – niekwestionowanego przez apelującego – stanu faktycznego pod ogólną normę prawną. To z kolei uzasadniałoby sformułowanie zarzutu obrazy z art. 438 pkt 1 albo 1a k.p.k.**

Jeśli zatem decydujemy się na sformułowanie zarzutów odnoszących się do sfery prawa procesowego, bo uważamy, że sąd błędnie ocenił materiał dowodowy, to w apelacji karnej na tych zarzutach poprzestańmy i nie formułujmy dodatkowych zarzutów np. błędnego zastosowania przepisu prawa materialnego. Ten ostatni jest bowiem oczywistą konsekwencją obrazy prawa

⁴² Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2020 r., sygnatura akt I KK 29/19.

procesowego i zgodnie z koncepcją „*pierwotnego uchybienia*”, na wskazaniu owego pierwotnego błędu porzeczamy. Z praktyką wskazywania zarówno błędu pierwotnego, jak i zarzutów, które są jego konsekwencją, często spotykam się w pracach egzaminacyjnych, co jest zazwyczaj oceniane jako istotny, merytoryczny błąd pracy i negatywny przykład konstruowania tzw. zarzutów „*mieszanych*” (zob. podrozdział 7.4.).

Pamiętajmy, że wyrokowanie jest wynikiem określonego procesu myślowego sądu, który można podzielić na etapy, odpowiadające konstrukcji większości uzasadnień wyroków karnych, także tych sporządzanych obecnie na formularzach. Najpierw sąd ocenia materiał dowodowy, a zatem daje (lub nie) wiarę poszczególnym dowodom, co wskazuje w uzasadnieniu. Z tego kształtuje się określony stan faktyczny, który sąd przyjmuje za niebudzący wątpliwości w danej sprawie. Opis ustalonego przez sąd stanu faktycznego zawarty jest z reguły w początkowej części uzasadnienia orzeczenia. Następnie sąd przytacza przepisy prawa materialnego, jakie jego zdaniem mają zastosowanie w danej sprawie (te z opisu czynu zarzuconego aktem oskarżenia i ewentualne inne, wynikłe np. ze zmiany opisu czynu i kwalifikacji prawnej) i przedstawia w jaki sposób rozumie te normy, a zatem przedstawia ich wykładnię. Dalej następuje to, co określamy mianem subsumcji, tj. przyporządkowania stanu faktycznego pod abstrakcyjną, wynikającą z przepisów, normę prawną. Etap ten zazwyczaj w wyrokach wyrażony jest sformułowaniem „*tak ustalony stan faktyczny wypełnia znamiona zarzuconego oskarżonemu czynu z art...*”. Dopiero w dalszej kolejności sąd odnosi się do wymiaru orzeczonej kary i pozostałych skutków wydanego wyroku. Świadomość powyższego jest o tyle istotna, że **pozwala apelującym na odtworzenie, w jakiej fazie ww. procesu doszło do popełnienia błędu, co z kolei determinuje rodzaj sformułowanego zarzutu apelacyjnego**.

Jeśli zatem kwestionujemy ocenę materiału dowodowego, np. nie zgadzamy się z wnioskiem jaki sąd wyprowadził z zeznań świadka albo z treści dokumentu, to wówczas nasze zarzuty dotyczą płaszczyzny prawa procesowego, a nie prawa materialnego. Oczywiście jest bowiem, że skoro sąd ustalił błędnie stan faktyczny (co jest wynikiem błędnej oceny poszczególnych dowodów zgromadzonych w sprawie), to w efekcie błędnie zastosował prawo materialne. Innymi słowy, skoro sąd niezasadnie dał wiarę świadkowi,

pomawiającemu oskarżonego (np. uznając, że oskarżony uszkodził ciało pokrzywdzonego), to błędnie zastosował art. 157 § 1 k.k. Wówczas zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. (albo ewentualnie innych z zakresu Kodeksu postępowania karnego, które posłużyły sądowi do oceny materiału dowodowego). Formułowanie zarzutu obrazy prawa materialnego w takiej sytuacji byłoby jednoznacznie błędne, skoro apelujący kwestionuje ustalenia faktyczne, a zatem jego zdaniem *wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę*, a nie obrazy przepisów prawa karnego materialnego.

Przykład 1 A: sąd w ustalonym stanie faktycznym wskazał, że oskarżony był obecny w barze „Kormoran” 15 stycznia 2020 r. i dokonał wówczas rozboju na pokrzywdzonym, posługując się nożem. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że powyższe fakty ustalone zostały w oparciu o zeznania świadka, uznane przez sąd za w pełni wiarygodne. Jeśli naszym zdaniem świadek nie był wiarygodny (bo np. był silnie skonfliktowany z oskarżonym i np. ze względu na okoliczności, nie mógł widzieć rzekomo „wyciągniętego i okazanego pokrzywdzonemu noża”), to wówczas kwestionujemy ocenę zeznań świadka. Zasadne byłoby zatem sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. w odniesieniu do dowodu z zeznań tego świadka. Formułowanie natomiast w takiej sytuacji zarzutu obrazy art. 280 § 2 k.k. byłoby nieprawidłowe, bo błąd sądu zaistniał na „wcześniejszym” etapie, tj. na płaszczyźnie oceny materiału dowodowego (a zatem przed ustaleniem – niebudzącego wątpliwości sądu – stanu faktycznego w sprawie i późniejszej subsumpcji tegoż stanu pod abstrakcyjną normę prawną).

Przykład 1B: sąd w ustalonym stanie faktycznym wskazał, że oskarżony był obecny w barze „Kormoran” 15 stycznia 2020 r. i dokonał wówczas rozboju na pokrzywdzonym, posługując się nożem. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że powyższe fakty sąd ustalił w oparciu o zeznania świadka, uznane przez sąd za w pełni wiarygodne źródło dowodowe, przy czym świadek mówił wyłącznie o obecności oskarżonego i nie mówił nic o wyciągnięciu noża, który został znaleziony przy oskarżonym. Sąd nie kwestionuje w uzasadnieniu wyroku, że w istocie brak jest w sprawie jakiegokolwiek dowodu, że

oskarżony nóż choćby okazał, a co więcej, aby nim się wówczas posługiwał. Sąd w uzasadnieniu wyroku, dokonując wykładni art. 280 § 2 k.k. napisał jednak, że „oskarżony miał przy sobie nóż i dlatego przypisany mu został ww. czyn przestępny”. W takim przypadku nie kwestionujemy zeznań świadka, uznając że błąd popełniony został na etapie odkodowywania normy prawnej art. 280 § 2 k.k., a zatem w odniesieniu do błędnej wykładni tej normy, polegającej na nieprawidłowym uznaniu, że już samo posiadanie noża jest tożsame ze znamieniem posługiwania się nim, o jakim mowa w dyspozycji art. 280 § 2 k.k.

Przykład 2A: sąd uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 226 § 1 k.k., dając w całości wiarę funkcjonariuszowi w odniesieniu do zachowania oskarżonego, przy czym funkcjonariusz nie został nigdy w postępowaniu przesłuchany, a całość ustaleń w tym zakresie poczyniona została wyłącznie w oparciu o treść notatki służbowej funkcjonariusza. Z uzasadnienia wyroku wprost wynika, że stan faktyczny sąd ustalił wyłącznie w oparciu o treść tego, co funkcjonariusz odnotował w treści ww. notatki. Jeśli kwestionujemy powyższe ustalenia faktyczne, to zasadnym byłoby sformułowanie zarzutu obrazy art. 174 k.p.k., polegającej na wadliwym zastąpieniu dowodu z zeznań funkcjonariusza treścią notatki służbowej, która nie stanowi dowodu i zgodnie z dyspozycją ww. normy, nie może być podstawą czynienia jakichkolwiek ustaleń faktycznych w sprawie. W takiej sytuacji konstruowanie zarzutu obrazy prawa materialnego, co do wadliwego zastosowania art. 226 § 1 k.k. byłoby błędne i zupełnie niepotrzebne (jako, że jest to oczywista konsekwencja błędu zaistniałego na płaszczyźnie procesowej – a zatem przed ustaleniem – niebudzącego wątpliwości sądu – stanu faktycznego w sprawie i późniejszej subsumpcji tegoż stanu pod abstrakcyjną normę prawną).

Przykład 2B: sąd uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 226 § 1 k.k., dając w całości wiarę funkcjonariuszowi w odniesieniu do zachowania oskarżonego, przy czym całość ustaleń w tym zakresie poczyniona została wyłącznie w oparciu o zeznania ww. funkcjonariusza. Jeśli kwestionujemy wiarygodność funkcjonariusza, to zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k., polegającej na wadliwej ocenie dowodu z zeznań funkcjonariusza

(np. niespójność, niezgodność z logiką etc.). W takiej sytuacji konstruowanie zarzutu obrazu prawa materialnego, co do wadliwego zastosowania art. 226 § 1 k.k. byłoby błędne i zupełnie niepotrzebne (albowiem podobnie jak w przykładzie 2A – jest to oczywista konsekwencja zaistniałego na płaszczyźnie procesowej błędu – a zatem przed ustaleniem – niebudzącego wątpliwości sądu – stanu faktycznego w sprawie i późniejszej subsumpcji tegoż stanu pod abstrakcyjną normę prawną).

Przykład 2C: sąd uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 226 § 1 k.k., dając w całości wiarę funkcjonariuszowi w odniesieniu do zachowania oskarżonego, przy czym całość ustaleń w tym zakresie poczyniona została wyłącznie w oparciu o zeznania ww. funkcjonariusza, który w zeznaniach wskazał m.in. że w czasie zdarzenia był „*po służbie i miał dzień wolny*”, czego sąd w sprawie nie kwestionował. Niezależnie zatem od ustaleń faktycznych, sąd nie mógł zastosować w tej sprawie normy art. 226 § 1 k.k., albowiem do znamion tego przestępstwa należy działanie przez funkcjonariusza „*podczas i w związku z pełnieniem czynności służbowych*”. W konsekwencji doszło do obrazu art. 226 § 1 k.k., poprzez jego niewłaściwie zastosowanie, w sytuacji gdy opis przypisanego oskarżonemu czynu nie był kompletny, albowiem nie zawierał wszystkich ustawowych znamion tego występkę, tj. znamienia działania „*podczas i w związku*” z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariusza.

Z powyższego wynika, że **zarzutów apelacyjnych nie da się skatalogować. Nie można przedstawić listy czy tabeli, jakie konkretnie zarzuty – materialne lub procesowe – należy standardowo formułować w określonych sytuacjach procesowych.** W orzecznictwie wypracowane zostały oczywiście pewne reguły, jakich zarzutów stawiać nie należy, jak np. zakwestionować błędnie ustaloną stronę podmiotową przestępstwa albo zastosowanie lub nie fakultatywnych instytucji prawa karnego materialnego (zob. rozdział 8). **Nie ma jednak zestawienia, które zastąpiłoby konieczność każdorazowej analizy *ad casum* określonej sytuacji procesowej w poszukiwaniu owego „pierwotnego uchybienia”.**

Powtarzając za K. Lipińskim, „w większości przypadków obrazu prawa materialnego odnosić będzie się do znamion strony przedmiotowej typu czynu

zabronionego”⁴³. Jednakże przyznać należy, że **konstruowanie zarzutów apelacyjnych w postępowaniu karnym nie jest proste. Wymaga rzeczywistego zrozumienia istoty tego, w którym momencie doszło do błędu i tym samym w jakich sytuacjach procesowych, który z zarzutów jest właściwy. W oczywisty sposób zależy to również zawsze od indywidualnych okoliczności danej sprawy, a dokładniej – tego, co sąd stwierdził w uzasadnieniu wyroku.** Uchybienie może być bowiem wynikiem błędnej oceny materiału dowodowego albo błędnego zastosowania prawa materialnego (bądź błędnej wykładni stosowanej przez sąd normy prawnej), jednak stwierdzenie, z którym przypadkiem mamy do czynienia zależy tylko i wyłącznie od tego, co zostało wskazane w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, nie od jakichś ogólnie ustalonych, abstrakcyjnych i zawsze powtarzalnych reguł w tym zakresie.

Można również powiedzieć, że **ustalenie owego „pierwotnego uchybienia” jest w istocie poszukiwaniem tego co było przyczyną popełnionego błędu** (jak do tego błędu doszło, czy sąd błędnie ocenił dowód z zeznań świadka bądź błędnie zinterpretował prawo materialne), **a co skutkiem tego uchybienia** (w wyniku błędnej oceny dowodów sąd błędnie zastosował prawo materialne, a przecież gdyby sąd prawidłowo ocenił dowody, to tym samym w ogóle nie stosowałby prawa materialnego wobec oskarżonego). Mylenie owego skutku z przyczyną jest tym, co w praktyce wiąże się z koncepcją tzw. „zarzutów mieszanych”⁴⁴, które zostały szerzej omówione w podrozdziale 7.4.

Pamiętaj! że przedmiotem zarzutu obrazu prawa materialnego może być wyłącznie naruszenie przez sąd jednoznacznego zakazu lub nakazu określonego postępowania. Jeśli natomiast przepisy Kodeksu karnego dają sądowi możliwość dokonania oceny i w zależności od jej wyniku, zastosowania lub nie określonego przepisu, wówczas formułowanie zarzutu obrazu

⁴³ K. Lipiński, *Łączenie i mieszanie zarzutów apelacji karnej*, Palestra 1/2020, s. 40.

⁴⁴ „(...) błędna z perspektywy prakseologicznej praktyka mieszania zarzutów ma miejsce jedynie wówczas, gdy skarżący jednocześnie powołuje przyczynę oraz skutek tego samego uchybienia”, *Ibidem*, s. 40.

prawa materialnego nie będzie prawidłowe. Przytoczenia wymaga ugruntowane stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym *obraza prawa materialnego może polegać na błędnej subsumcji określonego niekwestionowanego zachowania pod przepis prawa lub na zastosowaniu określonego przepisu prawa, pomimo że ustawa nie pozwala na jego zastosowanie lub niezastosowaniu określonego przepisu prawa gdy ustawa nakazuje jego zastosowanie. Natomiast gdy ustawa stwarza tylko możliwość zastosowania określonego przepisu prawa materialnego, to przez jego zastosowanie lub niezastosowanie, sąd nie dopuszcza się obrazy przepisu prawa materialnego*⁴⁵.

W konsekwencji, jeśli sąd I instancji błędnie – zdaniem apelującego – nie zastosował np. nadzwyczajnego złagodzenia kary w oparciu o art. 31 § 2 k.k. albo nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 1 k.k., wówczas właściwe będą zarzuty odnoszące się do błędu w ustaleniach faktycznych, nie zaś zarzuty obrazy prawa materialnego. Wynika to bowiem ze sformułowania ww. art. 31 § 2 k.k. oraz art. 42 § 1 k.k., w których ustawodawca pozostawił sądowi możliwość ich zastosowania, a nie nakaz (w przeciwieństwie np. do art. 42 § 2 k.k.).

Przykład 1: W sprawie o spowodowanie wypadku drogowego z art. 177 § 1 k.k., w wyroku skazującym, sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (który w tym przypadku jest orzekany fakultatywnie). Jeśli pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego uważa, że ze względu na okoliczności sprawy, środek ten powinien zostać orzeczony, wówczas w apelacji uzasadnione byłoby sformułowanie zarzutu obrazy art. 438 pkt 4 k.p.k., poprzez niesłuszne niezastosowanie przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wobec oskarżonego, choć z okoliczności sprawy wynikało, że prowadzenie pojazdu przez oskarżonego zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (mając na uwadze np. sposób jazdy oskarżonego/jego

⁴⁵ Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt IV KK 19/20.

zachowanie przed zdarzeniem/jego stan zdrowia etc.), co doprowadziło do wadliwego niezastosowania środka karnego z art. 42 § 1 k.k.⁴⁶

Przykład 2: W sprawie o spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości (art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178a § 1 k.k.), w wyroku skazującym, sąd nie orzekł zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (który w tym przypadku orzekany jest obligatoryjnie). Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w apelacji powinien sformułować, na podstawie art. 438 pkt 1a k.p.k., zarzut obrazy art. 42 § 2 k.k., poprzez jego błędne niezastosowanie, w sytuacji w której orzeczenie tego środka było obligatoryjne wobec faktu spowodowania wypadku drogowego przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości.

Przykład 3: w sprawie Anny B., oskarżonej o zabójstwo, wydano opinię psychiatryczną, z której wynika, że oskarżona działała w stanie poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym. Jeśli obrońca nie zgadza się z oceną sądu I instancji, który uznając oskarżoną za winną i jednocześnie prawidłowo ustalając ograniczoną poczytalność oskarżonej w stopniu znacznym, błędnie nie zastosował nadzwyczajnego złagodzenia orzeczonej wobec niej kary, w oparciu o art. 31 § 2 k.k., to w apelacji zasadne byłoby sformułowanie zarzutu z art. 438 pkt 4 k.p.k. Ustalenia sądu co do stopnia ograniczenia poczytalności oskarżonej są bowiem prawidłowe. Obrońca powinien natomiast zakwestionować ocenę sądu co do braku potrzeby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, nie zaś samych ustaleń, co do stopnia ograniczenia poczytalności oskarżonej. Błędne natomiast byłoby sformułowanie w takim stanie faktycznym zarzutu obrazy art. 31 § 2 k.k.

Kwestionowanie nieskorzystania przez sąd z możliwości zastosowania fakultatywnej instytucji prawa karnego omówione zostało w podrozdziale 9.11.

⁴⁶ Gdyby natomiast pełnomocnik kwestionował ustalenia faktyczne, w oparciu o które sąd stwierdził, że nie ma potrzeby orzeczenia środka karnego (albowiem przykładowo sąd błędnie ustalił, że pokrzywdzony przyczynił się do wypadku i dlatego nie orzekł środka karnego z art. 42 § 1 k.k.), wówczas zasadne byłoby sformułowanie zarzutu obrazy art. 438 pkt 3 k.p.k. w odniesieniu do wadliwie ustalonego przyczynienia się pokrzywdzonego.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) obraza prawa materialnego polega na jego wadliwym zastosowaniu lub niezastosowaniu, w orzeczeniu, które oparte jest na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie można więc mówić o naruszeniu przepisów prawa materialnego w sytuacji, gdy wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę (zob. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 16 listopada 2017 r., II KK 346/17, z dnia 4 stycznia 2017 r., III KK 379/16) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 16 października 2020 r., sygn. akt I KK 29/19**
- W judykaturze Sądu Najwyższego dominuje ugruntowane stanowisko, że z obrazą prawa materialnego mamy do czynienia wówczas, gdy do prawidłowo ustalonego stanu faktycznego sąd zastosował niewłaściwą kwalifikację prawną bądź dokonał wadliwej wykładni przepisów prawa materialnego. Sąd Najwyższy nie podziela poglądu, że przy zarzucie obrazy prawa materialnego za punkt wyjścia należy przyjmować nie to co Sąd ustalił, ale to co powinien ustalić (zob. post. SN z 16 listopada 2009 r., IV KK 105/09; post. SN z 3 września 2009 r., IV KK 295/09) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 569/19**
- (...) jeżeli wadliwość orzeczenia w aspekcie materialno – prawnym jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę lub naruszenia przepisów postępowania (obie sytuacje nie wystąpiły w rozpoznawanej sprawie), to nie można takiej sytuacji utożsamiać z obrazą prawa materialnego w rozumieniu art. 438 pkt 1 k.p.k., gdyż to może tylko polegać na błędnej wykładni zastosowanego przepisu, zastosowaniu przepisu niewłaściwego, a wreszcie na niezastosowaniu odpowiedniego przepisu w sytuacji, gdy jego zastosowanie jest obligatoryjne – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt II AKa 178/19**
- Na wstępie wypada przypomnieć, że – jak wynika z ukształtowanego orzecznictwa sądów – zarzut obrazy prawa materialnego jest uprawniony, gdy odwołujący nie kwestionuje treści ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd I instancji albo kwestionując je, jednocześnie zajmuje stanowisko, że nawet w stosunku do faktów, które sąd ustalił, prawo materialne

zastosowano wadliwie. Nie ma obrazy prawa materialnego, gdy wada orzeczenia jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych. Tylko niewłaściwa subsumcja niekwestionowanych ustaleń faktycznych pod konkretny przepis prawa materialnego (nadto inne postępowania wbrew wymogom obligatoryjnym) daje podstawę do formułowania zarzutu obrazy prawa materialnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 listopada 2019 r., sygn. akt II AKa 328/18, LEX nr 3056577

- *Apelacja jest skonstruowana nie w pełni prawidłowo, bo te same kwestie raz podnosi w ramach zarzutów obrazy prawa procesowego, a następnie powtarza pod postacią zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych. Przypomnieć więc trzeba, że zasadniczo winno stawiać się zarzut główny, tzw. pierwotny, a jego dalsze konsekwencje winny być wykazywane w uzasadnieniu środka odwoławczego. Dla przykładu wskazać można, że zarzut obrazy art. 7 k.p.k. wyprzedza zarzut dokonania błędu w ustaleniach faktycznych; wybór wiarygodnych źródeł dowodowych determinuje w istocie dalsze ustalenia. Odnośnie do naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. przypomnieć trzeba, że chodzi tu o wątpliwości sądu, a nie strony. Jeśli więc sąd nie powziął wątpliwości, nie wyraził ich, to nie mógł ich rozstrzygnąć ani na korzyść, ani na niekorzyść oskarżonego. Zarzut winien dotyczyć bądź to obrazy art. 7 k.p.k., bądź błędu w ustaleniach faktycznych pod postacią błędu dowolności. Jednakże wady konstrukcyjne środka zaskarżenia nie pozbawiają go skuteczności, dlatego Sąd Apelacyjny odniesie się do wszystkich zarzutów, chyba że wystarczające będzie odniesienie się do zarzutu głównego (pierwotnego) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 24 września 2019 r., sygn. akt II AKa 83/19, LEX nr 2978581*
- *(...) zarzut obrazy prawa materialnego zasadnie można podnosić jedynie wówczas, gdy nie kwestionuje się ustalonego w sprawie stanu faktycznego. Jest to zresztą rzecz oczywista, albowiem dopiero w chwili, gdy stan faktyczny sprawy zostanie ustalony w sposób bezsporny, można dokonywać prawno-karnej oceny zachowania sprawcy czynu będącego przedmiotem osądu. Nie można takiej oceny dokonywać wówczas, gdy sam przebieg zdarzenia i jego okoliczności faktyczne nie zostały w sposób jednoznaczny ustalone i są przez stronę procesu karnego kwestionowane – wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 2019 r., sygn. akt IV KK 143/18*

- W orzecznictwie Sądu Najwyższego i piśmiennictwie, konsekwentnie podkreśla się, iż obraza prawa materialnego polega na jego wadliwym zastosowaniu w orzeczeniu, które oparte jest na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie można więc mówić o obrazie prawa materialnego w sytuacji, gdy wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych, przyjętych za jego podstawę lub naruszenia przepisów procesowych (por. S. Zabłocki (w:) J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki – Kodeks postępowania karnego. Komentarz., Warszawa 2004, t. III, s. 111). Nie można zatem skutecznie postawić tego zarzutu – jak to czyni skarżący – z jednoczesnym kwestionowaniem przepisów postępowania w tym samym zakresie – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lutego 2019 r., sygn. akt V KK 3/19**
- W tej sytuacji należało już tylko odwołać się do ugruntowanego i nie budzącego wątpliwości tak w praktyce orzeczniczej jak i piśmiennictwie poglądu, że podniesienie zarzutu obrazy prawa materialnego dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy skarżący orzeczenie nie kwestionuje ustaleń faktycznych, które stanowiły podstawę zastosowania lub niezastosowania normy prawa materialnego – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 października 2018 r., sygn. akt II AKa 182/18**
- Do obrazy prawa materialnego dochodzi wówczas, gdy subsumcja ustalonego i niekwestionowanego stanu faktycznego pod przepis szczególnie przedmiotowej ustawy jest błędna – czy to poprzez nieprawidłowe określenie znamion przypisanego czynu wyszczególnionych w dyspozycji tego przepisu, czy to wadliwą jego interpretację i wykładnię, czy wreszcie gdy dochodzi do naruszenia w zakresie dotyczącym sankcji karnej za przestępstwo, gdy jej wymiar lub rodzaj nie jest przewidziany w zastosowanym przepisie. W wypadku kwestionowania prawidłowości przyjętej kwalifikacji prawnej czynu zarzut obrazy prawa materialnego podważa dokonaną przez Sąd wykładnię znamion strony przedmiotowej lub podmiotowej przypisanego przestępstwa. Zarzut błędnej wykładni znamion strony przedmiotowej odnosi się do opisu zabronionego zachowania zawartego w dyspozycji przepisu części szczególnej Kodeksu karnego lub innych ustaw karnych. „Zarzut obrazy prawa materialnego ma zawsze

samodzielny byt, a jego przesłanką jest twierdzenie skarżącego, że przy wydaniu orzeczenia doszło do wadliwej subsumcji ustalonych faktów pod przepis prawa materialnego, bądź też, że obrazą przepisu materialnego było zaniechanie takiej subsumcji” (tak przykładowo: postanowienie Sądu Najwyższego z 20.11.008 r., V KK 158/08, OSNwSK 2008, poz. 2340, LEX nr 531386) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 maja 2018 r., sygn. akt II AKz 32/18

- *Apelacja, już pod względem formalnym, jest nieprawidłowa, bowiem jednocześnie stawia zarzut obrazy prawa materialnego oraz przepisów postępowania, gdy tymczasem kwestia prawidłowości wykładni i zastosowania prawa materialnego staje się aktualna dopiero wówczas, gdy ustalenia faktyczne zostały dokonane i nie kwestionuje się ich zasadności. Kolejność i wynikająca z niej logika zarzutów powinna być zatem inna, bowiem dopiero wtedy, gdy zostanie ustalone, iż prawo procesowe nie zostało naruszone i sąd prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, zasadny staje się zarzut prawidłowości z kwalifikacji prawnej czynów – wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2015 r., sygn. akt WA 12/15*
- *Nie ma zatem wątpliwości, że chodzi o zarzut, o jakim mowa w art. 438 pkt 3 k.p.k., wszakże ustalenia o podmiotowej stronie czynu należą także do faktycznej podstawy orzeczenia. W orzecznictwie, a także w doktrynie, ugruntowane jest stanowisko, że obraza prawa materialnego polega na wadliwym jego zastosowaniu (lub niezastosowaniu) w orzeczeniu opartym na prawidłowych ustaleniach faktycznych. Nie ma więc obrazy prawa materialnego, gdy wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem błędnych ustaleń przyjętych za jego podstawę. Jeżeli zatem apelujący kwestionuje zastosowaną w wyroku kwalifikację prawną, ponieważ w działaniu oskarżonego dopatruje się innego od przypisanego mu przestępstwa (tak jak w tej sprawie, gdy obrońca dopatruje się wypełniania przez oskarżonego wyłącznie znamion przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. a nie usiłowania zabójstwa w zbiegu z art. z art. 157 § 1 k.k.) to podstawą takiej apelacji może być tylko zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku (art. 438 pkt 3 k.p.k.), a nie obrazy prawa materialnego (zob.m.in. wyrok SN z 23 lipca 1974 r., V KK 212/74, OSNKW 12/74, poz. 233; wyrok SN z 2 sierpnia 1978 r., I KR 155/78, OSNKW*

12/79, poz. 233; wyrok SN z 12 października 1983 r., V KRN 213/83, OSNPG 4/84, poz. 34) – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 grudnia 2014 r., sygn. akt II AKa 289/14**

- *Przecież instytucję przewidzianą w tym przepisie (art. 91 § 1 k.k. – uwaga autorki), jako instytucję prawa karnego materialnego, przy spełnieniu określonych przesłanek sąd nie może, lecz ma obowiązek zastosować. Zaniechanie więc stosowania instytucji prawa karnego materialnego, do respektowania której sąd jest zobowiązany stanowi więc obrazę i to zazwyczaj rażącą, prawa materialnego, uzasadniającą ingerencję w zaskarżony wyrok nawet poza granicami wniesionego środka odwoławczego* – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 21 października 2014 r., sygn. akt II AKa 22/14**

Ad. 7.2. Obraza prawa materialnego z art. 438 pkt 1 k.p.k. a obraza prawa materialnego z art. 438 pkt 1a k.p.k.

Ustawa nowelizująca Kodeks postępowania karnego z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1694) zmieniła w art. 1 pkt 74 lit. a – art. 438 pkt 1 k.p.k. w ten sposób, że do dotychczasowego brzmienia przepisu dodane zostało sformułowanie „w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu”. Nadto, w art. 1 pkt 74 lit. b ww. nowelizacji **wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego art. 438 pkt 1a**, zgodnie z którym orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia obrazy prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu⁴⁷.

Jak dotychczas brak jest stanowiska orzeczniczego, z którego jednoznacznie wynikałyby zasady formułowania zarzutów z art. 438 pkt 1 k.p.k. oraz z art. 438 pkt 1a k.p.k. Zgadzam się z poglądem D. Świeckiego, zgodnie z którym *dokonaną nowelizację należy ocenić krytycznie. Przede wszystkim*

⁴⁷ Omawiana nowelizacja weszła w życie z dniem 5 października 2019 r. i od tego czasu w Kodeks postępowania karnego funkcjonuje podział podstawy odwoławczej obrazy prawa materialnego na te uchybienia, które odnoszą się do kwalifikacji prawnej czynu oraz te, które dotyczą innych (aniżeli kwalifikacja) kwestii z zakresu prawa karnego materialnego.

prowadzi ona do powstania wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu stosowania tych dwóch podstaw odwoławczych. Dotychczasowy stan prawny nie budził takich wątpliwości z uwagi na wypracowane w orzecznictwie i doktrynie rozumienie pojęcia obrazy prawa materialnego oraz istniejący obowiązek korygowania naruszenia tego prawa na zarzut odwoławczy lub z urzędu. Za odejściem od utrwalonego od lat rozumienia tego pojęcia i zakresu jego stosowania nie przemawiają żadne dobre racje. Nie są nimi względy dotyczące praktyki stosowania prawa odnoszące się do kwestionowania przez praktyków potrzeby zmiany orzeczeń przez sądy odwoławcze z powodu naruszenia prawa materialnego, gdy stwierdzone uchybienie nie rzutuje na sytuację prawną oskarżonego. Argument o nadmiernym formalizmie zawarty w uzasadnieniu projektu nowelizacji nie jest przekonujący. Prawo materialne ze swej istoty jest sformalizowane i powinno takim pozostać, co oznacza, że należy je bezwzględnie prawidłowo stosować. Wspomniana nowelizacja prowadzi do relatywizacji obrazy prawa materialnego, gdyż niektóre naruszenia tego prawa nie mogą być skorygowane z urzędu ani na zarzut, gdyż ex lege wyłącza się taką możliwość. Powoduje to, że w obrocie prawnym pozostaną orzeczenia obarczone błędem w stosowaniu prawa materialnego tylko dlatego, że ze względów praktycznych zmiana wadliwego orzeczenia byłaby „nadmiernym formalizmem”. Ponadto zauważyć należy, że art. 438 pkt 1a został wadliwie skonstruowany, co tylko pogłębi wątpliwości interpretacyjne⁴⁸.

Odnosnie do tego kiedy należy formułować zarzuty z art. 438 pkt 1 k.p.k., Z. Kapiński wskazuje, że jako podstawę prawną zarzutu obrazy prawa materialnego wskazujemy art. 438 pkt 1 KK w każdym wypadku, gdy stwierdzamy zarzut obrazy prawa materialnego z Części szczególnej KK poprzez jego błędne zastosowanie lub niezastosowanie w zakresie prawno-karnej oceny czynu zarzucanego lub przypisanego oskarżonemu, czyli wówczas gdy kwestionujemy kwalifikację prawną czynu odnośnie tego czy ustalone przez sąd meriti zachowanie

⁴⁸ D. Świecki, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 438 k.p.k., Lex/el 2022, teza 6.

wyczerpuje czy nie znamiona czynu karalnego określonego w Części szczególnej KK lub też innej ustawie karnej⁴⁹.

Mając powyższe na uwadze, **jeśli zdaniem apelującego doszło do obrazu prawa materialnego w odniesieniu do kwalifikacji prawnej czynów, ujętych w części szczególnej Kodeksu karnego albo innych karnych ustaw szczególnych, wówczas zasadnym jest sformułowanie zarzutu z art. 438 pkt 1 k.p.k.**

Przykład 1: Sąd uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 286 § 1 k.k., przy czym w opisie czynu przypisanego w wyroku zabrakło wskazania znamienia „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. W takiej sytuacji – w apelacji obrońcy – właściwym byłoby sformułowanie zarzutu z art. 438 pkt 1 k.k., polegającego na tym, że sąd przypisał winę za czyn niezawierający wymaganego ustawą kompletu znamion przestępstwa oszustwa.

Przykład 2: Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że oskarżony dokonał rozboju kwalifikowanego, posługując się poduszką. W takiej sytuacji właściwym – z perspektywy obrońcy – byłoby sformułowanie zarzutu z art. 438 pkt 1 k.p.k., tj. obrazu art. 280 § 2 k.k., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na wadliwym uznaniu, przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym, że poduszka jest przedmiotem podobnie niebezpiecznym do broni palnej lub noża w rozumieniu art. 280 § 2 k.k.

To co komplikuje nieco w praktyce dokonanie wyboru między podstawą z art. 438 pkt 1 k.p.k. a art. 438 pkt 1a k.p.k. to fakt, że elementem kwalifikacji prawnej czynu jest nie tylko przepis części szczególnej (np. art. 286 § 1 k.k. czy art. 278 § 1 k.k.), ale **również niektóre przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, które bezpośrednio wpływają na oddanie pełnego obrazu zdarzenia rozumianego jako komplet znamion i okoliczności prawnokarnych, ujętych w opisie czynu przypisanego sprawcy.** Takimi przepisami będą na przykład: art. 12 § 1 k.k. (czyn ciągły), art. 13 § 1 k.k. (usiłowanie), 15 § 1 k.k. (dobrowolne odstąpienie od dokonania lub zapobiegnięcie

⁴⁹ Z. Kapiński, *Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy*, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 13.

skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego), art. 23 § 1 k.k. (czynny żal współdziałającego), art. 25 § 1 k.k. (obrona konieczna), art. 31 § 1 i 2 k.k. (niepoczytalności i poczytalność w znacznym stopniu ograniczona). Bez uwzględnienia zatem w kwalifikacji prawnej przypisanego czynu art. 25 § 1 k.k. (a zatem działania przez sprawcę w warunkach obrony koniecznej) czy też usiłowania z art. 13 § 1 k.k., wydane rozstrzygnięcie nie oddawałoby rzeczywistej istoty popełnionego czynu.

Przytaczając za D. Świeckim, **„rozumienie pojęcia kwalifikacji prawnej czynu może być dwojakie**. W wąskim znaczeniu kwalifikacja prawna czynu to przyporządkowanie go przepisowi ustawy karnej określającemu przestępstwo w części szczególnej Kodeksu karnego lub innych ustaw karnych. **Natomiast szerokie znaczenie kwalifikacji prawnej czynu to także zastosowanie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, modyfikujących odpowiedzialność karną za przestępstwo**. Na gruncie art. 399 § 1 przyjęto szerokie rozumienie kwalifikacji prawnej czynu, gdyż obowiązek sądu uprzedzenia o możliwości jej zmiany dotyczy nie tylko przepisu określającego typ przestępstwa, ale także przepisów części ogólnej, np. zastosowania kumulatywnej kwalifikacji (art. 11 § 2 k.k.), przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego (art. 12 k.k.), chuligańskiego charakteru czynu (art. 57a § 1 k.k.), recydywy z art. 64 § 1 i 2 k.k.”⁵⁰.

Na tle omawianej kwestii w doktrynie prawa karnego dostrzec można **dwa odmienne stanowiska**. Według Z. Kapińskiego „należy w tym miejscu powtórzyć, że chodzi o wąskie a nie o szerokie rozumienie pojęcia kwalifikacji prawnej czynu. Jest bowiem oczywiste, że w Części ogólnej KK znajdują się również inne przepisy, które są elementem kwalifikacji prawnej czynu i dotyczy to chociażby art. 64 KK, ale uznać należy, że nie odnoszą się one do kwestii znamion czynu, tylko do zaostrzenia odpowiedzialności karnej z uwagi

⁵⁰ D. Świecki, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 438 k.p.k., Lex/el 2022, teza 9, który dodatkowo przywołuje orzecznictwo w odniesieniu do zagadnienia szerokiego rozumienia pojęcia kwalifikacja prawna czynu na tle art. 399 § 1 k.p.k., w tym: wyrok Sądu Najwyższego z 5 lutego 1973 r., sygn. akt I KR 339/72; wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 1974 r., sygn. akt V KRN 6/74; wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 1983 r., sygn. akt II KR 347/82; wyrok Sądu Najwyższego składu 7 Sędziów z 16 marca 1984 r., sygn. akt RNw 2/84 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 1983 r., sygn. akt I KR 162/83.

*na uprzednią karalność oskarżonego i fakt odbywania kary pozbawienia wolności*⁵¹.

Odmienny pogląd w tej kwestii zajmuje D. Świecki, który wskazuje, że „(...) podstawa odwoławcza z art. 438 pkt 1 odnosi się do obrazu przepisów prawa materialnego dotyczących szeroko rozumianej kwalifikacji prawnej czynu. Tym określeniem objęte są przepisy Kodeksu karnego odnoszące się do elementów struktury przestępstwa, takich jak bezprawność (kontratypy, np. obrona konieczna – art. 25 k.k.), karalność czy zawinienie (niepoczytalność, stan ograniczonej poczytalności w stopniu znacznym, błąd), a także przepisy normujące instytucje prawne modyfikujące odpowiedzialność karną, takie jak kumulatywna kwalifikacja prawna czynu (art. 11 § 2 k.k.), czyn ciągły (art. 12 k.k.), chuligański charakter czynu (art. 57a § 1 k.k.), recydywa (art. 64 § 1 i 2 k.k.)”⁵².

Podkreślenia jednocześnie wymaga, że w odniesieniu do art. 64 § 1 lub 2 k.k. również S. Zabłocki wskazuje, że naruszenie tego przepisu odnosi się do kwalifikacji prawnej i powinno zostać oparte na art. 438 pkt 1 k.p.k. (nie zaś na art. 438 pkt 1a k.p.k.)⁵³. Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z 17 stycznia 2012 r. stwierdził, że skazanie w warunkach recydywy specjalnej, a więc ze wskazaniem w opisie czynu i jego kwalifikacji prawnej przesłanek z art. 64 k.k., jest rozstrzygnięciem co do winy (a nie tylko co do kary)⁵⁴.

W mojej ocenie **zarzut z art. 438 pkt 1 k.p.k. zasadny będzie w odniesieniu do przepisów prawa materialnego z części ogólnej Kodeksu karnego zawsze wtedy, kiedy przepis części ogólnej Kodeksu karnego ma istotne znaczenie dla oddania istoty czynu przypisanego sprawcy, zaś jego pominięcie wypaczałoby charakter tegoż czynu**. W omawianej kwestii nie ma jednak póki co jednomyślności, o czym należy pamiętać.

⁵¹ Z. Kapiński, *Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy*, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 14.

⁵² D. Świecki, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 438 k.p.k., Lex/el 2022, teza 11.

⁵³ S. Zabłocki, [w:] *Kodeks postępowania karnego. Tom IV*, red. R.A. Stefański i S. Zabłocki, Warszawa 2021, s. 290.

⁵⁴ Wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt V KK 388/11.

Podsumowując powyższe uwagi na przykładzie art. 64 § 2 k.k., skoro art. 64 § 2 k.k. wskazywany jest zarówno w podstawie prawnej skazania, jak i wymiaru kary, to jeśli apelujący twierdzi, że sąd nieprawidłowo przyjął wystąpienie recydywy specjalnej z art. 64 § 2 k.k., to w mojej ocenie słuszny jest pogląd, że uzasadnione będzie sformułowanie zarzutu obrazy prawa materialnego w postaci art. 64 § 2 k.k. w oparciu o art. 438 pkt 1 k.p.k. Jeśli natomiast sąd wymierzył karę wbrew obostrzeniom z art. 64 § 2 k.k., wówczas zasadne będzie sformułowanie zarzutu obrazy prawa materialnego w postaci art. 64 § 2 k.k. jednakże w oparciu o art. 438 pkt 1a k.p.k. (albowiem kwestia wymiaru kary, nie zaś zastosowania tej instytucji prawa karnego materialnego, nie dotyczy bezpośrednio kwalifikacji prawnej przypisanego czynu).

W każdym zaś inny przypadku – aniżeli analizowanej powyżej – obrazy przepisów prawa materialnego z części ogólnej Kodeksu karnego, np. błędnie zastosowanych lub niezastosowanych przepisów art. 42 § 1a pkt 1 k.k. albo art. 44 § 1 k.k. itd., właściwe będzie sformułowanie zarzutu z art. 438 pkt 1a k.p.k. Formułując ten zarzut należy pamiętać o konieczności wskazania, że na skutek wskazywanej obrazy prawa materialnego orzeczenie nie odpowiada prawu, co wskazane zostało powyżej (zob. początek rozdziału 6.2.2. niniejszej publikacji).

Przykład 1: Sąd w wyroku nie uwzględnił zgłoszonego przez oskarżyciela posiłkowego żądania z art. 46 § 1 k.k. W takiej sytuacji właściwym byłoby sformułowanie w apelacji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego zarzutu w oparciu o art. 438 pkt 1a k.p.k., tj. zarzutu obrazy art. 46 § 1 k.k., poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji w której orzeczenie tego środka kompensacyjnego było obligatoryjne.

Przykład 2: Sąd nieprawidłowo ustalił, że wobec oskarżonego spełnione zostały przesłanki recydywy z art. 64 § 2 k.k. i w konsekwencji, nieprawidłowo uwzględnił art. 64 § 2 k.k. zarówno w opisie czynu, jak i w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu oraz wymiarze orzeczonej wobec niego kary. W takiej sytuacji, w apelacji obrony, w mojej ocenie właściwe byłoby sformułowanie zarzutu w oparciu o art. 438 pkt 1 k.p.k., tj. zarzutu obrazy art. 64 § 2 k.k., poprzez jego wadliwe zastosowanie, w sytuacji braku spełnienia ustawowych przesłanek recydywy specjalnej.

Ad. 7.3. Jakie błędy procesowe – zgodnie ze stanowiskiem judykatury – nie stanowią obrazy prawa materialnego?

Jak wskazano powyżej, zarzutów apelacyjnych nie da się skatalogować. W orzecznictwie wypracowane zostały natomiast pewne reguły, jakich zarzutów stawiać nie należy (zob. rozdział 8). W niniejszym podrozdziale przytoczone zostaną tezy orzecznicze, wskazując w jakich przypadkach nie należy formułować zarzutów obrazy prawa materialnego.

- *Zarzut obrazy prawa materialnego nie może dotyczyć dyrektyw sądowego wymiaru kary zawartych w art. 53 § 1 i art. 54 § 1 k.k.⁵⁵ oraz okoliczności uwzględnianych przy wymiarze kary lub środków karnych wymienionych w art. 53 § 2 k.k. w zw. z art. 56 k.k. Przepisy te nie mają charakteru norm stanowczych, bo nie zobowiązują sądu do określonego zachowania, a pozostawiają swobodę orzekania co do zastosowanego stopnia represji karnej – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 marca 2020 r., sygn. akt II AKa 243/19, LEX nr 3108304*
- (...) *obraza prawa materialnego może polegać na błędnej subsumcji określonego niekwestionowanego zachowania pod przepis prawa lub na zastosowaniu określonego przepisu prawa, pomimo że ustawa nie pozwala na jego zastosowanie lub niezastosowaniu określonego przepisu prawa gdy ustawa nakazuje jego zastosowanie. Natomiast gdy ustawa stwarza tylko możliwość zastosowania określonego przepisu prawa materialnego, to przez jego zastosowanie lub niezastosowanie, sąd nie dopuszcza się obrazy przepisu prawa materialnego (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2006 r., V KK 368/06, R – OSNKW, poz. 2566) – postanowienie Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt IV KK 19/20*
- *Zarzut taki jest uprawniony jedynie wtedy, gdy ma charakter samoistny, a naruszenie prawa materialnego polega na jego wadliwym zastosowaniu (bądź niezastosowaniu) w orzeczeniu, które jest oparte na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Natomiast jeżeli wadliwość orzeczenia w aspekcie materialno – prawnym jest wynikiem błędnych*

⁵⁵ Dla ułatwienia autorka zaznaczyła zagadnienia, do których odnoszą się przytaczane orzeczenia.

ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę lub naruszenia przepisów postępowania (obie sytuacje nie wystąpiły w rozpoznawanej sprawie), to nie można takiej sytuacji utożsamiać z obrazą prawa materialnego w rozumieniu art. 438 pkt 1 k.p.k., gdyż to może tylko polegać na błędnej wykładni zastosowanego przepisu, zastosowaniu przepisu niewłaściwego, a wreszcie na niezastosowaniu odpowiedniego przepisu w sytuacji, gdy jego zastosowanie jest obligatoryjne – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt II AKa 178/19

- (...) z przepisu **art. 624 k.p.k.** wynika, że sąd może zwolnić od zapłaty kosztów sądowych, a więc zwolnienie to nie następuje obligatoryjnie, a fakultatywnie na podstawie swobodnej oceny orzekającego sądu. Tym samym nie jest prawidłowe stawianie zarzutu w ramach obrazy prawa materialnego z art. 438 pkt 1 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKa 133/19**
- (...) wynikająca z **art. 69 § 1 k.k.** instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary ma charakter fakultatywny, co oznacza, że zaniechanie jej zastosowania nie może stanowić obrazy prawa materialnego. Sąd bowiem jedynie może, ale nie musi, zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności – **wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 2019 r., sygn. akt V KK 71/18**
- Do wysunięcia takiego zarzutu (z art. 60 § 3 k.k. – uwaga autorki) uprawniałaby sytuacja, w której Sąd ustaliłby, że oskarżony ujawnił wobec organu ścigania informacje dotyczące osób współdziałających w przestępstwie oraz istotne okoliczności jego popełnienia, i – pomimo tego ustalenia – nie zastosowałby unormowania art. 60 § 3 k.k. Tymczasem, w sprawie takiego ustalenia nie przyjęto. W istocie więc, rozważany zarzut sytuuje się w kategorii zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, leżących u podstaw rozstrzygnięcia – błędu polegającego na nieustaleniu, że w wyjaśnieniach oskarżonego doszło do ujawnienia wszystkich uczestniczących w przestępstwie osób oraz istotnych okoliczności jego popełnienia – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2016 r., sygn. akt V KK 309/16**
- Przepis **art. 37a k.k.** nie ma charakteru normy stanowczej (zawierającej nakaz lub zakaz określonego postąpienia), zatem jego

obraza – w rozumieniu art. 438 pkt 1 k.p.k. – nie wchodzi w grę. Zgodnie bowiem z ugruntowanym od lat orzecznictwem nie stanowi obrazy prawa materialnego generalnie samo nieskorzystanie przez sąd z przysługujących mu możliwości określonego rozstrzygnięcia, a więc gdy nie skorzystał on jedynie z fakultatywnie przewidzianych rozstrzygnięć (tak np. wyrok SN z dnia 26 kwietnia 1977 r., I KR 65/77, OSNPG 1977, Nr 10, poz. 90, postanowienia SN: z dnia 25 lipca 2005 r., V KK 61/05, OSNKW, poz. 1412, s. 700–701, z dnia 21 grudnia 2006 r., V KK 368/06, LEX nr 324685, z dnia 7 października 2010 r., II KK 246/10, LEX nr 844430, czy z dnia 22 grudnia 2010 r., II KK 297/10, LEX nr 844434) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt II AKa 42/16**

- Zarzut obrazy prawa materialnego – co do zasady – nie może dotyczyć dyrektyw ustalania wysokości stawki dziennej grzywny, podobnie jak i sądowego wymiaru kary wskazanych w **art. 53 § 1 k.k.** oraz okoliczności uwzględnianych przy wymiarze kary lub środków karnych wymienionych w **art. 53 § 2 k.k. w zw. z art. 56 k.k.** Przepisy te nie mają bowiem charakteru norm stanowczych, gdyż nie zobowiązują sądu do określonego zachowania. Natomiast pozostawiają sądowi swobodę orzekania w zakresie zastosowanego stopnia represji karnej. W wypadku więc kwestionowania przez skarżącego wymiaru kary lub środków karnych z uwagi na nieprawidłową ocenę zawartych w **art. 33 § 3 k.k.** lub **art. 53 § 1 k.k.** dyrektyw albo okoliczności dotyczących wymiaru kary, zarzut odwoławczy powinien dotyczyć rażącej niewspółmierności kary lub środka karnego. Jedynie w wypadku, gdy sąd przy wymierzaniu kary w ogóle pominął dyrektywy jej wymiaru, można postawić zarzut obrazy prawa materialnego, co w przypadku oskarżonego R. G. nie miało miejsca (por. D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego – komentarz, Warszawa 2015 r., wydanie 2, tom II, s. 118–122) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 22 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 112/15**
- (...) jeśli skarżący kwestionuje **prawidłowość ustalenia zamiaru z jakim działał oskarżony** to w istocie kwestionuje zasadniczy w procesie karnym element ustaleń faktycznych, a nie błędnej oceny materialnoprawnej czynu przypisanego oskarżonemu, bo dopiero uznanie, iż doszło do błędnego ustalenia faktów związanych z zamiarem z jakim

działał sprawca upoważnia do podniesienia że nieprawidłowo dokonano subsumcji jego zachowania pod konkretny przepis prawa karnego materialnego – wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 45/16

- W tym miejscu należy również zwrócić uwagę skarżącemu, że nieprawidłowo opisał zaistniałe w wyroku uchybienie, które nie stanowi obrazy prawa materialnego. Z taką obrazą mamy bowiem do czynienia jeżeli zachodzi niezgodność pomiędzy ustaleniami faktycznymi a zastosowanym przepisem ustawy karnej, na skutek błędnej subsumcji ustaleń pod właściwy przepis ustawy. Podkreślić przy tym trzeba, że obraza prawa materialnego może wystąpić z różnych przyczyn, a w szczególności polegać może na błędnej wykładni danego przepisu, na zastosowaniu nieodpowiedniego przepisu lub zastosowaniu go w nieodpowiedni sposób, bądź też na zastosowaniu przepisu pomimo zakazu określonego rozstrzygnięcia lub niezastosowaniu normy, której stosowanie było obowiązkowe. (wyrok SN z 18 czerwca 2003 r. sygn. IV KKN 101/00, publ. Prok.i Pr.-wkł. 2004/5/9). W sytuacji natomiast, **gdy sąd wykaże się jedynie brakiem precyzji przy oznaczaniu normy prawnej**, polegającej na pominięciu punktu w danym paragrafie, prawidłowe jest podniesienie zarzutu naruszenia art. 413 § 1 pkt 6 k.p.k., a więc obrazy prawa procesowego, która miała wpływ na treść wyroku. Przepis ten nakazuje sądowi wskazanie w wyroku zastosowanych przepisów ustawy karnej, a więc dokładnego określenia podstawy prawnej rozstrzygnięcia – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II AKa 497/14**
- Przepis **art. 69§1 k.k.** ma charakter fakultatywny, ponieważ daje sądowi możliwość zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary gdy ziszczą się wymienione tam przesłanki. Nieskorzystanie z tej możliwości nie może więc być podstawą skutecznego zarzutu odwoławczego o jakim mowa w art. 438 pkt 1 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 października 2014 r., sygn. akt II AKa 303/14**
- (...) przepisy **art. 53 § 1 i 2 k.k.** stanowią dyrektywę sądowego wymiaru kary, a zatem nie mogą stać się podstawą zarzutu obrazy prawa materialnego. Z kolei w **art. 60 § 1 k.k. jak i w § 2** tego przepisu przewidziano możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, a to oznacza,

iz przepisy te nie mogą stać się podstawą zarzutu obrazy prawa materialnego, skoro nie obligowały sądu do określonego postąpienia – postanowienie Sądu Najwyższego z 7 października 2011 r., sygn. akt III KK 36/11

- *Obraza prawa materialnego nie polega na tym, że sąd nie zastosował jakiejś konstrukcji prawnej, jeżeli nie miał takiego obowiązku – postanowienie Sądu Najwyższego z 22 grudnia 2010 r., sygn. akt II KK 279/10*

Ad. 7.4. Niedopuszczalność konstruowania tzw. zarzutów „mieszanych”

W części 6.2.2.1. niniejszej publikacji zasygnalizowane zostało, że jeśli apelujący formułuje zarzut obrazy prawa materialnego, to dla sądu odwoławczego jasne jest, że nie kwestionuje tym samym ani ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd I instancji, ani przypisanej oskarżonemu winy. Dla zachowania „samokontroli” przez zdających sugerowane wręcz jest wpisywanie do zarzutu obrazy prawa materialnego sformułowania „przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym”, aby dzięki takiemu działaniu egzaminowany samodzielnie zweryfikował swój pogląd, czy rzeczywiście zarzut materialny jest poprawny i czy nie kwestionuje w swojej apelacji, w innym zarzucie (np. procesowym) tych samych kwestii, do których odnosi się zarzut z art. 438 pkt 1 albo 1a k.p.k.

Zarzutów opartych na art. 438 pkt 1 k.p.k. nie należy łączyć z zarzutami opartymi na art. 438 pkt 2 lub 3 k.p.k., albowiem – mając w pamięci, że ich przedmiotem są uchybienia pierwotne, popełnione przez sąd – zarzuty te stawiamy przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym. Zgoła odmiennie jest przy zarzutach z art. 438 pkt 1a k.p.k., albowiem dotyczą one wypadków obrazy prawa materialnego innych, niż odnoszących się do przyjętej kwalifikacji prawnej. Przykładem może być co do zasady sformułowany przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego zarzut obrazy art. 44 § 1 k.k., poprzez nieorzeczenie przepadku, mimo obowiązku wynikającego z dyspozycji ww. przepisu. Zarzut obrazy tego przepisu można sformułować nawet wówczas, gdy kwestionujemy stan faktyczny ustalony przez sąd. To z kolei prowadzi do konkluzji, że o ile zarzuty z art. 438 pkt 1 k.p.k. formułujemy wtedy, gdy nie kwestionujemy

ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd i nie łączymy ich z zarzutami opartymi na art. 438 pkt 3 k.p.k., to zarzuty z art. 438 pkt 1a k.p.k. (jako nie odnoszące się do kwalifikacji prawnej), możemy łączyć z zarzutami błędnych ustaleń faktycznych, albowiem treść tych zarzutów z reguły wzajemnie się nie wyklucza i nie są one ze sobą sprzeczne⁵⁶.

W odniesieniu do istoty „zarzutów mieszanych” warto odwołać się do stanowiska Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który w wyroku z 21 maja 2014 r. wskazał, że od dawna ugruntowany jest pogląd, że obraza prawa materialnego polega na jego wadliwym zastosowaniu lub niezastosowaniu w orzeczeniu, które jest oparte na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie ma obrazy prawa materialnego, gdy wadliwość orzeczenia jest wynikiem błędnych ocen i ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę. **W razie oparcia apelacji na zarzutach mieszanych, odpowiadających kilku przyczynom odwoławczym, jako podstawę skargi należy podawać zarzut pierwotny, a nie wtórny stanowiący pochodną pierwotnego. Nie jest właściwe powołanie kilku zarzutów, gdy jeden z nich jest konsekwencją drugiego albo gdy wzajemnie się wykluczają.** Jeśli apelujący kwestionuje przyjętą kwalifikację prawną, bo w działaniu oskarżonego dopatruje się innego od przypisanego mu działania, to podstawą apelacji jest zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, a nie zarzut obrazy prawa materialnego⁵⁷.

⁵⁶ Jak wskazuje D. Świecki, „zarzut obrazy prawa materialnego można postawić obok zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, gdy obraza prawa materialnego dotyczy nie kwalifikacji prawnej czynu, ale naruszenia innych przepisów prawa materialnego w zakresie środków reakcji karnej na przestępstwo, np. w apelacji oskarżyciel może postawić zarzut nieorzeczenia obligatoryjnego przypadku, o którym mowa w art. 44 § 1 k.k. (obraza prawa materialnego), i zarzut błędu w ustaleniach faktycznych w zakresie przyjęcia, że czyn oskarżonego stanowi wypadek mniejszej wagi. Także obok zarzutu obrazy prawa materialnego można postawić zarzut naruszenia przepisów procesowych, gdy naruszenie prawa materialnego dotyczy nie kwalifikacji prawnej czynu, ale wadliwego zastosowania prawa co do innych rozstrzygnięć, a niezależnie od tego skarżący może kwestionować prawidłowość przebiegu postępowania karnego. Podobnie można postawić zarzut rażącej niewspółmierności kary, gdy skarżący kwestionuje nie kwalifikację prawną czynu, ale naruszenie prawa materialnego w innym zakresie, np. co do środka karnego, a oprócz tego wymiar samej kary. Jednak gdy kara lub środek karny zostały wymierzone powyżej lub poniżej ustawowego progu, zarzut odwoławczy powinien dotyczyć obrazy prawa materialnego, a nie rażącej niewspółmierności kary lub środka karnego” (D. Świecki, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 438 k.p.k., Lex/el 2022, teza 19).

⁵⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 maja 2014 r., sygn. akt II AKa 79/14.

Podobnie istotę zarzutów mieszanych wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 28 kwietnia 2015 r., w którym stwierdził, że (...) **w razie bowiem oparcia skargi odwoławczej na zarzutach mieszanych, tj. twierdzeniu odpowiadającym kilku podstawom odwoławczym, jako podstawę odwołania należy powoływać zarzut tzw. pierwotny, a nie wtórny, stanowiący pochodną usterki pierwotnej.** Nieodpowiednie jest bowiem powoływanie kilku zarzutów, gdy jeden z nich jest konsekwencją innego bądź gdy zarzuty te wzajemnie się wykluczają. Jest to sytuacja zarzutu odwoławczego o charakterze „mieszanym”, gdy jeden zarzut powoduje kolejne, aż po niesprawiedliwość wyroku. Zbędne jest zatem przyjmowanie za podstawę apelacji wszystkich trzech przyczyn odwoławczych (jak uczyniono to w apelacji obrońcy oskarżonego M. J.), bo wystarczy przyjąć jedną z nich, a to pierwotną. Stwierdzenie jej spowodowałoby bowiem uwzględnienie apelacji i przeciwnie – oddalenie zarzutu pierwotnego skutkowałoby pominięciem rozważań odnośnie do zarzutów wtórnych (...) ⁵⁸.

Pamiętaj! Jeśli z zadania egzaminacyjnego wynika, że sąd przypisał w wyroku winę oskarżonemu za różne przestępstwa, to sformułowanie wobec jednego z czynów wyroku zarzutu obrazy prawa materialnego, a wobec innego zarzutu obrazy prawa procesowego – nie będzie przykładem konstruowania „zarzutów mieszanych”. Te bowiem dotyczą tej samej okoliczności i mówiąc obrazowo, dotyczą sytuacji, w której uchybienia z poszczególnych zarzutów pozostają ze sobą w związku przyczynowym – jedno z uchybień jest bowiem naturalną konsekwencją drugiego. Jednoczesne formułowanie zarzutów z wszystkich podstaw odwoławczych z art. 438 k.p.k. wobec różnych czynów nie pozostaje ze sobą w żadnym logicznym związku, bo zwyczajnie dotyczy odmiennych czynów i w związku z tym odmiennych „działań” sądu, podjętych odrębnie dla każdego z czynów.

Powyższe uwagi zobrazowane zostaną na przykładach.

⁵⁸ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II AKa 41/15.

Przykład 1 A (negatywny): sąd w ustalonym stanie faktycznym wskazał, że oskarżony był obecny w barze „Kormoran” 15 stycznia 2020 r. i dokonał wówczas rozboju na pokrzywdzonym, posługując się nożem. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że powyższe fakty sąd ustalił w oparciu o zeznania świadka, uznane przez sąd za w pełni wiarygodne źródło dowodowe. Jeśli naszym zdaniem świadek nie był wiarygodny (bo np. był silnie skonfliktowany z oskarżonym i nie mógł widzieć rzekomo „wyciągniętego i okazanego pokrzywdzonemu noża”), to wówczas kwestionujemy ocenę zeznań świadka, a zatem zasadnym jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. w odniesieniu do dowodu w postaci zeznań ww. świadka. Przykładem błędnie sformułowanego zarzutu „mieszanego” byłoby dodatkowe skonstruowanie w apelacji zarzutu obrazy prawa materialnego, polegającego na niewłaściwym zastosowaniu art. 280 § 2 k.k.

Przykład 1B (negatywny): sąd w ustalonym stanie faktycznym wskazał, że oskarżony był obecny w barze „Kormoran” 15 stycznia 2020 r. i dokonał wówczas rozboju na pokrzywdzonym, posługując się nożem. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że powyższe fakty sąd ustalił w oparciu o zeznania świadka, uznane za wiarygodne, przy czym świadek mówił wyłącznie o obecności oskarżonego i nie mówił nic o wyciągnięciu noża, który został znaleziony przy oskarżonym. Brak jest zatem jakiegokolwiek dowodu, że oskarżony nóż choćby okazał, a co więcej, aby nim się wówczas posługiwał. Sąd w uzasadnieniu wyroku, dokonując wykładni art. 280 § 2 k.k. napisał jednak, że „oskarżony miał przy sobie nóż i dlatego przypisany mu został ww. czyn przestępny”. W takim przypadku nie kwestionujemy zeznań świadka, uznając że błąd popełniony został na etapie odkodowywania normy prawnej art. 280 § 2 k.k., a zatem w odniesieniu do błędnej wykładni tej normy, polegającej na wadliwym uznaniu, że posiadanie noża jest tożsame ze znamieniem posługiwania się nim, o jakim mowa w dyspozycji art. 280 § 2 k.k. Przykładem błędnie sformułowanego zarzutu mieszanego byłoby dodatkowe skonstruowanie zarzutu obrazy prawa materialnego, polegającego na niewłaściwym zastosowaniu art. 280 § 2 k.k.

Przykład 2A (negatywny): sąd uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 226 § 1 k.k., dając w całości wiarę znajdującą się w aktach sprawy notatce

funkcjonariusza w odniesieniu do zachowania oskarżonego. Sam funkcjonariusz nie został nigdy w postępowaniu przesłuchany, zaś całość ustaleń w tym zakresie poczyniona została wyłącznie w oparciu o treść notatki służbowej funkcjonariusza. Jeśli kwestionujemy powyższe ustalenia faktyczne, to w apelacji zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 174 k.p.k., polegającej na wadliwym zastąpieniu dowodu z zeznań funkcjonariusza treścią notatki służbowej, które nie stanowi dowodu i nie może być podstawą czynienia ustaleń faktycznych. W takiej sytuacji konstruowanie dodatkowego zarzutu obrazy prawa materialnego, co do wadliwego zastosowania art. 226 § 1 k.k., byłoby błędne i zupełnie niepotrzebne (jako, że jest to oczywista konsekwencja zaistniałego na płaszczyźnie procesowej błędu). Skonstruowanie zaś takiego zarzutu byłoby klasycznym przykładem zarzutów „mieszanych” apelacji.

Przykład 2B (negatywny): sąd uznał oskarżonego za winnego czynu z art. 226 § 1 k.k., dając w całości wiarę funkcjonariuszowi w odniesieniu do zachowania oskarżonego, przy czym całość ustaleń w tym zakresie poczyniona została wyłącznie w oparciu o zeznania ww. funkcjonariusza. Jeśli kwestionujemy wiarygodność zeznań funkcjonariusza, to zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k., polegającej na wadliwej ocenie dowodu z jego zeznań (np. niespójność, niezgodność z logiką etc.). W takiej sytuacji konstruowanie dodatkowego zarzutu obrazy prawa materialnego, co do wadliwego zastosowania art. 226 § 1 k.k. byłoby błędne i zupełnie niepotrzebne (jako, że jest to oczywista konsekwencja zaistniałego na płaszczyźnie procesowej błędu). Skonstruowanie zaś takiego zarzutu byłoby klasycznym przykładem zarzutów „mieszanych” apelacji.

Przydatne orzecznictwo:

- *Postawiony zarzut jest oczywiście sformułowany błędnie, skarżący miesza w nim bowiem błędne ustalenie stanu faktycznego oraz nieprawidłową wykładnię przepisów, dotycząc także swobodnej oceny dowodów – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 14 czerwca 2021 r., sygn. akt IV Ka 887/20*
- *Jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, zarzut apelacyjny powinien dotyczyć tylko uchybienia o charakterze pierwotnym, a nie jego*

następstw. W razie oparcia odwołania na zarzutach tzw. mieszanych, to jest na twierdzeniu odpowiadającym kilku podstawom odwoławczym, jako podstawę odwołania należy powołać zarzut tzw. pierwotny. Nieodpowiednie jest powołanie kilku zarzutów, gdy jeden jest konsekwencją innego bądź gdy zarzuty wzajemnie się wykluczają. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych może być wywodzony z błędnej oceny materiału dowodowego, ale nie odwrotnie. Nie może przecież budzić wątpliwości, że to ocena materiału dowodowego generuje ustalenia faktyczne (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 września 2019 r., sygn. II AKa 95/19, KZS 2019/12/41, LEX nr 3007602) – wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 17 maja 2021 r., sygn. akt II Ka 236/21

- *Tymczasem prawidłowo skonstruowana apelacja wyłącza możliwość formułowania zarzutów mieszanych w odniesieniu do tej samej okoliczności – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 listopada 2020 r., sygn. akt II AKa 103/20*
- *Sformułowane przez obrońcę zarzuty o charakterze mieszanym obejmują błąd w ustaleniach faktycznych co do sprawstwa oskarżonego, który nastąpił w wyniku obrazy przepisów postępowania, tj. art. 7 k.p.k. W istocie stanowią one polemikę z ustaleniami Sądu I instancji, próbę zastąpienia ich własną odmienną oceną materiału dowodowego bez wykazania, jakich to uchybień w świetle wiedzy i doświadczenia życiowego dopuścił się Sąd w dokonanej przez siebie ocenie materiału dowodowego – wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 31 stycznia 2020 r., sygn. akt VI Ka 1098/19*
- *W orzecznictwie Sądu Najwyższego i piśmiennictwie, konsekwentnie podkreśla się, iż obraza prawa materialnego polega na jego wadliwym zastosowaniu w orzeczeniu, które oparte jest na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie można więc mówić o obrazie prawa materialnego w sytuacji, gdy wadliwość orzeczenia w tym zakresie jest wynikiem błędnych ustaleń faktycznych, przyjętych za jego podstawę lub naruszenia przepisów procesowych (por. S. Zabłocki (w:) J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki – Kodeks postępowania karnego. Komentarz., Warszawa 2004, t. III, s. 111). Nie można zatem skutecznie postawić tego zarzutu – jak to czyni*

*skarżący – z jednoczesnym kwestionowaniem przepisów postępowania w tym samym zakresie – **postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lutego 2019 r., sygn. akt V KK 3/19***

- *Od wielu lat ugruntowany jest bowiem pogląd, że w przypadku kwestionowania kwalifikacji prawnej czynu zarzut obrazy prawa materialnego można postawić tylko i wyłącznie wówczas, gdy skarżący nie podważa ustaleń faktycznych związanych z tą kwalifikacją. Jeżeli ustalenia faktyczne, na podstawie których Sąd dokonał kwalifikacji prawnej czynu nie są prawidłowe, to błędem pierwotnym jest błąd w ustaleniach faktycznych – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 października 2018 r., sygn. akt II AKa 402/17***
- *Zasadne przy tym jest zauważyć, że sposób w jaki obrońca sformułował zarzuty nie zasługuje na pełną aprobatę, ponieważ skarżący zmierzając do zdyskwalifikowania wyroku skazującego oskarżonych, posłużył się zarzutami mieszanymi z wykorzystaniem podstaw odwoławczych określonych w art. 438 pkt 1, 2 i 3 k.p.k., pomijając, że nie może być mowy o obrazie prawa materialnego, gdy wadliwość orzeczenia jest wynikiem naruszenia przepisów postępowania lub błędnych ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę. Jeżeli więc autor apelacji w pkt I i II podniósł zarzuty mające wykazać uchybienia z art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k., bezzasadne było podnoszenie w pkt III apelacji ogólnego zarzutu naruszenia prawa materialnego, tj. art. 300 § 2 k.k. poprzez zastosowanie tej kwalifikacji prawnej pomimo, że, w ocenie skarżącego, nie było podstaw prawnych przypisania oskarżonym takich czynów karalnych – **wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt II Ka 747/17***
- *(...) zarzut obrazy prawa materialnego formułowany być może tylko wówczas, gdy nie są kwestionowane ustalenia faktyczne w zakresie sprawstwa czynu i podstaw odpowiedzialności karnej, a zatem, gdy nie jest podważana ocena dowodów, będąca przecież podstawą takich ustaleń. Nie oznacza to jednak sytuacji, że takie „zdublowanie” zarzutów z pkt 438 pkt 1 i 2 k.p.k. nie jest dopuszczalne. Jest uzasadnione stawianie tych różnych zarzutów tak w apelacji, jak i w kasacji w układzie, gdy skarżący zarzuca obrazę prawa procesowego i w niej upatruje zasadniczą podstawę swego środka zaskarżenia, ale jednocześnie – nie mając pewności*

co do uwzględnienia takich, procesowych, zarzutów – dostrzega wadliwe zastosowanie (np. błąd w subsumcji) określonego przepisu prawa materialnego, nawet w tych, kwestionowanych przecież, ustaleniach faktycznych. W takim układzie zarzut obrazy prawa materialnego z reguły ma charakter zarzutu alternatywnego, a więc będzie stanowił przedmiot oceny wówczas, gdy zostaną zaaprobowane ustalenia faktyczne, a więc, gdy podstawowy zarzut naruszenia przepisów procesowych okaże się niezasadny – **wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 2016 r., sygn. akt V KK 239/16**

- W razie bowiem oparcia skargi odwoławczej na zarzutach mieszanych, tj. twierdzeniu odpowiadającym kilku podstawom odwoławczym, jako podstawę odwołania należy powoływać zarzut tzw. pierwotny, a nie wtórny, stanowiący pochodną usterki pierwotnej. Nieodpowiednie jest bowiem powoływanie kilku zarzutów, gdy jeden z nich jest konsekwencją innego bądź gdy zarzuty te wzajemnie się wykluczają. Jest to sytuacja zarzutu odwoławczego o charakterze „mieszanym”, gdy jeden zarzut powoduje kolejne, aż po niesprawiedliwość wyroku. Zbędne jest zatem przyjmowanie za podstawę apelacji wszystkich trzech przyczyn odwoławczych (jak uczyniono to w apelacji obrońcy oskarżonego M. J.), bo wystarczy przyjąć jedną z nich, a to pierwotną. Stwierdzenie jej spowodowałoby bowiem uwzględnienie apelacji i przeciwnie – oddalenie zarzutu pierwotnego skutkowałoby pominięciem rozważań odnośnie do zarzutów wtórnych (vide: wyrok tut. Sądu Apelacyjnego z dnia 11 lutego 1999 r. II AKa 18/99, KZS 1999/3/25) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II AKa 41/15**
- Od dawna ugruntowany jest pogląd, że obraza prawa materialnego polega na jego wadliwym zastosowaniu lub niezastosowaniu w orzeczeniu, które jest oparte na trafnych i niekwestionowanych ustaleniach faktycznych. Nie ma obrazy prawa materialnego, gdy wadliwość orzeczenia jest wynikiem błędnych ocen i ustaleń faktycznych przyjętych za jego podstawę. W razie oparcia apelacji na zarzutach mieszanych, odpowiadających kilku przyczynom odwoławczym, jako podstawę skargi należy podawać zarzut pierwotny, a nie wtórny stanowiący pochodną pierwotnego. Nie jest właściwe powołanie kilku zarzutów, gdy jeden

z nich jest konsekwencją drugiego albo gdy wzajemnie się wykluczają. Jeśli apelujący kwestionuje przyjętą kwalifikację prawną, bo w działaniu oskarżonego dopatruje się innego od przypisanego mu działania, to podstawą apelacji jest zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, a nie zarzut obrazy prawa materialnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 maja 2014 r., sygn. akt II AKa 79/14. LEX nr 1574403

- (...) *podniesienie w jednym środku zaskarżenia zarzutu obrazy prawa materialnego oraz zarzutu obrazy przepisów postępowania powoduje tak daleko idącą sprzeczność tego środka, że uniemożliwia wręcz łączne rozpoznanie stawianych w nim zarzutów. Oczywiście jest bowiem, że zarzut obrazy prawa materialnego może być skutecznie postawiony w wypadku niekwestionowania ustaleń faktycznych; w przeciwnym razie niewłaściwie ustalone fakty nie mogą stanowić podstawy subsumcji. Wbrew tym oczywistościom, autor kasacji próbuje jednocześnie kwestionować sposób ustalenia faktów i zarazem prawidłowość zastosowania do błędnych – jego zdaniem – ustaleń przepisu prawa materialnego. Nie oznacza to jednak niemożności rozpoznania kasacji w ogóle, powoduje jednak konieczność rozważania w pierwszej kolejności zarzutu obrazy przepisów prawa procesowego, który, w wypadku trafności, wyklucza możliwość rozpoznania zarzutu obrazy prawa materialnego, zaś w wypadku nieskuteczności – otwiera drogę do rozpoznania tego zarzutu. Taka więc konstrukcja kasacji wniesionej w niniejszej sprawie uniemożliwia kompleksowe rozpoznanie stawianych w niej zarzutów z powodu braku logiki w ich formułowaniu – postanowienie Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r., sygn. akt II KK 26/03*

Rozdział 8.

Wnioski apelacji

Ad. 8.1. Prawidłowa konstrukcja wniosku apelacji przy uwzględnieniu obecnego brzmienia art. 437 § 1 i 2 k.p.k.;

W praktyce podkreśla się, że wniosek apelacyjny nie wiąże sądu odwoławczego w tym sensie, że jeśli np. obrońca błędnie wniesie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji w sytuacji, gdy np. doszło do przedawnienia karalności przestępstwa (czego obrońca nie dostrzegł), wówczas sąd odwoławczy uchyli wyrok i umorzy postępowanie, niezależnie od ww. wniosku obrońcy.

Mimo jednak tego, że wniosek apelacyjny nie wiąże sądu odwoławczego, to w warunkach egzaminacyjnych prawidłowo (lub nieprawidłowo) sformułowane wnioski apelacji podlegają ocenie przez egzaminatorów. Choćby z tego względu warto zapoznać się z podstawowymi zasadami prawidłowego konstruowania wniosków apelacji.

Wniosek apelacyjny to w istocie żądanie, by sąd odwoławczy wydał określone rozstrzygnięcie. Wnosimy zatem, by rozstrzygnięcie sądu odwoławczego miało określoną treść. **Pomocne jest zatem zadanie sobie pytania – co powinien zrobić sąd odwoławczy i jak brzmiałaby sentencja wyroku sądu II instancji, jeśli zarzut apelacyjny jest zasadny?**

Zgodnie z art. 437 § 1 k.p.k., po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części. Z powyższego wynika, że możliwe decyzje sądu zawarte w sentencji wyroku sądu II instancji, wynikające z brzmienia art. 437 § 1 i 2 k.p.k., to:

- *utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy;*
- *zmienia zaskarżony wyrok i oskarżonego uniewinnia*
 - *albo zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że dokonuje zmiany opisu czynu lub kwalifikacji prawnej;*

- albo zmienia wyrok w zaskarżonej części w ten sposób, że orzeczoną wobec oskarżonego karę obniża/podwyższa do X lat pozbawienia wolności;
- albo zmienia zaskarżony wyrok i postępowanie karne wobec oskarżonego warunkowo umarza;
- uchyla zaskarżone orzeczenie i postępowanie karne wobec oskarżonego umarza
 - albo uchyla zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazuje sądowi I instancji do ponownego rozpoznania;

Wniosek apelacyjny powinien zatem odpowiadać jednemu z ww. punktów, przy czym – co najistotniejsze – powinien pozostawać spójny merytorycznie zarówno z zakresem i kierunkiem zaskarżenia apelacji, jak i zarzutami sformułowanymi we wniesionym środku odwoławczym (!).

Pytanie (?): Dlaczego wnosimy o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie w przypadku braku znamion, skoro art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wskazuje, że postępowania karnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, gdy brak jest znamion czynu zabronionego. Podobnie jest w przypadku, gdy czynu nie popełniono (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.). Dlaczego zatem nie wnosimy o zmianę wyroku i umorzenie postępowania?

Odpowiedź: Powyższy problem rozstrzyga art. 414 § 1 zd. 2 k.p.k. Zgodnie z ww. przepisem, w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych przemawiających za warunkowym umorzeniem postępowania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny. W konsekwencji, jeśli po otwarciu przewodu sądowego (tj. zwięzłego przedstawienia zarzutów oskarżenia na rozprawie – art. 385 § 1 k.p.k.) sąd doszedłby do wniosku, że zachodzi jeden z czterech przypadków, wskazywanych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k., wówczas sąd ten, stosując art. 414 § 1 zd. 2 k.p.k., wydałby wyrok

uniewinniający. Z kolei skarżący, który zarzuca w apelacji zaistnienie którejś z czterech negatywnych przesłanek procesowych (np. wobec dekompletacji znamion czynu zabronionego), powinien sformułować wniosek apelacji, jako wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie.

Przykład 1: jeśli jako obrońca zaskarżam wyrok w całości na korzyść oskarżonego, formułując zarzut obraży art. 286 § 1 k.k., poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie wobec braku wszystkich wymaganych znamion przestępstwa oszustwa, wówczas prawidłowe i spójne z powyższym wnioskiem będzie wniosek o zmianę zaskarżonego rozstrzygnięcia i uniewinnienie oskarżonego. Formułowanie w takiej sytuacji wniosku o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji albo o zmianę wyroku, poprzez orzeczenie kary łagodniejszej – byłoby merytorycznie niespójne ze sformułowaniem w apelacji zarzutem.

Przykład 2: jeśli jako obrońca zaskarżamy wyrok w części orzeczenia o karze na korzyść oskarżonego, formułując zarzut z art. 438 pkt 4 k.p.k., wówczas prawidłowym i spójnym z powyższym wnioskiem będzie wniosek o zmianę zaskarżonego rozstrzygnięcia, poprzez obniżenie orzeczonej kary do X lat pozbawienia wolności. Formułowanie w takiej sytuacji wniosków o zmianę wyroku i uniewinnienie byłoby merytorycznie niespójne nie tylko ze sformułowaniem w apelacji zarzutem, ale również z określonym w pracy zakresem zaskarżenia.

Przykład 3: jeśli jako obrońca zaskarżam wyrok w całości na korzyść oskarżonego, formułując szereg zarzutów z art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k., wówczas prawidłowe i spójne z powyższym wnioskiem będzie wniosek o zmianę zaskarżonego rozstrzygnięcia i uniewinnienie oskarżonego. Sformułowanie w takiej sytuacji wniosku o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania będzie nieprawidłowe (pozostające w sprzeczności z obecnym brzmieniem art. 437 § 2 k.p.k.).

Przykład 4: jeśli jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego zaskarżam wyrok uniewinniający w całości na niekorzyść oskarżonego, wówczas – stosownie

do art. 454 § 1 k.p.k. – powinniśmy wnosić o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Formułowanie w takiej sytuacji wniosku o zmianę wyroku i uznanie oskarżonego za winnego zarzuczonego mu przestępstwa oraz wymierzenie kary byłoby merytorycznie błędne wobec brzmienia art. 454 § 1 k.p.k.

Aktualne brzmienie ww. art. 437 § 2 k.p.k.⁵⁹ nie pozostawia wątpliwości, że zasadą jest zmiana orzeczenia co do istoty przez sąd odwoławczy, zaś uchylenie orzeczenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania możliwe jest wyjątkowo – jedynie w sytuacji wystąpienia jednego z trzech ww. przypadków (tj. 1. art. 439 § 1 k.p.k.; 2. art. 454 k.p.k.; 3. konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przed wejściem w życie ww. ustawy nowelizującej, art. 437 § 2 k.p.k. stanowił, że *jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (...)*. W praktyce poprzednie brzmienie omawianego przepisu skutkowało koniecznością uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania zawsze wtedy, kiedy apelujący skutecznie zakwestionował ocenę materiału dowodowego, dokonaną przez sąd I instancji. To zaś powodowało, że niektóre sprawy kilkukrotnie powracały do sądu I instancji zanim zapadło prawomocne rozstrzygnięcie, a postępowania niejednokrotnie z tej przyczyny trwały latami.

⁵⁹ Ustawą nowelizującą z 20 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.396), zmieniającą (w art. 12 pkt 1 lit. Zj) art. 437 § 2 k.p.k. z dniem 4 kwietnia 2015 r., wprowadzono następujące brzmienie tego przepisu: *Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości*. Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Omawiana nowelizacja art. 437 § 2 k.p.k. w zamierzeniu jej twórców miała zatem przeciwdziałać sytuacjom przewlekłości postępowań, wynikającym z konieczności uchylania orzeczenia i przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania zawsze wtedy, gdy sąd odwoławczy dostrzegał mankamenty w płaszczyźnie oceny materiału dowodowego przez sąd I instancji. Z tego też powodu **znowelizowane brzmienie art. 437 § 2 k.p.k. wprowadza zasadę zmiany orzeczenia co do istoty przez sąd odwoławczy, zezwalając na uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jedynie w sytuacji wystąpienia jednego z trzech przypadków:**

1. **art. 439 § 1 k.p.k.** – z oczywistych względów, konieczność uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w przypadku wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej dotyczy tylko tych przyczyn z art. 439 § 1 k.p.k., które mogłyby zostać wyeliminowane/naprawione w przypadku ponownego rozpoznawania sprawy przez sąd I instancji. Oczywistym jest, że w przypadku zaistnienia przyczyn z art. 439 § 1 pkt 1, 2 albo 3 k.p.k., przy ponownym orzekaniu przez sąd I instancji, uchybienia w obsadzie sądu czy w wyborze sądu orzekającego mogą i zostaną wyeliminowane. Zupełnie jednak odmiennie kształtowałaby się sytuacja, w przypadku bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. (*res iudicata*) albo z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. (z powodu określonego np. w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. przedawnienia). W obu tych wypadkach sprawa – niezależnie od jej wagi czy stopnia społecznej szkodliwości czynu – musiałaby formalnie zakończyć się nie zmianą orzeczenia co do istoty, ale uchyleniem zaskarżonego orzeczenia i umorzeniem postępowania.
2. **art. 454 k.p.k.** – zgodnie z art. 454 § 1 k.p.k., sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie. Z oczywistych względów, omawiany przypadek odnosi się do apelacji oskarżyciela posiłkowego lub publicznego, albowiem tylko te strony postępowania miałyby *gravamen* (interes, uprawnienie) w zaskarżeniu wyroku uniewinniającego oskarżonego przez sąd I instancji. W sytuacji zatem gdy w I instancji zapada orzeczenie uniewinniające, apelację od tego wyroku wnosi pełnomocnik oskarżyciela

posiłkowego, a sąd odwoławczy podziela zarzuty tej apelacji i gdyby miał wydawać wyrok, zmieniłyby to rozstrzygnięcie uniewinniające na niekorzyść oskarżonego (na orzeczenie skazujące lub warunkowo umarzające postępowanie), wówczas – zgodnie z art. 454 § 1 k.p.k. – sąd odwoławczy może jedynie uchylić tenże wyrok i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Zakaz z art. 454 § 1 k.p.k. (tzw. „*ne peius*” – niepogarszania sytuacji) kategorycznie uniemożliwia sądowi odwoławczemu dokonanie zmiany orzeczenia w omawianym przypadku. Dostrzec należy, że orzeczenie reformatoryjne, a zatem zmieniające orzeczenie na niekorzyść uniewinnionego w I instancji oskarżonego, wbrew zakazowi z art. 454 § 1 k.p.k., pozbawiałoby oskarżonego konstytucyjnego prawa do dwuinstancyjnego postępowania karnego. Zmienione rozstrzygnięcie z uniewinniającego na skazujące stałoby się bowiem natychmiast prawomocne i oskarżony nie miałby żadnej zwyczajnej drogi odwoławczej od tego wyroku.

Dla zainteresowanych:

- nowelizacją z 4 września 2019 r. (Dz. U. 2019.1694) wykreślono z art. 454 § 1 k.p.k. sformułowanie „co do którego w pierwszej instancji warunkowo umorzono postępowanie”. Poprzednie brzmienie art. 454 § 1 k.p.k. było bowiem następujące: *Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie*. Wykreślenie warunkowego umorzenie postępowania z treści art. 454 § 1 k.p.k. skutkuje tym, że sąd odwoławczy, jeśli podziela zarzuty apelacji wniesionej na niekorzyść oskarżonego, wobec którego w I instancji zapadło orzeczenie warunkowo umarzające postępowanie karne, może zmienić orzeczenie na niekorzyść oskarżonego. Nie musi wówczas, tak jak nakażywał mu art. 454 § 1 k.p.k. przed ww. nowelizacją, uchylać zaskarżonego rozstrzygnięcia i przekazywać sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.
- do dnia 1 lipca 2015 r. obowiązywał art. 454 § 2 k.p.k., zgodnie z którym sąd odwoławczy mógł orzec surowszą karę pozbawienia wolności

*tylko wtedy, gdy nie zmieniał ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku. Przepis ten został uchylony ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw⁶⁰. W obecnym stanie prawnym **przytaczane ograniczenie nie obowiązuje, o czym należy pamiętać.***

- *na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego z 20 października 2020 r., w którym wyrażono pogląd, że w przypadku gdy sąd odwoławczy dostrzega potrzebę zmiany wyroku uniewinniającego na wyrok warunkowo umarzający postępowanie, to zakaz z art. 454 § 1 k.p.k. nie stoi na przeszkodzie dokonaniu takiej zmiany⁶¹. Na tle ww. stanowiska Sądu Najwyższego zaznaczenia wymaga, że wyrok warunkowo umarzający postępowanie, choć stwierdza winę, nie jest wyrokiem skazującym. Wydaje się, że skoro art. 454 § 1 k.p.k. posługuje się sformułowaniem „może skazać”, to właśnie ta kwestia mogła doprowadzić do konkluzji, że wskazywana regulacja nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. orzeczenia kwestii tej wprost nie omawiał. Tymczasem orzeczenie to wydaje się być o tyle kontrowersyjne z punktu widzenia obrony, że zmiana wyroku uniewinniającego (a zatem nie stwierdzającego winy) na wyrok warunkowo umarzający postępowanie (wyrok wprawdzie nie – skazujący, ale jednak stwierdzający winę), to – wobec prawomocności tego wyroku jako wydanego przez Sąd II instancji – pozbawia oskarżonego prawa do kontroli tego orzeczenia w zwyczajnym trybie. Oskarżony nie ma bowiem już żadnej instancji w zwyczajnym trybie (skoro omawiane orzeczenie zapadło przed sądem II instancji i jest prawomocne z chwilą jego wydania), by zakwestionować ustalenia co do własnego zawinienia. Warto jednak mieć świadomość istnienia takiego poglądu w orzecznictwie.*

3. Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości.

Omawiany przypadek dotyczy sytuacji, w których braki przeprowadzonego postępowania dowodowego przed sądem I instancji są tak widoczne i istotne,

⁶⁰ Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 ze zm.

⁶¹ Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 października 2020 r., sygn. akt V KS 23/20.

że – aby móc mówić o rzetelnym procesie karnym – zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia tegoż postępowania w całości. Omawiany przypadek nie dotyczy zatem sytuacji, w której kwestionujemy ocenę dokonaną przez sąd w odniesieniu do któregoś z dowodów, przeprowadzonych na etapie postępowania przed sądem I instancji albo sytuacji, w której wprowadzie sąd pominął jakieś dowody, ale jednak w toku postępowania przeprowadził szereg innych.

Jak zaznaczył bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2021 r., *wskazana w przepisie art. 437 § 2 zd. drugie in fine k.p.k. potrzeba przeprowadzenia na nowo przewodu w całości jako przesłanka uchylenia przez sąd odwoławczy wyroku i przekazania sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania ma miejsce w sytuacji, gdy w postępowaniu pierwszoinstancyjnym doszło do takiego naruszenia norm prawa procesowego, które w realiach konkretnej sprawy, podważa rzetelność całego tego postępowania, co przemawia za powtórzeniem wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy w sądzie I instancji*⁶².

Podsumowując – jeśli w sprawie nie wystąpiła jedna z wyżej omawianych trzech okoliczności uzasadniających uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (zgodnie z art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k.), a w sprawie nie ma bezwzględnej przyczyny odwoławczej uzasadniającej uchylenie wyroku i umorzenie postępowania, wówczas sytuacja jest prosta – nasz wniosek apelacji powinien dotyczyć zmiany zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienia/zmiany opisu i kwalifikacji czynu/orzeczenia kary lub środków karnych w łagodniejszym wymiarze (w zależności od tego, jaki jest zakres apelacji i czego dotyczą nasze zarzuty apelacyjne). Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 12 czerwca 2019 r., *istota reformatoryjnego orzekania w II instancji w sprawach karnych polega właśnie na tym, że skoro pewne elementy materiału dowodowego można dla wydania merytorycznego rozstrzygnięcia przeprowadzić na rozprawie odwoławczej, to należy z tej możliwości*

⁶² Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2021 r., sygn. akt V KS 2/21.

skorzystać. **Orzeczenia kasatoryjne stanowią wyjątek od reguły i być zarezerwowane dla najbardziej błędnie przeprowadzonych postępowań**⁶³.

Dodatkowe uwagi:

- Z doświadczenia egzaminacyjnego wynika, że **zdający nierzadko formułują zbędne wnioski apelacyjne**. Takie sytuacje odnoszą się najczęściej do rozstrzygnięć o środkach karnych bądź kompensacyjnych (np. zakaz prowadzenia pojazdów przy skazaniu za przestępstwo wypadku drogowego, popełnione w stanie nietrzeźwości), które orzekane są w związku ze skazaniem i są zwyczajną konsekwencją skazania, zaś w apelacji obrońca wnosi o zmianę orzeczenia i uniewinnienie. Należy zatem pamiętać, że skoro apelujący wnosi o zmianę orzeczenia oraz o uniewinnienie (określając spójnie z tym wnioskiem zakres zaskarżenia jako „w całości”), wówczas nie ma potrzeby konstruowania dodatkowych wniosków co do rozstrzygnięć, będących konsekwencją wydanego wyroku skazującego. Wnioski odnoszące się w tego rodzaju sytuacjach np. do nieprawidłowo zastosowanych zakazów czy wadliwie orzeczonych środków kompensacyjnych pozostają „skonsumowane” we wniosku głównym (odnoszącym się do przypisanego przestępstwa) o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie. Innymi słowy, skoro wnosimy o zmianę wyroku skazującego za przestępstwo spowodowania w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, poprzez uniewinnienie oskarżonego, to nie ma potrzeby w apelacji formułować dodatkowych wniosków o uchylenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów z art. 42 § 2 k.k. Uwzględnienie przez sąd odwoławczy wniosku o zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie niejako automatycznie spowoduje bowiem uchylenie wszystkich konsekwencji prawnokarnych skazania.
- **Równie zbędny charakter ma wniosek o „wyeliminowanie lub uchylenie rozstrzygnięcia o karze łącznej”**, który często formułowany jest przez zdających. Należy zatem pamiętać, że dzieląc zarzuty apelacji, sąd odwoławczy z urzędu uchyli rozstrzygnięcie w przedmiocie uprzednio orzeczonej kary łącznej. Jak wskazał bowiem Sąd Najwyższy w wyroku

⁶³ Wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt IV KS 15/19.

z 23 lutego 2012 r., kara łączna zostaje rozwiązana wraz z uchYLENIEM orzeczeń, co do jednej z kar jednostkowych, w związku z czym zbędne jest uchYLENIE wyroku w części dotyczącej tej kary⁶⁴.

- W przypadku apelacji egzaminacyjnych, które sporządzane są wobec wyroków, uznających winę za kilka różnych czynów z Kodeksu karnego, **sugerowane jest, aby dla czytelności wyводу wnioski apelacji formułować oddzielnie dla każdego czynu, przypisanego zaskarżonym wyrokiem.** Przykładowo, jeśli sąd i instancji uznał w pkt 1 sentencji wyroku oskarżonego za winnego przestępstwa z art. 278 § 1 k.k., w pkt 2 za winnego przestępstwa z art. 177 § 2 k.k., zaś w pkt 3 za winnego przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. (a co do każdego z ww. czynów wyrok zaskarżamy i formułujemy co do tych czynów odrębne zarzuty), to sformułowanie jednego wniosku apelacyjnego obarczone jest dużym ryzykiem. Dla przejrzystości pracy, ale także niejako dla „samoskontrolowania” własnego poglądu, sugeruję aby w końcowym fragmencie petitum apelacji zawrzeć podtytuł „Wnioski apelacji” i w punktach wskazać, że: „**I. w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 1 zaskarżonego wyroku, wnoszę o; II. w odniesieniu do czynu przypisanego w pkt 2 zaskarżonego wyroku, wnoszę o**” itd.;
- Przy okazji każdych prowadzonych przeze mnie zajęć z aplikantami, przygotowującymi czy to do egzaminu zawodowego, czy do kolokwium rocznego, zawsze pojawia się to samo pytanie, które można zobrazować na następującym przykładzie: „czy jeśli sąd I instancji błędnie przypisał zaskarżonym wyrokiem czyn np. z art. 280 § 1 k.k., co do którego brak jest kompletu znamion, ale jednocześnie z materiału dowodowego wynika, że uzasadnionym byłaby zmiana przez sąd odwoławczy kwalifikacji prawnej czynu na art. 278 § 1 k.k., to czy apelujący powinien wnosić o zmianę wyroku i uznanie oskarżonego za winnego przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. (a zatem podawać sądowi odwoławczemu tę kwalifikację jako zasadną) czy też powinien wnosić o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego (wobec braku ustawowych znamion zarzuconego czynu z art. 280 § 1 k.k.)?”. Pomijamy w tym miejscu kwestię przyznania się

⁶⁴ Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2012 r., sygn. akt III KO 78/11.

*lub nie oskarżonego do określonych czynności sprawczych, skupiając się wyłącznie na zagadnieniu, czy w warunkach egzaminacyjnych w apelacji zasadne jest sugerowanie sądowi odwoławczemu potrzeby skazania oskarżonego z innego przepisu aniżeli będącego przedmiotem postępowania, choćby z łagodniejszej kwalifikacji, czy też właściwszym i rozumianym jako najdalej idące działanie na korzyść, jest przemilczenie tej potencjalnej kwalifikacji z art. 278 § 1 k.k., wychodząc z założenia, że obrońca nie jest od tego, by „pomagać sądowi odszukać właściwy przepis w celu skazania oskarżonego”. Z doświadczenia wiem, że sędziowie prowadzący zajęcia z aplikantami wypowiadają się w tej kwestii zazwyczaj odmiennie od obrońców – ci drudzy są bowiem zwolennikami koncepcji działania w najszerszej pojętym interesie oskarżonego, tj. składania w apelacjach wniosku o zmianę wyroku i uniewinnienie. Na powyższe pytanie nie ma jednej właściwej i poprawnej odpowiedzi. Zarówno sędziowie, jak i obrońcy mają odmienne role w postępowaniu karnym i stąd też istotna różnica stanowisk w omawianej kwestii. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, uwzględniającym także fakt, że praca egzaminacyjna sprawdzana jest zarówno przez sędziów, jak i adwokatów, jest niewskazywanie w *petitum* apelacji tej potencjalnej nowej kwalifikacji prawnej, ale zaznaczenie w uwagach bądź zastrzeżeniach zdającego do pracy egzaminacyjnej, że wprawdzie zdający dostrzega możliwość zakwalifikowania czynu zarzuczonego oskarżonemu z art. 278 § 1 k.k., to działając na korzyść oskarżonego nie wskazuje sądowi odwoławczemu tej okoliczności, wnosząc w interesie oskarżonego – wobec dekompletacji znamion czynu z art. 280 § 1 k.k. – o zmianę wyroku i uniewinnienie⁶⁵.*

- **Równie często pojawia się także pytanie, co zrobić jeśli czyn przypisany oskarżonemu zaskarżonym wyrokiem *de facto* jest wykroczeniem.**

⁶⁵ Mam świadomość, że powyższa rada nie znajduje oparcia w przepisach Kodeksu postępowania karnego, a sama apelacja powinna być całościowym dokumentem, z którego powinno jasno wynikać do czego dąży apelujący, bez potrzeby sięgania do jakich dodatkowych, pozaprocesowych form wypowiedzi w postaci uwag czy zastrzeżeń do pracy, tym niemniej w mojej ocenie w pewnych stanach faktycznych dopuszczalne byłoby sformułowanie ww. uwag w celu opisanym powyżej.

Sytuacja jest prostsza, jeśli wykroczenie uległo przedawnieniu, wówczas bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla oskarżonego, na podstawie art. 400 § 1 k.p.k. w zw. z art. 437 § 1 k.p.k. oraz w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w. należy wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania. Jeśli natomiast wykroczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu, powracamy do zagadnienia czy w warunkach egzaminacyjnych w apelacji zasadne jest sugerowanie sądowi odwoławczemu potrzeby skazania oskarżonego, tyle że za wykroczenie, czy też właściwszym i rozumianym jako daleko idące działanie na korzyść, jest przemilczenie tej kwestii, wychodząc z założenia, że obrońca nie jest od tego, by „pomagać sądowi odszukać właściwy przepis w celu skazania”. Aktualne pozostają uwagi wskazane w powyższym podpunkcie⁶⁶, z uzupełnieniem wynikającym z orzecznictwa, a mianowicie jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2018 r., sąd ma obowiązek stosować art. 400 k.p.k. wtedy, gdy ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi tylko (wyłącznie) wykroczenie, a nie przestępstwo, jak zakwalifikowano ten czyn w akcie oskarżenia. Sąd proceduje wówczas nadal w tym samym składzie, lecz nie w oparciu o przepisy postępowania karnego, ale przepisy regulujące postępowanie w sprawach o wykroczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie orzeczenie wyda dopiero sąd drugiej instancji, rozpoznając środek odwoławczy⁶⁷. Mając zatem na uwadze powyższe, a także fakt, że skazanie za wykroczenie z założenia wiąże się ze znacznie mniej dolegliwymi skutkami dla naszych klientów, wydaje się uzasadnione, aby w takiej sytuacji procesowej nie traktować jako złożonego na niekorzyść oskarżonego wniosku o zastosowanie przez Sąd art. 400 § 1 k.p.k. i w konsekwencji zmianę zaskarżonego wyroku oraz wymierzenie oskarżonemu łagodnej kary za wykroczenie.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) wskazana w przepisie art. 437 § 2 zd. drugie *in fine* k.p.k. potrzeba przeprowadzenia na nowo przewodu w całości jako przesłanka uchylenia

⁶⁶ W tym także aktualna pozostaje uwaga zawarta w przypisie nr 65.

⁶⁷ Wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2018 r., sygn. akt IV KK 439/17.

*przez sąd odwoławczy wyroku i przekazania sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania ma miejsce w sytuacji, gdy w postępowaniu pierwszoinstancyjnym doszło do takiego naruszenia norm prawa procesowego, które w realiach konkretnej sprawy, podważa rzetelność całego tego postępowania, co przemawia za powtórzeniem wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy w sądzie I instancji (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2019 r., I KZP 3/19) – **wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2021 r., sygn. akt V KS 2/21***

- *Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2018 r., I KZP 10/18, które Sąd Najwyższy w niniejszym składzie podziela „[m]ożliwość uchylenia wyroku uniewinniającego, umarzającego albo warunkowo umarzającego postępowanie karne i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania związana z regułą ne peius określoną w art. 454 § 1 k.p.k. (art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k.) zachodzi dopiero wtedy, gdy sąd odwoławczy – w wyniku usunięcia stwierdzonych uchybień stanowiących jedną z podstaw odwoławczych określonych w art. 438 pkt 1–3 k.p.k. (czyli np. po uzupełnieniu postępowania dowodowego, dokonaniu prawidłowej oceny dowodów, poczynieniu prawidłowych ustaleń faktycznych) – stwierdza, że zachodzą podstawy do wydania wyroku skazującego czemu stoi na przeszkodzie zakaz określony w art. 454 § 1 k.p.k. Sama tylko możliwość wydania takiego wyroku w ponownym postępowaniu przed sądem pierwszej instancji jest niewystarczająca dla przyjęcia wystąpienia reguły ne peius określonej w art. 454 § 1 k.p.k.”. Oznacza to, że sąd odwoławczy zobligowany jest albo uzupełnić postępowanie dowodowe, by upewnić się, że rozstrzygnięcie uniewinniające jest niezasadne, lub wyraźnie uargumentować, iż na podstawie zgromadzonego w sposób prawidłowy materiału dowodowego nie ma możliwości wydania wyroku uniewinniającego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 2 lutego 2021 r., sygn. akt I KS 1/21***
- *Sąd odwoławczy sam potwierdził fakt oparcia się przez Sąd Rejonowy na całości materiału dowodowego, uznał natomiast za nietrafną ocenę tych dowodów stwierdzając, że pozwalają one na ustalenie całkowicie odmiennego od przedstawionego przez D. L. stanu faktycznego. Tymczasem konieczność ponownej oceny dowodów przez sąd pierwszej instancji*

nie stanowi podstawy wydania wyroku kasatoryjnego w oparciu o przesłankę określoną w art. 437 § 2 zd. 2 *in fine* k.p.k. (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 24 kwietnia 2019, V KS 16/19; z dnia 25 czerwca 2019, III KS 20/19; z dnia 7 sierpnia 2019, III KS 27/19) – **wyrok Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt III KS 18/20**

- (...) uchylenie wyroku z powodu konieczności uzupełnienia postępowania dowodowego jedynie w części stanowi obrazę art. 437 § 2 zd. 2 *in fine* k.p.k.; jeżeli bowiem doszło do pominięcia ważnego dowodu, to sąd *ad quem* zobligowany jest zaistniałe uchybienie konwalidować – **wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2020 r., sygn. akt IV KS 30/20**
- (...) w razie istnienia podstaw do warunkowego umorzenia postępowania, Sąd nie powinien na podstawie art. 454 § 1 k.p.k. uchylać wyroku Sądu I instancji – **postanowienie Sądu Najwyższego z 20 października 2020 r., sygn. akt V KS 23/20**
- Naruszenie prawa do obrony w postaci niezawiadomienia obrońcy o terminie rozprawy z reguły ma wpływ na treść orzeczenia (por.m.in.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2019 r., V KS 41/19, w którym uznano, że „brak zawiadomienia o terminach rozpraw jednego z trzech obrońców, których może ustanowić oskarżony, stanowi naruszenie przepisów postępowania (art. 117 § 1 i art. 6 w zw. z art. 77 k.p.k.), powodujące konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości (art. 437 § 2 *in fine* k.p.k.), nawet jeżeli oskarżony korzystał w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji z pomocy dwóch innych obrońców”). Jednak w specyficznych okolicznościach tej sprawy należało ustalić, kiedy wygasło upoważnienie do obrony udzielone adwokatowi J. L. przez oskarżonego, bowiem w aktach sprawy nie widnieje żaden dokument, który wskazywałby na to wygaśnięcie (oprócz wspomnianej notatki urzędowej pozyskanej na etapie postępowania odwoławczego). Jeżeli stało się to przed rozpoznaniem sprawy na rozprawie przez Sąd Rejonowy, to uchybienie w postaci naruszenia obowiązku zawiadomienia adwokata o rozprawie mogło nie mieć wpływu na treść orzeczenia, skoro stosunek obrończy wygasł a jedynie ten fakt nie został przekazany do wiadomości organów procesowych przez obrońcę oskarżonego. Natomiast jeżeli do wygaśnięcia stosunku obrończego doszło już po przeprowadzeniu

rozprawy pierwszoinstancyjnej, to trudno będzie uznać, że naruszenie przez Sąd obowiązku zawiadomienia obrońcy o terminie rozprawy nie miało wpływu na treść wyroku – **wyrok Sądu Najwyższego z 1 października 2020 r., sygn. akt V KK 356/20**

- (...) biorąc pod uwagę, że przedmiotem rozpoznania jest zdarzenie historyczne a nie konkretna kwalifikacja prawna czynu, doprecyzowanie opisu czynu jest możliwe na etapie odwoławczym, zwłaszcza w sprawie, gdzie sam Sąd I instancji wskazuje, że jaki powinien być prawidłowy opis czynu i że tylko z uwagi na omyłkę nie dokonano tego na etapie pierwszoinstancyjnym – **wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2020 r., sygn. akt IV KS 22/19**
- (...) obecnie, stosownie do treści art. 437 § 2 k.p.k., uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1 k.p.k., art. 454 k.p.k. lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Stąd też w orzeczeniu kasatoryjnym niezbędne jest wyraźne sprecyzowanie, która z przesłanek wymienionych powyżej zdecydowała o treści rozstrzygnięcia sądu odwoławczego. Słusznie bowiem przyjmuje się w orzecznictwie, że „aby Sąd Najwyższy mógł ustosunkować się do podniesionych w skardze zarzutów, pisemne uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego winno być tak sformułowane, aby wynikało z niego jednoznacznie, która z przesłanek była podstawą uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2019 r., IV KS 39/19, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2017 r., II KS 3/17). (...) w obecnie funkcjonującym modelu postępowania odwoławczego sąd II instancji ma pełne prawo zarówno do uzupełniania materiału dowodowego, jak i do dokonywania nowej, odmiennej niż uczynił to sąd meriti oceny zgromadzonych dowodów oraz czynienia nowych ustaleń faktycznych, ale taki zakres orzekania musi być poprzedzony wnikliwą analizą wszystkich przeprowadzonych dowodów, przedstawieniem argumentacji uzasadniającej obdarzenie jednych z nich walorem wiarygodności i odmówienie tej wiarygodności innym dowodom oraz zaprezentowaniem nowych ustaleń faktycznych. W konsekwencji wywód ten musi również

spełniać wymagania określone w art. 424 § 1 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2020 r., sygn. akt I KS 7/20**

- *Ustawodawca ograniczył w art. 437 § 2 k.p.k. możliwości wydania wyroku kasatoryjnego jedynie do wypadków wskazanych w art. 439 § 1 k.p.k., art. 454 k.p.k. oraz do konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości. Przepis art. 454 k.p.k., do którego odwołał się Sąd II instancji stanowi natomiast, że Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie. Skoro w przepisie tym mowa o skazaniu, to poza zakresem wynikającego z niego zakazu pozostaje decyzja tego sądu o warunkowym umorzeniu postępowania oraz o umorzeniu postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu (...). Orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania oraz o umorzeniu postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu – bez względu na przesłanki wydania tych orzeczeń – nie stanowią wyroków skazujących – **wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2020 r., sygn. akt III KS 5/20***
- *Nieprawidłowe było wskazanie art. 440 k.p.k. jako podstawy uchylenia wyroku w tej sprawie. Zgodnie z tym przepisem, w razie stwierdzenia rażącej niesprawiedliwości orzeczenia, „podlega ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437 § 2 zdanie drugie uchyleniu”. O ile zatem nie ma przeszkód, aby Sąd odwoławczy zmienił wyrok na korzyść oskarżonego na podstawie art. 440 k.p.k. poza granicami zarzutów podniesionych w apelacji, o tyle już uchylenie wyroku w tym trybie jest uzależnione od tego, czy jednocześnie ziściła się przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 437 § 2 k.p.k., czyli bezwzględna podstawa odwoławcza z art. 439 § 1 k.p.k., zakaz ne peius z art. 454 k.p.k. lub konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości. W przedmiotowej sprawie żadna z tych przesłanek nie zaistniała – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2020 r., sygn. akt IV KS 54/19***
- *(...) podstawy wyroku kasatoryjnego są jasno i w pełni wymienione w art. 437 § 2 k.p.k. Obowiązkiem sądu odwoławczego jest wyraźne wykazanie i podanie jednej z tych podstaw w motywach wyroku*

kasatoryjnego; oczywiście bez wskazywania, jakie rozstrzygnięcie ma zapaść po ponownym rozpoznaniu sprawy. Zrozumiała obawa przed wkraczaniem w kompetencje sądu meriti nie usprawiedliwia tworzenia nieistniejących przesłanek wydania orzeczenia kasatoryjnego – **wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 2019 r., sygn. akt I KS 3/19**

- (...) obecna regulacja przewidziana w art. 437 k.p.k. wprowadziła istotną zmianę dotychczasowego modelu kontroli instancyjnej. Zakłada ona aktywną rolę sądu odwoławczego przy przeprowadzaniu dowodów i umożliwia ich samodzielną ocenę prowadzącą do dokonywania własnych ustaleń faktycznych. Natomiast wykazanie potrzeby przeprowadzenia przewodu sądowego w całości na nowo musi być powiązane z argumentacją potwierdzającą wadliwość przeprowadzenia wszystkich lub co najmniej zasadniczych dowodów w sprawie, której miałby dopuścić się Sąd I instancji – **wyrok Sądu Najwyższego z 18 lipca 2019 r., sygn. akt IV KS 24/19**
- (...) możliwość uchylecia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania związana z regułą *ne peius* określona w art. 454 § 1 k.p.k. (art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k.) zachodzi dopiero wtedy, gdy sąd odwoławczy – w wyniku usunięcia stwierdzonych uchybień stanowiących jedną z podstaw odwoławczych przewidzianych w art. 438 pkt 1–3 k.p.k. – stwierdza, że zachodzą podstawy do wydania wyroku skazującego, czemu stoi na przeszkodzie zakaz określony w art. 454 § 1 k.p.k. (zob. uchwała 7 s. SN z 20 września 2018 r., I KZP 10/18, OSNKW 2018 r., z. 11, poz. 73) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lipca 2019 r., sygn. akt II KS 15/19**
- (...) możliwość wydania przez sąd odwoławczy orzeczeń o charakterze kasatoryjnym jest obecnie w istotnym stopniu ograniczona, a to z uwagi na fakt, że została zastrzeżona tylko do wyjątkowych wypadków, wyraźnie wskazanych w ustawie. Wyjątkowy charakter sytuacji, w których dopuszczalne jest wydanie tego rodzaju judykatów, wywołuje również konieczność jednoznacznego wskazywania w treści ich uzasadnień, która z przesłanek określonych w art. 437 § 2 k.p.k. stała się podstawą uchylenia wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania (zob.m.in. postanowienie Sądu Najwyższego

z dnia 11 kwietnia 2018 r., IV KS 7/18, LEX nr 2499850) – **wyrok Sądu Najwyższego z 10 lipca 2019 r., sygn. akt IV KS 17/19**

- Istota reformatoryjnego orzekania w II instancji w sprawach karnych polega właśnie na tym, że skoro pewne elementy materiału dowodowego można dla wydania merytorycznego rozstrzygnięcia przeprowadzić na rozprawie odwoławczej, to należy z tej możliwości skorzystać. Orzeczenia kasatoryjne stanowią wyjątek od reguły i być zarezerwowane dla najbardziej błędnie przeprowadzonych postępowań – **wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt IV KS 15/19**
- (...) spośród trzech przesłanek uchylenia przez sąd drugiej instancji zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, wymienionych w art. 437 § 2 zdanie drugie k.p.k., stwierdzenie konieczności ponownego przeprowadzenia w całości, przez sąd pierwszej instancji, przewodu sądowego, ma znaczenie szczególne. Przesłanka ta stanowi wyraźne odstępstwo od czystego modelu apelacyjnego. Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k., jako powód uchylenia przez sąd odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, zachodzi wówczas, gdy orzekający sąd pierwszej instancji naruszył przepisy prawa procesowego, co skutkowało, w realiach sprawy, nierzetelnością prowadzonego postępowania sądowego, uzasadniającą potrzebę powtórzenia (przeprowadzenia na nowo) wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy w sądzie pierwszej instancji – **uchwała Sądu Najwyższego z 22 maja 2019 r., sygn. akt I KZP 3/19**
- (...) wymieniona w przepisie art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k. podstawa uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania z powodu konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości może budzić wątpliwości interpretacyjne. Użyte tu słowo „przewód” należy potraktować jako skrót pojęciowy, gdyż ustawa posługuje się pełnym określeniem „przewód sądowy” (rozdział 45). Na pierwszoinstancyjnym przewodzie sądowym przeprowadzane są dowody, a jego zasadniczą część stanowi postępowanie dowodowe. Przepis art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k. stanowi jednak nie „o powtórzeniu dowodów”, ale o powtórzeniu „przewodu”,

stąd konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości nie odnosi się tylko do potrzeby powtórzenia dowodów i może również dotyczyć samego przebiegu przewodu sądowego, gdy z uwagi na naruszenie przepisów procesowych niezwiązanych z przeprowadzaniem dowodów należy powtórzyć go w całości. Kontekst językowy użytego tu sformułowania „w całości” prowadzi do stwierdzenia, że chodzi tu o potrzebę ponownego przeprowadzenia wszystkich czynności na przewodzie sądowym – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 16 maja 2019 r., sygn. akt II AKa 59/19

Ad. 8.2. Wniosek apelacji w przypadku wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej

W art. 439 § 1 k.p.k. wyraźnie wskazano, że Sąd Odwoławczy uchyla zaskarżone orzeczenie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z bezwzględnych przyczyn odwoławczych, wskazywanych w tym przepisie. Z doświadczenia egzaminacyjnego wynika, że zdający zazwyczaj nie mają problemów z prawidłowym sformułowaniem wniosku o uchylenie orzeczenia. Problem pojawia się jednak z dalszą częścią wniosku – zdający albo w ogóle nie wnoszą o umorzenie postępowania bądź przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, albo też nie wiedzą, co powinno dalej stać się z postępowaniem po uchyleniu zaskarżonego wyroku przez sąd odwoławczy.

Należy podkreślić, że skutkiem uchylenia wyroku jest wyłącznie wyeliminowanie wadliwego orzeczenia sądu I instancji z obrotu prawnego. Taka decyzja sądu odwoławczego nie wpływa jednak na los całego postępowania w tym sensie, że po uchyleniu wadliwego orzeczenia sądu I instancji nadal do rozpoznania pozostaje wniesiona przez oskarżyciela skarga, tj. akt oskarżenia. Sformułowanie zatem wyłącznie wniosku o uchylenie orzeczenia jest wadliwym wnioskiem, albowiem jest on niepełny. Sąd odwoławczy nie wie, co zdaniem skarżącego miałoby stać się z postępowaniem karnym zainicjowanym aktem oskarżenia po uchyleniu wyroku. Problemy w tym zakresie wynikają zaś z tego, że ani z art. 439 § 1 k.p.k., ani z art. 17 § 1 k.p.k. (do którego odwołuje się art. 439 § 1 pkt. 9 k.p.k.) nie wynika wprost jaki powinien być dalszy wniosek

poza uchyleniem zaskarżonego orzeczenia sądu I instancji. Nie jest pomocny w omawianym zakresie także art. 437 § 2 k.p.k., który w zd. 1 w sposób ogólny odwołuje się do „*uchylenia i umorzenia postępowania*”, zaś w zd. 2 do „*uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania*”, bez wskazania które z powyższych dwóch rozstrzygnięć zastosować w przypadku wystąpienia poszczególnych przyczyn odwoławczych z art. 439 § 1 k.p.k.

Kryterium rozstrzygającym, który z wniosków (o umorzenie postępowania czy o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania) należy sformułować obok wniosku o uchylenie zaskarżonego orzeczenia jest to, czy postępowanie – wobec wystąpienia konkretnej bezwzględnej przyczyny odwoławczej – w ogóle mogłoby być dalej prowadzone.

Jeśli wyrok sądu I instancji obarczony jest bezwzględną przyczyną odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. (tj. w przypadku upływu okresu przedawnienia karalności), niezależnie od jakichkolwiek innych okoliczności występujących w sprawie, postępowanie nie będzie mogło się toczyć. Podobnie będzie w przypadku śmierci oskarżonego. Jeśli natomiast przyczyną uchylenia wyroku jest brak obecności któregośkolwiek z członków składu orzekającego na całej rozprawie, wówczas postępowanie może się dalej toczyć, z wyeliminowaniem przy ponownym rozpoznaniu błędu, który doprowadził do uchylenia wyroku sądu I instancji (tj. przy udziale wszystkich członków składu orzekającego na całej rozprawie – a zatem na każdym poszczególnym terminie rozprawy głównej, jeśli sąd odraczał terminy teje albo zarządzał w rozprawie przerwę).

W konsekwencji powyższego:

- *jeśli w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. – należałoby wniesć o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- *jeśli sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie – należałoby wniesć o uchylenie*

zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;

- jeśli sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- jeśli sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- jeśli orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznanie ustawie – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- jeśli zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- jeśli zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- jeśli zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*
- jeśli oskarżony zmarł – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*
- jeśli nastąpiło przedawnienie karalności – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*
- jeśli sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*
- jeśli brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*
- jeśli brak jest wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*

- *jeśli zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania;*
- *jeśli oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k. lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*
- *jeśli sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa – należałoby wnieść o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;*

Ad. 8.3. Powołanie nowych faktów lub dowodów w apelacji

Jak wskazano powyżej, po wejściu w życie 1 lipca 2015 r. nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, istotnej zmianie uległ model postępowania odwoławczego, w tym art. 427 § 3 k.p.k.⁶⁸ W poprzednim stanie prawnym wskazywanie nowych faktów i dowodów w apelacji nie podlegało ograniczeniom. Aktualnie ustawodawca wskazuje natomiast, że ***Odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie mógł powołać ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.*** Powyższe wprowadza zatem konieczność wykazania przez apelującego, że nie miał on możliwości powołania wnioskowanych w środku odwoławczym faktów lub dowodów na etapie postępowania przed sądem I instancji.

Wyraźnego zaakcentowania wymaga zatem, że **z łącznego odczytywania art. 427 § 3 k.p.k. i art. 452 § 2 pkt 2 i 3 k.p.k. wynika, że w odniesieniu do**

⁶⁸ Podkreślenia wymaga również, że art. 1 pkt 72 ustawy z 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1694) do k.p.k. dodano art. 427 § 3a k.p.k., obowiązujący od 5 października 2019 r., zgodnie z którym w środku odwoławczym nie można podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu, chyba że okoliczność, która ma być udowodniona, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego, lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym na podstawie art. 93g Kodeksu karnego.

nowych dowodów i faktów, dotyczących istoty sprawy brak jest w obecnym stanie prawnym prekluzji dowodowej. Zawsze zatem wtedy gdy sądowi I instancji nie było znane źródło dowodowe albo gdy pojawiło się ono już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, uzasadnione jest sformułowanie w apelacji wniosku o przeprowadzenie takiego dowodu przez sąd odwoławczy. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 grudnia 2018 r. wyraził jednoznaczny pogląd, że z uwagi na aktualne brzmienie art. 452 § 2 k.p.k. oraz treść art. 167 k.p.k. regułą jest obecnie prowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego przed sądem drugiej instancji i orzekanie reformatoryjne, zaś uchylenie wyroku sądu meriti w oparciu o przesłankę z art. 437 § 2 *in fine* k.p.k. powinno mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy bez ponowienia wszystkich dowodów nie jest możliwe wydanie trafnego rozstrzygnięcia⁶⁹.

Zaakcentowania również wymaga, że sąd odwoławczy, działając na podstawie art. 452 § 2 k.p.k., oddala wnioski dowodowe⁷⁰ w sytuacji, gdy przeprowadzenie dowodu przez ten sąd byłoby niecelowe z przyczyn określonych w art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k. (przypadki, w których sąd odwoławczy powinien wydać orzeczenie kasatoryjne) bądź też, gdy dowód nie był powołany przed sądem I instancji, pomimo że składający wniosek mógł go wówczas powołać, lub okoliczność, która ma być udowodniona, dotyczy nowego faktu, niebędącego przedmiotem postępowania przed sądem pierwszej instancji, a składający wniosek mógł go wówczas wskazać. Jednocześnie w art. 452 § 3 k.p.k. ustawodawca wskazał, że w tym drugim przypadku wniosku dowodowego nie można oddalić, jeżeli okoliczność, która ma być udowodniona, w granicach rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy, ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach, o których mowa w art. 64 k.k. lub art. 65 k.k., lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym na podstawie art. 93g k.k.

Odwołując się do zasad prawniczego wnioskowania logicznego, jeśli nie zachodzi przypadek, o jakim mowa w art. 452 § 2 i 3 k.p.k. oraz w art. 427

⁶⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt IV KS 29/18.

⁷⁰ Dla porządku zaznaczenia również wymaga, że sąd II instancji może oddalić wnioski dowodowe także na podstawie art. 170 § 1 pkt 1–6 k.p.k., którego odpowiednie stosowanie na etapie odwoławczym nie jest wyłączone (art. 458 k.p.k.).

§ 3 k.p.k., to przyjąć należu, że sąd odwoławczy nie może oddalić zgłoszonego w apelacji wniosku dowodowego, szczególnie że z uwagi na aktualne brzmienie art. 452 § 2 k.p.k. oraz treść art. 167 k.p.k. regułą jest obecnie prowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego przed sądem drugiej instancji i orzekanie reformatoryjne⁷¹.

Z powyższego wynika, że **jeśli na etapie postępowania odwoławczego nadal istnieją braki w płaszczyźnie dowodowej, wymagające wyjaśnienia, to sąd II instancji powinien w miarę możliwości braki te uzupełnić, nie zaś uchylać rozstrzygnięcie do ponownego rozpoznania**⁷². Dostrzeżenia wymaga również stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym w obowiązującym modelu postępowania odwoławczego, sąd drugiej instancji nie rozpoznaje sprawy ponownie, tylko kontroluje (zasadniczo w granicach zaskarżenia i – o ile je wskazano – podniesionych zarzutów) orzeczenie sądu pierwszej instancji. W związku z tym sąd odwoławczy jedynie uzupełniająco przeprowadza dowody, gdyż czyni to – co do zasady – w granicach kontroli odwoławczej (art. 433 § 1 k.p.k.)⁷³.

Łącząc powyższe tezy, należy dojść do wniosku, że w przypadku podnoszenia w apelacji zarzutów, które sprowadzają się do twierdzenia, że w dalszym ciągu w sprawie występują okoliczności/fakty, wymagające wyjaśnienia i jest to nadal procesowo możliwe oraz dopuszczalne, to należy takie wnioski dowodowe w apelacji zgłosić⁷⁴. Podstawą wniosku w tym zakresie jest art. 167 k.p.k. (stosowany odpowiednio w postępowaniu odwoławczym, na podstawie art. 458 k.p.k.) oraz 427 § 3 k.p.k., który wprost wskazuje, że odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie mógł powołać ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

⁷¹ Wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt IV KS 29/18.

⁷² Obowiązkiem sądu odwoławczego jest uzupełnienie postępowania dowodowego w sytuacji, gdy dostrzeża on braki w zakresie dotychczas przeprowadzonych dowodów, a jednocześnie jest to z jednej strony możliwe, a z drugiej, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy – wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt V KK 512/19.

⁷³ Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt V KK 280/19.

⁷⁴ Zaznaczenia jednocześnie wymaga, że uwaga ta dotyczy nowych, dotychczas niezgłoszonych wniosków dowodowych. Zagadnienie ponowienia w postępowaniu odwoławczym wniosków dowodowych uprzednio oddalonych omówione zostało w „Sytuacja 1” oraz w kolejnym podrozdziale.

Komentarza wymaga dodatkowo kwestia zasadności formułowania wniosków dowodowych w apelacji w kontekście formułowanych w środku odwoławczym zarzutów. Zagadnienie to wymaga odrębnego omówienia dwóch odmiennych sytuacji procesowych, z jakimi możemy spotkać się w praktyce.

Sytuacja 1 – Jeśli sąd I instancji miał informacje o dowodzie i jej nie wykorzystał (np. z akt wynikało nazwisko świadka zdarzenia, jednak sąd nie przesłuchał tej osoby w charakterze świadka), a także wtedy gdy wniosek dowodowy strony został w postępowaniu przed sądem I instancji oddalony, apelujący sformułuje w środku odwoławczym odpowiednio albo zarzut obrazy art. 167 k.p.k., albo obrazy art. 170 § 1 k.p.k. W przypadku gdy sąd odwoławczy uznałby te zarzuty za uzasadnione, wówczas powinien te pominięte dowody przeprowadzić, naprawiając tym samym „błąd” sądu I instancji. Uwzględniając zatem fakt, że w obecnym modelu postępowania odwoławczego sąd II instancji działa co do zasady reformatoryjnie (za wyjątkiem przypadków określonych w art. 437 § 2 *in fine* k.p.k.), niepotrzebnym wydaje się w takiej sytuacji procesowej formułowanie w apelacji dodatkowych wniosków dowodowych w omawianym zakresie.

Sytuacja 2 – Natomiast inaczej kształtuje się sytuacja, gdy sądowi I instancji nie było znane źródło dowodowe (np. dowód istniał, ale strona nie złożyła w tym zakresie wniosków) albo dowód ujawniony został już po wydaniu wyroku I instancji. W takich sytuacjach procesowych nie można sądowi I instancji czynić zarzutu braku wymaganej aktywności w celu dotarcia do prawdy materialnej. W odniesieniu do takich przypadków uzasadnione byłoby zatem sformułowanie w środku odwoławczym wniosku dowodowego z jednoczesnym zarzutem błędu w ustaleniach faktycznych, który jest wynikiem dokonywania tych ustaleń bez informacji wynikających z nieprzeprowadzonego dowodu. Nie jest to w oczywisty sposób okoliczność obciążająca sąd I instancji (skoro sądowi nie było znane źródło dowodowe albo źródło to ujawnione zostało już po wyroku), ale obiektywnie wyrok tego sądu nie jest prawidłowy, skoro nie uwzględnia okoliczności, które wynikałyby z tego nieprzeprowadzonego dowodu, obecnie zgłoszonego w apelacji. Apelujący wnosi zatem o uzupełnienie materiału dowodowego przez sąd odwoławczy

(zgłaszając omawiane wnioski dowodowe) i następnie dokonanie ustaleń stanu faktycznego z uwzględnieniem wyników uzupełnionego postępowania dowodowego.

Należy również pamiętać, że poza precyzyjnym określeniem w *petitum* apelacji środka dowodowego oraz okoliczności, na jakie dowód ten ma zostać przeprowadzony (tj. okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia), **wskazane jest również umotywowanie w uzasadnieniu apelacji zgłoszenia tychże wniosków na etapie postępowania odwoławczego z perspektywy niewystąpienia przesłanek art. 452 § 2 i 3 k.p.k.**

Przykład: Na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. oraz art. 427 § 3 k.p.k., wnoszę o dopuszczenie przez sąd II instancji dowodu z przesłuchania Andrzeja Zetowskiego w charakterze świadka (wezwanie na adres: ul. Klonowa 1/3, 00-002 Warszawa), na okoliczność zaobserwowanego przez świadka stanu psychofizycznego pokrzywdzonego w dniu zdarzenia, objętego niniejszym postępowaniem karnym, tj. znajdowania się przez pokrzywdzonego w stanie wskazującym na znaczne upojenie alkoholowe, co mogło mieć istotny miało wpływ na percepcję pokrzywdzonego i sposób zapamiętywania przez niego faktów, a który to dowód nie był znany na etapie postępowania przed sądem I instancji, albowiem świadek nawiązał kontakt z oskarżonym już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, informując oskarżonego, że posiada wiedzę na wnioskowany temat, o czym oskarżony dotychczas nie wiedział.

Przydatne orzecznictwo:

- *Zauważyć przecież trzeba, że choć art. 451 § 2 k.p.k. od 2016 r. otrzymał brzmienie „negatywne”, to odczytywany a contrario daje sądom odwoławczym podstawę do przeprowadzania postępowania dowodowego i to również co do istoty sprawy. Bezsprzecznie dowody te zgodnie z dyspozycją art. 167 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. przeprowadza się zarówno na wniosek stron, jak i z urzędu. Obowiązkiem sądu odwoławczego jest zatem uzupełnienie postępowania dowodowego w sytuacji, gdy dostrzeże on braki w zakresie dotychczas przeprowadzonych dowodów, a jednocześnie jest to z jednej strony możliwe, a z drugiej, ma znaczenie*

dla rozstrzygnięcia sprawy – wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt V KK 512/19

- *W obowiązującym modelu postępowania odwoławczego, sąd drugiej instancji nie rozpoznaje sprawy ponownie, tylko kontroluje (zasadniczo w granicach zaskarżenia i – o ile je wskazano – podniesionych zarzutów), orzeczenie sądu pierwszej instancji. W związku z tym sąd odwoławczy jedynie uzupełniając przeprowadza dowody, gdyż czyni to – co do zasady – w granicach kontroli odwoławczej (art. 433 § 1 k.p.k.). W konsekwencji zakres prawa do obrony w postępowaniu odwoławczym związany z prawem do złożenia wyjaśnień limitowany jest tymi granicami – postanowienie Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt V KK 280/19*
- *Treść art. 437 § 1 i 2 k.p.k. nie pozostawia przecież wątpliwości co do tego, iż sądowi ad quem przyznane zostało uprawnienie także do orzekania odmiennego co do istoty sprawy, o ile pozwalają na to zebrane dowody – „sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty”. Z kolei zakres merytorycznego orzekania przez sąd drugiej instancji wiąże się również z przyjętym przez ustawodawcę modelem postępowania odwoławczego. Orzekanie co do istoty sprawy, a zatem – co do zakresu odpowiedzialności oskarżonego – umożliwia w praktyce sądowi odwoławczemu treść art. 452 § 2 k.p.k., który pozwala także i na przeprowadzenie dowodów na rozprawie apelacyjnej. Jeśli chodzi o tę ostatnią możliwość, to w postępowaniu odwoławczym nie ma żadnych ograniczeń, co do wykorzystania źródeł dowodowych, zaś sąd ad quem przeprowadzając dowód na rozprawie apelacyjnej, jest przede wszystkim sądem merytorycznym. W postępowaniu odwoławczym dowody są przeprowadzane na tych samych zasadach, co przed sądem pierwszej instancji. Podstawą orzeczenia zmieniającego mogą być zarówno dowody zgromadzone tak sądem pierwszej instancji, jak i dowody przeprowadzone w postępowaniu odwoławczym – wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 lipca 2018 r., sygn. akt II AKa 92/18*
- *Z treści art. 452 § 2 k.p.k. wynika jasna zasada, że sąd odwoławczy sam przeprowadza dowody, a nie w celu ich przeprowadzenia uchyła zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (zob. D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach*

karnych. Komentarz i orzecznictwo. Warszawa 2018, s. 348; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 r., sygn. akt IV KS 29/18) – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2019 r., sygn. akt V KS 18/19**

- Z uwagi na aktualne brzmienie art. 452 § 2 k.p.k. oraz treść art. 167 k.p.k. regułą jest obecnie prowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego przed sądem drugiej instancji i orzekanie reformatoryjne, zaś uchylenie wyroku sądu meriti w oparciu o przesłankę z art. 437 § 2 *in fine* k.p.k. powinno mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy bez ponowienia wszystkich dowodów nie jest możliwe wydanie trafnego rozstrzygnięcia. Trafnie dostrzega się w piśmiennictwie, że poza podstawami oddalenia wniosku dowodowego określonymi w art. 170 § 1 k.p.k. i w art. 452 § 2 k.p.k. sąd odwoławczy nie jest blokowany innymi ograniczeniami w przeprowadzaniu dowodów, co umożliwia merytoryczne orzekanie także na podstawie dowodów przeprowadzonych w drugiej instancji (...) – **wyrok Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt IV KS 29/18**
- Podstawy oddalenia wniosku dowodowego zawiera przepis art. 170 k.p.k., który jako przepis ogólny ma zastosowanie także w postępowaniu odwoławczym. Natomiast art. 452 § 2 k.p.k. stanowi dodatkową podstawę oddalenia wniosku dowodowego odnoszącą się tylko do postępowania odwoławczego. Stanowi więc uzupełnienie podstaw oddalenia wniosku dowodowego wskazanych w art. 170 § 1 k.p.k. (vide D. Świecki, Komentarz do zmian w k.p.k. wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437) Część I. – art. 452 k.p.k., s. 535, Warszawa, 2016). Przepis art. 452 § 2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia w życie wyżej cytowanej ustawy, tj. od dnia 15 kwietnia 2016 r., nie ma charakteru obligatoryjnego. Zatem przeprowadzenie określonego dowodu w postępowaniu odwoławczym zależne jest od oceny sądu, która motywowana jest z kolei potrzebą ewentualnego poczynienia dodatkowych ustaleń faktycznych w ramach postępowania kontrolnego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 17 maja 2017 r., sygn. akt IV KK 139/17**
- Zatem w realiach sprawy oddalenie przez Sąd Okręgowy wniosków dowodowych zawartych w apelacji prawa nie naruszyło, także dlatego, że podstawą tej decyzji był m.in. przepis art. 427 § 3 k.p.k., w świetle którego

*odwołujący się może wskazać nowe dowody wtedy, gdy nie mógł ich powołać przed sądem I instancji, która to sytuacja w niniejszej sprawie nie miała miejsca. Zupełnie chybione jest przy tym przekonanie skarżącego, że na etapie postępowania apelacyjnego podstawą oddalenia wniosku dowodowego jest „tylko i wyłącznie” przepis art. 452 § 2 k.p.k. Sąd Najwyższy wielokrotnie, nie tylko w powołanych w odpowiedzi na kasację wyrokach z dnia 4 lutego 2015 r., II KK 57/14, LEX nr 1646021 i z dnia 8 grudnia 2016 r., II KK 252/16, LEX nr 2195663 wskazywał, że błędne jest oparcie przez sąd odwoławczy decyzji o oddaleniu wniosku dowodowego na przepisie art. 452 § 2 k.p.k. Wypada wszakże zaznaczyć, że po zmianie z dniem 15 kwietnia 2016 r. brzmienia tego przepisu powinien on zostać wskazany jako podstawa prawnej wspomnianej decyzji, o ile przeprowadzenie dowodu przez sąd odwoławczy byłoby niecelowe z przyczyn określonych w art. 437 § 2 zdanie drugie. Taki przypadek w rozpatrywanej sprawie jednak nie zachodził – **postanowienie Sądu Najwyższego z 19 października 2017 r., sygn. akt IV KK 336/17***

- *Dotychczasowe orzecznictwo o decyzjach sądu odwoławczego nie jest całkowicie aktualne w stanie prawnym obecnie obowiązującym. Nowy model postępowania odwoławczego w znacznym stopniu zawęził możliwość uchylecia wyroku z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, ograniczając ją do zasady ne peius oraz konieczności powtórzenia postępowania dowodowego w całości. Nieaktualne są te wywody Sądu Najwyższego, w których wskazywano na konieczność uchylecia wyroku omal w każdym wypadku podejmowania nowej decyzji czy oceny – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 listopada 2016 r., sygn. akt II AKa 175/16, LEX nr 2287992***

Ad. 8.4. Ponowienie w apelacji wniosków dowodowych, które podlegały oddaleniu na etapie postępowania przed Sądem I instancji

Jeśli w toku postępowania przed sądem I instancji wydane zostało postanowienie o oddaleniu wniosków dowodowych, które to wnioski zdaniem

autora apelacji miały prowadzić do wykazania korzystnych dla oskarżonego faktów bądź okoliczności, to zasadnym i spójnym ze sformułowanymi w apelacji zarzutami jest ponowienie tychże oddalonych w I instancji wniosków dowodowych w złożonym środku odwoławczym. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 167 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k.

Jeśli zatem autor apelacji formułuje np. zarzut obrazu art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k., polegający na bezzasadnym oddaleniu wniosku o przesłuchanie X w charakterze świadka (który to świadek ma mieć istotną wiedzę na temat przebiegu zdarzenia, będącego przedmiotem postępowania), to spójnym z ww. zarzutem będzie sformułowanie w *petitum* apelacji dodatkowego wniosku na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k. o przeprowadzenie tego oddalonego dowodu na etapie postępowania odwoławczego. Podobnie, jeśli Sąd I instancji oddalił wniosek o powołanie nowej opinii biegłego na podstawie art. 201 k.p.k. *a contrario*, a autor apelacji w tej decyzji procesowej upatruje błędu procesowego, wówczas właściwym byłoby ponowienie w apelacji, na podstawie art. 167 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k., uprzednio złożonego wniosku w trybie art. 201 k.p.k.

Rozdział 9.

Najczęstsze zarzuty oraz zagadnienia apelacyjne w oparciu o zasady wypracowane przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne

O ile we wcześniejszych fragmentach niniejszej publikacji wskazane zostało, że zarzutów apelacyjnych nie da się skatalogować w formie prostej tabeli, jakie zarzuty formułować niezależnie od okoliczności, to z orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego wynikają pewne zasady, których znajomość ułatwia prawidłowe formułowanie zarzutów. Wiedza w tym zakresie pozwala także na uniknięcie błędów merytorycznych, które – jak wynika z mojego doświadczenia egzaminacyjnego – zdarzają się zbyt często i w istotny sposób wpływają na końcową ocenę pracy.

Wybrane zagadnienia przedstawione zostały poniżej w formie krótkich pytań i odpowiedzi. Dodatkowo, dla ułatwienia przygotowań zdających, przytoczone zostało również najważniejsze orzecznictwo, potwierdzające sformułowane tezy.

Ad. 9.1. Czy zasady procesowe mogą być podstawą zarzutu apelacyjnego?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, zasady procesowe nie powinny być podstawą zarzutu apelacyjnego, za wyjątkiem zasad wynikających z art. 5 § 2 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 6 k.p.k. Zaznaczenia jednak wymaga, że formułowanie zarzutu obraży art. 5 § 2 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 6 k.p.k. wymaga spełnienia określonych warunków, co szerzej omówione zostało w podrozdziałach 9.2., 9.3. i 9.4.

W kontekście natomiast zbyt często pojawiających się w apelacjach zarzutów obraży art. 2 k.p.k. czy art. 4 k.p.k., jednoznacznego stwierdzenia wymaga, że takie działanie jest błędem i pozostaje w sprzeczności

z ugruntowaną linią orzecniczą, ukształtowaną na tle tych przepisów.

Zasady procesowe to przecież pewne ogólne wytyczne, jakim odpowiadać powinien prawidłowo przeprowadzony proces karny. Dyrektywy właściwego postępowania mają charakter ogólny, a ich doprecyzowaniem są przepisy Kodeksu postępowania karnego, określające w dalszej części tego aktu prawnego funkcjonowanie określonej instytucji prawa procesowego (np. umożliwienie powoływania dowodów z urzędu w oparciu o art. 167 k.p.k. służy realizacji zasady prawdy materialnej, zaś norma wynikająca z art. 410 k.p.k. ma urzeczywistniać zasadę obiektywizmu). Skoro zatem w apelacji zdający twierdzi, że sąd I instancji dokonał wadliwej oceny dowodów, to oczywiste jest, że nie mógł być jednocześnie obiektywny i nie dotarł do prawdy materialnej. Sugerowane jest zatem nieformułowanie w apelacjach zarzutów obrazy art. 2 k.p.k. czy art. 4 k.p.k.⁷⁵ – przy czym bez znaczenia w omawianym kontekście pozostaje to, czy przepisy te miałyby być samodzielną podstawą zarzutu czy też miałyby pozostawać w związku z innym, bardziej sprecyzowanym naruszeniem.

Przydatne orzecznictwo, potwierdzające że art. 2 k.p.k. i art. 4 k.p.k. nie mogą być podstawą zarzutów apelacyjnych i kasacyjnych:

- (...) *przepis art. 2 § 2 k.p.k. nie może stanowić podstawy zarzutu kasacyjnego, gdyż stanowi on generalną dyrektywę działania organów wymiaru sprawiedliwości i dopiero wykazanie naruszenia szczegółowych norm procesowych stanowiących jego konkretyzację, może być traktowane jako spełnienie ustawowego wymagania przedstawienia zarzutów kasacyjnych – postanowienie Sądu Najwyższego z 9 lutego 2021 r., sygn. akt III KK 356/20*
- (...) *naruszenie przepisów art. 2 § 2 k.p.k. bądź art. 4 k.p.k. – mających charakter gwarancji procesowych – nie może stanowić podstawy apelacji lub kasacji. Przestrzeganie naczelnych zasad procesu karnego jest gwarantowane w przepisach szczegółowych i dopiero wskazanie naruszenia*

⁷⁵ Zaznaczenia wymaga, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach procesowych dopuszczalne jest formułowanie zarzutu obrazy art. 4 k.p.k., występującego w związku z innym przepisem Kodeksu postępowania karnego, np. 4 k.p.k. w zw. z art. 41 k.p.k. Jest to jednak wyjątek nie zaś reguła, o czym należy pamiętać.

tych konkretnych, szczegółowych przepisów może uzasadniać zarzut apelacyjny, zażaleniowy lub kasacyjny. Niezbędne jest tu zatem wykazanie konkretnej normy prawnej procesowej, którą naruszono w związku z przedmiotową zasadą (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. akt V KK 332/03; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt II KK 239/17) – postanowienie Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt III KK 147/20

- *Podstawy stawianych zarzutów nie mogą stanowić przepisy postępowania o charakterze ogólnym, które wyznaczają ogólne zasady postępowania karnego. Taki zaś charakter ma przepis art. 2 § 2 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 grudnia 2019 r., sygn. akt II AKa 180/19*
- (...) *w orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie prezentowany jest pogląd, iż zarzut obrazy prawa procesowego powinien opierać się na naruszeniu norm tworzących konkretne nakazy lub zakazy, a nie norm o charakterze ogólnym, taki zaś charakter mają powołane przez obrońcę przepisy art. 2 § 2 k.p.k. i art. 4 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 maja 2019 r., sygn. akt II AKa 58/19*
- (...) *art. 2 § 2 k.p.k. i 4 k.p.k. stanowią zasady ogólne procesu karnego i z utrwalonego w tym zakresie orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego jak również Sądów Apelacyjnych nie mogą one stanowić samodzielnej podstawy zarzutów apelacyjnych – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 lutego 2019 r., sygn. akt II AKa 322/18*

Ad. 9.2. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 5 § 2 k.p.k. i czy prawidłowe jest łączenie tego zarzutu z art. 7 k.p.k. albo z art. 410 k.p.k.

Z doświadczenia egzaminacyjnego wynika, że w apelacjach często formułowany jest wadliwy merytorycznie zarzut obrazy art. 5 § 2 k.p.k. Zdający zarzucają naruszenie zasady *in dubio pro reo* wtedy, gdy chcą zakwestionować ocenę dowodów dokonaną przez sąd I instancji i zamiast formułować zarzut obrazy art. 7 k.p.k., błędnie decydują się na sformułowanie zarzutu z art. 5 § 2 k.p.k.

Tymczasem zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, **zarzut obraży art. 5 § 2 k.p.k. tylko wówczas będzie prawidłowy i skuteczny, gdy odnosi się do wątpliwości sądu, nie strony.** Innymi słowy, formułując ten zarzut należy wykazać, że sąd, a nie obrońca czy pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, rzeczywiście miał wątpliwości, których nie udało się usunąć i jednocześnie nie rozstrzygnął tychże wątpliwości na korzyść oskarżonego. Z oczywistych względów w bardzo rzadkich sytuacjach w uzasadnieniach wyroków spotkamy się z przyznaniem przez sąd, że takowe wątpliwości rzeczywiście miał i jednocześnie rozstrzygnął je na niekorzyść oskarżonego. Sąd bowiem z reguły wskazuje, że korzystając z art. 7 k.p.k., rozstrzygnął wszelkie wątpliwości i dał wiarę określonym dowodom, w związku z czym nie miał w ogóle potrzeby sięgania po art. 5 § 2 k.p.k.

Pamiętać również należy, że w orzecznictwie od lat wskazuje się, że **zarzuty obraży art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. mają charakter rozłączny** – albo bowiem sąd ocenił materiał dowodowy (nie dając wiary określonym dowodom, usunął tym samym ewentualne wątpliwości, jakie mogłyby powstać) i nie musiał w ogóle sięgać po art. 5 § 2 k.p.k., albo sięgnął po art. 5 § 2 k.p.k., a zatem – logicznie rzecz ujmując – nie mógł jednocześnie obrazić art. 7 k.p.k. **W analogicznym stopniu powyższe uwagi odnoszą się do art. 410 k.p.k.**, albowiem przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy sąd opiera swoje orzeczenie na materiale nieujawnionym na rozprawie głównej, bądź tylko na części materiału ujawnionego i jego rozstrzygnięcie nie jest wynikiem analizy całokształtu ujawnionych okoliczności. Odwołując się do zasad prawidłowego rozumowania – skoro sąd nie ocenił materiału dowodowego w jego całokształcie, to nie może jednocześnie być mowy o wątpliwościach, których nie da się usunąć i które w dalszej kolejności rozstrzygane są na niekorzyść oskarżonego.

Przydatne orzecznictwo, wskazujące okoliczności w jakich zarzut obraży art. 5 § 2 k.p.k. byłoby merytorycznie uzasadniony, jak również potwierdzające rozłączny charakter zarzutów obraży art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k.:

- (...) zastosowanie art. 5 § 2 k.p.k. możliwe jest jedynie wówczas gdy mimo przeprowadzenia wszystkich możliwych dowodów oraz dokonania ich oceny, spełniającej wymogi określone w art. 7 k.p.k. pojawia się w sprawie wątpliwości, których nie da się wyeliminować – **wyrok**

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 października 2021 r., sygn. akt II AKa 286/20

- (...) warunkiem skutecznego zarzutu naruszenia zasady *in dubio pro reo* jest wykazanie, że pomimo rozstrzygania na podstawie kompletnej i prawidłowo ocenionej podstawy dowodowej nadal, w kategoriach obiektywnych, istnieje stan niedających się usunąć wątpliwości. To powoduje, że zarzut naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. nie może być stawiany łącznie z obrazą art. 7 k.p.k. Jeżeli bowiem skarżący kwestionuje ocenę dowodów i wynikające z niej ustalenia, to powyższe wyklucza naruszenie przywołanej reguły – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt II AKa 24/21**
- Dla zasadności zarzutu obrazy art. 5 § 2 k.p.k. nie wystarczy zaprezentowanie przez skarżącego własnych wątpliwości, co do stanu dowodów. O naruszeniu tego przepisu można mówić wówczas, gdy sąd ustalając, że zachodzą niedające się usunąć wątpliwości, nie rozstrzygnie ich na korzyść oskarżonego, co w tej sprawie nie miało miejsca. (...) Jednocześnie należy pamiętać, że naruszenie zasady *in dubio pro reo* możliwe jest jedynie wtedy, gdy sąd w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe i w sposób zgodny z art. 7 k.p.k. ocenił zgromadzone dowody, a pomimo tego z dowodów uznanych za wiarygodne nadal wynikają co najmniej dwie wersje faktyczne i organ procesowy rozstrzyga niedające się usunąć wątpliwości niezgodnie z kierunkiem określonym w przepisie art. 5 § 2 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lipca 2021 r., sygn. akt IV KK 726/19, LEX nr 3232651**
- (...) zarzut obrazy art. 5 § 2 k.p.k. nie może być podnoszony jednocześnie z zarzutem naruszenia art. 7 k.p.k., gdyż dotyczy wtórnej do ustaleń faktycznych płaszczyzny procedowania. Niedające się usunąć wątpliwości mogą powstać jedynie wówczas, gdy sąd orzekający, po wyczerpaniu wszystkich możliwości dowodowych, oceni materiał dowodowy zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez zasadę swobodnej oceny dowodów. Zatem przepisy art. 5 § 2 k.p.k. i art. 7 k.p.k. mają charakter rozłączny (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. V KK 270/12, SIP „Legalis” nr 797165). W konsekwencji podniesienie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. wyklucza możliwość skutecznego

wysunięcia zarzutu obraży art. 5 § 2 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2021 r., sygn. akt IV KK 415/20**

- (...) art. 5 § 2 k.p.k. (...) odnosi się tylko do wątpliwości, które ma i których nie był w stanie rozstrzygnąć organ procesowy rozpoznający sprawę, nie zaś do zastrzeżeń strony niezadowolonej z ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy – **postanowienie Sądu Najwyższego z 17 marca 2021 r., sygn. akt V KK 34/21**
- Zarzut naruszenia art. 5 § 2 k.p.k. może być uznany za skuteczny tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że orzekający w sprawie sąd rzeczywiście miał wątpliwości o takim charakterze i nie rozstrzygnął ich na korzyść oskarżonego. Natomiast z naruszeniem art. 410 k.p.k. mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy sąd opiera swoje orzeczenie na materiale nieujawnionym na rozprawie głównej, bądź tylko na części materiału ujawnionego i jego rozstrzygnięcie nie jest wynikiem analizy całokształtu ujawnionych okoliczności. Z przyczyn oczywistych nie można więc jednocześnie skutecznie zarzucić naruszenia norm wynikających z obu tych przepisów. Dodać ponadto można, że tak, jak dla zasadności zarzutu naruszenia art. 5 § 2 k.p.k., nie wystarczy zaprezentowanie przez stronę własnych wątpliwości co do stanu dowodów, tak też w żadnej mierze dokonanie przez sąd oceny dowodów i oparcie się na określonych z nich, przy jednoczesnym odmówieniu wiary dowodom przeciwnym nie stanowi naruszenia dyspozycji art. 410 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 24 lutego 2021 r., sygn. akt II KK 172/20**
- Zarzut naruszenia art. 5 k.p.k. jest zupełnie bezpodstawny skoro naruszenie to możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy orzekający w sprawie sąd rzeczywiście powziął wątpliwości co do treści ustaleń faktycznych lub wykładni prawa i wobec niemożności ich usunięcia rozstrzygnął je na niekorzyść oskarżonego. Natomiast gdy pewne ustalenia faktyczne zależne są od np. dania wiary lub odmówienia jej wyjaśnieniom oskarżonego czy świadków, nie można mówić o naruszeniu zasady *in dubio pro reo*, a ewentualne zastrzeżenia co do oceny wiarygodności konkretnego dowodu lub grupy dowodów rozstrzygane mogą być jedynie na płaszczyźnie utrzymania się przez sąd w granicach sędziowskiej swobody ocen wynikającej z art. 7 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 grudnia 2020 r., sygn. akt II AKa 182/20**

- (...) nawet jeżeli w sprawie zarysowały się różne wersje przebiegu zdarzenia, nie oznacza to zawsze zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 5 § 2 k.p.k., które stosownie do zasady wyrażonej w tym przepisie, powinno się rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego. Nakaz *in dubio pro reo* odnosi się jedynie do takich sytuacji, które faktycznie nie dają się usunąć, co oznacza, że Sąd powinien podejmować czynności zmierzające do wyeliminowania zaistniałych wątpliwości i dopiero po wykorzystaniu wszystkich istniejących możliwości dowodowych, o ile wątpliwości te istnieją nadal, sięgnąć po regułę z art. 5 § 2 k.p.k. Reguła ta nie ma jednak zastosowania, gdy wątpliwości są następstwem niedokładnego i niewyczerpującego postępowania dowodowego bądź dokonania oceny dowodów w sposób niepełny i niespełniający standardów wyznaczonych przez zasadę swobodnej oceny dowodów określonej w art. 7 k.p.k. (...) – **wyrok Sądu Najwyższego z 24 listopada 2020 r., sygn. akt II KK 377/19**
- Zgodnie z regułą *in dubio pro reo*, niedające się usunąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Przesłanką postąpienia zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 5 § 2 k.p.k. jest ustalenie, że w sprawie zachodzą „niedające się usunąć wątpliwości”. O takich wątpliwościach można mówić dopiero po dokonaniu przez Sąd analizy całokształtu materiału dowodowego w sposób zgodny z wymogami art. 7 k.p.k. (por. m.in.: wyrok Sądu Najwyższego z 27 lutego 2018 r., III KK 286/17) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 2020 r., sygn. akt V KK 324/19**
- (...) naruszenie zasady *in dubio pro reo* możliwe jest jedynie wtedy, gdy sąd w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe i w sposób zgodny z art. 7 k.p.k. ocenił zgromadzone dowody, a pomimo tego z dowodów uznanych za wiarygodne nadal wynikają co najmniej dwie wersje faktyczne i organ procesowy rozstrzyga niedające się usunąć wątpliwości niezgodnie z kierunkiem określonym w przepisie art. 5 § 2 k.p.k. Jeżeli zatem, jak w tej sprawie, kwestionuje się ocenę poszczególnych dowodów, nie może być mowy o naruszeniu art. 5 § 2 k.p.k. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, nie budzi bowiem wątpliwości fakt, że niemożliwym jest jednoczesne zarzucenie uchybienia przepisom art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. (...) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2020 r., sygn. akt V KK 49/20**

- *Pozbawione logiki jest stawianie jednocześnie zarzutu obrazy art. 7 i art. 5 § 2 k.p.k. Jeżeli obrońca oskarżonego kwestionuje ocenę dowodów, to takiej sytuacji nie dotyczy art. 5 § 2 k.p.k., tylko art. 7 k.p.k. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli pewne ustalenia faktyczne zależne są na przykład od dania wiary wyjaśnieniom oskarżonego lub zeznaniom pokrzywdzonego, to nie można mówić o naruszeniu zasady *in dubio pro reo*, a ewentualne zastrzeżenia co do oceny wiarygodności konkretnego dowodu lub grupy dowodów mogą być rozstrzygane jedynie na płaszczyźnie utrzymania się przez sąd w granicach sędziowskiej swobodnej oceny dowodów wynikającej z treści art. 7 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 lutego 2020 r., sygn. akt II AKa 641/19, LEX nr 3227698*
- *(...) naruszenie reguły *in dubio pro reo* możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy po przeprowadzonym prawidłowo postępowaniu dowodowym i odpowiadającej standardom wynikającym z art. 7 k.p.k. ocenie materiału dowodowego, nadal istnieją niedające się usunąć wątpliwości, które sąd rozstrzyga niezgodnie z kierunkiem określonym w przepisie art. 5 § 2 k.p.k. Oznacza to, że w przypadkach, w których skarżący kwestionuje ocenę poszczególnych dowodów, nie może być mowy o naruszeniu art. 5 § 2 k.p.k. Zarzuty obrazy art. 7 k.p.k. i art. 5 § 2 k.p.k. mają bowiem charakter rozłączny (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 r., II KK 18/17, LEX nr 2311295, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 2019 r., III KK 215/18, LEX nr 2602107) – postanowienie Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt IV KK 651/19*

Ad. 9.3. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k.?

Zarzut obrazy art. 7 k.p.k. jest najczęściej przywoływanym przepisem w praktyce formułowania zarzutów apelacyjnych, przez co jego skuteczność z reguły jest ograniczona. Podkreślenia wymaga, że dowolność oceny materiału dowodowego zdaniem ustawodawcy sprowadza się do sprzeczności poczynionych ustaleń faktycznych sądu I instancji z zasadami prawidłowego rozumowania, wskazaniami wiedzy powszechnej i doświadczeniem życiowym.

Orzecznictwo dodatkowo uzupełnia kryteria oceny materiału dowodowego z art. 7 k.p.k. o dodatkowe elementy, wynikające z innych przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym np. konieczności ujawnienia w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, czy rozważenia okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.

Niewystarczająca jest zatem odmienna ocena poszczególnych dowodów dokonana przez apelującego, bez wykazania, że sąd I instancji dokonując tejże (odmiennej) oceny, postąpił wbrew któremuś z ww. kryteriów. Przywołując w tym miejscu wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 czerwca 2020 r., wyrażnego zaakcentowania wymaga niekwestionowany w orzecznictwie pogląd, że *przekonanie sądu o wiarygodności jednych dowodów i jej braku w przypadku innych, pozostaje pod ochroną przepisu art. 7 k.p.k., jeżeli zostało poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, rozważeniem okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, pozostaje zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz zostało wyczerpująco i logicznie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku*⁷⁶.

W jednym z judykatów Sąd Najwyższy wskazał natomiast, że przepisy polskiej procedury karnej nie zawierają katalogu reguł oceny wiarygodności dowodu. Niewątpliwie dużą rolę przy dokonywaniu takiej oceny odgrywa element subiektywnej oceny sędziego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż każdy sędzia ma własny, indywidualny zbiór kryteriów, które wykorzystuje przy ocenie wiarygodności wyjaśnień, zeznań. Oczywiście zagwarantowana ustawą swoboda sędziowska w zakresie dokonywania oceny dowodów, nie może przekształcać się w niekontrolowalną dowolność w odrzucaniu lub uznawaniu dowodów za wiarygodne. Sąd zawsze powinien potrafić wykazać, że u podstaw takiej oceny legły racjonalne przesłanki i ocena taka zgodna jest z dyrektywami zawartymi w art. 7 k.p.k., a zatem dokonana została z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego⁷⁷.

W konsekwencji, **sformułowanie w apelacji zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. wymaga każdorazowo wykazania, że ocena sądu jest sprzeczna albo**

⁷⁶ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 czerwca 2020 r., sygn. akt II AKa 62/20.

⁷⁷ Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r., sygn. akt IV KK 350/20.

z zasadami doświadczenia życiowego, albo z zasadami prawidłowego rozumowania, albo z zasadami wiedzy powszechnej, albo nie została poprzedzona ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, a dodatkowo, że mogło mieć to wpływ na treść zapadłego rozstrzygnięcia. Nie każda bowiem okoliczność, nawet dowolnie oceniona przez sąd, ma znaczenie dla kwestii ustalenia sprawstwa bądź skutków uznania oskarżonego za winnego. Wykazania przez apelującego potencjalnego wpływu na treść rozstrzygnięcia wprost wymaga natomiast art. 438 pkt 2 k.p.k.

Dla uchylenia ryzyka uznania zarzutu apelacyjnego obrazu art. 7 k.p.k. wyłącznie za „bezzasadną polemikę”, wskazane byłoby zatem takie sformułowanie zarzutu obrazu art. 7 k.p.k. w *petitum* apelacji, aby już z jego treści wynikała owa dostrzegana przez apelującego sprzeczność z kryteriami, wynikającymi z brzmienia tego przepisu (przy jednoczesnym zachowaniu elementów prawidłowej konstrukcji zarzutów obrazu prawa procesowego – zob. podrozdział 6.2.2.2. niniejszej publikacji).

Dodatkowego zaakcentowania wymagają sprecyzowane w orzecznictwie **szczególne kryteria oceny dowodu z pomówienia** (tj. zeznania albo wyjaśnienia, stanowiące zasadniczo podstawę ustalenia sprawstwa czynu zabronionego). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi dowód ten *jest dowodem niejako szczególnym, dowodem, którego przeprowadzenie wymaga ponadprzeciętnej skrupulatności w jego przeprowadzeniu i ocenie, tak aby ocena tego pomówienia, jako podstawy faktycznej, co do winy pomówionego, nie nasuwała żadnych zastrzeżeń. W praktyce orzeczniczej wypracowano standardy, którymi winna odznaczać się ocena dowodu z tzw. pomówienia*⁷⁸. Tego rodzaju dowód powinien być oceniany ze szczególną wnikliwością i ostrożnością, mając na uwadze:

- A) czy informacje tak uzyskane są przyznane przez pomówionego,
- B) czy są potwierdzone innymi dowodami, choćby w części,
- C) czy są spontaniczne, złożone wkrótce po przeżyciu objętych nimi zaszłości, czy też po upływie czasu umożliwiającącego uknucie intrygi,
- D) czy pochodzą od osoby bezstronnej, czy też zainteresowanej obciążeniem pomówionego,

⁷⁸ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 5 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 199/12.

- E) czy są konsekwentne i zgodne co do zasady oraz szczegółów w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania, czy też zawierają informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające bądź inne niekonsekwencje,
- F) czy pochodzą od osoby nieposzlakowanej czy też przestępcy, zwłaszcza obeznanego z mechanizmami procesu karnego,
- G) czy udzielający informacji sam siebie również obciąża, czy też tylko przerzuca odpowiedzialność na inną osobę, by siebie uchronić przed odpowiedzialnością⁷⁹.

W przypadku sformułowania zatem w apelacji zarzutu obraży art. 7 k.p.k. w odniesieniu do dowodu z pomówienia (np. zeznań świadka koronnego, które w ocenie zdającego są jedynym wskazanym przez sąd dowodem, potwierdzającym sprawstwo oskarżonego) – dla skuteczności sformułowanego zarzutu – konieczne jest wykazanie, że niespełnione zostały ww. kryteria oceny tego dowodu.

Na marginesie – **nie ma potrzeby powtarzania w treści zarzutu sformułowań ustawowych**, szczególnie przy przepisie, który jest najczęściej wykorzystywany w praktyce (tj. nie ma potrzeby formułowania zarzutu jako „*obraża art. 7 k.p.k., polegająca na dowolnej, a nie swobodnej ocenie dowodów bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, poprzez (...)*”). Zarzut powinien być możliwie jak najbardziej skondensowany co do treści, przy czym (przy zachowaniu wszystkich trzech elementów konstrukcyjnych zarzutu obraży prawa procesowego) z jego treści powinno jasno wynikać, co dokładnie skarżący ma na myśli i w czym konkretnie upatruje błąd, popełnionego przez sąd I instancji.

Przykład pozytywny: zarzucam obrazę art. 7 k.p.k., poprzez sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego uznanie, że niemożliwym jest, aby oskarżony w dniu 12 lutego 2022 roku ok. godz. 21.15 w 12 minut przemierzył się z ul. Kwiatowej na ul. Rabatową w Warszawie, podczas gdy z powszechnie

⁷⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 2021 r., sygn. akt IV KK 573/20.

dostępnych danych Google Maps wynika, że odległość pomiędzy ww. miejscami to 2 kilometry, a czas przejazdu w ww. godzinach to ok. 4 minut (wydruk w załączeniu), co doprowadziło do bezpodstawnego uznania wyjaśnień oskarżonego w omawianej kwestii za niewiarygodne.

Przykład negatywny I: zarzucam obrazę art. 7 k.p.k., polegającą na dowolnej, a nie swobodnej ocenie dowodów bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, co doprowadziło do bezpodstawnego uznania oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego przestępstwa.

Przykład negatywny II: zarzucam obrazę art. 7 k.p.k., poprzez dowolną ocenę dowodu z wyjaśnień oskarżonego, którego wyjaśnienia przy zachowaniu reguł swobodnej (a nie dowolnej) oceny dowodów, powinny zostać uznane za wiarygodne, co doprowadziło do bezpodstawnego skazania oskarżonego.

Przydatne orzecznictwo, wskazujące okoliczności w jakich zarzut obrazę art. 7 k.p.k. jest merytorycznie uzasadniony:

- (...) jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie II AKa 72/06 nie jest ani wystarczające, ani skuteczne jedynie teoretyczne i gołosłowne wysłowienie pewnej hipotetycznej możliwości i na tej tylko podstawie formułowanie zarzutu, że ustalenia sądu są błędne, bowiem tej ewentualności nie uwzględniają lub też nie stanowią jej bezwzględego zaprzeczenia. Każde dowodowe twierdzenie wymaga uwiarygodnienia, poprzez wskazanie na fakty realnie istniejące i poddające się obiektywnemu poznaniu procesowemu. Bez takiego zaś wymogu zakwestionowane mogłyby zostać wszelkie dowody i ustalenia sądu, a sąd byłby wikłany w niekończące się i w wielu wypadkach całkowicie nierealne procedury badania tych hipotez i ich dowodowego weryfikowania (OSA 2007 Nr 1, poz. 4, str. 50, KZS 2006 Nr 9, poz. 54, OSA/Wr. 2007 Nr 1, poz. 23, Legalis Numer 80195). Norma wyrażona w art. 5 § 2 k.p.k. zostaje bowiem naruszona nie tylko wtedy, gdy nieusuwalnych wątpliwości nie rozstrzygnięto na korzyść oskarżonego, ale również wtedy, gdy organ procesowy bezzasadnie korzysta z tej dyrektywy (wyrok Sądu

Najwyższego z dnia 28 września 2015 r., sygn. IV KK 143/15, *Legalis Numer 1341833*). W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy wykorzystał w toku postępowania sądowego wszystkie istniejące możliwości dowodowej weryfikacji tez aktu oskarżenia i twierdzeń obrony, nie uchylając się od oceny dowodów i wyczerpującej argumentacji w tym zakresie, słusznie uznając, iż wątpliwości co do sprawstwa oskarżonej nie zaistniały – **wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 26 maja 2022 r., sygn. akt II Ka 258/22**

- (...) zarzut błędu „dowolności”, a taki został w rzeczywistości sformułowany w apelacji, co zresztą jasno wynika zarówno z samej treści tych zarzutów, jak i uzasadnienia apelacji, jest jednak tylko wtedy słuszny, gdy zasadność ocen i wniosków, wyprowadzonych przez sąd orzekający z okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego, nie odpowiada prawidłowości logicznego rozumowania, przy czym dla swej skuteczności wymaga on od apelującego wykazania, jakich konkretnych uchybień w świetle wskazań wiedzy, doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania dopuścił się sąd w dokonanej ocenie materiału dowodowego a nie tylko ograniczenia się do własnej oceny tego materiału (por. wyrok SN z 20 lutego 1975 r., II K 355/74, OSNPG 1975 Nr 9, poz. 84; wyrok SN z 22 stycznia 1975 r., I KR 197/74, OSNKW 1975 Nr 5, poz. 58) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 27 października 2021 r., sygn. akt II AKa 149/21**
- (...) skuteczne postawienie zarzutu obrazy art. 7 k.p.k. wymaga wykazania przez autora apelacji, że Sąd meriti oceniając poszczególne dowody uczynił to w sposób dowolny, który nie respektuje zasady swobodnej ich oceny i wykazania w czym konkretnie owa dowolność się przejawia. Analizując treść wymienionych w pkt a – g zarzutów obrazy art. 7 k.p.k. należy uznać, że mają one charakter polemiczny i skarżący nie wykazał w sposób przekonujący jakich błędów i uchybień w procesie oceny poszczególnych dowodów dopuścił się Sąd orzekający w pierwszej instancji – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 września 2021 r., sygn. akt II AKa 234/20**
- (...) W judykaturze powszechnie akceptowany jest pogląd, iż dowód z pomówienia należy oceniać ze szczególną wnikliwością i ostrożnością, mając na uwadze:

- czy informacje tak uzyskane są przyznane przez pomówionego,
 - czy są potwierdzone innymi dowodami, choćby w części,
 - czy są spontaniczne, złożone wkrótce po przeżyciu objętych nimi zaszłości, czy też po upływie czasu umożliwiającemu uknuć intrygi,
 - czy pochodzą od osoby bezstronnej, czy też zainteresowanej obciążeniem pomówionego,
 - czy są konsekwentne i zgodne co do zasady oraz szczegółów w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania, czy też zawierają informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające bądź inne niekonsekwencje,
 - czy pochodzą od osoby nieposzlakowanej czy też przestępcy, zwłaszcza obeznanego z mechanizmami procesu karnego,
 - czy udzielający informacji sam siebie również obciąża, czy też tylko przerzuca odpowiedzialność na inną osobę, by siebie uchronić przed odpowiedzialnością (...) – **wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 2021 r., sygn. akt IV KK 573/20**
- (...) przekonanie sądu o wiarygodności jednych dowodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną art. 7 k.p.k. wtedy, gdy: – jest poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy (art. 410 k.p.k.), i to w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy (art. 2 § 2 k.p.k.); – stanowi wyraz rozważenia wszystkich tych okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego (art. 4 k.p.k.); – jest wyczerpujące i logiczne – z uwzględnieniem wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego; – uargumentowane w uzasadnieniu wyroku (art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k.) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 czerwca 2021 r., sygn. akt II AKa 27/21**
 - Sąd odwoławczy ma oczywiście prawo dokonać odmiennej – od dokonanej przez Sąd pierwszej instancji – oceny zebranych w sprawie dowodów i na tej podstawie dokonać odmiennych ustaleń faktycznych oraz wydać orzeczenie reformatoryjne, ale pod warunkiem, że w sposób rzetelny wykaże, jakich to błędów i w odniesieniu do których to dowodów dopuścił się Sąd orzekający w pierwszej instancji przy ocenie zebranego w sprawie materiału dowodowego i dlaczego jego ustalenia faktyczne

są nietrafne. Sąd pierwszej instancji, który bezpośrednio przeprowadza dowody na rozprawie, ma bowiem ustawowo zagwarantowaną swobodę w ocenie przeprowadzonych dowodów i ocena ta podlega ochronie przewidzianej w art. 7 k.p.k. dopóty, dopóki nie zostanie wykazana jej błędność. Sąd odwoławczy, dzieląc podniesiony w apelacji zarzut obraży art. 7 k.p.k., musi rzeczowo wykazać, przy ocenie którego to konkretnie dowodu nie zostały uwzględnione zasady prawidłowego rozumowania, wskazania wiedzy czy też doświadczenia życiowego. Prezentowanie natomiast własnej – możliwej w realiach konkretnej sprawy – oceny dowodów, bez wykazania błędności tej, której dokonał Sąd pierwszej instancji, nie upoważnia jeszcze Sądu odwoławczego do zajęcia w tej materii stanowiska odmiennego. Sąd odwoławczy, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie prowadzi samodzielnie postępowania dowodowego co do istoty sprawy, jest bowiem głównie sądem kontrolującym procedowanie przed Sądem pierwszej instancji i stanowisko tego Sądu może zakwestionować jedynie wówczas, gdy wykaże, że to postępowanie i jego wynik obrażają prawo (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2018 r., II KK 449/17, LEX nr 2541499) – **wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt III KK 78/21**

- (...) dla skuteczności zarzutu naruszenia art. 7 k.p.k. nie jest wystarczające samo wykazywanie, że określona grupa dowodów pozwala na przyjęcie, iż zdarzenie mogło mieć inny, alternatywny przebieg. Należy bowiem wykazać, którym wskazaniom wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego uchybił sąd orzekający, czyniąc kwestionowane ustalenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2009 r., sygn. WA 26/09 w: OSNwSK 2009/1/1844) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lutego 2021 r., sygn. akt IV KK 460/20**
- (...) przepisy polskiej procedury karnej nie zawierają katalogu reguł oceny wiarygodności dowodu. Niewątpliwie dużą rolę przy dokonywaniu takiej oceny odgrywa element subiektywnej oceny sędziego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż każdy sędzia ma własny, indywidualny zbiór kryteriów, które wykorzystuje przy ocenie wiarygodności wyjaśnień, zeznań (por. np. B. Wojciechowski, *Analiza i ocena zeznań świadków*, Sopot 2016, s. 207–217). Oczywiście zagwarantowana ustawą swoboda sędziowska

w zakresie dokonywania oceny dowodów, nie może przekształcać się niekontrolowalną dowolność w odrzucaniu lub uznawaniu dowodów za wiarygodne. Sąd zawsze powinien potrafić wykazać, że u podstaw takiej oceny leży racjonalne przesłanki i ocena taka zgodna jest z dyrektywami zawartymi w art. 7 k.p.k., a zatem dokonana została z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r., sygn. akt IV KK 350/20**

- Odmówienie wiary niektórym zeznaniom lub wyjaśnieniom złożonym przez świadków lub oskarżonych, a w rezultacie ich pominięcie jako podstawy dowodowej podczas dokonywanych ustaleń faktycznych, nie może być utożsamiane ani z brakiem oceny okoliczności, których tego rodzaju dowód dotyczy w kontekście finalnego rozstrzygnięcia, ani też nie jest wyrazem złamania zasady bezstronności sądu, bowiem odmowa przyznania waloru wiarygodności niektórym z przeprowadzonych dowodów, przy jednoczesnej aprobacie i uwzględnieniu innych dowodów, jest niczym więcej niż realizacją przysługującego sądowi orzekającemu uprawnienia w ramach czynienia ustaleń faktycznych, z pełnym uwzględnieniem zasady swobodnej oceny dowodów wymienionej w art. 7 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2020 r., sygn. akt II AKa 98/20**
- (...) przekonanie Sądu o wiarygodności jednych dowodów i jej braku w przypadku innych, pozostaje pod ochroną przepisu art. 7 k.p.k., jeżeli zostało poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, rozważeniem okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, pozostaje zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz zostało wyczerpująco i logicznie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku (tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r. sygn. IV KK 104/18, lex nr 2498022) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 czerwca 2020 r., sygn. akt II AKa 62/20**
- (...) skuteczne podniesienie zarzutu naruszenia art. 7 k.p.k. wymaga wykazania, że ocena dokonana przez sąd jest sprzeczna z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego, nie została poprzedzona ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, bądź

argumentacja zaprezentowana przez sąd za tak dokonany wybór pozostaje w sprzeczności z zasadami logiki. Przekonanie sądu o wiarygodności jednych dowodów i jej braku w przypadku innych, pozostaje pod ochroną przepisu art. 7 k.p.k., jeżeli zostało poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy, rozważeniem tych przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, pozostaje zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego oraz zostało wyczerpująco i logicznie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2018 r., IV KK 104/2018, LEX nr 2498022) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2020 r., sygn. akt V KK 31/20**

- (...) gdy oskarżony decyduje się na złożenie wyjaśnień, to podlegają one ocenie pod względem wiarygodności tak jak każdy inny dowód – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2020 r., sygn. akt IV KK 526/19**
- Treść normy art. 7 k.p.k. (swobodna ocena dowodów) ma charakter zasady ogólnej. Tylko wskazanie naruszenia konkretnych przepisów proceduralnych, które wypełniają normy ogólne może być uznane za skuteczny zarzut apelacyjny (...). Przekonanie o wiarygodności jednych dowodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną prawa procesowego ponieważ poprzedził je ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy (art. 410 k.p.k.), i to w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy (art. 2 § 2 k.p.k.), stanowiło ono wynik rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego (art. 4 k.p.k.), było wyczerpująco i logicznie – z uwzględnieniem wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a nadto zgodnie art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. – właściwie uargumentowane w uzasadnieniu wyroku – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 31 października 2019 r., sygn. akt II AKa 297/19**
- • Zasada swobodnej oceny dowodów wyrażona w art. 7 k.p.k. nakazuje organom procesowym oceniać materiał dowodowy na podstawie wewnętrznego przekonania, uwzględniając wskazania wiedzy oraz doświadczenia życiowego, bez związania ustawowymi regułami dowodowymi. Przekonanie sądu orzekającego o wiarygodności jednych

z dowodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną przepisu art. 7 k.p.k., gdy: – jest poprzedzone ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy (art. 410 k.p.k.) i to w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy (art. 2 § 2 k.p.k.); – jest wynikiem rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego (art. 4 k.p.k.); – jest wystarczająco i logicznie, z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia życiowego, umotywowane w uzasadnieniu wyroku (art. 424 k.p.k.). Wykluczone jest aprioryczne eliminowanie osobowych źródeł dowodowych z powodu ich indywidualnych cech lub właściwości. Nie mają znaczenia kategorie ilościowe źródeł dowodowych. Nie ma nakazu całkowitego uznania wiarygodności lub jej braku określonego środka dowodowego. Zeznaniom tego samego świadka lub wyjaśnieniom tego samego oskarżonego można częściowo dać wiarę, a części jego depozycji wiary odmówić – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt II AKa 101/17, LEX nr 2757826

- *W realiach niniejszej sprawy nie ulega bowiem wątpliwości, że jedynym dowodem mającym świadczyć o sprawstwie oskarżonych Mateusza F. i Łukasza W. (konsekwentnie nie przyznających się do winy) są wyjaśnienia współoskarżonego Mateusza F. Jest to zatem dowód z pomówienia współoskarżonego, który – na co wielokrotnie też zwracał uwagę SN – jest dowodem niejako szczególnym, dowodem, którego przeprowadzenie wymaga ponadprzeciętnej skrupulatności w jego przeprowadzeniu i ocenie, tak aby ocena tego pomówienia, jako podstawy faktycznej, co do winy pomówionego, nie nasuwała żadnych zastrzeżeń. W praktyce orzeczniczej wypracowano standardy, którymi winna odznaczać się ocena dowodu z tzw. pomówienia.*
- *Wskazano, że dokonując oceny tego dowodu należy zwrócić uwagę czy: 1) informacje uzyskiwane tą drogą są przyznawane przez pomówionego, 2) są one choćby w części, potwierdzone innymi dowodami, 3) są spontaniczne, 4) pochodzą od osoby bezstronnej, bądź zainteresowanej obciążeniem pomówionego, 5) są konsekwentne i zgodne, co do zasady oraz szczegółów w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania, 6) pochodzą od osoby nieposzlakowanej, czy też przestępcy*

obeznanego z mechanizmem procesu karnego, 7) pomawiający sam siebie obciąża, czy też tylko przerzuca odpowiedzialność na inną osobę, by siebie uchronić przed odpowiedzialnością.

- *Dowód z pomówienia może bowiem być dowodem winy, o ile jest logiczny, stanowczy, konsekwentny, zgodny z logiką wypadków, nie jest wyrazem osobistego zainteresowania pomawiającego, wyrażającym się w przerzucaniu winy na inną osobę, czy umniejszaniu swojego stopnia zawinienia. Pamiętać także należy o tym, że obowiązująca w polskim procesie karnym zasada swobodnej oceny dowodów nie preferuje dowodów z rozprawy sądowej ponad dowody zebrane w toku śledztwa, dając sądowi możliwość wyboru dowodów najbardziej wiarygodnych, na podstawie wiedzy Sądu i jego doświadczenia życiowego, ale zasada ta w takim wypadku zobowiązuje Sąd do szczególnej ostrożności przy ocenie i przyjmowaniu dowodu z pomówień, które następnie zostały odwołane oraz przekonywującego uzasadnienia zajętego stanowiska. Obowiązek dochodzenia prawdy obiektywnej dyktuje, aby dowody z pomówień wspierać innymi dowodami, które razem z pomówieniami dałyby sądowi podstawę do pełnego przekonania o winie osoby oskarżonej. Ważne również jest to, że dla oceny wartości dowodowej pomówienia oskarżonego przez współ-oskarżonego istotne znaczenie ma stan zdrowia psychicznego pomawiającego, albowiem niewątpliwie inaczej oceniać należy owe pomówienie przez osobę zdrową psychicznie, a inaczej – przez osobę z defektami w zakresie zdrowia psychicznego (...) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 5 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 199/12*

Ad. 9.4. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 6 k.p.k.?

W art. 6 k.p.k. zawarta jest w mojej ocenie najważniejsza zasada procesu karnego – zasada prawa do obrony. Powtarzając za M. Kurowskim, „uregulowane w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP prawo do obrony zostało na mocy art. 6 wprowadzone do polskiego postępowania karnego. Prawo do obrony jest uznawane za jedno z fundamentalnych praw człowieka i jako takie

znalazło swoje odzwierciedlenie w aktach prawa międzynarodowego. W szczególności jest ono wprost gwarantowane w art. 14 ust. 3 lit. b oraz d MPPOiP oraz art. 6 ust. 3 lit. c EKPC. Już w tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że prawo to jest związane z prawem do informacji procesowej oraz do dysponowania odpowiednim czasem do przygotowania obrony, jako gwarantującymi możliwość podjęcia realnej obrony⁸⁰.

Podobnie zasadę prawa do obrony ocenił Sąd Najwyższy w wyroku z 1 września 2020 r., w którym wskazał, że przepis art. 6 k.p.k. statuuje jedną z podstawowych gwarancji procesowych oskarżonego, jaką jest prawo do obrony w sensie materialnym, rozumiane jako prawo przeciwstawiania się tezie oskarżenia, jak i prawo do obrony w sensie formalnym, rozumiane jako prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Szczególną wagę wspomnianego przepisu obrazuje fakt, iż przenosi on na grunt Kodeksu postępowania karnego unormowanie zawarte w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, jak też w art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności⁸¹. Prawo do obrony jest ściśle powiązane z prawem do rzetelnego procesu i tym, co określamy mianem „fair trial”.

Szereg przepisów Kodeksu postępowania karnego jest wyrazem realizacji zasady prawa do obrony. Przykładem takich przepisów są art. 79 i 80 k.p.k., traktujące o obronie obligatoryjnej (tj. sytuacjach procesowych, w których oskarżony bezwzględnie musi mieć obrońcę dla właściwej reprezentacji własnych interesów), a także art. 353 § 1 i 2 k.p.k. (odroczenie rozprawy na wniosek obrońcy lub oskarżonego, jeśli pomiędzy terminem zawiadomienia o rozprawie a dniem rozprawy nie minęło przynajmniej 7 pełnych dni), czy też art. 399 § 2 k.p.k. (odroczenie lub przerwanie rozprawy na wniosek oskarżonego w sytuacji pouczenia o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzuconego czynu, co ma umożliwiać oskarżonemu właściwe przygotowanie się do obrony również w odniesieniu do rozważanej przez sąd zmodyfikowanej kwalifikacji prawnej czynu), czy art. 175 § 1 k.p.k. (zostawiający oskarżonemu wybór jaką obronę chce w procesie podjąć) itd.

⁸⁰ M. Kurowski, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 6 k.p.k., Lex/el 2022, teza 1.

⁸¹ Wyrok Sądu Najwyższego z 1 września 2020 r., sygn. akt V KK 241/19.

Konsekwencją powyższego jest to, że **w przypadku twierdzeń apelującego, że doszło do naruszenia prawa oskarżonego do obrony, zasadne jest takie skonstruowanie zarzutu, by jego podstawą nie był wyłącznie art. 6 k.p.k.** Jak podkreślił bowiem Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27 lutego 2019 r., *przepis art. 6 k.p.k. jako zawierający generalną zasadę procesu karnego, tj. zasadę prawa do obrony, nie może stanowić samoistnej podstawy odwoławczej. O ile skarżący zarzuca skarżonemu orzeczeniu uchybienie przewidzianej w tym przepisie zasadzie procesowej to powinien przywołać tę normę, ale w związku z innym przepisem, który – jako realizujący tę zasadę – został także naruszony*⁸².

W przypadku naruszenia prawa oskarżonego do obrony, sugerowana jest zatem następująca konstrukcja zarzutu:

- „zarzucam obrazę art. 6 k.p.k. w zw. z art. 175 § 1 k.p.k., poprzez (...)”
albo
- „zarzucam obrazę art. 399 § 2 k.p.k., poprzez (...), co doprowadziło do naruszenia prawa do obrony oskarżonego, określonego w art. 6 k.p.k.”,

przy czym właściwsza w mojej ocenie jest druga konstrukcja zarzutu (tj. wskazanie obrazy art. 6 k.p.k. jako skutku obrazy określonego przepisu Kodeksu postępowania karnego).

W kontekście zarzutów apelacyjnych należy również pamiętać, że **nie każde naruszenie prawa oskarżonego do obrony skutkuje zaistnieniem bezwzględnej przyczyny odwoławczej**. W art. 439 § 1 pkt 10 i 11 k.p.k. wskazano jakie naruszenia prawa do obrony skutkują koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku sądu I instancji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

Zaakcentowania w omawianym kontekście wymaga również to, że kwestia naruszenia prawa do obrony na skutek błędnych zawiadomień o terminach czynności procesowych i uniemożliwienie tym samym uczestnictwa w nich

⁸² Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r., sygn. akt III KZ 10/19.

oskarżonemu nie stanowi bezwzględnej przyczyny odwoławczej, ale obrazę art. 117 § 2 w zw. z konkretnym przepisem odnoszącym się do określonej sytuacji procesowej, np. fikcji doręczenia przez tzw. awizo z art. 133 § 2 k.p.k., której skutkiem może być obraza art. 6 k.p.k. Tak też w jednym z orzeczeń wskazał Sąd Najwyższy w odniesieniu do sytuacji przypadku doręczenia przez awizo⁸³.

W szerszym zakresie problematyka naruszenia prawa do obrony, stanowiącego bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 10 i 11 k.p.k., omówiona została w podrozdziale 6.3.10. i 6.3.11 niniejszej publikacji.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) oddalenie wniosku o bezpośrednie przesłuchanie biegłych na rozprawie i uniemożliwienie oskarżonemu i jego obrońcy zadawania biegłym pytań, rażąco narusza prawo oskarżonego do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 200 § 3 k.p.k.) i pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą kontrydiktoryjności (tak trafnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 marca 2006 r., III KK 241/05, LEX nr 186751) – **wyrok Sądu Najwyższego z 11 czerwca 2021 r., sygn. akt V KK 197/20**
- W związku z przebiegiem rozprawy oraz zgłoszoną przez oskarżonego i jego obrońcę potrzebą kontaktu sąd zarządził przerwę i umożliwił ten kontakt. Z powodu ograniczeń językowych i lokalowych kontaktów odbywał się z udziałem tłumacza przysięgłego oraz w obecności konwojujących oskarżonego funkcjonariuszy Policji. Oskarżony uznał, że nie będzie rozmawiał z obrońcą w obecności konwojujących, rezygnując z rozmowy. O tej okoliczności obrońca poinformował Sąd, a rozprawa była kontynuowana. Jednak ani obrońca, ani oskarżony nie złożyli w związku z tymi okolicznościami i oświadczeniami żadnych dalszych wniosków zmierzających do uzyskania przerwy w rozprawie, celem skorzystania z możliwości rozmowy w sposób poufny. Nie zostały w szczególności złożone wnioski o przerwę w rozprawie celem przygotowania wniosków dowodowych. W tym układzie Sąd, zgodnie z obowiązującymi regułami kontynuował rozprawę, zamknął przewód sądowy i odroczył wydanie

⁸³ Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt V KK 307/17.

wyroku na 14 dni. Obrona miała zatem dodatkowy czas między dniem rozprawy, tj. 25 kwietnia 2019 r., a dniem ogłoszenia wyroku, tj. 9 maja 2019 r. na wniesienie o wznowienie przewodu sądowego i złożenie umotywowanych wniosków dowodowych – **postanowienie Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt I KK 13/20**

- *Jedną z podstawowych gwarancji procesowych jest, przewidziane w art. 6 k.p.k., prawo do obrony w znaczeniu materialnym. Przejawem realizacji tego uprawnienia w postępowaniu przed Sądem meriti jest – wynikające z art. 374 § 1 k.p.k. – prawo do udziału oskarżonego w rozprawie głównej. Należy w pełni zaaprobować pogląd wyrażony w doktrynie, że ewentualna nieobecność oskarżonego, z wyjątkami wynikającymi z art. 374 § 1 zd. 2 i art. 374 § 1a k.p.k., musi być wynikiem jego świadomej decyzji woli, a nie braku stosownej informacji czy też nawet wprowadzenia go w błąd przez organ procesowy. Pierwszoplanową rzeczą jest więc zapewnienie mu gwarancji procesowych podjęcia oraz zrealizowania rzeczywistej i świadomej decyzji woli, czy chce on wziąć udział w rozprawie (...). Warunkiem domniemania, że nieobecność oskarżonego na rozprawie wynika wyłącznie z podjętej przez niego decyzji jest dochowanie wobec oskarżonego szeregu gwarancji procesowych, realizujących w szczególności obowiązek poinformowania o dacie i miejscu rozprawy. Do gwarancji tych należą: 1) obowiązek pouczenia oskarżonego o treści art. 374 § 1 k.p.k., a w przypadku postępowania zainicjowanych przed 1 lipca 2015 r. – z uwzględnieniem dyspozycji art. 31 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 338 § 1a k.p.k.; 2) obowiązek prawidłowego zawiadomienia oskarżonego o terminie rozprawy, zgodnie z wymogami ustawy procesowej; 3) nieprzeprowadzenie czynności procesowej na wniosek oskarżonego, który należycie usprawiedliwił swoją nieobecność na rozprawie i złożył wniosek w tym zakresie lub jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo oskarżonego wynikało z powodu przeszkód żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn (art. 117 k.p.k.). Tylko w razie zachowania wyżej wskazanych warunków można przyjąć (wzruszalne) domniemanie, że nieobecność oskarżonego wynika jedynie z wyrażonej*

przez niego woli i sąd może prowadzić rozprawę podczas jego nieobecności. Taka sama sytuacja zachodzi pomimo niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, jeżeli sąd dysponuje niebudzącym wątpliwości dowodem, że oskarżony jest pouczone o treści niniejszego artykułu oraz został zawiadomiony o terminie rozprawy. W przeciwnym razie rozprawy nie można prowadzić pod jego nieobecność i najpierw należy dopełnić zrealizowania wszystkich powyższych gwarancji (zob. P. Rogoziński, Komentarz do art. 374 k.p.k., teza 3) – wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2020 r., sygn. akt IV KK 481/20

- (...) przepis art. 6 k.p.k. statuuje jedną z podstawowych gwarancji procesowych oskarżonego, jaką jest prawo do obrony w sensie materialnym, rozumiane jako prawo przeciwstawiania się tezie oskarżenia, jak i prawo do obrony w sensie formalnym, rozumiane jako prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Szczególną wagę wspomnianego przepisu obrazuje fakt, iż przenosi on na grunt Kodeksu postępowania karnego unormowanie zawarte w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, jak też w art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – **wyrok Sądu Najwyższego z 1 września 2020 r., sygn. akt V KK 241/19**
- Sąd ad quem trafnie uznał, że oskarżona miała prawo do odmowy składania wyjaśnień na rozprawie czy też odpowiedzi na pytania, co wynika wprost z art. 175 § 1 k.p.k. Skorzystanie z takiego uprawnienia przez współoskarżonego, nie można odczytywać jako naruszenie prawa do obrony drugiego współoskarżonego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2020 r., sygn. akt V KK 628/19**
- (...) art. 77 k.p.k. gwarantuje oskarżonemu prawo do korzystania z pomocy trzech obrońców. Kiedy sąd pomija, nawet przez przeoczenie, jednego z obrońców, w konsekwencji czego obrońca nie bierze udziału w postępowaniu i nie pełni przypisanych mu funkcji, bez wątpienia dochodzi do rażącej obrazu nie tylko tej regulacji, ale i zasady prawa do obrony określonej w art. 6 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r., sygn. akt V KS 41/19**
- Zgodnie z art. 78 § 1 k.p.k., oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może zażądać, aby wyznaczono mu obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku

dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Warunkiem przystąpienia do rozpoznawania wniosku w takim przedmiocie jest „należyte” wykazanie przez oskarżonego niemożności poniesienia kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru. Co prawda to na oskarżonym ciąży obowiązek wykazania tej okoliczności, jednakże o obowiązku i sposobach wykazania ubóstwa trzeba go pouczyć, do czego zobowiązuje przepis art. 16 § 2 k.p.k., z konsekwencjami procesowymi określonymi w art. 16 § 1 k.p.k. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 1 lipca 2009 r., sygn. III KK 3/09; wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2014 r., III KK 251/13). Co istotne, przepis art. 78 § 1 k.p.k. odnosi się czasu terażniejszego, a zatem wymagane jest by oskarżony należycie wykazał aktualnie niemożność poniesienia kosztów obrony, co powinno skutkować wyznaczeniem obrońcy z urzędu. Sąd powinien więc oceniać jego sytuację majątkową w chwili orzekania w tym przedmiocie. (...). Jeżeli we wniosku oskarżony nie wykazał w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, Sąd powinien wezwać go do uzupełnienia wniosku i do udokumentowania okoliczności potwierdzających ubóstwo. Taki sposób procedowania wynika wprost z § 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 53). W sytuacji gdy takich kroków nie podjęto, trudno mówić o prawidłowym zweryfikowaniu zasadności wniosku. Wobec tego oskarżony został pozbawiony możliwości korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, co spowodowało obrazę art. 6 k.p.k. w zw. z art. 78 § 1 k.p.k. Pozbawienie oskarżonego uzasadnionego prawa do korzystania z pomocy obrońcy, z zasady ma wpływ na treść wyroku, co jest stanowiskiem konsekwentnie prezentowanym w judykaturze (por. wyroki Sądu Najwyższego z: 8 września 1996 r., III KKN 67/96, Wokanda, 1997, nr 2, s. 8 – **postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2019 r., sygn. akt IV KS 5/19**

- (...) przepis art. 6 k.p.k. jako zawierający generalną zasadę procesu karnego, tj. zasadę prawa do obrony, nie może stanowić samoistnej podstawy odwoławczej. O ile skarżący zarzuca skarżonemu orzeczeniu uchybienie przewidzianej w tym przepisie zasadzie procesowej to powinien

przywołać tą normę, ale w związku z innym przepisem, który – jako realizujący tą zasadę – został także naruszony – postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r., sygn. akt III KZ 10/19

- *Nie można zatem żądać od oskarżonego, aby przedstawił swoje alibi i w konsekwencji wyciągać niekorzystne dla niego wnioski, gdy tego nie uczyni (...). Postąpienie wbrew tej regule stanowi naruszenie art. 6 k.p.k., art. 74 § 1 k.p.k. i art. 175 § 1 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 12 lutego 2019 r., sygn. akt II AKa 179/17*
- *(...) Trybunał stwierdza, iż postępowanie karne, które toczyło się przeciwko skarżącemu, w jego całokształcie, nie naprawia wad procesowych zaistniałych na etapie postępowania przygotowawczego, spośród których należy wskazać na następujące najpoważniejsze uchybienia:*
 - *Ograniczenia prawa dostępu skarżącego do obrońcy były szczególnie szerokie. Skarżący został przesłuchany przez policję w trakcie swego zatrzymania bez możliwości wcześniejszego skonsultowania się z obrońcą lub zapewnienia sobie obecności obrońcy, a w toku późniejszego przesłuchania przez sędziego śledczego w czasie tej i pozostałych czynności śledczych obrońca nie był obecny.*
 - *W takich okolicznościach, bez otrzymania wcześniej wystarczająco jasnej informacji o prawie skarżącego do zachowania milczenia, skarżący złożył szczegółowe wyjaśnienia w okresie, kiedy był zatrzymany przez policję. Skarżący przedstawił następnie inne wersje wydarzeń i złożył wyjaśnienia, w których, nawet jeżeli stricte sensu skarżący nie obciążył siebie, to wyjaśnienia te poważnie zmieniły jego położenie, w szczególności w odniesieniu do zarzutu usiłowania zabójstwa C.L.*
 - *Wszystkie przedmiotowe oświadczenia zostały dopuszczone w charakterze dowodów przez sąd krajowy bez przeprowadzenia odpowiedniego badania okoliczności, w jakich zostały złożone, oraz wpływu nieobecności obrońcy [w trakcie przesłuchania skarżącego w postępowaniu przygotowawczym] na ich treść (...).*
- *Trybunał podkreśla, jak to czynił w sprawach z art. 6 ust. 1 Konwencji, których przedmiotem była ocena ogólnej rzetelności postępowania, iż nie jest jego zadaniem funkcjonowanie jako sąd czwartej instancji. Dokonując takiej oceny, jak wymaga tego art. 6 ust. 1, Trybunał musi jednakże*

uważnie przeanalizować przeprowadzenie postępowania krajowego, przy czym konieczna jest bardzo ścisła weryfikacja tego, czy ograniczenie prawa dostępu do obrony opierało się na pilnych powodach. W niniejszej sprawie to suma różnych wskazanych powyżej czynników, a nie poszczególny czynnik oddzielnie, sprawiły, że postępowanie jest nierzetelne jako całość. W związku z tym miało miejsca naruszenie art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 9 listopada 2018 r., **BEUZE v. BELGIA**, nr skargi 71409/10, LEX nr 2576340

- (...) wynikająca z art. 399 § 1 k.p.k. konieczność uprzedzenia stron o możliwej zmianie kwalifikacji prawnej czynu, jest istotnym mechanizmem umożliwiającym efektywne prowadzenie obrony. Dostarczenie stronom, w tym obronie, bieżącej informacji o rozważanej przez sąd kwalifikacji prawnej czynu jest niezbędne dla odpowiedniego ukierunkowania podejmowanych przez strony kroków procesowych, w tym wniosków dowodowych, i przedstawianej argumentacji. Warto też przypomnieć, że prawo do aktualnej informacji o treści stawianego oskarżonemu zarzutu, w tym o prawnej kwalifikacji czynu, jest składową prawa do rzetelnego procesu sądowego, wynikającą z art. 6 ust. 3 lit. a Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (...) gwarancja procesowa wynikająca z art. 399 § 1 k.k. w zw. z art. 458 k.p.k. polega bowiem na dostarczeniu oskarżonemu przez organ procesowy jasnej i wyraźnej informacji o możliwej zmianie normatywnej treści zarzutu; nie można od obowiązku uprzedzenia odstąpić ze względu na rzekomą oczywistość sytuacji i w oparciu o założenie, że oskarżony możliwości zmiany kwalifikacji gotów jest się domyślić – **wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt III KK 229/17**
- (...) w kategorii uchybienia z art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. nie mieści się okoliczność kwestionowania skuteczności zawiadomienia o terminie rozprawy, a przecież w istocie skarżący w kasacji to czyni, twierdząc, że pomimo „awiza” brak było dowodu czy skazany faktycznie odebrał wezwanie (...). Okoliczność ta może być jedynie przedmiotem zarzutu naruszenia art. 117 § 2 k.p.k. w zw. z art. 133 § 2 k.p.k., czy też nawet art. 6 k.p.k.; nie może być jednak powodem wskazania istnienia uchybienia z art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt V KK 307/17**

- (...) oskarżony nie może ponosić negatywnych konsekwencji postępowania obrońcy, jak też ponosić konsekwencji niewłaściwego funkcjonowania aparatu wewnątrzsądowego. Oskarżony ma prawo liczyć, że ustanowiony obrońca udzieli mu należytej pomocy prawnej, a więc także z uwagi na stan swojego zdrowia podejmie niezbędne czynności, aby rozprawa mogła odbyć się z jego udziałem – **wyrok Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r., sygn. akt III KK 12/17**
- Żaden przepis proceduralny nie określa podejrzanemu (oskarżonemu) terminu, do którego może on złożyć wyjaśnienia, jeśli tylko zdecyduje się na ich przekazanie. Dotyczy to nie tylko postępowania sądowego, ale także postępowania przygotowawczego. Podejrzany korzystający ze swego prawa do obrony może odmówić odpowiedzi na pytania, może odmówić składania wyjaśnień, ale może także w ramach realizacji swego prawa złożyć wyjaśnienia w każdym czasie, gdy tylko uzna, że z punktu widzenia jego interesów jest to dla niego korzystne, a obowiązkiem organów ścigania, ale i Sądu jest odebranie ich od niego. Jego prawo do złożenia wyjaśnień w swojej obronie nie może być ograniczone jakimkolwiek terminem, jeśli tylko korzysta z niego w dopuszczalny i prawem dozwolony sposób – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 maja 2017 r., sygn. akt II AKa 70/17**
- Przepis art. 6 k.p.k. ogólnie gwarantuje oskarżonemu prawo do korzystania z pomocy obrońcy, lecz nie wprowadza zasady, iż na żądanie oskarżonego nie można przeprowadzać czynności procesowych bez udziału jego obrońcy. Przepisy szczegółowe kodeksu postępowania karnego zapewniają realizację prawa do obrony w takim zakresie, w jakim ustawodawca uznał to za niezbędne. Celowi temu służą na przykład przepisy o obronie obligatoryjnej (art. 79 i art. 80 k.p.k.), o wyznaczaniu obrońcy z urzędu (art. 78 i art. 81 k.p.k.), a także art. 353 k.p.k., gwarantujący oskarżonemu dysponowanie stosownym okresem do ustanowienia obrońcy przed pierwszą rozprawą, czy też art. 117 § 2 k.p.k., gwarantujący należyte zawiadamianie, między innymi, obrońców o terminach czynności procesowych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2006 r., sygn. IV KK 33/06, R-OSNKW 2006, poz. 1). Realizację prawa do obrony gwarantuje również przepis art. 27 ust. 2 Prawa o adwokaturze, zgodnie

z którym „advokat, wypowiadając pełnomocnictwo, zawiadamia o tym zainteresowane organy; jest także obowiązany jeszcze przez dwa tygodnie pełnić swe obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta” – **postanowienie Sądu Najwyższego z 28 października 2016 r., sygn. akt V KK 255/16, LEX nr 2174127**

- (...) zmiana opisu czynu, która nie powoduje zmiany kwalifikacji prawnej czynu, nie wymaga uprzedzenia oskarżonego o takim zamiarze, albowiem postępowanie i wydane w jego następstwie orzeczenie nadal dotyczy tego samego czynu, o który wniesiono oskarżenie, a żaden przepis proceduralny nie wymaga takiego uprzedzenia, a zatem nie można mówić o naruszeniu przepisów postępowania, w tym przede wszystkim art. 399 § 1 k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 31 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 280/15**
- Nieuwzględnienie bowiem przez sąd I instancji tych wniosków dowodowych nie może zostać a priori uznane za naruszenie prawa do obrony. Dopuszczenie określonych dowodów stanowi bowiem kompetencję sądu, która wykonywana jest w ramach granic wyznaczonych w art. 7 k.p.k. Dlatego też decyzja sądu w tym zakresie mogłaby być oceniana w kategoriach naruszenia gwarancji procesowych z art. 6 k.p.k. jedynie w razie precyzyjnego wykazania przez skarżącą w jaki sposób oddalenie określonego wniosku dowodowego naruszyło prawo do obrony oskarżonego – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 18/16**
- (...) nie sposób mówić o ograniczeniu prawa do obrony, jeżeli czynność w sposób już nie budzący żadnych wątpliwości, co do prawidłowości jej przebiegu, została powtórnie dokonana – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 2 października 2015 r., sygn. akt II AKa 163/14**
- Słusznie zauważa obrońca oskarżonego G. w apelacji, iż temu oskarżonemu w toku rozpoznawania sprawy na etapie postępowania sądowego utrudniano możliwość zapoznania się z aktami sprawy, czym poniekąd formalnie naruszano jego prawo do obrony w rozumieniu art. 6 k.p.k., tj. w wyniku obrazu przepisu art. 156 § 1 k.p.k. Przepis art. 156 § 1 k.p.k. jasno bowiem stanowi, iż stronom udostępnia się akta sprawy

sądowej. Oznacza to, iż po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia wraz z aktami sprawy należy stronie umożliwić zapoznanie się z tymi aktami, jeżeli strona wyrazi taką wolę. Chwilowym wyjątkiem od tej zasady może być jedynie niemożność wydania akt stronie z przyczyn organizacyjno-technicznych, jak choćby z powodu zapoznawania się w tym samym czasie z aktami przez skład orzekający, inne strony postępowania czy przesłanie akt np. do innego sądu (...). Nie można natomiast na niekorzyść oskarżonych wziąć pod uwagę faktu, iż oskarżeni w toku procesu nie wyrazili skruchy i nie przeprosili pokrzywdzonych, jak to błędnie przyjmuje Sąd I instancji (...), bowiem nie można poczytywać na niekorzyść oskarżonych prezentowanej przez nich postawy procesowej w ramach przysługującego im prawa do obrony (art. 6 k.p.k.). Skoro zaś żaden z oskarżonych nie przyznawał się do winy, to trudno żądać od każdego z nich, by wyrażał na rozprawie skruchę i przepraszał pokrzywdzonych za swoje przestępcze działania. Odwrotna zaś byłaby sytuacja, gdyby oskarżeni przyznali się do winy, wyrazili skruchę i przeprosili pokrzywdzonych. Wówczas bowiem takie zachowanie się oskarżonych stanowiłoby istotną okoliczność łagodzącą – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 września 2015 r., sygn. akt II AKa 168/14**

- Ten sam adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci klienci na to się godzili. Racją unormowania zawartego w przepisie art. 85 § 2 k.p.k. jest wyłączenie możliwości kontynuacji obrony tych oskarżonych, co do których wystąpiła kolizja interesów oraz odsunięcie podejrzenia, że adwokat mógłby wykorzystać dotychczas uzyskane informacje z naruszeniem interesów tego oskarżonego, którego nie broniłby w dalszym postępowaniu. Jednocześnie wskazać trzeba, że naruszenie zakazu określonego w przepisie art. 85 § 1 k.p.k. musi być oceniane na kanwie realiów konkretnej sprawy, zwłaszcza etapu jej zaawansowania i momentu objęcia przez adwokata obrony oskarżonych w kontekście ujawnienia przez sąd sprzeczności interesów. Sam fakt, że adwokat podjął się obrony oskarżonych (czy to z wyboru, czy z urzędu), pomiędzy którymi zachodzi kolizja interesów, automatycznie nie generuje potrzeby, a zarazem konieczności, by obrońca ten został odsunięty od obrony każdego z tych oskarżonych. „Wychwycenie”

*sprzeczności interesów w bardzo wczesnej fazie od podjęcia się przez adwokata obrony w sytuacji kolizyjnej, a więc w takim momencie, gdy obrońca nie był jeszcze w stanie zapoznać się z linią obrony oskarżonych i modelować sytuacji procesowej wadliwie reprezentowanych przez niego oskarżonych oraz bezzwłoczne uruchomienie mechanizmów, o których mowa w art. 85 § 2 k.p.k., może stworzyć sytuację, w której adwokat nie będzie zmuszony do zrezygnowania z udziału w sprawie. Samo złożenie pełnomocnictwa, czy też wyznaczenie adwokata jako obrońcy z urzędu, ale bez podjęcia konkretnych czynności obrończych stwarza jednak sytuację, w której tenże adwokat nie powziął od poszczególnych oskarżonych wiadomości o sprawie i nie miał wpływu na uzewnętrznione modelowanie linii obrony poszczególnych oskarżonych. Wydaje się, że przyjęcie odmiennej koncepcji stanowiłoby naruszenie fundamentalnej zasady swobody wyboru obrońcy – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II AKz 389/10, LEX nr 663655***

- Trybunał przypomina, że nawet jeżeli zasadniczym celem artykułu 6 Konwencji, w przypadku postępowań karnych, jest zagwarantowanie sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez „sąd” właściwy do rozstrzygnięcia o zasadności „każdego oskarżenia”, nie oznacza to, iż postanowienie to nie ma zastosowania w postępowaniu przygotowawczym. W rezultacie, artykuł 6 – a w szczególności ustęp 3 – może mieć zastosowanie zanim sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia sądowi, jeżeli i w takim stopniu, w jakim bezstronność postępowania sądowego mogłaby ponieść uszczerbek z powodu niezastosowania owych postanowień w początkowym etapie. Sposób, w jaki artykuł 6 §§ 1 i 3 (c) Konwencji ma być zastosowany w postępowaniu przygotowawczym, zależy od szczególnych cech danego postępowania oraz od okoliczności sprawy (zob. *Brennan przeciwko Wielkiej Brytanii*, nr 39846/98, 16.10.2001, § 45, ETPC 2001-X). W swoim wyroku w sprawie *John Murray przeciwko Wielkiej Brytanii* (nr 18731/91, 8.2.1996, § 63, ETPC 1996-I) Trybunał zauważył również, że choć artykuł 6 zwykle wymaga, aby oskarżony mógł korzystać z pomocy obrońcy na początkowym etapie przesłuchania policyjnego, prawo to, które nie jest wyraźnie zawarte w Konwencji, może zostać ograniczone w słusznym celu. W każdym przypadku należy postawić pytanie,

czy ograniczenie, na tle całego postępowania, pozbawiło oskarżonego prawa do sprawiedliwego procesu (zob. także sprawę Brennan, cytowaną powyżej, ibid.). Trybunał zauważa, że pozostaje bezsporne, iż skarżący nie posiadali środków, aby zatrudnić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu karnym w ich sprawie. Nie jest również kwestionowany fakt, iż wniosek skarżących o wyznaczenie obrońcy z urzędu został zignorowany przez władze, a w rezultacie skarżący nie mieli obrońcy przez ponad rok. Biorąc pod uwagę liczbę czynności procesowych (w tym przesłuchiwanie skarżących i poddawanie ich badaniom), które w tym czasie przeprowadzono (zob. §§ 40–45 powyżej), zdaniem Trybunału owo ograniczenie, pozbawiające skarżących prawa do właściwej obrony podczas śledztwa i w postępowaniu sądowym, było nieuzasadnione. W związku z powyższym, Trybunał uznaje, że miało miejsce naruszenie artykułu 6 §§ 1 i 3 (c) Konwencji – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 czerwca 2002 r., BERLIŃSKI v. POLSKA, nr skarg 27715/95 i 30209/96. LEX nr 53648

- *Podjęcie się przez adwokata obrony kilku oskarżonych w jednej sprawie w sytuacji, gdy ich interesy są ze sobą sprzeczne, stanowi naruszenie podstawowego prawa oskarżonego, jakim jest prawo do obrony w procesie karnym (art. 9 k.p.k. – obecnie art. 6 k.p.k. – uwaga autorki), i z reguły ma wpływ na treść wyroku – wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 1980 r., sygn. akt II KR 163/80*
- *Skoro odmowa złożenia wyjaśnień lub udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania uznana została w polskim procesie karnym jako jeden z elementów prawa oskarżonego do obrony, to skorzystanie z tego prawa nie może być poczytane za okoliczność obciążającą – wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 1977 r., sygn. akt V KR 176/77*

Ad. 9.5. Czy w apelacjach karnych można formułować zarzuty obrazy prawa cywilnego?

Na tak sformułowane pytanie odpowiedzieć należy twierdząco z zastrzeżeniem, że w oczywisty sposób odpowiedź ta dotyczy zasadniczo przepisów

prawa cywilnego materialnego. Sąd karny nie stosuje bowiem przepisów odnoszących się do procedury cywilnej – wyjątkiem w tym zakresie jest odpowiednie zastosowanie przepisów „obowiązujących w postępowaniu cywilnym” w kwestiach dotyczących pełnomocnika (art. 89 k.p.k.⁸⁴) oraz zastosowanie przepisów cywilnych wprost w oparciu o art. 558 k.p.k. Zdarza się jednak, że sąd karny przy rozstrzygnięciu o odpowiedzialności oskarżonego stosuje przepisy prawa cywilnego materialnego bądź Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, należących do szeroko pojętego prawa cywilnego. Należy również podkreślić, że w sprawach przestępstw nieumyślnych konieczne jest co do zasady wykazanie odstępstwa od standardów wypracowanych w danej dziedzinie. To zaś powoduje, że sąd karny nierzadko musi „sięgnąć” do przepisów z innej dziedziny prawa, by stwierdzić, czy rzeczywiście doszło w danym przypadku do naruszenia obowiązujących reguł ostrożności (tj. naruszenia standardu, określonego i obowiązującego w danej sferze życia).

Omawiając zagadnienie stosowania przepisów prawa cywilnego materialnego przez sądy karne, nie sposób nie wskazać, że orzekając o zadośćuczynieniu z art. 46 § 1 k.k. sąd karny stosuje reguły cywilnoprawne, wypracowane na tle art. 444 k.c. i art. 445 k.c. Podobnie, aby ocenić czy doszło do przestępstwa na szkodę spółki, sąd musi nierzadko zastosować przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jeśli zatem sąd nieprawidłowo zinterpretuje ww. przepisy materialnoprawne bądź przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym zastosuje ww. przepisy, choć zdaniem skarżącego przepisy te nie znajdują zastosowania do tegoż niekwestionowanego stanu faktycznego, wówczas dopuszczalne i właściwe jest sformułowanie w apelacji zarzutów obrazy prawa materialnego, których podstawą będą przepisy „pozakarne”. Sytuacja taka nie występuje często, tym niemniej warto mieć świadomość, że w praktyce taka możliwość występuje.

⁸⁴ Jak wskazuje K. Eichstaedt, „(...) mówiąc o odpowiednim stosowaniu przepisów obowiązujących w postępowaniu cywilnym, należy wspomnieć m.in. o: 1) art. 93 k.p.c. – dotyczącym prostowania lub odwoływania oświadczeń pełnomocnika; 2) art. 94 i 95 k.p.c. – dotyczącym wypowiedzenia pełnomocnictwa (J. Grajewski [w:] Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. 1, 2015, komentarz do art. 89)” – K. Eichstaedt, [w:] D. Świecki (red.), B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, *Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany*, komentarz do art. 89 k.p.k., opubl. LEX/el 2022, teza 2.

W przypadku zarzutu obrazy prawa materialnego z innej dziedziny prawa aniżeli przepisy karne, zarzuty konstruuje się według wcześniej omówionych zasad, odnoszących się do zarzutów obrazy prawa karnego materialnego (zob. podrozdział 6.2.2.1. niniejszej publikacji).

Zaznaczenia jednocześnie wymaga, że jeśli zdaniem skarżącego sąd zasądził nadmierną wysokość zadośćuczynienia od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego, to zasadne jest sformułowanie w tym zakresie zarzutów, kwestionujących ustalenia faktyczne dotyczące rozmiaru szkody. Błędem byłoby natomiast sformułowanie w takiej sytuacji zarzutu obrazy prawa materialnego. Zarzut obrazy prawa materialnego byłby bowiem dopuszczalny wtedy, gdy sąd przy ocenie wysokości środka kompensacyjnego pod uwagę wziął elementy niewynikające z treści art. 444 k.c. i 445 k.c. oraz wypracowanego na ich tle orzecznictwa cywilnego. Jak słusznie bowiem wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku, *skoro zgodnie z art. 46 § 1 k.k. sąd karny, orzekając omawiany środek kompensacyjny, stosuje przepisy prawa cywilnego, to ustalenie rozmiaru krzywdy musi opierać się na zasadach wynikających z prawa cywilnego, w tym wypracowanych w orzecznictwie sądów cywilnych*⁸⁵.

Przydatne orzecznictwo:

- *Ustalenie wysokości zadośćuczynienia, przy wykorzystaniu ujętego w art. 445 § 1 k.c. nieokreślonego kryterium „sumy odpowiedniej”, należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego. Powinno obejmować wszelką niematerialną krzywdę, wyrządzoną bezprawnie, a zatem niezastuszenie, uszkodowanemu. Na krzywdę składa się cierpienie, ból fizyczny, poczucie nieszczęścia, lęk, czy w końcu dyskomfort psychiczny wynikający z pogorszenia jakości życia, ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, ale także pozbawienia możliwości odczuwania przyjemności, realizowania zainteresowań. Kwota pieniężna przyznana w ramach zadośćuczynienia powinna w pełni lub w stopniu możliwym zrekompensować wyrządzoną uszkodowanemu krzywdę. Choć przepisy prawa cywilnego nie wskazują wysokości zadośćuczynienia, to nie można redukować – marginalizować tej formy naprawienia szkody, bowiem z perspektywy*

⁸⁵ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKa 105/19.

poszkodowanego jest to istotny, a niekiedy zasadniczy, środek kompensacji jego krzywdy. „Odpowiednie” zadośćuczynienie powinno zatem obejmować rodzaj, czas i natężenie cierpień poszkodowanego przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności sprawy – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt II AKa 140/21

- *Skutkiem istniejącego w ustawodawstwie cywilnym, a z mocy art. 46 § 1 k.k., także karnym, obligatoryjnego rozwiązania o solidarnej odpowiedzialności sprawców deliktu, jest zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych, którzy żądać mogliby spełnienia obowiązku od wszystkich sprawców jak również od każdego z osobna. Konsekwencją naprawienia szkody przez jednego ze sprawców, jest natomiast zwolnienie ze zobowiązania pozostałych (art. 366 § 1 k.c.). O ile zatem naprawienie szkody przez któregośkolwiek ze sprawców w ramach czynów przypisanych w niniejszej sprawie miałyby miejsce, jego konsekwencją jest wygaśnięcie zobowiązania orzeczonego z tytułu obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 k.k. wobec pozostałych. Dotyczy to także skazanych w niniejszej sprawie w sytuacji, gdyby doszło do spełnienia świadczeń orzeczonych solidarnie wobec nich oraz K. M. Istotne jest przy tym, że jakkolwiek wygaśnięcie zobowiązań wobec dłużników solidarnych następuje z mocy samego prawa, to z drugiej strony pozytywne określenie obowiązku naprawienia szkody wobec współsprawców sądzonych w różnych postępowaniach umożliwia w przyszłości ustalenie zakresu odpowiedzialności regresowej – postanowienie Sądu Najwyższego z 2 marca 2021 r., sygn. akt II KK 25/21*
- *Zatem wobec złożenia przez pokrzywdzoną (...) RBL wniosku w trybie art. 46 § 1 k.k., zmierzającego do ustalenia istnienia cywilnoprawnego roszczenia i szkody w rozumieniu przepisów k.c. w zakresie możliwości dochodzenia kar umownych wobec osób trzecich, które uniemożliwić miał swoim zachowaniem oskarżony, to na pokrzywdzonej spoczywał ciężar dowodowy wykazania istnienia oraz wysokości szkody. Pokrzywdzona jest bowiem podmiotem, który w tej sprawie powinien wykazać, tj. udowodnić istnienie podstaw i wysokość roszczenia cywilnego – wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2021 r., sygn. akt I KA 10/20*
- *W związku z wnioskiem o zasadzenie na rzecz pokrzywdzonego zadośćuczynienia zgłoszonym na podstawie art. 46 § 1 k.k. sąd zasądził (...)*

tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Do orzeczenia w tym zakresie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądowym na rozmiar zasądzonego zadośćuczynienia mogą mieć wpływ rozmaite okoliczności, do których – oprócz natężenia doznawanych przez poszkodowanego cierpień – należą m.in.: rodzaj naruszonego dobra osobistego, stopień winy sprawcy (zob. wyrok SN z 16 kwietnia 2002 r., V CKN 1010/00, *Legalis* nr 55210; wyrok SN z 19 sierpnia 1980 r., IV CR 283/80, *Legalis* nr 22193), czas trwania cierpień poszkodowanego czy ujemne skutki zdrowotne, jakie będzie on zmuszony znosić w przyszłości (wyrok SN z 29 września 2004 r., II CK 531/03, *Legalis* nr 277051). Wśród wskazywanych w orzecznictwie okoliczności wpływających na wysokość zadośćuczynienia niektóre mają charakter bardziej uniwersalny, inne zaś nadają się wyłącznie do ustalenia rozmiaru krzywdy wyrządzonej naruszeniem konkretnego dobra osobistego. Kryteria ujawnione dotąd w orzecznictwie mogą być traktowane jedynie jako wskazówki. Najistotniejsze jest bowiem to, by wysokość zadośćuczynienia odzwierciedlała wszelkie okoliczności danego przypadku, które mogą wpływać na rozmiar i intensywność doznawanych przez poszkodowanego cierpień – **wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 7 listopada 2019 r., sygn. akt II K 24/19**

- Skoro zgodnie z art. 46 § 1 k.k. sąd karny, orzekając omawiany środek kompensacyjny, stosuje przepisy prawa cywilnego, to ustalenie rozmiaru krzywdy musi opierać się na zasadach wynikających z prawa cywilnego, w tym wypracowanych w orzecznictwie sądów cywilnych. W przedmiotowej sprawie podstawowe znaczenie ma przepis art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c., z których wynika, iż w wypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na skutek czynu niedozwolonego sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W piśmiennictwie cywilistycznym wskazuje się, że chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienie fizyczne (ból i inne dolegliwości) oraz cierpienia psychiczne (ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniem fizycznym lub następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, niemożności uprawiania określonej działalności np. sportu, wyłączenie

z normalnego życia). Zadośćuczynienie powinno obejmować wszystkie cierpienia. Ma więc ono charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę za całą krzywdę doznaną przez poszkodowanego (zob. G. Bieniek (red.), Kodeks cywilny Księga trzecia Zobowiązania Komentarz, t. 1, Warszawa 2002, s. 430). Pomimo niemożności precyzyjnego ustalenia rozmiarów uszczerbku o niemajątkowym charakterze rozstrzygnięcie w tym zakresie powinno opierać się na kryteriach zobiektywizowanych, a nie mieć na względzie wyłącznie subiektywne odczucia poszkodowanego (wyrok SN z dnia 3 czerwca 2010 r., III CSK 279/10, LEX nr 898254). Zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny i jego wysokość musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Wysokość ta nie może być jednak nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i aktualnych stosunków majątkowych społeczeństwa (tak m.in. wyrok SN z dnia 26 lutego 1962 r., 4 CR 902/61, OSNCP 1963, z. 5, poz. 107; orzeczenie SN z dnia 24 czerwca 1965 r., I PR 203/65, LEX nr 13394). Z drugiej strony wskazuje się jednak na to, iż oceniając rozmiar doznanej krzywdy, trzeba wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, w tym: rozmiar cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie (intensywność) i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), ujemne skutki zdrowotne, jakie osoba poszkodowana będzie zmuszona ponosić w przyszłości, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz inne czynniki podobnej natury (tak Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 8 grudnia 1973 r., III CZP 37/73, OSNC 1974, z. 9, poz. 145; wyroki SN: z dnia 10 grudnia 1997 r., III CKN 219/97, LEX nr 897880; z dnia 29 września 2004 r., II CK 531/03, LEX nr 137577; z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, LEX nr 369691). Wobec tego przyznanie poszkodowanemu zadośćuczynienia zależy od uznania sądu przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, w tym także indywidualnych właściwości i subiektywnych odczuć osoby pokrzywdzonej (zob. wyroki SN: z dnia 27 sierpnia 1969 r., I PR 280/65, OSNCP 1970, z. 6, poz. 11; z dnia 6 czerwca 1997 r., II CKN 204/97, LEX nr 1633795). Krzywdą jest z reguły trwałe kalectwo powodujące cierpienie fizyczne oraz ograniczenie ruchów i wykonywanie czynności życia

codziennego. Wynikłe z uszkodzenia ciała ograniczenie wydolności pracy i utrudnienia w jej wykonaniu, niestanowiące podstawy do przyznania renty inwalidzkiej, nie mogą być pominięte przy ocenie roszczenia z tytułu zadośćuczynienia i powinny mieć wpływ na jego wysokość (tak wyrok SN z dnia 4 czerwca 1968 r., I PR 175/68, OSNCP 1969, z. 2, poz. 37). Podkreśla się również, iż zdrowie jest szczególnie cennym dobrem i przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia w przypadkach ciężkich uszkodzeń ciała prowadzi do niepożądanego deprecjacji tego dobra (zob. wyrok SN z dnia 16 lipca 1997 r., II CKN 273/97, LEX nr 286781). Zdrowie ludzkie jest dobrem o szczególnie wysokiej wartości, w związku z czym zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu powinno być odpowiednio duże. W orzecznictwie sądów cywilnych także wskazuje się, że zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, zarówno doznanych, jak i tych, które zapewne powstaną w przyszłości. Ma charakter całościowy i jednoznaczny, powinien stanowić rekompensatę pieniężną za całą krzywdę, zaś podstawą odmowy przyznania zadośćuczynienia nie może też być fakt, iż w dniu orzekania doznana krzywda przestała już istnieć (wyrok SN z dnia 14 listopada 1961 r., 4 CR 193/61, „Nowe Prawo” 1962, nr 9, s. 1223). Sąd Najwyższy wielokrotnie też podkreślał, że ze względu na kompensacyjny charakter zadośćuczynienia jego wysokość musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, adekwatną do warunków gospodarki rynkowej. W orzecznictwie wskazuje się jednocześnie, że mierzenie krzywdy wyłącznie stopniem uszczerbku na zdrowiu stanowiłoby niedopuszczalne uproszczenie nieznaające oparcia w treści art. 445 § 1 k.c. (wyrok SN z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05, LEX nr 153254) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKa 105/19**

Ad. 9.6. Czy w apelacji zasadne jest formułowanie zarzutu obrazy art. 424 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.k.?

Nie budzi w zasadzie wątpliwości, że zarzuty stawiane uzasadnieniu wyroku nie są prawidłowe i skuteczne. Wynika to z faktu, że uzasadnienie sporządzane

jest już po wydaniu orzeczenia, co w sensie logicznym wyklucza możliwość (wymaganego art. 438 pkt 2 k.p.k.) wpływu uchybień w tym zakresie na treść uprzednio wydanego wyroku. Wprawdzie w praktyce jeszcze do niedawna pojawiały się koncepcje, że skoro uzasadnienie jest odzwierciedleniem procesu myślowego, który doprowadził sąd I instancji do określonego rozstrzygnięcia, to braki czy błędy uzasadnienia ujawniają analogiczne braki i błędy tegoż procesu myślowego.

Obecny stan prawny zawiera rozwiązania rozstrzygające wcześniejsze wątpliwości w omawianym zakresie⁸⁶, poprzez wskazanie w art. 455a k.p.k. wprost, że nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424 k.p.k. Potwierdza to również najnowsze stanowisko orzecnicze, z którego wynika, że *obraza przepisu art. 424 k.p.k. nie stanowiła nigdy i nie stanowi obecnie naruszenia prawa procesowego o charakterze mającym wpływ na treść orzeczenia, bowiem do sporządzenia uzasadnienia dochodzi po wydaniu wyroku*⁸⁷.

Warto jednakże podkreślić za Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, że *nie można wprawdzie uchylić wyroku z tego powodu, że jego pisemne uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424 k.p.k., jednakże braki w uzasadnieniu nadal mogą wskazywać, że w procesie wyrokowania lub na etapie gromadzenia dowodów doszło do uchybień, które świadczą o takim stopniu wadliwości wyroku, który powoduje konieczność jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji; wymaga to jednak wyeksponowania innych jeszcze uchybień, które zostaną powiązane z treścią uzasadnienia wyroku dla wzmocnienia argumentacji w zakresie jego wadliwości, w szczególności (i najczęściej) w zakresie naruszenia reguł procesowych z art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k.*⁸⁸

⁸⁶ Art. 5 pkt 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U.2015.396), zmieniającej k.p.k. z dniem 1 lipca 2015 r. wprowadził bowiem art. 455a k.p.k., zgodnie z którym nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424 k.p.k.

⁸⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 stycznia 2022 r., sygn. akt II AKa 21/21.

⁸⁸ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5 lipca 2019 r., sygn. akt II AKa 178/19.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) obraza przepisu art. 424 k.p.k. nie stanowiła nigdy i nie stanowi obecnie naruszenia prawa procesowego o charakterze mającym wpływ na treść orzeczenia, bowiem do sporządzenia uzasadnienia dochodzi po wydaniu wyroku. Nadto, z uwagi na treść art. 455a k.p.k. obowiązującego od 1 lipca 2015 r. podnoszenie tego rodzaju zarzutu jest niezasadne i bezcelowe, skoro nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 stycznia 2022 r., sygn. akt II AKa 21/21**
- (...) praktyka, w której Sąd nie przedstawia w uzasadnieniu całości motywów rozstrzygnięcia, lecz wskazuje, że część tych motywów jest zawarta w innym dokumencie, jest błędna. Zgodnie z art. 424 § 1 pkt 2 k.p.k. uzasadnienie musi zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku, czyli w przypadku wyroku łącznego – przesłanek łączenia lub niełączenia poszczególnych kar i wymogowi temu nie czyni zadość odesłanie do innych uzasadnień, choćby sporządzonych przez tego samego sędziego, jak właśnie uzasadnienie w sprawie (...). Uzasadnienie w danej sprawie ma być dokumentem kompletnym i samodzielny w tym sensie, że jego lektura ma być wystarczająca dla odtworzenia toku rozumowania Sądu I instancji (...). obrońca musi wykazać, że obraza ta mogła mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia (art. 438 pkt 2 k.p.k.) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 września 2021 r., sygn. akt II AKa 177/21**
- (...) art. 424 § 1 pkt 1 *in fine* nie wymaga, aby w uzasadnieniu sąd wykazał, dlaczego na podstawie danego dowodu dokonał ustaleń faktycznych. Przepis ten nakazuje jedynie uzasadnić, dlaczego sąd nie uznał dowodów przeciwnych. Zachodzi tu bowiem logiczna zależność pomiędzy trafnością ocen przeciwnych dowodów. Prawidłowe odrzucenie jednych dowodów świadczy o zasadnym przyjęciu innych – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lipca 2021 r., sygn. akt II AKa 81/21**
- Nowe unormowanie treści przepisu art. 424 § 1 k.p.k. nie tylko pozwala, ale wręcz nakazuje sądowi odstąpić od dotychczasowej praktyki. Nie oznacza jednak zwolnienia sądu od obowiązku respektowania sporządzenia uzasadnienia gwarantującego prawo strony do rzetelnego procesu, tak w ujęciu konwencyjnym, jak i konstytucyjnym, stosownie do

rozważań zaprezentowanych wcześniej. To zaś oznacza, by także na formularzu UK 2 uzasadnienie wyroku odpowiadało tym standardom. Gdyby zaś orzekający sąd uznał, że sporządzenie uzasadnienia wyroku na formularzu UK 2 nie daje właściwego instrumentarium procesowego dla zrealizowania wskazanego standardu, może odstąpić od tego obowiązku, sporządzając uzasadnienie wyroku w dotychczasowej formie (tak też, zob. wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20, OSNKW, z. 9–10, 2020, poz. 41 z orzecnictwem i poglądami doktryny tam przytoczonymi) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 grudnia 2020 r., sygn. akt II AKa 169/20**

- Brak pisemnego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji nie uniemożliwia, a tylko w pewnym stopniu utrudnia, dokonanie przez sąd odwoławczy kontroli instancyjnej takiego wyroku. Na etapie postępowania apelacyjnego możliwa jest zawsze ocena całości materiału procesowego zebranego w sprawie, w szczególności dowodów przeprowadzonych w toku postępowania sądowego, treści decyzji procesowych podjętych w tym postępowaniu, zapisów treści protokołów rozpraw i posiedzeń oraz innych czynności organów procesowych. Te źródła wiedzy o przebiegu postępowania poprzedzającego wydanie wyroku sądu pierwszej instancji, oraz wszelkie rzeczowe i logiczne wnioski, które można wysnuć z ich analizy, z uwzględnieniem zasad poprawnego prawniczego rozumowania, stanowią *in concreto* podstawę do oceny trafności i prawidłowości kontrolowanego orzeczenia – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 września 2019 r., sygn. akt IV KS 39/19**
- (...) nie można wprowadzić uchylić wyroku z tego powodu, że jego pisemne uzasadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424 k.p.k., jednakże braki w uzasadnieniu nadal mogą wskazywać, że w procesie wyrokowania lub na etapie gromadzenia dowodów doszło do uchybień, które świadczą o takim stopniu wadliwości wyroku, który powoduje konieczność jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji; wymaga to jednak wyeksponowania innych jeszcze uchybień, które zostaną powiązane z treścią uzasadnienia wyroku dla wzmocnienia argumentacji w zakresie jego wadliwości, w szczególności (i najczęściej) w zakresie naruszenia reguł procesowych z art. 7 k.p.k.

i art. 410 k.p.k. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 438/15, LEX nr 2073883 oraz wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 521/15, Biul.SAKa 2016/2/13) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5 lipca 2019 r., sygn. akt II AKa 178/19

- (...) *przedmiotem kontroli odwoławczej jest wyrok, a nie samo uzasadnienie, ewentualne nieprawidłowości w jego sporządzeniu nie oznaczają nieprawidłowości wyroku, to materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, stanowiący podstawę dowodową wyroku, powinien decydować o trafności zawartych w nim rozstrzygnięć, a nie sam dokument w postaci uzasadnienia. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w fakcie, że uzasadnienie jest sporządzane po wydaniu wyroku, a zatem nie może mieć wpływu na jego treść. Oczywiście pewne braki uzasadnienia, jak brak istotnych ustaleń faktycznych, brak oceny istotnych dowodów, mogą, ale nie muszą wskazywać na zaistnienie istotnych uchybień związanych z etapem wyrokowania – wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 1 marca 2019 r., sygn. akt II AKa 222/18*

Ad. 9.7. W jakich okolicznościach zasadne jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 410 k.p.k.?

Art. 410 k.p.k. traktuje o konieczności oparcia rozstrzygnięcia sądu o całość kształt dowodów, zgromadzonych w sprawie i ujawnionych we właściwej procesowo formie na rozprawie. **Dowody nieujawnione na rozprawie głównej nie mogą być bowiem podstawą czynienia w sprawie jakichkolwiek ustaleń faktycznych.**

Należy zatem pamiętać, że zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sąd ma obowiązek zapoznać się z dowodami bezpośrednio. Z tego względu m.in. sąd wzywa na rozprawę świadków i na rozprawie ich przesłuchuje, zgodnie z zasadą bezpośredniości. Natomiast, aby sąd mógł zapoznać się z zeznaniami świadka bądź wyjaśnieniami oskarżonego, złożonymi na etapie postępowania przygotowawczego, musi je ujawnić – odpowiednio w trybie art. 391 k.p.k. lub art. 392 k.p.k, albo art. 389 k.p.k.

W tym kontekście zaznaczenia wymaga, że np. **ujawnienie na rozprawie głównej zeznań**, złożonych przez świadka w postępowaniu przygotowawczym, wymaga albo ich odczytania na rozprawie głównej (art. 391 § 1 k.p.k.) w trakcie bezpośredniego przesłuchania świadka przed sądem, albo wydania postanowienia o ujawnieniu tychże zeznań przez ich odczytanie (art. 392 § 1 k.p.k.) bądź bez ich odczytywania (art. 392 § 1 k.p.k. w zw. z art. 394 § 2 k.p.k.), nie zaś wyłącznie zaliczenia do materiału dowodowego w trybie art. 405 § 2 k.p.k. **Bez ujawnienia tym samym treści zeznań świadka z postępowania przygotowawczego na rozprawie głównej w sposób powyżej wskazany, sąd nie powinien czynić w oparciu o ten dowód żadnych ustaleń w sprawie**⁸⁹.

Zarzut obrazy art. 410 k.p.k. będzie skuteczny wtedy, gdy sąd nie ocenił dowodu, który ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, a nie gdy nie rozważył wszystkich pojedynczych dowodów, bez względu na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia⁹⁰.

Zarzut obrazy art. 410 k.p.k. może być także podniesiony wówczas, gdy sąd fragmentarycznie ocenia określony dowód, np. gdy wybiera z treści zeznań świadka tylko te fragmenty, które pasują do ustalanego stanu faktycznego. Wówczas uzasadnione byłoby sformułowanie zarzutu obrazy art. 410 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k., np. poprzez dowolną ocenę zeznań świadka, czynioną z pominięciem określonego fragmentu jego wypowiedzi, która sprzeczna jest z oceną tychże zeznań, dokonaną przez sąd.

⁸⁹ Dodatkowego komentarza wymaga zagadnienie ujawnienia w postępowaniu karnym treści, zapisanych na płycie CD. Sposób ujawnienia tych danych zależy od tego, co dokładnie utrwalone zostało na tym nośniku. Jeśli bowiem płyta CD zawiera nagrania, np. z czynności operacyjno-rozpoznawczych (podśluchu), to płyta ta stanowi dokument w rozumieniu procesowym i może podlegać ujawnieniu na zasadach art. 405 § 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 393 § 1 k.p.k. Jeśli jednak płyta CD zawiera nagranie czynności przesłuchania oskarżonego lub świadka (art. 393a k.p.k.), wówczas sporządza się protokół skrócony czynności protokolowanej i odtworzenie nagrania przesłuchania następuje na takich samych zasadach, jak odczytanie protokołu przesłuchania.

⁹⁰ Jak zaznaczył Sąd Najwyższy w jednym z najnowszych orzeczeń, *nie można (...) zarzutu naruszenia art. 410 k.p.k. opierać na tym, że pewne dowody nie stanowiły podstawy ustaleń, jeżeli zostały rozważone, a ich znaczenie ocenione w sposób czyniący zadość wymogom art. 7 k.p.k.* – postanowienie Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2021 r., sygn. akt IV KK 564/21.

W apelacji podstawą zarzutu odnoszącego się do braku oparcia orzeczenia na ujawnionych dowodach zawsze będzie art. 410 k.p.k., nie zaś art. 92 k.p.k.⁹¹

Przydatne orzecznictwo:

- *Przepis powyższy (art. 410 – uwaga autorki) nie może być rozumiany w ten sposób, że każdy z przeprowadzonych dowodów ma stanowić podstawę ustaleń Sądu. Jest to oczywiście niemożliwe, gdy z różnych dowodów wynikają sprzeczne okoliczności. Z naruszeniem tej regulacji nie należy zatem utożsamiać sytuacji uznania za wiarygodne określonych dowodów lub ich części, z jednoczesnym odmówieniem tego przymiotu innym, co stanowi przecież podstawową prerogatywę Sądu. Nie można więc zarzutu naruszenia art. 410 k.p.k. opierać na tym, że pewne dowody nie stanowiły podstawy ustaleń, jeżeli zostały rozważone, a ich znaczenie ocenione w sposób czyniący zadość wymogom art. 7 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2021 r., sygn. akt IV KK 564/21***
- *O naruszeniu tego przepisu wolno byłoby mówić, gdyby orzeczenie Sądu meriti oparte zostało na materiale nieujawnionym na rozprawie głównej, ewentualnie tylko na części ujawnionego materiału (...) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 24 listopada 2021 r., sygn. akt I KK 146/21***
- *(...) normy zawartej w art. 410 k.p.k. nie można rozumieć w ten sposób, że każdy z przeprowadzonych na rozprawie głównej dowodów ma stanowić podstawę ustaleń faktycznych. Byłoby to w wielu wypadkach w istocie niemożliwe ze względu na wzajemną sprzeczność okoliczności wynikających z różnych dowodów. Sam fakt, że tak dokonana ocena dowodów nie satysfakcjonuje autorki apelacji nie oznacza, że jej kwestionowanie należy uznać za skuteczne, zwłaszcza że skarżący nie przedstawia przekonujących i merytorycznych argumentów podważających dokonaną przez Sąd meriti ocenę dowodów – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 listopada 2021 r., sygn. akt II AKa 76/21***
- *Zatem podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej, zaś w uzasadnieniu sąd ma obowiązek wskazać jakie fakty uznał za udowodnione, na jakich w tej*

⁹¹ Postanowienie Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r., sygn. akt IV KK 578/18.

mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Na sądzie orzekającym ciąży przy tym obowiązek badania oraz uwzględniania w toku procesu okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, a korzystając z prawa swobodnej oceny dowodów, przekonanie o winie w zakresie przypisanego oskarżonemu czynu sąd powinien logicznie i przekonująco umotywować w uzasadnieniu wyroku. Uzasadnienie więc winno logicznie wskazywać na jakich dowodach Sąd I instancji oparł ustalenie każdego istotnego dla sprawy faktu, a także należyście rozważać i oceniać wszystkie dowody przemawiające za przyjętymi przez sąd ustaleniami faktycznymi lub przeciwnie, wyjaśniać istotne wątpliwości w sprawie i sprzeczności w materiale dowodowym oraz się do nich ustosunkować – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 19 października 2021 r., sygn. akt II AKa 81/21

- *Odmówienie wiary niektórym zeznaniom lub wyjaśnieniom złożonym przez świadków lub oskarżonych, a w rezultacie ich pominięcie jako podstawy dowodowej podczas dokonywanych ustaleń faktycznych, nie może być utożsamiane ani z brakiem oceny okoliczności, których tego rodzaju dowód dotyczy w kontekście finalnego rozstrzygnięcia, ani też nie jest wyrazem złamania zasady bezstronności sądu, bowiem odmowa przyznania waloru wiarygodności niektórym z przeprowadzonych dowodów, przy jednoczesnej aprobacie i uwzględnieniu innych dowodów, jest niczym więcej niż realizacją przysługującego sądowi orzekającemu uprawnienia w ramach czynienia ustaleń faktycznych, z pełnym uwzględnieniem zasady swobodnej oceny dowodów – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 września 2021 r., sygn. akt II AKa 292/20*
- *(...) o obrazie art. 410 k.p.k. można mówić dopiero wówczas, gdyby sąd rozpoznający sprawę rzeczywiście nie odniósł się w ramach oceny dowodów, do przeprowadzonych na określonym terminie rozprawy dowodów, przy czym niezbędnym jest wówczas wykazanie, które dowody pominięto i jakie mogły one mieć znaczenie dla poprawności poczynionych ustaleń faktycznych – postanowienie Sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 r., sygn. akt V KK 524/20*
- *(...) nie może być mowy o obrazie art. 410 k.p.k. w przypadku uznania określonych dowodów za wiarygodne, a odmówienie tego waloru innym*

i w konsekwencji nie przyjęcie tych ostatnich jako podstawy ustalania faktów. Nie może dojść także do naruszenia tej regulacji przez sąd drugiej instancji, jeżeli nie przeprowadza on postępowania dowodowego, a także nie dokonuje własnej – odmiennej od pierwszoinstancyjnej – oceny dowodów, akceptując tę jaka została przeprowadzona w toku postępowania rozpoznawczego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 1 października 2020 r., sygn. akt IV KK 407/20**

- *Istotą art. 410 k.p.k. jest to, że Sąd ferując wyrok nie może opierać się na tym, co nie zostało ujawnione na rozprawie, jak również i to, że wyroku nie można wydawać na części materiału dowodowego, a musi on być wynikiem analizy całokształtu ujawnionych okoliczności, a więc i tych które je podważają. Oczywistym jest również to, że Sąd nie może oprzeć rozstrzygnięcia na dowodzie, które nie uznał za wiarygodny. W takiej sytuacji obrońca winien kwestionować ocenę dowodu, a nie czynić zarzutu jego pominięcia –* **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 października 2019 r., sygn. akt II AKa 132/19**
- *(...) przepis art. 92 k.p.k. jest ujęty w dziale IV zatytułowanym „Czynności procesowe” i rozdziale 11 regulującym „Orzeczenia, zarządzenia, polecenia”. Ma on więc charakter ogólny i odnosi się wprost do orzeczeń, których podstawę stanowić może tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia. Oznacza to, iż dyrektywy wynikające z przepisu art. 92 k.p.k. powinny być przestrzegane w razie wydawania przez organy procesowe wszelkich rozstrzygnięć, a więc wyroków, postanowień i zarządzeń –* **postanowienie Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r., sygn. akt IV KK 578/18**
- *(...) nie może też budzić zastrzeżeń konstatacja – odnoszona zwłaszcza do spraw, w których zeznania świadka anonimowego stanowią jedną z głównych podstaw dowodowych rozstrzygnięcia, a tym bardziej do tych, w których ocena standardu przeprowadzenia tego dowodu, czy jego wiarygodności jest przedmiotem zarzutów środka odwoławczego – że także wszyscy sędziowie zasiadający w składzie sądu apelacyjnego obowiązani są zapoznać się, w sposób wyżej wskazany, z pełnymi protokołami jego zeznań. Trudno bowiem przyjąć, by prawidłowe rozpoznanie środka odwoławczego (a nawet możliwe przecież wykroczenie poza*

granice podniesionych w nim zarzutów – art. 433 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k.) mogło nie być poprzedzone samodzielnym, bez wątpienia warunkującym wprost obiektywizm ocen, zbadaniem przez każdego sędziego tak istotnych dla rozstrzygnięcia kwestii. Trudno też uznać, by praktyka odmienna nie tylko dawała wystarczającą gwarancję, iż okoliczności objęte tajemnicą istotnie były przedmiotem zobiektywizowanego procesu rozważań sądu, ale też, by zdolna była z jego rozstrzygnięcia usunąć cechę swojego rodzaju zwielokrotnienia arbitralności ocen, która i tak, w związku ze specyfiką dowodu z zeznań świadka anonimowego, jest nie do uniknięcia. Zapewnienia prawa do obrony w tych warunkach, nie sposób więc nie upatrywać także w opisanym standardzie orzekania sądu, w którym nie mieści się rezygnacja z zapoznania się przez wszystkich sędziów z całością zeznań świadka anonimowego, stanowiących istotny dowód w sprawie – **wyrok Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2009 r., sygn. akt V KK 93/09**

- (...) „nieuwzględnienie w należyтым stopniu” okoliczności łagodzących nie może być podstawą zarzutu naruszenia art. 410 k.p.k. Byłoby to możliwe wtedy tylko, gdyby okoliczności te zostały przez Sąd w ogóle pominięte (...) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 października 2007 r., sygn. akt III KK 236/07**
- Przeprowadzenie tego dowodu (przesłuchanie świadka) w trybie art. 396 § 2 k.p.k. wymagało ujawnienia złożonych zeznań na rozprawie głównej. Zgodnie bowiem z art. 410 k.p.k. podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej. Czynność poinformowania stron o przesłuchaniu świadka, jaką podjął przewodniczący składu orzekającego (...), nie stanowi ujawnienia dowodu w rozumieniu przywołanego przepisu. Tym samym dowód ten nie mógł być podstawą faktyczną wyroku – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 3 listopada 2004 r., sygn. akt II AKa 189/04, LEX nr 181134**
- Samo oświadczenie wnioskodawcy, iż podtrzymuje swoje dotychczasowe zeznania, bez ich uprzedniego odczytania albo ujawnione bez odczytania, nie spełniają wymogu o jakim mowa w art. 357 k.p.k. i taki dowód nie może stanowić podstawy orzekania (...) – **postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 7 czerwca 1994 r., sygn. akt II AKr 94/94**

Ad. 9.8. Czy właściwe jest formułowanie w apelacji zarzutu obrazy art. 167 k.p.k.?

Pomimo tego, że zarzut obrazy art. 167 k.p.k. często formułowany jest w apelacjach, to w praktyce rzadko kiedy jest zarzutem trafnym. Wprawdzie sąd karny ma obowiązek, zgodnie z art. 2 § 2 k.p.k., dążyć do wykrycia prawdy materialnej, to jednak jak zaznacza Sąd Najwyższy, *Sąd orzekający ma zatem obowiązek dochodzenia do prawdy również w sytuacji, gdy strony nie wnioskują o przeprowadzenie nowych dowodów, ale dopiero wówczas, gdy dokonując oceny dowodów uzna, że materiał dowodowy jest niepełny i nasuwa wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy i tym samym wymaga uzupełnienia*⁹². Co więcej, *naruszenie art. 167 k.p.k. może mieć miejsce wówczas, gdy zaniechano przeprowadzenia dowodu, mimo że zachodziły ku temu uzasadnione przesłanki, a jego uzyskanie było niezbędne dla prawidłowego wyrokowania, a nie podyktowane poszukiwaniem ewentualnego wsparcia dla irrelevantnych procesowo tez*⁹³.

Konsekwencją powyższego poglądu jest to, że to sąd ocenia czy zgromadzony materiał dowodowy wymaga owego uzupełniania czy też nie. W praktyce zdarza się, że błędna ocena materiału dowodowego, np. zeznań świadka, dokonana przez sąd, pozbawia go potrzeby dalszej weryfikacji tegoż materiału. Innymi słowy zdarza się, że sąd błędnie przekonany był o kompletności materiału dowodowego i braku potrzeby dalszej jego weryfikacji. Wówczas jednak zasadne jest sformułowanie w apelacji zarzutów, które kwestionują płaszczyznę oceny materiału dowodowego, nie zaś niewykorzystanie przez sąd z urzędu z inicjatywy dowodowej. Jak ocenił to bowiem Sąd Najwyższy, *nie można uznać za naruszenie prawa sytuacji, gdy sądy powszechne za pomocą innych, niż by sobie życzyły tego strony, określonych dowodów realizują swój obowiązek ustalenia prawdy materialnej*⁹⁴, zaś – *sąd pierwszej instancji nie narusza przepisu art. 167 k.p.k. wtedy, gdy nie podejmuje z urzędu inicjatywy*

⁹² Postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lipca 2021 r., sygn. akt III KK 182/21.

⁹³ Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt II KK 405/20.

⁹⁴ Postanowienie Sądu Najwyższego z 28 października 2021 r., sygn. akt II KK 405/19.

dowodowej, uznając zebrany w sprawie materiał dowodowy za wystarczający do sprawiedliwego wyrokowania⁹⁵.

Zarzut obrazu art. 167 k.p.k. mógłby być zatem skuteczny w sytuacji, gdy z akt sprawy wynika, że sąd miał informację o określonym dowodzie i wiedzy takiej nie wykorzystał⁹⁶ i dodatkowo dowód ten mógł mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, nie zaś wówczas, gdy sąd takiej potrzeby nie widzi, na skutek ewentualnych błędów popełnionych w płaszczyźnie oceny materiału dowodowego (w takiej sytuacji bowiem uzasadnione byłoby sformułowanie zarzutu np. obrazu art. 7 k.p.k., polegającej na błędnej ocenie materiału dowodowego jako wystarczającego do rozstrzygnięcia sprawy).

Przydatne orzecznictwo:

- *Art. 167 k.p.k. nakłada na Sąd meriti obowiązek przeprowadzenia dowodów z urzędu, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy – innymi słowy – w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wyrokowania. Sąd orzekający ma zatem obowiązek dochodzenia do prawdy również w sytuacji, gdy strony nie wnioskują o przeprowadzenie nowych dowodów, ale dopiero wówczas, gdy dokonując oceny dowodów uzna, że materiał dowodowy jest niepełny i nasuwa wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy i tym samym wymaga uzupełnienia – postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lipca 2021 r., sygn. akt III KK 182/21, LEX nr 3305227*
- *Przepis art. 167 k.p.k. daje organowi procesowemu prawo, a zarazem obowiązek wykrycia i przeprowadzenia dowodów na istotne okoliczności sprawy. Organ procesowy jest zobowiązany przeprowadzić z urzędu wszelkie dowody potrzebne do ustalenia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, kwalifikacji prawnej zarzuconych mu czynów i kwestii ewentualnego wymiaru kary (por. wyrok SN z 7 czerwca 1974 r., V KRN 43/74, OSNKW 1974/11, poz. 212). Fakt, że strony były bierne i nie domagały się przeprowadzenia dowodu, nie zwalniał sądu z odpowiedniej inicjatywy dowodowej. Brak aktywności rodził in*

⁹⁵ Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II KK 466/18.

⁹⁶ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa 339/17.

concreto realną groźbę wydania niesprawiedliwego wyroku – co obligeowało do dopuszczenia określonego dowodu (por. wyrok SN z 10 lipca 2008 r., II KK 33/08) – **wyrok Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt V KK 142/21**

- *Naruszenie art. 167 k.p.k. może mieć miejsce wówczas, gdy zaniechano przeprowadzenia dowodu, mimo że zachodziły ku temu uzasadnione przesłanki, a jego uzyskanie było niezbędne dla prawidłowego wyrokowania, a nie podyktowane poszukiwaniem ewentualnego wsparcia dla irrelevantnych procesowo tez* – **postanowienie Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2021 r., sygn. akt II KK 405/20**
- (...) *naruszenie przepisu art. 167 k.p.k. w tej warstwie, w której z przepisu tego wynika obowiązek przeprowadzania dowodów ex officio i prowadzenia postępowania o modelowo inkwizycyjnym charakterze może stanowić ośnowę zarzutu formułowanego w postępowaniu zaskarżeniowym (apelacyjnym, kasacyjnym), to jednak dokonanie oceny, czy in concreto doszło do naruszenia przepisu art. 167 k.p.k. przez zaniechanie przeprowadzenia dowodów proprio motu uwzględniać musi łącznie co najmniej dwie okoliczności: określony układ dowodowy występujący w danym postępowaniu (uzasadniający w danej sprawie konieczność ewentualnego przedsięwzięcia przez organ procesowy aktywności z urzędu, z uwagi na ryzyko dla celu procesu określonego w art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k., mogące ewentualnie płynąć z pasywności organu procesowego) oraz udział profesjonalnych uczestników (w tym przedstawicieli procesowych stron) w postępowaniu karnym i możliwość nieskrępowanego podejmowania czynności procesowych zorientowanych na realizację własnych interesów procesowych w postępowaniu, w tym do formułowania na bieżąco wniosków dowodowych, których uwzględnienie – zdaniem podmiotu profesjonalnego (także obrońcy) – jest nieodzowne z uwagi na potrzebę dokonania ustaleń faktycznych odpowiadających prawdzie. Oceniając więc pasywność sądu w zakresie przeprowadzenia określonych dowodów z urzędu konieczne jest uwzględnienie nie tylko tego, jaki konkretnie dowód i dlaczego nie został przeprowadzony mimo istnienia obowiązku podejmowania przez sąd czynności dowodowych z urzędu, ale także tego, czy uczestnicy postępowania, którzy następnie w postępowaniu odwoławczym sygnalizują*

*uchybiecie polegające na nieprzeprowadzeniu dowodu, domagali się uprzednio przeprowadzenia określonych dowodów – **postanowienie Sądu Najwyższego z 12 lutego 2021 r., sygn. akt II KK 385/20***

- *(...) nie można uznać za naruszenie prawa sytuacji, gdy sądy powszechne za pomocą innych, niż by sobie życzyły tego strony, określonych dowodów realizują swój obowiązek ustalenia prawdy materialnej – **postanowienie Sądu Najwyższego z 28 października 2020 r., sygn. akt II KK 405/19***
- *Dowodów nie przeprowadza się wychodząc z założenia, że być może treść nowych depozycji będzie mogła mieć jakieś znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Przyjęcie odmiennej wykładni zasad dowodowych rodziłoby konieczność uwzględniania wniosków dowodowych w nieskończoność. Dowód nie może być przeprowadzany niejako „na wszelki wypadek”, dla sprawdzenia możliwości wykreowania nowej wersji zdarzeń, które mają zdyskwalifikować prawdziwość depozycji niekorzystnych dla oskarżonego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2013 r., III KK 42/13, LEX nr 1331333) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 lipca 2019 r., sygn. akt II AKa 94/18***
- *(...) wynikająca z art. 167 k.p.k. powinność dopuszczenia przez sąd dowodów z urzędu, przy braku stosownego wniosku strony, powstaje tylko wtedy, gdy dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych uzależnione jest od przeprowadzenia dowodu, o którym sąd powziął informację i którego przeprowadzenie jest w ogóle możliwe – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 20 marca 2019 r., sygn. akt II AKa 43/19***
- *(...) sąd pierwszej instancji nie narusza przepisu art. 167 k.p.k. wtedy, gdy nie podejmuje z urzędu inicjatywy dowodowej, uznając zebrany w sprawie materiał dowodowy za wystarczający do sprawiedliwego wyrokowania – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II KK 466/18***
- *(...) wniosek dowodowy musi zmierzać do ustalenia określonej okoliczności, której ustalenie ma znaczenie dla rozpoznania sprawy. Nie wszystkie okoliczności, których ustalenia żąda strona, mogą być przedmiotem dowodzenia, ale tylko te, które po pierwsze są dopuszczalne, po drugie mają znaczenie dla jej rozstrzygnięcia, po trzecie są przydatne do stwierdzenia*

wnioskowanych okoliczności, po czwarte są możliwe do przeprowadzenia, a także nie zmierzają do przedłużenia postępowania. Oceniając materiał dowodowy zebrany w sprawie, ale także rozważając konieczność przeprowadzenia innych dowodów wnioskowanych przez strony, Sąd musi mieć na uwadze wiele okoliczności, w tym wymienione w art. 7 k.p.k. (przy ocenie) i art. 170 k.p.k. (przy rozważaniach) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 października 2018 r., sygn. akt II AKa 402/17

- *W sytuacji, gdy Sąd I instancji trafnie zastosował normę art. 170 k.p.k. oddalając wnioski dowodowe oskarżyciela subsydiarnego, nie mógł dopuścić się obrazy art. 167 k.p.k. w odniesieniu do tych samych dowodów. Norma art. 167 k.p.k. określa podmioty dysponujące inicjatywą dowodową, w tym wskazuje na możliwość działania przez Sąd z urzędu. Sąd wyraził swoje stanowisko co do zasadności przeprowadzenia wnioskowanych dowodów oddalając te wnioski na podstawie art. 170 k.p.k. Nie sposób więc oczekiwać, by odmawiając uwzględnienia inicjatywy dowodowej strony Sąd miał jednocześnie obowiązek przeprowadzenia danych dowodów z urzędu – wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 kwietnia 2018 r., sygn. akt II AKa 123/18*
- *Przepis art. 427 § 3 k.p.k. nie stoi natomiast na przeszkodzie podniesieniu zarzutu naruszenia przepisów postępowania art. 366 § 1 k.p.k. w zw. z art. 167 § 1 k.p.k., jeżeli Sąd miał informację o określonym dowodzie i wiedzy takiej nie wykorzystał – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 listopada 2017 r., sygn. akt II AKa 339/17*

Ad. 9.9. Postanowienie o oddaleniu wniosków dowodowych jako kazus na egzaminie adwokackim?

Kiedy w aktach egzaminacyjnych znajduje się postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego, złożonego przez obrońcę, a zdaniem autora apelacji wniosek ten zmierzał do wykazania okoliczności istotnych z punktu widzenia obrony oskarżonego (a zatem był wnioskiem, który zmierzał do poprawienia sytuacji procesowej oskarżonego), wówczas **zasadne jest sformułowanie w pracy zarzutu obrazy przepisu, który był podstawą oddalenia wniosku**

dowodowego. Jeśli zatem sąd wydał postanowienie na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k., uzasadniając że okoliczność, która miałaby być udowodniona zgłoszonym wnioskiem dowodowym nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, a apelujący nie zgadza się z tym stanowiskiem, wówczas **uzasadnione jest sformułowanie zarzutu obrazy art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k., ze wskazaniem błędu w rozumowaniu sądu i uzasadnieniem odmiennego stanowiska obrony w tym zakresie.** Zaakcentowania natomiast wymaga, że jeśli sąd w oparciu o art. 201 k.p.k. *a contrario* oddali wniosek o dopuszczenie dowodu z nowej opinii biegłego sądowego, wówczas wskazane jest **sformułowanie zarzutu obrazy art. 201 k.p.k.** (nie zaś art. 170 § 1 k.p.k.).

Podkreślenia dodatkowo wymaga, że powtórzenie sformułowań ustawowych w treści postanowienia, wydanego na podstawie art. 170 § 1 k.p.k., nie jest wystarczające. Jak wskazuje bowiem Sąd Najwyższy, *oddalając natomiast na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k. wniosek dowodowy, sąd orzekający nie może ograniczyć się do stwierdzenia, że dana okoliczność nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż takie uzasadnienie odmowy przeprowadzenia dowodu jest wyłącznie powtórzeniem treści ustawy, nie odpowiada prawidłowo rozumianemu nakazowi uzasadnienia postanowienia, a wreszcie – w zasadzie uniemożliwia Sądowi Najwyższemu dokonanie kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji pod kątem zasadności (lub też bezzasadności) zarzutów podniesionych w kasacji (...). Skoro zaś odwołanie się przez sąd jedynie do tekstu ustawy, wskazującego na możliwe podstawy oddalenia wniosku dowodowego, należy uważać za równoznaczne z brakiem uzasadnienia postanowienia, które w tej materii powinno być szczególnie precyzyjne*⁹⁷.

Dla porządku przypomnieć również należy, że **zgodnie z art. 170 § 3 k.p.k. oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.** W konsekwencji, *przepisy k.p.k. nie przewidują oddalania wniosków dowodowych w sposób „dorozumiany” i nie bez istotnych powodów wprowadzają precyzyjny rygor procedowania w związku ze złożonym wnioskiem dowodowym.*

⁹⁷ Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2011 r., sygn. akt V KK 303/10. Natomiast w wyroku z 1 września 2010 r. (sygn. akt IV KK 102/10) Sąd ten wskazał, że *miejszem właściwym do wskazania powodów oddalenia wniosków dowodowych jest uzasadnienie postanowienia wydanego na podstawie art. 170 k.p.k. (art. 170 § 3 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5 k.p.k.), a nie uzasadnienie wyroku.*

Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia (art. 170 § 3 k.p.k.), a orzeczenia nie można wydać w sposób dorozumiany⁹⁸. Gdyby natomiast sąd w ogóle nie rozpoznał złożonych wniosków dowodowych, wówczas doszłoby do obrazy art. 167 k.p.k. w zw. z art. 366 k.p.k.⁹⁹

Przydatne orzecznictwo:

- *Artykuł 201 k.p.k. stanowi samoistną podstawę do dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej lub do przeprowadzenia nowej opinii, o ile spełnione zostaną przesłanki przewidziane w tym przepisie. A contrario artykuł ten może stanowić samodzielną podstawę do oddalenia wniosku dowodowego o przeprowadzenie opinii uzupełniającej, bądź o dopuszczenie nowej opinii, jeżeli strona tego się domaga a przeprowadzony już dowód z opinii jest jasny, pełny, niesprzeczny oraz nie zachodzi sprzeczność między opiniami – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 16 października 2018 r., sygn. akt II AKa 229/18*
- *Przepis art. 170 § 1 k.p.k. w odniesieniu do dowodu z opinii biegłego może mieć zastosowanie jedynie przy rozpoznawaniu pierwszego w sprawie wniosku o powołanie ekspertów, których dotąd nie powołano, albo wniosku o powołanie biegłego odnośnie do zupełnie innego przedmiotu opinii niż ten, którego dotyczy złożona już opinia. Jeżeli natomiast wniosek dowodowy dotyczy – jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie – powołania nowych biegłych odnośnie do okoliczności objętych wydaną już opinią, to jego rozpatrywanie, a tym samym uwzględnianie lub oddalanie następuje w oparciu o art. 201 k.p.k., a nie art. 170 § 1 k.p.k. W pierwszym z przywołanych przepisów wskazuje się bowiem, w jakich sytuacjach możliwe jest wezwanie ponownie tych samych biegłych na rozprawę w celu przesłuchania odnośnie tego, co było przedmiotem opinii lub powołanie dla tej samej kwestii nowych ekspertów. A contrario zatem, to przy braku wskazanych w art. 201 k.p.k. okoliczności, a nie w sytuacjach określonych w art. 170 § 1 k.p.k., wniosek taki podlega oddaleniu – postanowienie Sądu Najwyższego z 17 maja 2017 r., sygn. akt IV KK 133/17*

⁹⁸ Wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2015 r., sygn. akt III KK 232/15.

⁹⁹ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 409/12.

- *Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują oddalania wniosków dowodowych w sposób „dorozumiany” i nie bez istotnych powodów wprowadzają precyzyjny rygor procedowania w związku ze złożonym wnioskiem dowodowym. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia (art. 170 § 3 k.p.k.), a orzeczenia nie można wydać w sposób dorozumiany. Oddalenie to może nastąpić jedynie w oparciu o jedną z podstaw ustawowych, określonych w art. 170 § 1 pkt 1–5 k.p.k. (...) – wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2015 r., sygn. akt III KK 232/15*
- (...) kwestie związane z opiniami biegłych należy rozważać na tle art. 201 k.p.k. i nie powinno się stosować art. 170 § 2 k.p.k., gdyż mogłoby to prowadzić do sytuacji, że strona niezadowolona z opinii biegłego mogłaby, raz po raz, żądać powołania kolejnych biegłych, aż któryś z nich złożyłby opinię wykazującą to, co strona zamierza udowodnić (tak m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1996 r., sygn. akt: IV KKN 38/96, OSNKW 9-10/1996, poz. 56) – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28 stycznia 2014 r., sygn. akt II AKa 431/13**
- Drugą podstawą oddalenia tego wniosku dowodowego był art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. Jednak w tym zakresie Sąd odwoławczy w ogóle nie uzasadnił swojego stanowiska, bo za takie nie może być uznane powtórzenie słów ustawy – **wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2013 r., sygn. akt V KK 86/13**
- Oddalając wniosek dowodowy, sąd nie może ograniczyć się do powtórzenia treści ustawy, nie odpowiada to bowiem prawidłowo rozumianemu nakazowi uzasadnienia postanowienia, a wreszcie i uniemożliwia sądowi odwoławczemu dokonanie kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia sądu I instancji (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z 27 lipca 1977 r., V KR 84/77, OSNKW 1/1978, poz. 11). Brak uzasadnienia postanowienia, wydanego na rozprawie, o oddaleniu wniosku dowodowego uniemożliwia kontrolę słuszności decyzji sądu w odniesieniu do podstaw takiego oddalenia, wymienionych taksatywnie, stanowiąc obrazę przepisów postępowania, mogących mieć wpływ na treść orzeczenia (...) – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt II AKa 106/13**
- Przepisy art. 167 k.p.k. w zw. z art. 366 k.p.k. zostałyby naruszone, gdyby sąd orzekający w ogóle nie odniósł się do wniosków dowodowych

złożonych przez prokuratora. W sytuacji, gdy Sąd Okręgowy tych dowodów nie przeprowadził i oddalając je wskazał w postanowieniu podstawy prawne i merytoryczne takiej decyzji, to zarzut winien dotyczyć obrazu tego przepisu, który stał się podstawą tej decyzji. W niniejszej sprawie winien to być przepis art. 170 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 237a k.p.k. *a contrario*, gdyż nie spełnienie przez prokuratora wynikających z tego ostatniego przepisu wymogów, skutkowało uznaniem tych dowodów za uzyskane w nielegalny sposób, co czyni je niedopuszczalnymi, i spowodowało ich pominięcie przy rozpoznaniu sprawy – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 409/12**

- Oddalając natomiast na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k. wniosek dowodowy, sąd orzekający nie może ograniczyć się do stwierdzenia, że dana okoliczność nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż takie uzasadnienie odmowy przeprowadzenia dowodu jest wyłącznie powtórzeniem treści ustawy, nie odpowiada prawidłowo rozumianemu nakazowi uzasadnienia postanowienia, a wreszcie – w zasadzie uniemożliwia Sądowi Najwyższemu dokonanie kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji pod kątem zasadności (lub też bezzasadności) zarzutów podniesionych w kasacji (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1977 r., V KR 84/77, OSNKW 1978/1/11). Skoro zaś odwołanie się przez sąd jedynie do tekstu ustawy, wskazującego na możliwe podstawy oddalenia wniosku dowodowego, należy uważać za równoznaczne z brakiem uzasadnienia postanowienia, które w tej materii powinno być szczególnie precyzyjne (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 1999 r., IV KKN 178/96, Prok. i Pr. 1999/9/13; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2007 r., V KK 222/07, R-OSNKW 2007/2670), to takie uchybienie należy poczytać za rażące i mogące mieć wpływ na treść orzeczenia (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 1987 r., IV KR 186/87, OSPiKA 1988, z. 3, poz. 69) – **wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2011 r., sygn. akt V KK 303/10**
- Sąd Najwyższy wielokrotnie wyjaśniał, że nie stanowi uzasadnienia postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego powtórzenie słów ustawy np., że „wniosek w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania” (...) miejscem właściwym do wskazania powodów oddalenia wniosków

dowodowych jest uzasadnienie postanowienia wydanego na podstawie art. 170 k.p.k. (art. 170 § 3 k.p.k. w zw. z art. 94 § 1 pkt 5t k.p.k.), a nie uzasadnienie wyroku (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2009 r., V Kk 35/09, LEX nr 512077) – wyrok Sądu Najwyższego z 1 września 2010 r., sygn. akt IV KK 102/10

- (...) każdy wniosek dowodowy zmierza siłą rzeczy do przedłużenia rozprawy, podobnie jak przeprowadzenie każdego dodatkowego dowodu przedłuża postępowanie karne. Późne wystąpienie strony z inicjatywą dowodową może zatem, lecz nie musi, świadczyć o zaistnieniu przesłanki określonej w pkt 5 art. 170 § 1 k.p.k. Niezbędne jest wówczas ustalenie przyczyn opóźnienia i wiążącej się z upływem czasu możliwości stwierdzenia wskazywanych w tezie dowodowej okoliczności, a niezbędne jest również uwzględnienie wszelkich innych okoliczności sprawy przydatnych do prawidłowego rozstrzygnięcia o wniosku (...) – wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 2004 r., sygn. akt IV KK 230/04

Ad. 9.10. W jaki sposób w apelacji kwestionujemy zamiar sprawczy?

Zaakcentowania wymaga, że „z utrwalonego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego wynika, że zamiar sprawczy nie jest ustaleniem z dziedziny ocen materialnoprawnych. Cytując jedno ze wskazanych poniżej orzeczeń, „zamiar oznacza (...) zjawisko obiektywnej rzeczywistości, realny przebieg procesów psychicznych, nie jest zaś pojęciem z dziedziny ocen czy też z dziedziny wartości. Ustalenie zamiaru – lub jego braku – jest więc ustaleniem natury faktycznej”. W konsekwencji, jeśli chcemy zakwestionować ustalenie odnoszące się do przypisanego w wyroku zamiaru sprawczego, prawidłowe jest sformułowanie w tym zakresie zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych i wskazanie zewnętrznych, przedmiotowych i zobiektywizowanych okoliczności, które przemawiają za ustaleniem innej postaci zamiaru, aniżeli ustalił sąd¹⁰⁰.

¹⁰⁰ K. Gajowniczek – Pruszyńska, M. Tomkiewicz, *Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów*, C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 135.

Przypomnieć należy, że **zamiar jest kategorią odnoszącą się wyłącznie do strony podmiotowej czynu, sprowadzającej się do umyślności**. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2011 r. i co zacytowano we fragmencie powyżej – *zamiar oznacza (...) zjawisko obiektywnej rzeczywistości, realny przebieg procesów psychicznych, nie jest zaś pojęciem z dziedziny ocen czy też z dziedziny wartości*¹⁰¹.

Przypomnieć zatem należy, że zgodnie z art. 9 § 1 k.k., czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić (tzw. zamiar bezpośredni) albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi (tzw. zamiar ewentualny). **Przy nieumyślności nie ma mowy o zamiarze, jest natomiast o naruszeniu ostrożności, czy też określonych reguł bezpieczeństwa obowiązujących w danych okolicznościach bądź danej sferze życia**. Zaakcentowania wymaga, że istotę zamiaru ewentualnego wyjaśniona została przez Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IV KK 143/18.

Rozróżnienie zamiaru bezpośredniego od ewentualnego jest istotne, albowiem zamiar ewentualny w praktyce wpływa na łagodniejszy wymiar orzeczonej kary aniżeli przypisany oskarżonemu zamiar bezpośredni. Nadto, zakwestionowanie istnienia zamiaru sprawczego może prowadzić do całkowitego braku odpowiedzialności sprawcy, jeśli Kodeks karny nie przewiduje tego rodzaju czynu, popełnionego z winy nieumyślnej.

Przykład: jeśli sprawca odpowiada za oszustwo i w toku postępowania wykazane zostanie, że brak jest możliwości przypisania mu wymaganego zamiaru bezpośredniego (kierunkowego, tj. działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej), wówczas sąd uniewinni oskarżonego. Nie ma bowiem nieumyślnego odpowiednika przestępstwa oszustwa. Jeśli natomiast w sprawie o zabójstwo z art. 148 § 1 k.k. sąd uznałby, że brak jest zamiaru tak bezpośredniego, jak i ewentualnego (bo sprawca w ogóle w swojej świadomości nie miał spowodowania skutku śmiertelnego, albowiem ani się na niego nie godził, ani tym bardziej nie chciał tego skutku), to wówczas możliwym

¹⁰¹ Wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2011 r., sygn. akt III KK 280/10.

byłaby zmiana kwalifikacji zarzuconego oskarżonemu czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci, tj. czyn z art. 155 k.k.

Przyjmijmy zatem, że **zamiar sprawczy kwestionujemy poprzez zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, tj. w oparciu o art. 438 pkt 3 k.p.k.** Jeśli zatem sąd I instancji uznał oskarżonego za winnego przestępstwa zabójstwa w zamiarze bezpośrednim, zaś zdaniem apelującego dowody zgromadzone w sprawie nie potwierdzają, że oskarżony chciał zaistnienia skutku śmiertelnego, a wyłącznie miał ten skutek w świadomości i godził się na jego zaistnienie, bezpośrednio dążąc do osiągnięcia innego zamierzonego celu, wówczas zasadne jest sformułowanie w środku odwoławczym zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych w odniesieniu do nieprawidłowo ustalonego zamiaru sprawczego. **Formułowanie natomiast zarzutu obrazy praw materialnego w omawianym zakresie jest błędne.**

Przydatne orzecznictwo:

- *Jeżeli skarżący kwestionuje kwalifikację prawną czynu co do wypełnienia znamion strony podmiotowej przypisanego przestępstwa, ale w związku z nieprawidłowymi ustaleniami faktycznymi, to podstawą apelacji powinien być zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. Obrońca stawiając zarzut obrazy art. 156 § 3 k.k. poprzez jego niezastosowanie w istocie kwestionuje dokonane przez sąd ustalenie, że śmierć pokrzywdzonego była objęta winą umyślną oskarżonej. Skarżący stawiając taki zarzut w istocie zmierza do wykazania, że oskarżona zadając ciosy nożem nie godziła się na śmierć pokrzywdzonego. Dlatego też zarzut odwoławczy powinien dotyczyć błędnego, zdaniem obrońcy, ustalenia, że oskarżona działała z zamiarem zabójstwa, a nie obrazy art. 156 § 3 k.k. poprzez jego niezastosowanie – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt II AKa 42/21*
- (...) do przypisania zamiaru ewentualnego, konieczne jest ustalenie, że sprawca co prawda nie chciał by doszło do realizacji znamion czynu zabronionego, ale ma świadomość wysokiego (istotnego) prawdopodobieństwa dokonania takiego czynu. Najczęściej też fakt posiadania przez sprawcę takiej świadomości wnioskuje się z okoliczności o charakterze

przedmiotowym. Ale dla przyjęcia zamiaru ewentualnego niezbędny jest także drugi warunek – godzenie się na czyn będący przestępstwem. I właśnie tego drugiego warunku dotyczyła argumentacja Sądu odwoławczego wskazująca na to, że oskarżeni nie tyle pozostawali obojętni, co do skutków swoich działań, ale miarkując przemoc, nie chcieli dopuścić do śmierci pokrzywdzonego. Chęć uniknięcia tej śmierci w istocie wpływała na sposób stosowania przez sprawców przemocy wobec pokrzywdzonego – **wyrok Sądu Najwyższego z 24 listopada 2020 r., sygn. akt V KK 33/19**

- Wielokrotnie orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla iż zamiar, choć istnieje tylko w świadomości sprawcy, podlega identycznemu dowodzeniu, jak okoliczności ze sfery przedmiotowej, a więc z zastosowaniem odpowiednich zasad dowodzenia i wnioskowania (por.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2006 r., II KK 92/06, OSN w SK z 2006 r., z. 1, poz. 2576; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2004 r., IV KK 276/03, OSN w SK z 2004, z. 1, poz. 29; wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2007 r., II AKa 66/07, KZS z 2007 r., z. 6, poz. 44; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 2000 r., III AKa 70/00, Prok.i Pr. – wkł. z 2001 r., z. 6, poz. 19). Aby poczynić miarodajne ustalenia faktyczne w zakresie zamiaru, jaki przyświecał sprawcy zatem przede wszystkim należy mieć na uwadze fakty istniejące obiektywnie, należące do strony przedmiotowej czynu, a nie same jego wypowiedzi – tym samym zamiar jako świadomość rzeczywistości i powiązana z nią wola określonego zachowania, jest elementem stanu faktycznego (rzeczywistości), i jako taki podlega dowodzeniu według wszystkich reguł postępowania dowodowego i dokonywania ustaleń faktycznych. Ustalenie zamiaru wymaga oceny całokształtu okoliczności i sposobu działania sprawcy (vide przykładowo: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r., II AKa 295/18) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2020 r., sygn. akt II AKa 90/20**
- Stopień winy sprawcy działającego z zamiarem nagłym jest mniejszy niż gdy sprawca realizuje zamiar przemyślany. Sprawca nie ma bowiem dość czasu i warunków do wszechstronnego przemyślenia czynu, więc podejmuje decyzję określonego zachowania się, której w innych warunkach być może nie podjąłby. Dlatego decyzja podjęta w sposób nagły, pod

wpływem emocji, zaskoczenia, zagrożenia, bez możliwości racjonalnego rozważenia okoliczności, jest mniej naganna od zamiaru przemysłanego, gdy sprawca ma czas i możliwość wszechstronnego przemyślenia czynu, a jednak przestępstwo z rozmysłem przygotowuje i następnie wykonuje – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 marca 2020 r., sygn. akt II AKa 243/19, LEX nr 3108304**

- „Dla wykazania wypełnienia podmiotowej strony zbrodni zabójstwa tak w postaci zamiaru bezpośredniego jak i ewentualnego nie jest wystarczające wskazanie na sposób działania, w tym takie jego elementy jak rodzaj użytego narzędzia, siła ciosu czy skierowanie agresywnych działań przeciwko ośrodkom ważnym dla życia pokrzywdzonego. Są to niewątpliwie bardzo istotne elementy, które jednakże nie mogą automatycznie przesądzić zarówno o spełnieniu strony podmiotowej zbrodni zabójstwa, jak i zdecydować o przypisanej sprawcy postaci zamiaru. Zazwyczaj niezbędna jest nadto analiza motywacji sprawcy, stosunków pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym w czasie poprzedzającym agresywne działania sprawcy, tła zajścia itp.” (zob. wyrok SN z dnia 4 stycznia 2006 r., sygn. III KK 123/05, LEX nr 172208). Zatem, ani zadanie ciosu w miejsce dla życia niebezpieczne, ani nawet użycie narzędzia mogącego spowodować śmierć człowieka, samo przez się nie decyduje jeszcze o tym, że sprawca działał w zamiarze bezpośrednim zabicia człowieka – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 grudnia 2019 r., sygn. akt II AKa 217/19**
- Treść przeżyć psychicznych, relewantnych dla oceny zamiaru sprawcy, należy zatem ustalić na podstawie wszystkich okoliczności sprawy z uwzględnieniem zarówno przesłanek natury przedmiotowej (rodzaj użytego narzędzia, godzenie w ważne dla życia ludzkiego organy ciała, ilość ciosów i ich siła) oraz natury podmiotowej (osobowość oskarżonego to jest jego charakter, usposobienie, poziom umysłowy, reakcje emocjonalne, zachowanie w stosunku do otoczenia, tło i powody zajścia, zachowanie przed popełnieniem przestępstwa i po jego popełnieniu, stosunek do osoby pokrzywdzonej) – por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 30 grudnia 2014 r., sygn. II AKa 231/14) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 września 2019 r., sygn. akt II AKa 74/19**

- *Oczywistym jest, że każdemu człowiekowi w działaniu zawsze towarzyszy zamiar bezpośredni („chce”), zaś zamiar ewentualny jest niejako „produktem ubocznym”. Zamiar ewentualny, będący w istocie zamiarem wynikowym, nigdy bowiem nie występuje samodzielnie, lecz zawsze obok zamiaru bezpośredniego. Wszelka aktywność człowieka (działanie) lub jej brak (zaniechanie), jest zachowaniem w jakimś celu (dążenie do czegoś). Umysłność działania w formie zamiaru ewentualnego, nie może być bezpośrednim czynnikiem sprawczym określonego zachowania i nigdy nie kieruje działaniem sprawcy. Istota tego zamiaru polega na tym, że jest on zawsze związany z jakimś bezpośrednim zamiarem, czyli z dążeniem do osiągnięcia celu i z tego względu nie występuje samoistnie. Innymi słowy, konstrukcja zamiaru ewentualnego, przyjęta w art. 9 § 1 k.k., polega na tym, że sprawca realizując swój cel, który zamierza osiągnąć, przewiduje też realną możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na zaistnienie takiego skutku, jaki w rezultacie jego kierunkowego działania nastąpi. Jednocześnie „zamiar”, to określony proces zachodzący w psychice sprawcy, wyrażający się w świadomej woli zrealizowania przedmiotowych znamion czynu zabronionego, przy czym zamiar zarówno bezpośredni, jak i ewentualny oznacza zjawisko obiektywnej rzeczywistości, realny przebieg procesów psychicznych, nie jest zaś pojęciem z dziedziny ocen czy też z dziedziny wartości. Tak rozumiany zamiar podlega takiemu samemu dowodzeniu jak elementy strony przedmiotowej określonego typu czynu zabronionego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2018 r., II AKa 188/18, LEX nr 2583934). Stąd też zamiar nie może być przedmiotem przypuszczeń i domniemań, a jego ustalenie nie może się opierać na formułowaniu teoretycznie możliwej wersji zdarzenia. Ustalenie zamiaru jest oczywiście niejednokrotnie bardzo trudne, o ile sam sprawca swojego zamiaru nie jawi. Jeżeli jednak Sąd ustala, że oskarżona działała z zamiarem bezpośrednim spowodowania śmierci pokrzywdzonego („chciała”), to jednocześnie musi wykazać, że w psychice oskarżonej taki proces rzeczywiście nastąpił, a nie jedynie, że taki proces być może nastąpił, albo „powinien był nastąpić”. Niejednokrotnie przecież sprawca „w ogóle nie pomyślał”, że swoim zachowaniem może spowodować śmierć człowieka i tego nie chce, a nawet żadnych*

skutków swojego postąpienia sobie nie uświadamia i na nie się nie godzi. Gdyby bowiem o tym pomyślał, to z pewnością niejednokrotnie tak by się nie zachował – refleksja, niestety, przychodzi często dopiero po czynie. Stąd też ustalenia sądów o tym, czego sprawca chciał, a na co jedynie się godził, nie mogą być dowolne, ale muszą opierać się o całokształt okoliczności sprawy, a w przypadku braku niezbędnych przesłanek do poczynienia ustaleń bezspornych, zastosowanie znajduje – jak do każdych innych ustaleń – zasada *in dubio pro reo* (art. 5 § 2 k.p.k.). Przecież nawet zadanie ciosu w miejsce dla życia niebezpieczne, ani nawet użycie narzędzia mogącego spowodować śmierć człowieka, samo przez się nie decyduje jeszcze o tym, że sprawca działał w zamiarze zabicia człowieka, chociażby ewentualnym – **wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 2019 r., sygn. akt IV KK 143/18**

- Ustalenia co do świadomości sprawcy oraz zamiaru z jakim podejmował określone działania to sfera faktów, a nie prawa materialnego (...) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt III KK 750/18**
- (...) różnica między zamiarem wynikowym, a świadomą nieumyślnością (lekkomyślnością) uwidacznia się właśnie w sferze wolicjonalnej. I w przypadku zamiaru ewentualnego i w przypadku lekkomyślności sprawca ma bowiem świadomość, że swoim zachowaniem może wyczerpać znamiona czynu zabronionego. Różnica polega natomiast na tym, że w przypadku zamiaru ewentualnego sprawca godzi się z tą konsekwencją, natomiast w przypadku lekkomyślności tej konsekwencji nie chce i się nań nie godzi, a znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego realizuje dlatego, że bezpodstawnie sądzi, że jego popełnienia uniknie. Granica między zamiarem ewentualnym a nieumyślnością jest zatem niezwykle wąska, co powoduje, że dokonując ustaleń w tym przedmiocie należy starannie zwracać uwagę na cechy charakterystyczne dla zamiaru w określonej jego formie i tylko tam można przyjąć istnienie owej formy zamiaru (w tym wypadku ewentualnego), gdzie wola sprawcy jest niedwuznaczna. „Godzenie się”, będące istotą zamiaru ewentualnego, to bowiem akceptacja stanu rzeczy objętego znamionami przedmiotowymi, które sprawca może zrealizować. „Godzenie się” przybiera postać różnego rodzaju stanów

obojętności sprawcy wobec tego, co czyni lub co może z jego zachowań wyniknąć. W tym przypadku chodzi bowiem o przeżycie psychiczne, które da się zwerbalizować następująco: „dopuszczam taką możliwość”, „wszystko mi jedno, czy to nastąpi, czy nie”, „lepiej żeby nie nastąpiło, ale jeśli nastąpi, to trudno” (zob. R. Dębski, J. Giezek, Z. Jędrzejewski, T. Kaczmarek, V. Konarska-Wrzonek, J. Lachowski, Ł. Pohl, A. J. Szwarc, R. Zawłocki (w:) *Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. System Prawa Karnego*, tom 3, pod red. R. Dębskiego, Warszawa 2013, s. 556). W doktrynie trafnie zauważa się również, że uznanie, iż sprawca działał w wykonaniu zamiaru ewentualnego wykluczone jest nie tylko w sytuacji, gdy podejmował on środki przeciwdziałające realizacji czynu zabronionego, ale także wtedy, gdy częściowo zrezygnował z celu do którego dążył, a także gdy liczył na „szczęśliwą gwiazdę” (zob. A. Wąsek (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, *Kodeks Karny. Komentarz. Tom I, Art. 1–116*, Warszawa 1999, s. 107, 108). W judykaturze zasadnie wskazuje się nadto, że do okoliczności, na podstawie których należy poczynić ustalenia co do zamiaru sprawcy, zalicza się nie tylko godzenie w ważne dla życia ludzkiego organy, siłę ciosu, ich wielokrotność, rodzaj i rozmiary użytego narzędzia, głębokość i kierunek ran, rodzaj uszkodzeń ciała, stopień zagrożenia dla życia ludzkiego, lecz również stosunek sprawcy do pokrzywdzonego, jego właściwości i dotychczasowy tryb życia, zachowanie przed popełnieniem przestępstwa, a także pobudki, motywy oraz tło zdarzenia. Uzewnętrznione przejawy zachowania sprawcy pozwalają wnioskować o jego zamiarze (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 czerwca 2013 r., II AKa 88/13). Kontynuując powyższy wątek trzeba podkreślić, że warunkiem przyjęcia, iż sprawca czynu zabronionego działał z zamiarem ewentualnym jest po pierwsze ustalenie, iż miał on świadomość, że podjęte działanie może wyczerpywać przedmiotowe znamiona czynu opisanego w ustawie karnej, a – po drugie – stwierdzenie, że sprawca akceptował sytuację, iż jego czyn wyczerpuje przedmiotowe znamiona przestępstwa. Owa akceptacja musi przy tym przybierać postać aktu woli polegającej na godzeniu się z góry z takim stanem rzeczy. Zgody na skutek nie można ani domniemywać, ani też jej się domyślać. W każdym

wypadku należy w sposób stanowczy wykazać, że stanowiła ona jeden z elementów procesów zachodzących w psychice sprawcy (zob. wyrok SN z dnia 6 lutego 1973 r., sygn. akt V KRN 569/71, OSNPG 1973/6/72). Powyższe prowadzi do konkluzji, że ustalenia dotyczące zamiaru ewentualnego w zakresie zabójstwa nie mogą się opierać na fragmentarycznych faktach wiążących się z czynnościami wykonawczymi, lecz powinny być wnioskiem koniecznym, wynikającym nie tylko z analizy całokształtu przedmiotowych i podmiotowych okoliczności zdarzenia przestępnego, ale i jego tła, zachowania się sprawcy przed i po jego zaistnieniu – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2018 r., sygn. akt II KK 104/18**

- Rodzaj zamiaru, z jakim działa sprawca przestępstwa, należy do sfery ustaleń faktycznych sądu co do strony podmiotowej czynu – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 maja 2017 r., sygn. akt II AKa 54/17**
- (...) jeśli skarżący kwestionuje prawidłowość ustalenia zamiaru z jakim działał oskarżony to w istocie kwestionuje zasadniczy w procesie karnym element ustaleń faktycznych, a nie błędnej oceny materialnoprawnej czynu przypisanego oskarżonemu, bo dopiero uznanie, iż doszło do błędnego ustalenia faktów związanych z zamiarem z jakim działał sprawca upoważnia do podniesienia że nieprawidłowo dokonano subsumcji jego zachowania pod konkretny przepis prawa karnego materialnego – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 45/16**
- Zamiar oznacza przecież zjawisko obiektywnej rzeczywistości, realny przebieg procesów psychicznych, nie jest zaś pojęciem z dziedziny ocen czy też z dziedziny wartości. Ustalenie zamiaru – lub jego braku – jest więc ustaleniem natury faktycznej (zob. A. Zoll (w:) A. Zoll (red.): Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2004, t. I, s. 137) – **wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2011 r., sygn. akt III KK 280/10**
- (...) zamiar, choć istnieje tylko w świadomości sprawcy, jest faktem psychologicznym, podlega więc identycznemu dowodzeniu, jak okoliczności ze sfery przedmiotowej, z zastosowaniem odpowiednich zasad dowodzenia bądź wnioskowania. Jeśli sprawca nie wyraził swego zamiaru słowami, wnioskuje się o nim z okoliczności zajścia – **postanowienie Sądu Najwyższego z 22 grudnia 2006 r., sygn. akt II KK 92/06**

Ad. 9.11. W jaki sposób w apelacji kwestionujemy nieskorzystanie przez sąd z możliwości zastosowania fakultatywnej instytucji prawa karnego?

Przedmiotem zarzutu apelacyjnego może być wyłącznie naruszenie przez sąd zakazu lub nakazu określonego postępowania. Nie jest jednak tak, że wykluczone jest kwestionowanie niezastosowania przez sąd instytucji prawa karnego, którego zastosowanie pozostaje w zakresie swobodnej oceny sądu. **Niewątpliwie błędem byłoby kwestionowanie instytucji, które sąd – wola ustawodawcy – może, ale nie musi zastosować, poprzez formułowanie zarzutu obrazy prawa materialnego.**

Nieprawidłowym merytorycznie byłby zatem zarzut obrazy prawa materialnego, tj. art. 69 § 1 k.k., który miałby się sprowadzać do wadliwego niezastosowania wobec oskarżonego instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy zdaniem obrony okoliczności sprawy uzasadniają wymierzenie oskarżonemu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, w takiej sytuacji **właściwe będzie natomiast skonstruowanie zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych**, polegającego albo na nadmiernym wyeksponowaniu okoliczności wpływających na negatywną prognozę kryminologiczną wobec oskarżonego, na zdeprecjonowaniu znaczenia okoliczności, które za taką prognozą przemawiają ależ na niezbyt wnikliwym zbadaniu okoliczności, przemawiających za skorzystaniem np. z nadzwyczajnego złagodzenia kary – bądź też zarzutu rażącej niewspółmierności orzeczonej wobec oskarżonego kary¹⁰².

Przydatne orzecznictwo:

- *Wprawdzie warunkowe umorzenie ma charakter fakultatywny, co oznacza, że nawet mimo ziszczenia się wszystkich przesłanek jego stosowania, sąd nie musi go zastosować, owo ziszczenie się przesłanek warunkowego umorzenia ma bowiem charakter warunku progowego, koniecznego, ale niewystarczającego, trzeba jeszcze woli sądu, nie mniej uznać należało, iż*

¹⁰² Wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 1977 r., sygn. I KR 65/77.

w okolicznościach sprawy owe warunki progowe były wystarczające, by wobec oskarżonego zastosować dobrodziejstwo wspomnianej instytucji – wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 18 lutego 2022 r., sygn. akt IV Ka 79/22

- (...) *pomijając unormowanie art. 60 § 3 k.k., nadzwyczajne złagodzenie kary jest instytucją stosowaną fakultatywnie, w ramach przysługującej sądowi swobody kształtowania kary (art. 53 § 1 in principio k.k.), zatem nie można twierdzić, że jej niezastosowanie w konkretnym wypadku jest skutkiem naruszenia prawa przez sąd orzekający, co sugeruje skarżący, przytaczając jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujące, że jest dopuszczalne kwestionowanie w kasacji niewspółmierności kary jako skutku rażącego naruszenia prawa. Fakultatywność wspomnianej instytucji oznacza, że nawet akcentowane przez skarżącego młodość skazanego i przewaga okoliczności łagodzących (w kwestii tych okoliczności wypada jednak poczynić zastrzeżenie, że jest to li tylko pogląd skarżącego) nie obligowały Sądu Okręgowego do podzielenia stanowiska Sądu I instancji, iż wymierzona Ł. P. kara za jeden z czynów powinna być nadzwyczajnie złagodzona – postanowienie Sądu Najwyższego z 17 marca 2021 r., sygn. akt III KK 427/20*
- (...) *przepisu art. 624 k.p.k. wynika, że sąd może zwolnić od zapłaty kosztów sądowych, a więc zwolnienie to nie następuje obligatoryjnie, a fakultatywnie na podstawie swobodnej oceny orzekającego sądu. Tym samym nie jest prawidłowe stawianie zarzutu w ramach obrazy prawa materialnego z art. 438 pkt 1 k.p.k. – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II AKa 133/19*
- *W odniesieniu do zarzutu naruszenia prawa materialnego, przypomnieć należy, że uchybienie takie może polegać na błędnej subsumcji określonego zachowania pod przepis prawa, na zastosowaniu określonego przepisu prawa, pomimo że ustawa nie pozwala na jego zastosowanie lub na niezastosowaniu określonego przepisu prawa, gdy ustawa nakazuje jego zastosowanie. Nie dochodzi do naruszenia prawa materialnego w sytuacji, kiedy strona kwestionuje poczynione w sprawie ustalenia faktyczne domagając się zastosowania określonego przepisu prawa materialnego do – konkurencyjnej wobec przyjętej przez Sąd – forsowanej wersji zdarzenia*

(...). Nie dochodzi do naruszenia prawa materialnego także wówczas, gdy ustawa stwarza organowi postępowania tylko możliwość zastosowania określonego przepisu. Nie może być przedmiotem zarzutu obrazy prawa materialnego w szczególności naruszenie dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 § 1 i 2 k.k.), czy brak warunkowego zawieszenia wykonania kary (zob. np. postanowienia SN: z 19 października 2006 r., V KK 259/06, LEX nr 198111; z 30 maja 2017 r., II KK 155/17, LEX nr 2298293; wyroki SN: z 15 stycznia 2008 r., III KK 279/07, LEX nr 346545; z 28 października 2008 r., V KK 141/08, LEX nr 469416) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV KK 160/19**

- (...) wynikająca z art. 69 § 1 k.k. instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary ma charakter fakultatywny, co oznacza, że zaniechanie jej zastosowania nie może stanowić obrazy prawa materialnego. Sąd bowiem jedynie może, ale nie musi, zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności – **wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 2019 r., sygn. akt V KK 71/18**
- W kategorii nieporozumienia należy traktować zarzut obrazy pozostałych przepisów prawa materialnego, tj. obrazy art. 53 § 1 k.k., art. 60 § 2 k.k. i art. 69 § 1 k.k.: – przepis art. 53 k.k., określający ogólne dyrektywy wymiaru kary objęte sferą swobodnego uznania sędziowskiego, nie ma charakteru normy stanowczej (zawierającej nakaz lub zakaz określonego zachowania), zatem jego obraza nie może być uwzględniona, a podważenie przyjętych na podstawie tych przepisów ocen sądu możliwe jest tylko w ramach zarzutu rażącej niewspółmierności kary (np. postanowienia Sądu Najwyższego: dnia z 28 maja 2015 r., II KK 126/15, LEX nr 1786791; z dnia 4 lutego 2015 r., V KK 331/14, LEX nr 1640273); – wynikająca z art. 69 § 1 k.k. instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary ma charakter fakultatywny, co oznacza, że zaniechanie jej zastosowania nie może stanowić obrazy prawa materialnego. Uwaga ta dotyczy także instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary z art. 60 § 2 k.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r., sygn. akt II KK 155/17**
- (...) zarzut obrazy prawa materialnego może być zasadny tylko wówczas, gdy dotyczy zastosowania lub niezastosowania przepisu zobowiązującego sąd do jego bezwzględnej respektowania. Jeżeli natomiast ustawa stwarza

tylko fakultatywną możliwość zastosowania określonego przepisu prawa materialnego, to przez niestosowanie tego przepisu sąd nie dopuszcza się „obrazy” przepisu prawa materialnego, natomiast w takim przypadku mogą występować warunki do stawiania wyrokowi zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku oraz rażącej niewspółmierności wymierzonej kary (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1977 r. sygn. I KR – 65/77 – OSNPG 1977/10/90) – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 12 października 2016 r., sygn. akt II AKa 211/16**

- Przepis art. 37a k.k. nie ma charakteru normy stanowczej (zawierającej nakaz lub zakaz określonego postąpienia), zatem jego obraza – w rozumieniu art. 438 pkt 1 k.p.k. – nie wchodzi w grę. Zgodnie bowiem z ugruntowanym od lat orzecznictwem nie stanowi obrazy prawa materialnego generalnie samo nieskorzystanie przez sąd z przysługujących mu możliwości określonego rozstrzygnięcia, a więc gdy nie skorzystał on jedynie z fakultatywnie przewidzianych rozstrzygnięć (tak np. wyrok SN z dnia 26 kwietnia 1977 r., I KR 65/77, OSNPG 1977, Nr 10, poz. 90, postanowienia SN: z dnia 25 lipca 2005 r., V KK 61/05, OSNKW, poz. 1412, s. 700–701, z dnia 21 grudnia 2006 r., V KK 368/06, LEX nr 324685, z dnia 7 października 2010 r., II KK 246/10, LEX nr 844430, czy z dnia 22 grudnia 2010 r., II KK 297/10, LEX nr 844434) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt II AKa 42/16**
- Przepis art. 69§1 k.k. ma charakter fakultatywny, ponieważ daje sądowi możliwość zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary gdy ziszczą się wymienione tam przesłanki. Nieskorzystanie z tej możliwości nie może więc być podstawą skutecznego zarzutu odwoławczego o jakim mowa w art. 438 pkt 1 k.p.k. – **wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 października 2014 r., sygn. akt II AKa 303/14**

Ad. 9.12. Czy art. 53 k.k. może być podstawą zarzutu apelacyjnego?

W orzecznictwie od lat prezentowany jest pogląd, że **sądowe dyrektywy wymiaru kary (art. 53 k.k.) nie zawierają norm stanowczych, a ujęte**

w nim dyrektywy i przesłanki podlegają ocenie w ramach swobodnego uznania sędziowskiego. **Podważanie zatem ocen dokonywanych w tej sferze możliwe jest jedynie w ramach zarzutu rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.), nie zaś obrazy prawa materialnego**¹⁰³. Ponownie przypomnieć należy, że przedmiotem zarzutu apelacyjnego może być wyłącznie naruszenie przez sąd określonych zakazów lub nakazów wynikających wprost z przepisów. Tymczasem art. 53 § 1 k.k., podobnie zresztą jak art. 54 § 1 k.k., pozostawia sądowi swobodę co do zastosowanego stopnia represji karnej, o ile ocena ta mieści się w granicach określonych dyrektywami, wynikającymi z tego przepisu.

Z tego względu, w przypadku kwestionowania wymiaru orzeczonej kary (co jest wynikiem stwierdzenia, że sąd w niewystarczającym stopniu uwzględnił okoliczności łagodzącego w stosunku do oskarżonego albo nadmiernie wyeksponował okoliczności go obciążające), **należy sformułować zarzut z art. 438 pkt 4 k.p.k., nie zaś obrazy art. 53 § 1 k.k.**

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został również nieco odmienny od powyższego pogląd, zgodnie z którym w skrajnych przypadkach możliwe byłoby sformułowanie zarzutu obrazy art. 53 § 1 k.k. – wtedy, gdy sąd wprost zanegował zastosowanie się do dyrektyw z niego płynących¹⁰⁴. Przypadek ten wydaje się być jednak na tyle wyjątkowy, że zdaniem autorki, nie zmienia to ogólnej reguły wskazanej powyżej.

Przydatne orzecznictwo:

- *Choć kategorię nie da się wykluczyć podniesienia obrazy art. 53 § 1 k.k., jako obrazy prawa materialnego, jednakże taka sytuacja będzie miała miejsce jedynie wówczas, gdy skarżący wykaże, że wymierzając karę, sąd pominął którąś ze wskazanych tam dyrektyw wymiaru kary (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2018 r., IV KK 64/18, LEX nr 2498073) – postanowienie Sądu Najwyższego z 22 maja 2020 r., sygn. akt IV KK 536/19*

¹⁰³ Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 listopada 2016 r., sygn. akt III KK 191/16; postanowienie Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r., sygn. akt III KK 155/17.

¹⁰⁴ Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 listopada 2016 r., sygn. akt III KK 191/16; postanowienie Sądu Najwyższego z 22 maja 2020 r., sygn. akt IV KK 536/19.

- *Nie dochodzi do naruszenia prawa materialnego także wówczas, gdy ustawa stwarza organowi postępowania tylko możliwość zastosowania określonego przepisu. Nie może być przedmiotem zarzutu obrazy prawa materialnego w szczególności naruszenie dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 § 1 i 2 k.k.), czy brak warunkowego zawieszenia wykonania kary (zob. np. postanowienia SN: z 19 października 2006 r., V KK 259/06, LEX nr 198111; z 30 maja 2017 r., II KK 155/17, LEX nr 2298293; wyroki SN: z 15 stycznia 2008 r., III KK 279/07, LEX nr 346545; z 28 października 2008 r., V KK 141/08, LEX nr 469416) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV KK 160/19***
- *Zarzut obrazy prawa materialnego nie może dotyczyć dyrektyw sądowego wymiaru kary zawartych w art. 53 § 1 i art. 54 § 1 k.k. oraz okoliczności uwzględnianych przy wymiarze kary lub środków karnych wymienionych w art. 53 § 2 k.k. w zw. z art. 56 k.k. Przepisy te nie mają charakteru norm stanowczych, bo nie zobowiązują sądu do określonego zachowania, a pozostawiają swobodę orzekania co do zastosowanego stopnia represji karnej – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 4 marca 2020 r., sygn. akt II AKa 243/19, LEX nr 3108304***
- *Przepis art. 53 § 1 k.k. nie ma charakteru normy stanowczej (zawierającej nakaz lub zakaz określonego zachowania), zatem jego obraza – w rozumieniu art. 438 pkt 1 k.p.k. – nie wchodzi w grę. Wspomniany przepis określa objęte sferą swobodnego sędziowskiego uznania ogólne dyrektywy wymiaru kary, dlatego podważenie przyjętej na ich podstawie oceny sądu jest możliwe tylko w ramach zarzutu rażącej niewspółmierności kary (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2015 r., V KK 331/14, i przywołane tam orzecznictwo). Podobny charakter ma przepis art. 53 § 2 k.k. Nie ma wątpliwości, że również zarzut naruszenia dyrektyw wymiaru kary przewidzianych w art. 53 § 2 k.k. nie jest zarzutem naruszenia prawa materialnego, a ma charakter zarzutu dotyczącego niewspółmierności kary (...) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2019 r., sygn. akt V KK 320/18***
- *Podnoszenie obrazy art. 53 § 1 k.k., jako obrazy prawa materialnego, wchodzi jedynie w rachubę wówczas, gdy skarżący wykaże, że sąd wymierzając karę pominął którąś ze wskazanych tam dyrektyw wymiaru*

kary – postanowienie Sądu Najwyższego z 14 marca 2018 r., sygn. akt IV KK 64/18

- (...) przepis art. 53 k.k., określający ogólne dyrektywy wymiaru kary objęte sferą swobodnego uznania sędziowskiego, nie ma charakteru normy stanowczej (zawierającej nakaz lub zakaz określonego zachowania), zatem jego obraza nie może być uwzględniona, a podważenie przyjętych na podstawie tych przepisów ocen sądu możliwe jest tylko w ramach zarzutu rażącej niewspółmierności kary (np. postanowienia Sądu Najwyższego: dnia z 28 maja 2015 r., II KK 126/15, LEX nr 1786791; z dnia 4 lutego 2015 r., V KK 331/14, LEX nr 1640273) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r., sygn. akt II KK 155/17**
- (...) przepis art. 53 k.k. nie zawiera unormowania stanowczego, a ujęte w nim dyrektywy i przesłanki podlegają ocenie w ramach swobodnego uznania sędziowskiego. Podważanie zatem ocen dokonywanych w tej sferze możliwe jest jedynie w ramach zarzutu rażącej niewspółmierności kary (art. 438 pkt 4 k.p.k.), nie zaś obrazy prawa materialnego (np. postanowienie SN z dnia 3 października 2011 r., V KK 96/11). W skrajnych wypadkach możliwe byłoby do wyobrażenia naruszenie prawa materialnego – art. 53 k.k. – ale tylko wówczas, gdyby sąd wprost zanegował zastosowanie się do dyrektyw z niego płynących, co oczywiście w tej sprawie nie wystąpiło – **postanowienie Sądu Najwyższego z 8 listopada 2016 r., sygn. akt III KK 191/16**

Ad. 9.13. Czy art. 115 § 2 k.k. może być podstawą zarzutu apelacyjnego?

Zgodnie z art. 115 § 2 k.k., przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Nie budzi wątpliwości orzeczniczych i doktrynalnych, że powyższy katalog ma charakter zbioru zamkniętego.

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w jednym z najnowszych orzeczeń, potwierdzając tym samym utrwaloną od lat linię orzecznictwą w tym zakresie, *uchybień przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu mogą przybierać postać obrazy prawa materialnego, ale dzieje się tak wówczas, gdy przy ocenie stopnia karygodności czynu sąd pominął okoliczności wymienione w art. 115 § 2 k.k. lub wziął pod uwagę okoliczności niewyszczególnione w tym przepisie*¹⁰⁵. Gdyby zatem sąd I instancji uznał, że przestępstwa rozboju wiążą się z założeniami z wyższym stopniem społecznej szkodliwości czynu, właściwe byłoby sformułowanie zarzutu obrazy prawa materialnego, albowiem wymienione przez sąd kryterium nie mieści się w katalogu okoliczności wpływających *in concreto* na stopień społecznej szkodliwości czynu z art. 115 § 2 k.k.¹⁰⁶

W powyższym kontekście wyraźnego zaznaczenia wymaga, że *na stopień społecznej szkodliwości nie mają wpływu – jak wynika z art. 115 § 2 k.k. – okoliczności dotyczące sprawcy niezwiązane z czynem przestępczym, np. warunki rodzinne, dotychczasowy tryb życia, zachowanie po popełnieniu przestępstwa, nagminność, dotychczasowa karalność*¹⁰⁷. Tymczasem **wywody w przedmiocie niskiego stopnia społecznej szkodliwości czynu z powoływaniem się wprost na okoliczności odnoszące się bezpośrednio do sprawcy są jednym z najczęściej powtarzających się błędów tak w praktyce, jak i w pracach egzaminacyjnych.**

Podkreślić zatem należy, że jeśli sąd I instancji wprowadzi przedmiotem analizy uczynił elementy wyszczególnione w art. 115 § 2 k.k., jednak dokonał tej oceny błędnie, wówczas zasadne będzie sformułowanie **zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych**. Gdyby zatem sąd wadliwie ustalił, że oskarżony działał z motywacji zasługującej na szczególną dezaprobatę (np. bezmyślnie czy bez jakiegokolwiek przyczyny), podczas gdy zdaniem obrony motywację

¹⁰⁵ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 marca 2022 r., sygn. akt II AKa 294/21.

¹⁰⁶ Jak wielokrotnie wskazywał bowiem Sąd Najwyższy, *w żadnym wypadku nie można stwierdzić, że konkretna kategoria przestępstw (...) może być z góry uznana za kategorię społecznie szkodliwą. Ocena taka winna być dokonana zawsze indywidualnie w stosunku do konkretnego popełnionego przestępstwa* (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2004 r., sygn. akt II KK 210/04; postanowienie Sądu Najwyższego z 17 listopada 2020 r., sygn. akt IV KK 83/20; wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 2020 r., sygn. akt V KK 53/20).

¹⁰⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 marca 2018 r., sygn. akt II AKa 51/18.

tę należy ocenić inaczej (np. jako działania honorowe), wówczas należałoby w apelacji sformułować zarzut z art. 438 pkt 3 k.p.k. Sąd nieprawidłowo ocenił bowiem określoną okoliczność, co w konsekwencji wpłynęło na błędnie ustalony stopień społecznej szkodliwości czynu zarzuconego oskarżonemu, a w dalszej kolejności na wymiar orzeczonej wobec oskarżonego kary.

Przydatne orzecznictwo:

- (...) *uchybień przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu mogą co prawda przybierać postać obrazy prawa materialnego, ale dzieje się tak wówczas, gdy przy ocenie stopnia karygodności czynu Sąd I instancji pominął okoliczności wymienione w art. 115 § 2 k.k. lub wziął pod uwagę okoliczności niewyszczególnione w tym przepisie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. III KK 118/17). Takich zaś uchybień prokurator w swojej apelacji nie wytknął. Apelujący utrzymywał natomiast, że Sąd I instancji okolicznościom z art. 115 § 2 k.k. przydał zbyt dużą lub zbyt małą rangę. Taka konstrukcja omawianego zarzutu wskazywała, że apelujący w istocie kwestionował ustalenia faktyczne Sądu I instancji. Jego zarzut winien zatem przybrać postać zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, nie zaś naruszenia prawa materialnego – wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 marca 2022 r., sygn. akt II AKa 294/21*
- *Ocena stopnia społecznej szkodliwości konkretnego zachowania powinna być oceną całościową, uwzględniającą okoliczności wymienione w art. 115 § 2 k.k., nie zaś sumą czy pochodną ocen częściowych takiej czy Innej „ujemności” tkwiącej w poszczególnych okolicznościach i dlatego też, jeżeli w art. 1 § 2 k.k. mówi się o znikomej społecznej szkodliwości czynu, to wymóg znikomości dotyczy społecznej szkodliwości ocenianej kompleksowo, nie zaś jej poszczególnych czynników (...). Artykuł 115 § 2 k.k. zobowiązuje, aby Sąd przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu brał pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Ustawodawca, kształtując*

w tej regulacji prawnej normatywne przesłanki oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, sformułował bowiem zamknięty katalog okoliczności, z których każda charakteryzuje się prawną doniosłością. Nieskorzystanie w ocenie którejkolwiek z nich oraz formułowanie własnych okoliczności, różnych od ustawowych i nadawanie im zasadniczego znaczenia, jest naruszeniem prawa materialnego i musi powodować uwzględnienie kasacji – **wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 2021 r., sygn. akt III KK 346/20, LEX nr 3305210**

- Uchybienia przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu mogą przybierać dwojaką postać, tj. obrazy prawa materialnego oraz błędu w ustaleniach faktycznych. Błąd co do prawa materialnego występuje wówczas, gdy przy ocenie stopnia karygodności czynu pominięto okoliczności (lub okoliczność) wymienione w art. 115 § 2 k.k. lub wzięto pod uwagę okoliczności (lub okoliczność) niewyszczególnione w tym przepisie. Błąd w ustaleniach faktycznych występuje natomiast wtedy, gdy okolicznościom z art. 115 § 2 k.k. przydano zbyt dużą lub zbyt małą rangę (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 14 listopada 2017 r., V KK 274/17, LEX nr 2428824; z dnia 7 czerwca 2017 r., III KK 118/17, LEX nr 2350659; z dnia 2 czerwca 2015 r., V KK 41/15, LEX nr 1765633) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2021 r., sygn. akt III KK 49/21**
- Nie można się zgodzić z autorem kasacji, że głównym determinantem wysokości społecznej szkodliwości czynu jest wysokość ustawowego zagrożenia karą. Właśnie bowiem po to ustawodawca wymienił w art. 115 § 2 k.k. tak liczne i różnicowane przesłanki podlegające ocenie przy ustalaniu społecznej szkodliwości czynu, by nie istniało zagrożenie, że sądy będą stosować tylko automatycznie zagrożenie karą jako najważniejszy wyznacznik tej oceny. Przecież wręcz nie ma w tym katalogu przesłanki ‘zagrożenia karą’ (...). Należy wszak pamiętać, że różnice w surowości sankcji grożących za popełnienie poszczególnych typów przestępstw oddają co najwyżej różnice w ocenie społecznej szkodliwości poszczególnych kategorii (rodzajów) zachowań się objętych kryminalizacją. Tu zaś mówimy nie o takiej ocenie, lecz o ocenie szkodliwości konkretnego zachowania się należącego do określonej kategorii. Dlatego też w pewnych przypadkach społeczna szkodliwość czynów realizujących

znamiona występów zagrożonych stosunkowo łagodnymi sankcjami może być znaczna (zob. W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53–116, wyd. V, teza 11). Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie II KK 210/04 (LEX nr 155024), stwierdził – „Nie można w żadnym razie przyjąć, że na ocenę społecznej szkodliwości zarzuconego oskarżonemu czynu decydujący wpływ ma zagrożenie ustawowe. Ocena taka winna być dokonana zgodnie z wymogami art. 115 § 2 k.k., tj. powinna odnosić się ściśle do okoliczności związanych z samymi czynami – z ich stronami przedmiotowymi i podmiotowymi. W żadnym wypadku nie można stwierdzić, że konkretna kategoria przestępstw (...) może być z góry uznana za kategorię społecznie szkodliwą. Ocena taka winna być dokonana zawsze indywidualnie w stosunku do konkretnego popełnionego przestępstwa” – **postanowienie Sądu Najwyższego z 17 listopada 2020 r., sygn. akt IV KK 83/20**

- (...) ustawodawca, formułując w zacytowanym przepisie normatywne przesłanki oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, zbudował zamknięty katalog okoliczności, z których każda charakteryzuje się prawną doniosłością. Pominięcie w ocenie którejkolwiek z nich, czy też formułowanie własnych okoliczności, odmiennych od ustawowych i nadawanie im zasadniczego znaczenia, stanowi naruszenie prawa materialnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2016 r., V KK 250/16, LEX nr 2152411). Nie jest zatem właściwe ferowanie oceny stopnia społecznej szkodliwości, jakim nacechowane ma być dane zachowanie, wyłącznie o ocenę cząstkową, opartą na pojedynczych elementach (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2016 r., V KK 104/16, LEX nr 2080103) – **wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 2020 r., sygn. akt V KK 53/20**
- Zarzuty z pkt 5, 7 i 8 to niedopuszczalne w postępowaniu kasacyjnym zarzuty błędów w ustaleniach faktycznych. W tej kategorii mieszczą się bowiem: ocena stopnia szkodliwości społecznej czynu, wystąpienie przesłanek ciągu przestępstw i okoliczności uzasadniających przyjęcie wypadku mniejszej wagi – **postanowienie Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2019 r., sygn. akt III KK 427/18**

Ad. 9.14. Formułowanie zarzutu obrazy art. 193 § 1 k.p.k. a zarzutu obrazy art. 201 k.p.k.?

Zarzut obrazy art. 193 § 1 k.p.k. zasadny będzie w tych wszystkich przypadkach, gdy sąd samodzielnie rozstrzygnie kwestie, wymagające wiedzy specjalnej. Jeśli zatem w sprawie o kradzież np. telefonu sąd oprze się wyłącznie na twierdzeniach pokrzywdzonego w zakresie wartości tego telefonu albo sam uzna, że wartość telefonu nie budzi wątpliwości i w konsekwencji nie powoła biegłego ds. wyceny ruchomości, uzasadnione będzie sformułowanie zarzutu obrazy art. 193 § 1 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k., poprzez dowolne rozstrzygnięcie przez sąd orzekający kwestii, wymagającej wiedzy specjalnej, co mogło doprowadzić do wadliwego ustalenia, że mamy do czynienia z przestępstwem, nie zaś wykroczeniem¹⁰⁸. Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą, w każdym przypadku, w którym zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia zagadnień specjalistycznych, sąd nie może dokonać tego procesu myślowego samodzielnie i to nawet wówczas, gdyby faktycznie takową specjalistyczną wiedzę posiadał. Konieczne jest powołanie biegłego z tego zakresu wiedzy, której dotyczy zagadnienie wymagające ustalenia i wydanie stosownej opinii (np. przez biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, z zakresu medycyny sądowej, z zakresu psychologii, z zakresu badania pisma ręcznego itd.).

Podobnie, jeśli w sprawie została sporządzona jakakolwiek opinia specjalistyczna, to sąd w oparciu wyłącznie o własne przekonanie (a zatem bez powołania kolejnego eksperta) nie może poczynić ustaleń sprzecznych z wnioskami tejże opinii. Byłoby to bowiem także zastąpienie wiedzy specjalisty własnymi przekonaniem, czego sądowi zrobić nie wolno¹⁰⁹. W takiej

¹⁰⁸ Na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) zmianie ulec ma art. 119 § 1 k.w., który po wejściu w życie ma mieć brzmienie: Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Po wejściu w życie tego przepisu przestępstwem z art. 278 § 1 k.k. będzie zatem kradzież rzeczy ruchomej o wartości przekraczającej 800 zł (nie zaś tak, jak dotychczas – 500 zł). Ww. ustawa z 7 lipca 2022 r. ogłoszona została w Dzienniku Ustaw 13 grudnia 2022 r. Omawianej nowelizacja, zgodnie z art. 33 ustawy, wchodzi w życie z upływem 3 miesięcy od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (tj. od 14 marca 2023 r.).

¹⁰⁹ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2017 r., sygn. akt II AKa 178/17.

sytuacji zasadne byłoby sformułowanie zarzutu obrazy art. 193 § 1 k.p.k. w zw. z art. 7 k.p.k.

Należy jednocześnie pamiętać, że nie ma potrzeby zasięgania opinii biegłego w kwestiach, które wynikają z wiedzy powszechnej, czy przeciętnych umiejętności i wiedzy, dostępnych każdemu (np. w celu dokonania wyliczeń matematycznych/arytmetycznych etc.).

Natomiast **zarzut obrazy art. 201 k.p.k. uzasadniony jest wówczas, gdy sąd dysponuje już opinią ekspercką i błędnie uznaje ją za pełną, jasną oraz pozbawioną wewnętrznych sprzeczności**. Nierzadko zarzut obrazy art. 201 k.p.k. łączony jest z art. 7 k.p.k., albowiem zdaniem apelujących, sąd sprzecznie z treścią art. 7 k.p.k. ocenił dowód z opinii biegłego i nie dostrzegł, że opinia ta nie spełnia kryteriów jasności, pełności albo braku wewnętrznej sprzeczności.

W kontekście kwestionowania opinii biegłego sądowego zaakcentowania wymaga, że formułowanie zarzutu obrazy art. 201 k.p.k. zarówno w apelacji, jak na etapie procedowania przed sądem I instancji, wymaga wykazania zaistnienia przesłanek, wskazanych w dyspozycji tego przepisu. Niewystarczające jest zatem posłużenie się ogólnymi sformułowaniami, kwestionującymi jakość dotychczasowej ekspertyzy specjalistycznej. **Konieczne jest bowiem każdorazowe wykazanie, że opinia jest niejasna, niepełna lub wewnętrznie sprzeczna bądź też zachodzi sprzeczność pomiędzy kilkoma sporządzonymi opiniami**. W argumentacji pomocne jest orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, które wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem każdej z przesłanek wymienionych w art. 201 k.p.k. Dla ułatwienia najważniejsze tezy orzecznicze w tym zakresie przytoczone zostały poniżej.

Przydatne orzecznictwo:

- *Przepis art. 201 k.p.k. nawet w wypadku stwierdzenia wskazanych w nim wadliwości opinii („opinia jest niepełna, niejasna albo, gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie”) przewiduje dwojaki sposób rozwiązania problemu jej niejasności, niepełności, czy sprzeczności, pozostawiając decyzję co do wyboru metody organowi procesowemu przeprowadzającemu postępowanie dowodowe. Dlatego też przyjmuje się, że w postępowaniu jurysdykcyjnym to sąd*

orzekający decyduje, czy wezwać ponownie tych samych biegłych, czy też powołać innych w zależności od tego, które z tych rozwiązań uzna w konkretnych realiach za celowe. W wypadkach, gdy złożona opinia odznacza się wyjątkowo rażącymi uchybieniami, o jakich mowa w art. 201 k.p.k., celowe będzie od razu powołanie innego biegłego – **wyrok Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2021 r., sygn. akt IV KK 496/20, LEX nr 334334**

- Zgodnie z utrwaloną praktyką, pozaprocesowa opinia biegłego nie może stanowić dowodu będącego przedmiotem oceny sądu, póki dowód taki nie zostanie przeprowadzony w sposób przewidziany przez przepisy procesowe (...). Biegli powoływani są postanowieniem organu procesowego prowadzącego postępowanie. Dopiero takie postąpienie konstytuuje biegłych w procesie. Opinia wykonana bez polecenia organu procesowego, na zlecenie osoby zainteresowanej, nie ma waloru środka dowodowego. Dopiero więc z chwilą wydania postanowienia o powołaniu biegłego celem sporządzenia opinii, staje się on uczestnikiem postępowania, zaś wydana przez niego opinia uzyskuje cechy opinii w rozumieniu przepisów postępowania karnego (...). Przepis art. 170 § 1 k.p.k. w odniesieniu do dowodu z opinii biegłego może mieć zastosowanie jedynie przy rozpoznawaniu pierwszego w sprawie wniosku o powołanie ekspertów, których dotąd nie powołano, albo wniosku o powołanie biegłego odnośnie do zupełnie innego przedmiotu opinii niż ten, którego dotyczy złożona już ekspertyza. Natomiast materię wydania opinii uzupełniającej lub też nowej opinii, jeżeli dotychczasowa ekspertyza jest niepełna lub niejasna czy też wewnętrznie sprzeczna, reguluje kompleksowo art. 201 k.p.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 23 listopada 2021 r., sygn. akt III KK 250/21, LEX nr 334333**
- (...) obowiązek przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych powstaje wówczas, gdy w sprawie wystąpiły uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego (podejrzanego). Jednakże owe wątpliwości, jak wskazuje się dalej w judykaturze, powinny zostać chociaż uprawdopodobnione, co oznacza, że muszą mieć podstawę w konkretnych okolicznościach sprawy, wynikać z tych okoliczności w sposób obiektywny. Nie mogą natomiast stanowić one jedynie subiektywnego przekonania oskarżonego (podejrzanego) lub jego obrońcy, ale muszą zostać powzięte

przez organ procesowy (por. uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1977 r., VII KZP 11/77, OSNKW 1977, z. 7–8, poz. 68; (...)). Co więcej nawet ujawnienie się w toku procesu karnego, dowodów czy to w postaci wyjaśnień oskarżonego (podejrzanego) czy też dowodów z dokumentów w postaci dokumentacji medycznej nie może oznaczać, że już zaistniały „uzasadnione wątpliwości co do poczytalności”, albowiem inaczej organ procesowy zostałby pozbawiony możliwości dokonania oceny tej przesłanki, a jak już wcześniej wspomniano to ten organ winien powziąć uzasadnione wątpliwości w powyższym zakresie (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r., V KK 61/09) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2021 r., sygn. akt II KK 127/21**

- Zarówno dyspozycja art. 7 k.p.k., jak i art. 193 § 1 k.p.k. nie zakazuje Sądowi czynienia własnych ustaleń obejmujących jakiekolwiek wiadomości ze sfery techniki, czy działania urzędzeń. Domeną biegłych są „wiadomości specjalne”, a więc takie wiadomości faktyczne czy praktyczne, które wykraczają poza przeciętne umiejętności czy wiedzę. Wiedza dostępna dla dorosłego człowieka o odpowiednim doświadczeniu życiowym i wykształceniu (zob. wyrok SN z 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, OSNKW 1976/10-11, poz. 133) może natomiast zostać zastąpiona wiedzą i doświadczeniem sędziowskim (zob. postanowienie SN z 22 grudnia 2010 r., II KK 291/10) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 10 lutego 2021 r., sygn. akt IV KK 574/20**
- Przepis art. 193 § 1 k.p.k. obliguje Sąd do zasięgnięcia opinii biegłego lub biegłych, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Opinia biegłego winna zatem dotyczyć kwestii, których poznanie bezpośrednio przez sąd ze względu na konieczność posiadania wiadomości specjalnych albo w ogóle nie byłoby możliwe albo byłoby znacznie utrudnione (...). sama zdolność do rozpoznania głosu jest zdolnością występującą powszechnie i nie zastrzeżoną jedynie dla biegłych stosownej specjalności, zatem Sąd mając bezpośrednią styczność z oskarżonym na rozprawie jest władny samodzielnie dokonać identyfikacji jego głosu utrwalonego na nośniku. Co istotne, w niniejszej sprawie owa identyfikacja dokonana została na podstawie

o wiele szerszej analizy, aniżeli tylko aspekty fonetyczne. Jej przeprowadzenie w takim zakresie było możliwe tylko przez Sąd mający wiedzę na temat istoty sprawy i całokształtu jej okoliczności – **postanowienie Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2021 r., sygn. akt III KK 145/20**

- *Nie aktualizuje określonego w tym przepisie obowiązku niezadowolenie strony z przedstawionych w sporządzonych opiniach wniosków czy też to, że stanowią one dowód winy oskarżonego, lecz wyłącznie obiektywna konkluzja, że dotychczasowa opinia jest niespełna, niejasna albo sprzeczna wewnętrznie lub z innymi opiniami wydanymi w tej samej sprawie –* **postanowienie Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2021 r., sygn. akt IV KK 515/20**
- *Opinia jest niejasna wówczas, gdy organ procesowy nie może zrozumieć wywodów biegłego, jeśli nie jest dlań jasne, jakie biegły w ogóle zajmuje stanowisko, poglądy biegłego są niespójne, a tezy wieloznaczne (postanowienie Sądu Najwyższego z 27 września 2006 r., sygn. IV KK 330/06, OSNKW (r) 2006, poz. 1822) –* **postanowienie Sądu Najwyższego z 27 listopada 2020 r., sygn. akt II KK 326/20**
- *Nawet zakładając, że rozpoznający sprawę sędzia Sądu ad quem orientował się w stopniu ponadprzeciętnym w problematyce logowania się telefonów i azymutów, na których doszło do tego logowania, to i tak zobligowany był skorzystać z dowodu z opinii biegłego, co jasno wynikało z treści art. 193 § 1 k.p.k. –* **wyrok Sądu Najwyższego z 9 września 2020 r., sygn. akt IV KK 155/19**
- (...) *opinia jest niepełna, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione biegłemu pytania, na które zgodnie z zakresem posiadanych wiadomości specjalnych i udostępnionych materiałów dowodowych może oraz powinien udzielić odpowiedzi lub jeżeli nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności, albo też nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen oraz poglądów. Opinia jest zaś niejasna, jeżeli jej sformułowanie nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, albo jeżeli zawiera wewnętrzne sprzeczności, posługuje się nielogicznymi argumentami. Natomiast, sprzeczność w samej opinii zachodzi wówczas, gdy co do tych samych, istotnych okoliczności, dokonane zostały*

odmienne ustalenia, odmienne oceny albo też z przeprowadzonych takich samych czynności sformułowane zostały odmienne wnioski (tak Sąd Najwyższy m.in. w: postanowieniach z 22.10.2015, III KK 239/15, LEX nr 1820402 i z 26.06.2008, V KK 206/08, OSNwSK 2008/1/1350, także w wyroku z 7.10.2009, III KK 122/09, LEX nr 532391) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 października 2019 r., sygn. akt II AKa 148/19

- *Ogólna fakultatywność unormowania zawartego w art. 201 k.p.k. nie oznacza w każdym wypadku dowolności sądu w sferze decyzji o zasięgnięciu opinii biegłych, w sytuacjach określonych w tym unormowaniu, a jedynie przyznaje sądowi pewien luz decyzyjny, którego zakres jest uzależniony od oceny występowania przesłanek zastosowania tego przepisu. Oczywiście wydaje się bowiem to, że jeżeli sąd, zgodnie z art. 193 k.p.k., uznając, że stwierdzenie okoliczności, mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, wymaga wiadomości specjalnych, zasięga opinii biegłych danej specjalności, to w wypadku, gdy wnioski tych opinii są ze sobą sprzeczne, a jednocześnie nie ma podstaw, by pozbawić którąkolwiek z tych opinii waloru rzetelności, to tym bardziej wskazuje to, że rozstrzygnięcie danego zagadnienia wymaga wiadomości specjalnych, których nie posiada sąd. Nie chodzi tu o to – wbrew temu, co akcentuje Sąd odwoławczy – że to same opinie są wiążące dla Sądu, lecz to Sąd jest związany wydanymi wcześniej własnymi decyzjami procesowymi, na mocy których uznaje kompetencje powołanych biegłych oraz potrzebę zasięgnięcia ich opinii – wyrok Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt III KK 270/18*
- *Sąd nie jest biegłym, aby stwierdzić, że nie można odtworzyć treści nagrań dysponując lepszej jakości sprzętem. Nie można zaakceptować również decyzji Sądu odwoławczego o oddaleniu wniosku o przeprowadzenie dowodu z nagrań przesłanych przez oskarżonego w dniu rozprawy na adres mailowy Sądu, tylko w oparciu o treść art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. przyjmując, że zmierza on do przedłużenia postępowania, skoro oskarżony wskazywał, że na tych nagraniach są również dowody świadczące o jego niewinności – wyrok Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r., sygn. akt V KK 79/18*

- *Opinia biegłego winna dotyczyć kwestii, których poznanie bezpośrednio przez organ procesowy ze względu na konieczność posiadania wiadomości specjalnych albo w ogóle nie byłoby możliwe albo byłoby znacznie utrudnione(...). Opinia biegłego winna dotyczyć kwestii, których poznanie bezpośrednio przez organ procesowy ze względu na konieczność posiadania wiadomości specjalnych albo w ogóle nie byłoby możliwe albo byłoby znacznie utrudnione. W niniejszej sprawie zaś nie było potrzeby wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii wzbudzających wątpliwości natury specjalistycznej – wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 listopada 2018 r., sygn. akt II AKa 332/18*
- (...) silne wzburzenie jest zjawiskiem fizjologicznym, a zarazem pojęciem prawnym, którego ustalenie w kontekście związku tego stanu z usprawiedliwiającymi okolicznościami należy do zadań sądu i nie wymaga zasięgnięcia opinii biegłych. W obliczu bardzo obszernej, a zarazem prawidłowej argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu organu odwoławczego, której powielanie nie jest rolą Sądu Najwyższego, przypomnieć jedynie należało, że Sąd II instancji wskazał na szereg okoliczności towarzyszących krytycznemu zdarzeniu, wyjaśniając dlaczego uznanie, że nie zachodzą podstawy do przypisania skazanemu afektu fizjologicznego, było zasadne (...). W pełni podzielając wywód Sądu Apelacyjnego, należało jedynie dodać, że prawidłowo poczynione ustalenia faktyczne w sprawie uprawniały do stwierdzenia, że wzburzenie pojawiło się w psychice sprawcy, ale nie było usprawiedliwione w sensie prawnokarnym, co determinowało wykluczenie typu uprzywilejowanego z art. 148 § 4 k.k. i przyjęcie kwalifikacji prawnej czynu z art. 148 § 1 k.k. – **postanowienie Sądu Najwyższego z 14 listopada 2018 r., sygn. akt IV KK 516/18**
- Artykuł 201 k.p.k. stanowi samoistną podstawę do dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej lub do przeprowadzenia nowej opinii, o ile spełnione zostaną przesłanki przewidziane w tym przepisie. A contrario artykuł ten może stanowić samodzielną podstawę do oddalenia wniosku dowodowego o przeprowadzenie opinii uzupełniającej, bądź o dopuszczenie nowej opinii, jeżeli strona tego się domaga a przeprowadzony już dowód z opinii jest jasny, pełny, niesprzeczny oraz nie zachodzi

sprzeczność między opiniami – wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 16 października 2018 r., sygn. akt II AKa 229/18

- *Dowód z opinii innych biegłych dopuszcza się tylko wtedy, gdy dotychczasowa opinia pochodzi od biegłych podlegających wyłączeniu albo niekompetentnych (art. 196 § 2 k.p.k.), bądź gdy jest ona niepełna albo niejasna (art. 201 k.p.k.). Strona żądająca powołania innych biegłych musi wykazać, że zachodzi okoliczność określona w art. 201 k.p.k., a więc dotychczas wydana opinia jest niepełna, niejasna albo nielogiczna lub że zachodzi sprzeczność w samej opinii. Samo ogólne stwierdzenie o konieczności powołania nowych biegłych, bez wskazania na wady dotychczasowej opinii, nie czyni złożonego w tym przedmiocie wniosku zasadnym. Gdyby bowiem kierować się tylko tym kryterium, że dotychczasowa opinia nie spełnia oczekiwań strony, która za pośrednictwem nowej opinii chce wykazać stan przeciwny do wynikającego z opinii, wówczas nigdy nie udałoby się postępowania zakończyć w rozsądnym terminie, skoro strona niezadowolona z dotychczas sporządzonej opinii mogłaby bez końca wnosić o kolejne opinie, a gdyby biegli ją zadowolili, to identyczne wnioski mogłaby zgłaszać strona przeciwna, z opinii takiej niezadowolona – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2 października 2018 r., sygn. akt II AKa 254/18, LEX nr 2645335*
- *Podstawa powołania biegłego zachodzi wówczas, gdy dla ustalenia faktów sprawy niezbędne jest zbadanie okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych. Dowodu z opinii biegłego nie można zastępować innym dowodem, np. dowodem z zeznań świadka posiadającego wiadomości specjalne. Tym niemniej w świetle wyjaśnień oskarżonej przyznającej na etapie postępowania przygotowawczego, iż dokonała podrobienia podpisu na dokumencie przelewu, jak i wskazania przez nią okoliczności w jakich to nastąpiło i powodów tego zachowania, dodatkowe sięganie do opinii biegłego jest zbędne. Zadaniem biegłych jest podzielenie się wiedzą specjalną z sądem, ułatwienie sądowi dokonania oceny dowodów i uczynienia na tym tle ustaleń faktycznych. W przedmiotowej sprawie, jednak powyższe było zbędne w świetle zgromadzonych dowodów, a zwłaszcza wyjaśnień oskarżonej – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 maja 2018 r., sygn. akt II AKa 441/17*

- *Procedura karna nie daje temu sądowi prawa do arbitralnego dyskwalifikowania opinii bez wykazania, że jest ona niepełna lub niejasna albo też nierzetelna. Przy tym jeżeli, tak jak w przedmiotowej sprawie, sąd nie akceptuje wniosków opinii dotyczących istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych (art. 193 § 1 k.p.k.) to sąd ten nie może wówczas zanegować wydanej opinii bez powołania innego biegłego posiadającego tego typu wiadomości, czyli innymi słowy, sąd nie może zastępować biegłych w opiniowaniu w zakresie wiedzy specjalistycznej – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2017 r., sygn. akt II AKa 178/17*
- *Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie sądowym występuje praktycznie jednolity pogląd, że wiedza sądu nie stanowi dowodu w sprawie, umożliwia jedynie i ułatwia sądowi ocenę dowodu z opinii biegłego. Nawet gdyby sąd posiadał wiadomości specjalne, to i tak jest zobowiązany skorzystać z dowodu w postaci opinii biegłego. Organ procesowy nie może zrezygnować z opinii biegłego, jeżeli ustalenie faktu wymaga wiedzy specjalnej. Nie może też odrzucić wszystkich opinii specjalistycznych i przyjąć w danej sprawie własnego odmiennego stanowiska (...) – wyrok Sądu Najwyższego z 2 marca 2017 r., sygn. akt II KK 358/16*
- *Treść ekspertyzy wariograficznej, o jakiej stanowi art. 199a k.p.k., dowodzi wyłącznie tego, jakie były reakcje organiczne oskarżonego na określone zadawane mu pytania, które to reakcje odzwierciedlają stosunek emocjonalny strony biernej procesu do danych zdarzeń. Dowód z ekspertyzy wariograficznej nie może być dopuszczony w celu „oceny wiarygodności wyjaśnień oskarżonego”, zaś wyniku tej ekspertyzy nie należy postrzegać w kategoriach dowodu sprawstwa lub braku sprawstwa oskarżonego. W judykaturze podnosi się, że skoro wniosek obrońcy o dopuszczenie dowodu z ekspertyzy wariograficznej złożony został na zaawansowanym etapie postępowania sądowego, po dokładnym zapoznaniu się przez oskarżonego z aktami sprawy, to powyższy dowód utracił już swą wartość poznawczą. Wobec tego wniosek obrońcy w tym przedmiocie trafnie oddalono się na podstawie art. 170 § 1 pkt 3 k.p.k. (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt II AKa 363/14) (...). Strona domagająca się wydania opinii uzupełniającej, powinna wykazać,*

w jakim zakresie ekspertyza złożona na piśmie jest niepełna lub niejasna czy wewnętrznie sprzeczna, albo na czym polega jej sprzeczność z inną opinią wydaną w tej sprawie, a więc uprawdopodobnić zaistnienie sytuacji wskazanych w art. 201 k.p.k. (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt II AKa 13/16) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7 grudnia 2016 r., sygn. akt II AKa 157/16

- *Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i jednolitym orzecznictwem wypracowanym na gruncie wskazanego przepisu, opinia jest niepełna, jeżeli nie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione biegłemu pytania, na które zgodnie z zakresem posiadanych wiadomości specjalnych i udostępnionych materiałów dowodowych może oraz powinien udzielić odpowiedzi lub jeżeli nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności, albo też nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen oraz poglądów. Opinia jest zaś niejasna, jeżeli jej sformułowanie nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, albo jeżeli zawiera wewnętrzne sprzeczności, posługuje się nielogicznymi argumentami. Natomiast, sprzeczność w samej opinii zachodzi wówczas, gdy co do tych samych, istotnych okoliczności, dokonane zostały odmienne ustalenia, odmienne oceny albo też z przeprowadzonych takich samych czynności sformułowane zostały odmienne wnioski (tak Sąd Najwyższy m.in. w: postanowieniach z 22.10.2015, III KK 239/15, LEX nr 1820402 i z 26.06.2008, V KK 206/08, OSNwSK 2008/1/1350, także w wyroku z 7.10.2009, III KK 122/09, LEX nr 532391) – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 lipca 2016 r., sygn. akt II AKa 170/16*
- *Opinię można uznać za niepełną także wtedy, gdy biegły pomija ujawnione w toku postępowania dowody lub gdy opinia zawiera tylko wnioski, bez przedstawienia przesłanek, na podstawie których biegły te wnioski sformułował. Niejasność opinii, o której mowa w przepisie, ma miejsce w razie niezrozumiałości wywodów biegłego, niemożności ustalenia, w jaki sposób biegły doszedł do końcowych wniosków, wreszcie wtedy, gdy wywody te i wnioski są nielogiczne. Do wewnętrznej sprzeczności opinii dochodzi wówczas, gdy wnioski biegłego wzajemnie się wykluczają lub gdy wnioski nie przystają do wyników badań przeprowadzonych*

przez biegłego (zob. postanowienie SN z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt II KK 19/08, Lex nr 406869) – postanowienie Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt III KK 132/16

- *Opinia jest zaś niejasna, jeżeli jej sformułowanie nie pozwala na zrozumienie wyrażonych w niej ocen i poglądów, a także sposobu dochodzenia do nich, albo jeżeli zawiera wewnętrzne sprzeczności, posługuje się nielogicznymi argumentami. Natomiast, sprzeczność w samej opinii zachodzi wówczas, gdy co do tych samych, istotnych okoliczności, dokonane zostały odmienne ustalenia, odmienne oceny albo też z przeprowadzonych takich samych czynności sformułowane zostały odmienne wnioski (tak Sąd Najwyższy m.in. w: postanowieniach z 22.10.2015, III KK 239/15, LEX nr 1820402 i z 26.06.2008, V KK 206/08, OSNwSK 2008/1/1350, także w wyroku z 7.10.2009, III KK 122/09, LEX nr 532391) – wyrok Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt II AKa 44/16*
- *W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że niepełność opinii w rozumieniu powyższego przepisu utożsamiać należy z taką jej treścią, która nie zawiera odpowiedzi na wszystkie zadane biegłemu pytania, lub nie uwzględnia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii okoliczności albo też nie zawiera uzasadnienia wyrażonych w niej ocen i poglądów. Niejasność natomiast związana jest z niespójnością, wieloznacznością wniosków końcowych, które utrudniają odczytanie ostatecznego poglądu biegłego (por. T. Grzegorzczak, k.p.k., Komentarz, t. I, wyd. 6, Warszawa 2014 r. str. 715–716 wraz z powołanymi orzeczeniami SN) – postanowienie Sądu Najwyższego z 4 listopada 2015 r., sygn. akt III KK 122/15*

Ad. 9.15. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu i wyjście poza granice aktu oskarżenia?

Zgodnie z art. 399 § 1 k.p.k., jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, sąd uprzedza o tym obecne na rozprawie strony. Jeśli zatem w trakcie przewodu sądowego sąd dochodzi do przekonania, że

kwalfikacja prawna czynu zarzuconego aktem oskarżenia nie jest prawidłowa i jednocześnie sąd dostrzega, że czyn ten powinien zostać zakwalifikowany inaczej, wówczas powinien pouczyć strony o możliwości dokonania stosownej zmiany.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, **niepouczenie o dostrzegalnej przez sąd możliwości zmiany kwalifikacji na niekorzyść oskarżonego** (tj. o możliwości zakwalifikowania czynu zarzuconego oskarżonemu z przepisu, przewidującego surowszą sankcję) **stanowi obrazę art. 399 § 1 k.p.k., skutkującą naruszeniem prawa do obrony** (obrazą art. 6 k.p.k.). Zdający konstruują w takich przypadkach albo zarzut obrazy art. 399 § 1 k.p.k. w zw. z art. 6 k.p.k., albo zarzut (samodzielnej) obrazy art. 399 § 1 k.p.k., której skutkiem jest obraza art. 6 k.p.k.

Powyższe wymaga jednak dodatkowego komentarza. Wobec znowelizowanej treści art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k. i wynikającego stąd zamkniętego katalogu podstaw uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, **zarzut obrazy art. 399 § 1 k.p.k. nie będzie w obecnym stanie prawnym skuteczny**. Brak pouczenia o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu skutkuje wprawdzie brakiem rzetelnego procesu, o jakim mowa w art. 6 ust. 3 lit. a Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, to jednak brak jest podstawy prawnej do zmiany w takiej sytuacji procesowej zaskarżonego orzeczenia. Uchybienie to ma bowiem charakter formalny i nie rzutuje na merytoryczną prawidłowości zmienionej przez sąd kwalifikacji prawnej czynu. Obraza art. 399 § 1 k.p.k. nie stanowi jednocześnie jednej z przyczyn uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, zgodnie z art. 437 § 2 *in fine* k.p.k. Wobec tak ukształtowanego stanu prawnego, uzasadnione jest wskazywanie np. w uzasadnieniu apelacji, że zdający dostrzegają uchybienie sądu w postaci braku stosownego pouczenia w protokole rozprawy głównej zgodnie z art. 399 § 1 k.p.k., jednak nie formułują w tym przedmiocie zarzutu apelacyjnego ze względu na obecną treść art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k.

Zgodnie z art. 399 § 2 k.p.k., na wniosek oskarżonego, a zatem także obrońcy, można przerwać rozprawę w celu umożliwienia mu przygotowania się do obrony. Mimo, że ustawodawca posługuje się pojęciem „można przerwać”, w orzecznictwie wypracowany został zasadniczo jednomyślny

pogląd, że w przypadku stosownego wniosku obrony, sąd nie powinien takiego wniosku oddalić. Powtarzając za Sądem Apelacyjnym w Warszawie, *funkcja tego przepisu* (art. 399 § 1 k.p.k. – przypis autorki) *sprowadza się do braku zaskakiwania stron procesu zmienionym wartościowaniem prawno-karnym zachowania sprawcy*¹¹⁰. Oskarżony (i tym samym obrona) musi mieć czas na przygotowanie argumentacji, odpowiadającej na zarzut oskarżenia w danej sprawie, w tym przygotowanie stosownej argumentacji prawnej odnoszącej się tak do faktów, jak i samego prawa (np. przyjętej w orzecznictwie i doktrynie prawa karnego interpretacji poszczególnych znamion). **Brak odroczenia lub zarządzenia przerwy w rozprawie na wniosek obrony, zgłoszony w trybie art. 399 § 2 k.p.k., stanowić będzie obrazę art. 399 § 2 k.p.k., skutkującą naruszeniem prawa oskarżonego do obrony.** Jednak także w tym przypadku zastosowanie znajdują wskazane powyżej uwagi dotyczące skuteczności tego zarzutu w kontekście obecnego brzmienia art. 437 § 2 *in fine* k.p.k. Brak jest bowiem przesłanek do zmiany orzeczenia tylko z tego powodu, że sąd nie odroczył rozprawy na wniosek złożony w trybie art. 399 § 2 k.p.k. Jednocześnie, obraza art. 399 § 2 k.p.k. nie stanowi jednej z przyczyn uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, zgodnie z art. 437 § 2 *in fine* k.p.k.

W omawianym kontekście warto odnotować również pogląd Sądu Najwyższego, zgodnie z którym obowiązek z art. 399 § 1 k.p.k. to *nakaz skierowany do sądu, który winien postąpić w sposób określony w tym przepisie i to niezależnie od tego, czy chodzi o przepis przewidujący surowszą odpowiedzialność sprawcy, czy też łagodniejszą. Oczywiście, badając możliwość ewentualnego istotnego wpływu tego rodzaju uchybienia na treść wyroku sądu odwoławczego należy w realiach omawianej sprawy stwierdzić, że takiego istotnego wpływu nie sposób z góry odrzucić*¹¹¹.

Należy zgodzić się, że **z obrażą art. 399 § 1 k.p.k. będziemy zatem mieli do czynienia zawsze wtedy, gdy sąd nie pouczył o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu** (tak na niekorzyść, jak i na korzyść oskarżonego)¹¹².

¹¹⁰ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lipca 2021 r., sygn. akt II AKa 96/21.

¹¹¹ Wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2019 r., sygn. akt V KK 57/18.

¹¹² Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2014 r., sygn. akt V KK 336/14.

Mając jednak na uwadze konieczność wykazania wpływu uchybienia na treść zapadłego rozstrzygnięcia, polegającego na braku pouczenia w trybie art. 399 § 1 k.p.k., wydaje się, że z założenia oczywisty wpływ na treść wyroku ma niepouczenie oskarżonego o możliwości zmiany kwalifikacji zarzucanego mu czynu na kwalifikację surowszą. Co zaś tyczy się braku pouczenia o zmianie kwalifikacji na łagodniejszą, wydaje się z kolei, że wykazanie w tym zakresie wpływu na treść zapadłego orzeczenia jest zdecydowanie trudniejsze, o ile nierzadko niemożliwe¹¹³. Formalnie jednakże, skoro ustawodawca formułuje jednoznacznie nakaz uprzedzenia stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu, to sąd ma taki obowiązek niezależnie od tego, czy zmiana ta byłaby zmianą na korzyść oskarżonego, czy też nie.

Wskazywane powyżej **pouczenie to nic innego jako postanowienie, wydane przez sąd w toku rozprawy** o treści „*na podstawie art. 399 § 1 k.p.k., sąd poucza o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu na art. ...*”. W przypadku zatem dostrzeżenia na egzaminie zmiany kwalifikacji prawnej czynu na surowszą, czyli zakwalifikowania czynu oskarżonego z przepisu, przewidującego surowszą kwalifikację w porównaniu do kwalifikacji prawnej, przyjętej w akcie oskarżenia, należy sprawdzić w protokołach rozprawy głównej, zawartych w aktach egzaminacyjnych, czy sąd wydał w toku przewodu sądowego stosowne postanowienie i tym samym w procesowo właściwej formie pouczył oskarżonego, stosownie do treści art. 399 § 1 k.p.k.

Przykład I: Oskarżonemu zarzucono popełnienie czynu zabronionego z art. 278 § 1 k.k. Jeśli zatem w toku przewodu sądowego, sąd doszedłby do przekonania, że w działaniach oskarżonego pojawił się element zaboru i czyn w związku z tym powinien zostać zakwalifikowany nie jako „zwykła” kradzież z art. 278 § 1 k.k., ale jako rozbój z art. 280 § 1 k.k., to o takiej

¹¹³ Jednakże można wyobrazić sobie sytuację procesową, w której sąd nie poucza o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej na taką, która formalnie wcale nie jest dla oskarżonego niekorzystna (np. zmiana obejmować miałaby kwalifikację prawną przewidującą łagodniejszą sankcję). Potencjalna zmiana wymagałaby jednak odmiennej taktyki/linii obrony aniżeli dotychczas przyjmowana w toku postępowania przez oskarżonego. Wówczas wydaje się, że argumentacja przemawiająca za obrazą art. 399 § 1 k.p.k. byłaby uzasadniona.

możliwej zmianie kwalifikacji prawnej czynu sąd powinien pouczyć. Brak takiego pouczenia i dokonanie ww. zmiany w wyroku będzie naruszeniem prawa do obrony oskarżonego, albowiem dokonana przez sąd zmiana była zmianą na niekorzyść oskarżonego (art. 278 § 1 k.k. przewiduje bowiem łagodniejszą sankcję aniżeli czyn z art. 280 § 1 k.k.).

Przykład II: Oskarżonemu zarzucono popełnienie czynu zabronionego z art. 280 § 1 k.k. Jeśli zatem w toku przewodu sądowego, sąd doszedłby do przekonania, że w działaniach oskarżonego brak było elementu zaboru i czyn powinien zostać zakwalifikowany jako kradzież z art. 278 § 1 k.k., to brak pouczenia w tym przedmiocie i dokonanie ww. zmiany w wyroku nie będzie naruszeniem prawa do obrony oskarżonego, albowiem dokonana przez sąd zmiana nie była zmianą na niekorzyść oskarżonego i jednocześnie nie wydaje się by wymagała odmiennej linii obrony niż przyjmowana dotychczas (art. 278 § 1 k.k. przewiduje bowiem łagodniejszą sankcję aniżeli czyn z art. 280 § 1 k.k., a jednocześnie jego znamiona wchodzą w zakres znamion art. 280 § 1 k.k.). Formalnie zatem zabrakło wymaganego pouczenia, jednakże wobec zmiany kwalifikacji prawnej czynu dokonanej na korzyść – nie sposób twierdzić, że doszło w tym zakresie również do obrazy art. 6 k.p.k.

Przykład III: Oskarżonemu zarzucono popełnienie czynu zabronionego z art. 280 § 1 k.k. Jeśli zatem w toku przewodu sądowego, sąd doszedłby do przekonania, że w trakcie tego zdarzenia oskarżony posługiwał się nożem, wówczas powinien poinformować o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu na art. 280 § 2 k.k. i (wobec treści art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k.) stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi okręgowemu jako rzeczowo właściwemu do rozpoznania sprawy oskarżonego w I instancji.

Zaznaczenia jednocześnie wymaga, że **problematyka „wyjścia poza granice oskarżenia” jest jednym z kluczowych i najtrudniejszych zagadnień praktyki karnej**. Analiza orzecznictwa wypracowanego na tle art. 399 § 1 k.p.k. wskazuje jak trudno w praktyce ocenić, czy zmieniając opis czynu i w konsekwencji jego kwalifikację prawną, sąd zachował granice tożsamości historycznej ocenianego zdarzenia – rozumianego jako granice skargi głównej,

wyznaczone zdarzeniem historycznym, czy też wykroczył poza nie (szerzej na ten temat również z rozdziale 9.15 oraz 10 niniejszej publikacji).

Podkreślenia wymaga, że odrębnym zagadnieniem są dokonywane przez sąd w wyroku **zmiany opisu czynu** w stosunku do opisu, przyjętego w akcie oskarżenia. Sama zmiana opisu nie stanowi obrazy art. 399 § 1 k.p.k., albowiem art. 399 § 1 k.p.k. odnosi się do kwalifikacji prawnej czynu, nie zaś jego opisu¹¹⁴. Jak podkreśla się w orzecznictwie, *zmiany opisu czynu są dopuszczalne, gdy sąd dokonuje oceny tego samego w znaczeniu ontologicznym zachowania oskarżonego, które stanowiło przedmiot oskarżenia*¹¹⁵. Jak zaznaczył bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 30 października 2012 r., zgodnie z *zasadą skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.), ramy postępowania jurysdykcyjnego są określone przez zdarzenie historyczne opisane w akcie oskarżenia, a nie przez poszczególne elementy tego opisu (...). Zatem, zasada skargowości nie ogranicza sądu w ustaleniach wszystkich cech faktycznych tego zdarzenia oraz w zakresie oceny prawnej rozpoznawanego czynu. W konsekwencji, sąd nie jest związany ani szczegółowym opisem czynu zawartym w zarzucie aktu oskarżenia, ani kwalifikacją prawną nadaną temu czynowi przez oskarżyciela (...). Warunkiem wprowadzenia (...) zmian jest jedynie to, aby w realiach dowodowych konkretnej sprawy oczywistym było, iż sąd dokonywał oceny tego samego zachowania oskarżonego, które stanowiło przedmiot oskarżenia (tzw. tożsamość czynu zarzucanego i przypisywanego)*¹¹⁶.

Przydatne orzecznictwo:

- *Obraza art. 399 § 1 k.p.k. nie może być uznana za uchybienie, które zawsze i w każdej sytuacji stanowi obrazę przepisów postępowania mogącą mieć wpływ na treść wyroku sądu I instancji (art. 438 pkt 2 k.p.k.). Funkcja tego przepisu sprowadza się do braku zaskakiwania stron procesu zmienionym wartościowaniem prawno-karnym zachowania sprawcy.*

¹¹⁴ Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 marca 2015 r., sygn. akt V KK 463/14.

¹¹⁵ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 listopada 2018 r., sygn. akt II AKa 508/2018, LEX nr 3007602.

¹¹⁶ Wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 2012 r., sygn. akt II KK 9/12.

W sytuacji, gdy Sąd Okręgowy wyeliminował z opisu i kwalifikacji prawnej część zachowań oskarżonych, pozostawiając jedno stanowiące ich element, nie uprzedzając o tym stron, w realiach tej sprawy nie mogło mieć wpływu na treść wyroku – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lipca 2021 r., sygn. akt II AKa 96/21

- *Zakaz wyjścia poza granice oskarżenia oznacza niedopuszczalność orzekania poza ramami zdarzenia będącego przedmiotem oskarżenia. Oceny tej dokonuje się z punktu widzenia konkretnego zdarzenia faktycznego, którego dotyczy akt oskarżenia. Nie ma przy tym znaczenia kwalifikacja prawna czynu przyjęta przez oskarżyciela w akcie oskarżenia. Jak trafnie to wyraził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, czy sąd „zmieścił się” w granicach skargi, decyduje tożsamość zdarzenia historycznego, do którego należy objętego czyn przypisany i zdarzeniem objętego aktem oskarżenia (wyrok z dnia 21 listopada 2018 r. – II AKa 332/18). W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, iż nie stanowi wyjścia poza granice oskarżenia, zatem i naruszenia zasady skargowości, dokonanie w przewodzie sądowym co do tego samego zdarzenia ustaleń faktycznych odmiennych niż przyjęte w zarzucie, np. daty, czy okresu popełnienia czynu. Jak trafnie stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wypadku innych ustaleń co do czasu popełnienia czynu, dla zachowania tej tożsamości niezbędne jest wyłącznie wykazanie niezmienności podmiotu czynu, przedmiotu ochrony, a także tożsamości osoby pokrzywdzonej (wyrok z dnia 18 października 2018 r. – II AKa 402/17). Powszechnie przyjmuje się, że opis czynu zawarty w akcie oskarżenia ani zastosowana kwalifikacja prawna nie są wiążące dla orzekającego sądu, a wiąże sąd zdarzenie w znaczeniu historycznym. Jak trafnie przyjął Sąd Apelacyjny w Szczecinie, w zakresie uprawnień sądu mieszczą się zmiany co do czasu i miejsca popełnienia badanego czynu, co do stanów faktycznych zarówno strony przedmiotowej, jak podmiotowej, ustalenia odmiennego działania sprawców, skutku i powiązania go z zachowaniem sprawców, czy odmiennej kwalifikacji prawnej (wyrok z dnia 24 maja 2018 r. – II AKa 75/2018). Jak trafnie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach, zmiany opisu czynu są dopuszczalne, gdy sąd dokonuje oceny tego samego w znaczeniu ontologicznym zachowania oskarżonego, które stanowiło przedmiot oskarżenia (wyrok*

z dnia 30 listopada 2018 r. – II AKa 508/2018) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 17 września 2019 r., sygn. akt II AKa 95/19, LEX nr 3007602**

- Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, sąd uprzedza o tym obecne na rozprawie strony. Jest to więc nakaz skierowany do sądu, który winien postąpić w sposób określony w tym przepisie i to niezależnie od tego, czy chodzi o przepis przewidujący surowszą odpowiedzialność sprawcy, czy też łagodniejszą. Oczywiście, badając możliwość ewentualnego istotnego wpływu tego rodzaju uchybienia na treść wyroku sądu odwoławczego należy w realiach omawianej sprawy stwierdzić, że takiego istotnego wpływu nie sposób z góry odrzucić – **wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2019 r., sygn. akt V KK 57/18**
- Ewentualna zmiana opisu czynu w czynie przypisanym w porównaniu z treścią czynu zarzucanego, o ile nie wiąże się z koniecznością dokonania zmiany w kwalifikacji prawnej czynu, nie pociąga za sobą obowiązku sądu pouczenia stron o możliwości takiej modyfikacji. Wynika to wprost nie tylko z treści art. 399 § 1 k.p.k., ale także z zestawienia tego przepisu z treścią art. 314 k.p.k. To ostatnie uregulowanie, mające wszak zastosowanie jedynie na etapie postępowania przygotowawczego, przewiduje konieczność wydania nowego postanowienia o przedstawieniu zarzutów (w praktyce przyjmującego postać postanowienia o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów) w wypadkach – w omawianym tu zakresie – gdy należy podejrzanemu zarzucić czyn w zmienionej w istotny sposób postaci lub też gdy czyn ten należy zakwalifikować z surowszego przepisu. W tym więc zakresie organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ma wobec stron obowiązek informacyjny, który przybiera postać sformalizowanego postanowienia, w sytuacji, gdy uznaje, że podejrzanemu należy zarzucić czyn w zmienionej w istotny sposób postaci. Ustawodawca w art. 399 § 1 k.p.k. takiej konieczności nie nakłada na sąd orzekający w postępowaniu sądowym, ograniczając obowiązek informacyjny jedynie do wypadku możliwej zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Jednoznaczny w swej treści art. 399 § 1 k.p.k., jak i wykładnia systemowa

wewnętrzna, nakazują przyjąć, że możliwość – którą dostrzeżę sąd – zmiany opisu czynu, który ma być przypisany, w porównaniu z opisem czynu zarzucanego, nie pociąga za sobą obowiązku sądu uprzedzenia o możliwości takiej zmiany. Takiego kategorycznego obowiązku nie da się wywieść także z przepisu art. 16 § 2 k.p.k., czego oczekuje skarżący, gdyż przepis ten przewiduje, co prawda, w ramach zasady lojalności możliwość udzielania informacji uczestnikom postępowania, jednak dotyczyć ma ona, jak wyraźnie wskazano w tym przepisie, jedynie ciążących obowiązków lub przysługujących uprawnień. Ewentualna zmiana opisu czynu nie mieści się więc w przedmiocie tej regulacji – **wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2019 r., sygn. akt III KK 553/17, LEX nr 2609153**

- (...) naruszenie dyrektywy wynikającej z treści art. 399 § 1 k.p.k. nie jest uchybieniem należącym do kręgu bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Jego znaczenie w procesie, a przede wszystkim wpływ na treść rozstrzygnięcia, należy analizować w realiach konkretnej sprawy, uwzględniając zdarzenia procesowe, które miały miejsce w dotychczasowym postępowaniu – **postanowienie Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2019 r., sygn. akt III KK 473/18**
- Oczywiście jest, że ramy postępowania jurysdykcyjnego określone są przez zdarzenie historyczne opisane w skardze wszczynającej postępowanie, a nie przez poszczególne elementy tego opisu, co oznacza wszakże, że sąd związany jest tymi ramami, a zatem przedmiotem orzekania nie mogą zachowania wykraczające poza wspomniane zdarzenie historyczne. Inaczej mówiąc, granice oskarżenia zostają utrzymane dopóty, dopóki w miejsce czynu zarzucanego, w ramach tego samego zdarzenia historycznego można przypisać oskarżonemu czyn, nawet ze zmienionym opisem i jego oceną prawną, ale mieszczący się w tym samym zespole zachowań człowieka. Obowiązkiem Sądu odwoławczego było zatem, przy założeniu, że ze względu na wniesienie apelacji wyłącznie na korzyść, nie może dojść do pogorszenia sytuacji procesowej oskarżonego w zestawieniu z wyrokiem sądu pierwszej instancji, rozważenie, czy w realiach sprawy, w szczególności zważywszy na opis czynu przypisanego w wyroku Sądu Rejonowego, możliwe jest przypisanemu innemu czynu zabronionego, w szczególności zagrożonego łagodniejszą sankcją w porównaniu

z art. 286 § 1 k.k. Sąd Okręgowy winien zatem rozstrzygnąć, czy możliwe jest przypisanie oskarżonemu odpowiedzialności z art. 292 § 1 k.k., o czym sam wspominał, czy z art. 300 § 2 k.k., na co wskazano w postanowieniu Sądu Najwyższego w sprawie II KK 272/17, a następnie, dopiero po stwierdzeniu takiej możliwości, uprzedzić strony w trybie art. 399 § 1 k.p.k. – **wyrok Sądu Najwyższego z 28 listopada 2018 r., sygn. akt II KK 92/18**

- Nie można zgodzić się z obrońcą, że zmiana dokonana przez Sąd w zakresie ustalenia czasu popełnienia przestępstwa wskazuje na to, że zdarzenie objęte aktem oskarżenia jest innym zdarzeniem historycznym niż to, za które został skazany oskarżony. Nie stanowi wyjścia poza granice oskarżenia i związane z tym naruszenie zasady skargowości dokonanie w toku przewodu sądowego odmiennych niż przyjęte w zarzucie ustaleń faktycznych co do tego samego zdarzenia np. w zakresie daty, czy okresu popełnienia czynu. W wypadku poczynienia innych ustaleń co do czasu popełnienia czynu, dla zachowania tej tożsamości niezbędne jest wyłączenie wykazanie niezmienności podmiotu czynu, przedmiotu ochrony, a także tożsamość osoby pokrzywdzonej – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 października 2018 r., sygn. akt II AKa 402/17**
- (...) wynikająca z art. 399 § 1 k.p.k. konieczność uprzedzenia stron o możliwej zmianie kwalifikacji prawnej czynu, jest istotnym mechanizmem umożliwiającym efektywne prowadzenie obrony. Dostarczenie stronom, w tym obronie, bieżącej informacji o rozważanej przez sąd kwalifikacji prawnej czynu jest niezbędne dla odpowiedniego ukie-runkowania podejmowanych przez strony kroków procesowych, w tym wniosków dowodowych, i przedstawianej argumentacji. Warto też przypomnieć, że prawo do aktualnej informacji o treści stawianego oskarżonemu zarzutu, w tym o prawnej kwalifikacji czynu, jest składową prawa do rzetelnego procesu sądowego, wynikającą z art. 6 ust. 3 lit. a Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie ma przy tym znaczenia – jak błędnie twierdzi prokurator w pisemnej odpowiedzi na kasację – że po zmianie dokonanej przez Sąd Apelacyjny kwalifikacja była korzystniejsza dla skazanego niż przyjęta w wyroku Sądu Okręgowego; wszak ani przepis art. 399 § 1 k.p.k., ani standard konwencyjny nie

uzależnia obowiązku uprzedzenia stron o możliwej korekcie kwalifikacji od kierunku tej korekty. Nie sposób zgodzić się też z argumentacją prokuratora, że możliwość tej zmiany była rzekomo oczywista w kontekście wniosków opinii biegłej M. N. i nie mogła stanowić dla obrony zaskoczenia. Omówiona wyżej gwarancja procesowa wynikająca z art. 399 § 1 k.k. w zw. z art. 458 k.p.k. polega bowiem na dostarczeniu oskarżonemu przez organ procesowy jasnej i wyraźnej informacji o możliwej zmianie normatywnej treści zarzutu; nie można od obowiązku uprzedzenia odstąpić ze względu na rzekomą oczywistość sytuacji i w oparciu o założenie, że oskarżony możliwości zmiany kwalifikacji gotów jest się domyślić – **wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt III KK 229/17**

- (...) określony w akcie oskarżenia czyn ma charakter hipotetyczny: wersja wydarzeń przedstawiona przez oskarżyciela nie może być uznana za ostateczną. Właśnie temu służy rozprawa, by umożliwić weryfikację tej wersji/hipotezy. Zgodnie z zasadą, że to sąd zna prawo (*iura novit curia*), kwalifikacja prawna zaproponowana przez prokuratora nie jest dla sądu wiążąca (zob. S. Waltoś, *Akt oskarżenia w procesie karnym*, Warszawa 1963, s. 45 i n.; S. Stachowiak, *Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym*, Poznań 1975, s. 208). Jest to jedynie pogląd prawny prokuratora na zarzucany czyn. Polski Kodeks postępowania karnego przewiduje w art. 399 § 1 k.p.k., że jeżeli w toku rozprawy okaże się, że nie wychodząc poza granice oskarżenia, można czyn zakwalifikować według innego przepisu prawnego, sąd uprzedza o tym obecne na rozprawie strony. Możliwe jest nawet dokonanie zmiany kwalifikacji prawnej czynu na rozprawie odwoławczej (art. 455 k.p.k.). To sąd jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji co do prawa, które znajdzie zastosowanie i dokonania wiążącej subsumcji. Niezależne od opinii oskarżyciela sąd zajmuje samodzielne stanowisko co do kwalifikacji prawnej. Jest to jego uprawnienie, a zarazem obowiązek. Zmiana kwalifikacji prawnej to jedynie zmiana prawnego obrazu tego samego zdarzenia faktycznego, poza granice którego sąd nie wykracza (por: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1977 r., III KR 170/77, OSNPG 1977, z. 11, poz. 117) – **wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2016 r., sygn. akt III KK 294/16**

- Z treści art. 399 § 1 k.p.k. nie wynika powinność Sądu uprzedzania o zmianie opisu czynu w zakresie określenia daty czy miejsca zdarzenia. W odniesieniu do skazanego w opisie czynu II skorygowano jedynie datę popełnienia przestępstwa z 23 marca 2010 r., na – 25 na 26 marca 2010 r. Poprawienie Sądu Rejonowego należało zatem do czynności o charakterze „kosmetycznym”, nie wymagających zachowania jakiegś szczególnej formy czy też procedury. Wynikające z art. 399 § 1 k.p.k. uprzedzenie stron dotyczy, czego nie dostrzega skarżący – zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu – **postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2015 r., sygn. akt V KK 463/14**
- Tożsamość czynu nie może być postrzegana nazbyt wąsko i obejmować wyłącznie opis zawarty w akcie oskarżenia. Kluczową jest ocena, czy dodatkowe, nowe elementy opisu dotyczą tego samego zdarzenia, stanowiącego faktyczny przedmiot toczącego się postępowania (...) – **wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 października 2014 r., sygn. akt II AKa 131/12**
- Zmiany w opisie czynu dokonane przez sąd pierwszej instancji nie naruszają zasady skargowości, dotyczyły one w istocie jedynie korekt w odniesieniu do czasu popełnienia przestępstwa i wysokości przywłaszczonych kwot. Zmiany te znalazły przy tym oparcie w dowodach ujawnionych w toku przewodu sądowego (...). Analiza orzecznictwa w tym zakresie prowadzi do jednoznacznego wniosku, że dokonane przez sąd zmiany w zakresie okresu popełnienia czynu czy wartości przedmiotu przestępstwa nie stanowią wyjścia poza granice oskarżenia w sytuacji, w której zachowana jest tożsamość oskarżonego, osoby pokrzywdzonej, miejsca i sposobu działania przez wykorzystanie tej samej sposobności. (zob. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 r., III KK 217/12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2012 r., II KK 9/12). Nie ulega wątpliwości, że sąd nie jest związany opisem czynu zawartym w akcie oskarżenia i może dokonywać w nim zmian. Warunkiem jest jedynie, by nie istniały wątpliwości, co do tego, że przedmiotem orzekania było to samo w sensie historycznym zdarzenie, które opisane zostało w akcie oskarżenia – **postanowienie Sądu Najwyższego z 19 lutego 2014 r., sygn. akt II KK 360/13**

- O tym, czy sąd orzekł w wyroku skazującym w granicach aktu oskarżenia, decyduje tożsamość zdarzenia historycznego zarzucanego w skardze i przypisanego w wyroku. Znaczenie określenia „zdarzenie historyczne” obejmuje opisane w skardze zdarzenie faktyczne i jest ono pojęciem o szerszym znaczeniu niż pojęcie „czynu” oskarżonego, polegającego na jego działaniu lub zaniechaniu (por.: wyroki Sądu Najwyższego; z dnia 2 marca 2011 r., III KK 366/10, OSNKW 2011, z. 6, poz. 51, z dnia 4 kwietnia 2006 r., III KK 306/06, OSNKW 2006, z. 7–8, poz. 69, z dnia 22 kwietnia 1986 r., IV KR 129/86, OSNPG 1986, z. 12, poz. 167, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r., III KK 97/10, OSNKW 2011, z. 6, poz. 50, Tomasz Grzegorzczuk, *Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz*. Wyd. 5, str. 96, tezy 2 i 3, str. 849–851) – **postanowienie Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt V KK 18/13**
- Zgodnie z zasadą skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.), ramy postępowania jurysdykcyjnego są określone przez zdarzenie historyczne opisane w akcie oskarżenia, a nie przez poszczególne elementy tego opisu (...). Zatem, zasada skargowości nie ogranicza sądu w ustaleniach wszystkich cech faktycznych tego zdarzenia oraz w zakresie oceny prawnej rozpoznawanego czynu. W konsekwencji, sąd nie jest związany ani szczegółowym opisem czynu zawartym w zarzucie aktu oskarżenia, ani kwalifikacją prawną nadaną temu czynowi przez oskarżyciela. Dlatego, jak to wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie, nie jest wyjściem poza ramy oskarżenia, takie postąpienie, w którym sąd w wyniku przeprowadzonego przewodu sądowego i weryfikacji ujawnionego materiału dowodowego: (1) Ustali, że rozpoznawane przez niego zdarzenie miało miejsce w innym czasie, niż to przyjął prokurator w akcie oskarżenia, choćby swe twierdzenia podtrzymywał w trakcie rozprawy sądowej. Ustalenie możliwie dokładnej daty popełnienia przestępstwa jest bowiem nie tylko prawem, ale i obowiązkiem sądu; (2) Dokona w wyroku pewnych ustaleń faktycznych odmiennie, niż to zostało przyjęte w akcie oskarżenia, popieranym przez prokuratora; przy czym ustalenia te mogą dotyczyć nie tylko strony przedmiotowej, ale także (co nawet występuje częściej) strony podmiotowej czynu; (3) Przyjmie odmienne, co do szczegółów, zachowanie się i sposób działania poszczególnych sprawców, bowiem tożsamości zdarzenia nie

może wyłączać to, że postępowanie dowodowe doprowadzi do ustaleń, iż nie wszyscy uczestnicy zdarzenia, które stanowiło dla prokuratora *asumpt* do wystąpienia z oskarżeniem, zachowywali się tak, jak im to zarzucono; (4) Powiąże zachowanie oskarżonego, zarzucane mu w akcie oskarżenia, z odmiennym skutkiem niż to stwierdza prokurator. Warunkiem wprowadzenia jednej, czy też nawet wszystkich, powyższych zmian jest jedynie to, aby w realiach dowodowych konkretnej sprawy oczywistym było, iż sąd dokonywał oceny tego samego zachowania oskarżonego, które stanowiło przedmiot oskarżenia (tzw. tożsamość czynu zarzucanego i przypisywanego) – **wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 2012 r., sygn. akt II KK 9/12**

- Można natomiast zwrócić uwagę np. na przywoływane już postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 r. (IV 139/11), w którym wskazano, że nie negując możliwości przypisania osobie, której zarzucono przestępstwo kradzieży lub kradzieży z włamaniem, zamiast niego przestępstwa paserstwa, należy jednak podkreślić, iż nie można mówić o tożsamości czynów, jeżeli przypisywane przestępstwo paserstwa miało miejsce już w jakiś czas po kradzieży i w okolicznościach nie mających nic wspólnego z opisem i podstawą faktyczną czynu zarzucanego, gdyż nie chodzi wówczas tylko o odmienny sposób wejścia w posiadanie rzeczy pochodzącej z czynu zabronionego, lecz o zupełnie inne zdarzenie faktyczne, w którego ramach doszło do takiego posiadania – **wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2012 r., sygn. akt V KK 240/11**

Ad. 9.16. Brak kompletu znamion w opisie czynu przypisanego oskarżonemu a apelacja tylko do co kary ze strony oskarżyciela posiłkowego

Z zasady *nullum crimen sine lege* wynika, że przypisane oskarżonemu wyrokiem przestępstwo musi zawierać pełen komplet znamion, określonych przez ustawodawcę w przepisie, stanowiącym podstawę skazania. Gdyby zatem okazało się, że w zawartym w wyroku skazującym opisie czynu np. z art. 286 § 1 k.k. sąd nie ujął „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”, oczywiste jest,

że opis taki nie zawiera wszystkich wymaganych znamion oszustwa. Jeśli w takiej sytuacji wyrok zostanie zaskarżony przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na niekorzyść oskarżonego, ale w części (albowiem ten nie dostrzeże dekompletacji znamion przypisanego oskarżonemu czynu), zaś jednocześnie obrońca zaskarży wyrok w całości na korzyść oskarżonego, to sąd odwoławczy nie będzie miał możliwość skorygowania opisu tego czynu, poprzez uzupełnienie brakujących znamion. Byłoby to bowiem dokonywanie zmian na niekorzyść oskarżonego, poza zakresem zaskarżenia wyroku na jego niekorzyść przez oskarżyciela. Sąd odwoławczy w takiej sytuacji zmieniałby zaskarżone orzeczenie i oskarżonego uniewinnił, czyniąc tak niezależnie od tego, jak poważny czyn przestępny był przedmiotem sądowej oceny.

Zaskarżenie zatem wyroku w opisanej powyżej sytuacji w części (a zatem nie co do winy) byłoby błędem pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, ponieważ poprzez brak zaskarżenia wyroku w całości na niekorzyść oskarżonego sąd odwoławczy nie mógłby dokonywać zmian wyroku na niekorzyść oskarżonego (np. uzupełniając brakujące znamiona przestępstwa) i w konsekwencji musiałby uwzględnić wniosek obrony o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego. Podstawą takiego rozstrzygnięcia byłby art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 414 § 1 k.p.k. *in fine*.

W sytuacji jak opisana powyżej, rozstrzygnięcie powinno zostać zaskarżone przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w całości na niekorzyść oskarżonego, zaś w apelacji należało sformułować zarzut obrazy art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., poprzez pominięcie jednego ze znamion czynu, przy prawidłowo poczynionych w tym zakresie ustaleniach faktycznych.

Przydatne orzecznictwo:

- *Ma rację obrońca oskarżonego, że czyn przypisany w jego warstwie określającej znamiona ustawowe nie odpowiada wymogom art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., bowiem nie zawiera wszystkich relewantnych dla przypisania popełnienia przestępstwa groźby karalnej przesłanek. Jak to ujął Sąd Najwyższy w sprawie V KK 286/17: Wyrok skazujący zgodnie z tym przepisem powinien zawierać dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną. Opis czynu przypisanego winien być jednoznaczny, nie dający możliwości różnych jego interpretacji*

i winien być zawarty w sentencji wyroku, a nie w uzasadnieniu – wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 31 października 2019 r., sygn. akt II AKa 213/19

- (...) opis czynu przypisanego, który ma postać zjawiskową pomocnictwa, w zakresie czynu zabronionego, do którego popełnienia udzielono pomocy, powinien zawierać wszystkie znamiona typu czynu zabronionego popełnianego w formie sprawczej, także należące do strony podmiotowej. W wypadku oszustwa wymagane jest więc, aby opis taki zawierał znamie kierunkowe w postaci działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oczywiście niekoniecznie po stronie pomocnika, ale koniecznie po stronie osoby, której udzielana jest pomoc do oszustwa. *Prima vista*, takiego znamienia nie zawiera opis czynu przypisanego skazanemu w zakresie czynu zabronionego, do którego udzielił pomocy. Sąd Okręgowy nie wskazał bowiem, jak to zwyczajowo czyni się w opisach czynów przypisanych w sprawach o przestępstwo oszustwa, iżby sprawca miał działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd Najwyższy wielokrotnie już jednak podkreślał, że postępowanie karne nie jest procesem formułkowym i nie wymaga się, aby w wyroku skazującym powtarzać określenia ustawowe. Wystarczające jest, aby opis czynu odpowiadał wyrażeniom ustawowym, stanowiącym znamiona typu czynu zabronionego – **postanowienie Sądu Najwyższego z 19 września 2019 r., sygn. akt IV KK 495/19**
- (...) wyrok skazujący zgodnie z tym przepisem powinien zawierać dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną. Opis czynu przypisanego winien być jednoznaczny, nie dający możliwości różnych jego interpretacji i winien być zawarty w sentencji wyroku, a nie w uzasadnieniu – **wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt V KK 286/17**
- (...) brak w opisie czynu przypisanego oskarżonemu w wyroku (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.) jakiegokolwiek znamienia ustawowego typu czynu zabronionego skutkuje niemożnością przypisania odpowiedzialności karnej za ten czyn (art. 1 § 1 k.k. i art. 115 § 1 k.k.). Przywołane przez Sąd odwoławczy orzeczenia Sądu Najwyższego (II KK 141/14 oraz III KK 148/09) są właśnie potwierdzeniem tego stanowiska. Przecież w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2009 r., (III KK 148/09, LEX nr 560583)

wyraźnie ujęto, na tle zbrodni z art. 148 § 1 k.k., że w opisie czynu znamię podmiotowe (umyślność) znajdowało się. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tego postanowienia stwierdził trafnie, że: „Przestępstwa umyślne są zatem regułą, a przestępstwa nieumyślne – wyjątkiem. Nie ma więc potrzeby uzupełnienia powyższej formuły słowem „umyślnie”, bo byłoby to zbędne superfluum. Zwrot o działaniu sprawcy, z zamiarem pozbawienia życia, zamiast czynności czasownikowej „zabija”, użytej w art. 148 § 1 k.k., jest wynikiem zastosowania tzw. metody podstawiania, jako jednego z dwóch zasadniczych sposobów konkretyzowania istoty czynu. Zamiast powtarzać w opisie czynu jego ustawowe znamiona (metoda repetycji), zastępuje się je wyrażeniami równoważnymi, a przy tym „oddającymi stan faktyczny sprawy””. Tak więc w sprawie tej nie stwierdzono braku znamienia podmiotowego w opisie czynu, a jedynie wyrażono – słusznie – tezę, że ustawowe znamię zawarte w opisie czynu przestępnego, wymagane dla przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej według reguły z art. 1 § 1 k.k. i art. 115 § 1 k.k., może być opisane innymi słowami, ale takimi, które je zastępują znaczeniowo, są równoważne. (...). W sytuacji gdy wyrok sądu pierwszej instancji nie został zaskarżony na niekorzyść, to sąd odwoławczy, stwierdzając brak w opisie czynu znamienia ustawowego, nie mógł utrzymać zaskarżonego wyroku w mocy, a jedynym orzeczeniem powinna być zmiana wyroku i uniewinnienie oskarżonego od wszystkich przypisanych oskarżonemu czynów. Jest jasne, że przy wniesieniu apelacji wyłącznie na korzyść Sąd odwoławczy nie mógł uzupełnić opisu czynu o brakujący opis, który byłby równoznaczny z pominiętym znamieniem; byłoby to bowiem naruszenie przepisu art. 434 § 1 k.p.k. Z drugiej zaś strony, przy braku apelacji na niekorzyść Sąd odwoławczy nie mógł także uchylić zaskarżonego wyroku i przekazać sprawy do ponownego rozpoznania, albowiem uzupełnienie opisu czynu nie byłoby możliwe z uwagi na przepis art. 443 k.p.k. Już tylko na marginesie podnieść należy, że w obecnym stanie prawnym, nawet gdyby złożono apelację na niekorzyść niedotyczącą tego elementu (tj. braku opisu czynu w wyroku pomimo dokonania ustaleń w uzasadnieniu wyroku), a dotyczącą np. wymiaru kary, to zważywszy na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2016 r., I KZP 10/16 (OSNKW 2016,

z. 12, poz. 79), nie byłoby możliwe osiągnięcie celu w postaci uzupełnienia opisu czynu o pominięte znamię (ustalone w uzasadnieniu wyroku) przy wykorzystaniu przepisu art. 440 k.p.k. jako podstawy uchylenia wyroku (taką możliwość wskazywano np. w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2007 r. IV KK 210/07, R-OSN KW 2007, poz. 1858; z dnia 10 czerwca 2010 r., IV KK 1/10, LEX nr 590282; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2013 r., IV KK 402/12, OSN KW 2013, z. 9, poz. 81). Skoro sąd odwoławczy – zgodnie ze wskazaną uchwałą – powinien stosować przepisy nowe, tj. znowelizowane ustawą z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 437), to uchylenie wyroku na niekorzyść jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach art. 439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości (art. 440 k.p.k.). Żadna z tych okoliczności w takim układzie nie wchodzi w rachubę – **wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt V KK 372/16**

- Przepis art. 413 k.p.k. określa, co każdy wyrok powinien zawierać. Niezbędnym elementem wyroku jest więc przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu (art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k.), zaś w przypadku wyroku skazującego dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikacji prawnej (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.). (...). To, za co oskarżeni zostali skazani, musi wynikać z treści wyroku i nie może być odczytywane z akt sprawy i z treści aktu oskarżenia – **wyrok Sądu Najwyższego z 1 października 2014 r., sygn. akt II KK 69/14**

Rozdział 10.

Jak czytać akta egzaminacyjne na egzaminie zawodowym?

Każdy prawnik zajmujący się prawem karnym ma wyrobioną własną metodykę zapoznawania się z aktami sprawy pod kątem sporządzenia środka odwoławczego. Poniższe uwagi skierowane są do tych, którzy nie mają jeszcze wypracowanej własnej metodyki pracy i potrzebują delikatnego ukierunkowania.

1. Akta zaczynamy czytać od wyroku (samej sentencji):

- *szukamy błędów o charakterze materialnoprawnym, które wynikają już tylko z samej sentencji wyroku, bez konieczności czytania na tym etapie całości akt, w tym m.in., czy z sentencji nie wynika:*
 - *brak kompletu znamion czynu przypisanego oskarżonemu (czyn z art. 286 § 1 k.k., przypisany oskarżonemu, nie zawiera sformułowania „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej” albo czyn z art. 222 § 1 k.k. zamiast znamion „podczas lub w związku z wykonywaniem czynności służbowej” zawiera sformułowanie „podczas lub w trakcie wykonywania czynności służbowej”);*
 - *sąd przekroczył ustawowe granice wymiaru orzeczonej wobec oskarżonego kary lub środka karnego (np. orzekł karę 16 lat pozbawienia wolności, albo karę 4 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 177 § 1 k.k., albo 16 lat zakazu prowadzenia pojazdów);*
 - *sąd orzekł przepadek, w sytuacji gdy przypisane oskarżonemu przestępstwo nie przewiduje takiej możliwości (zob. art. 44 § 7 k.k.) – sprawdzamy tym samym, czy wszystkie zastosowane przez sąd instytucje części ogólnej Kodeksu karnego mają właściwe podstawy prawne i umocowanie w ustawie;*
- *sprawdzamy okres przedawnienia przestępstwa przypisanego oskarżonemu;*
- *sprawdzamy, czy przypisane przestępstwo ma charakter czynu ściganego publicznoskargowo, ale na wniosek pokrzywdzonego, czy też jest*

prywatnoskargowe – tak, by później zweryfikować w aktach, czy skutecznie złożony został wniosek o ściganie, czy oskarżyciel prywatny w terminie złożył akt oskarżenia, czy nie było podstaw do umorzenia postępowania wobec ewentualnego niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzeniu pojednawczym/rozprawie¹¹⁷;

2. Następnie porównujemy opis czynu przypisanego w sentencji wyroku do czynu zarzucanego aktem oskarżenia:

- *sprawdzamy, czy nie doszło do zmiany kwalifikacji prawnej czynu i jeśli wynikiem takiego porównania jest wniosek, że sąd zmienił kwalifikację na niekorzyść oskarżonego¹¹⁸, to w dalszej kolejności szukamy w protokołach rozpraw, czy sąd pouczył o takiej możliwości, zgodnie z art. 399 § 1 k.p.k., a także czy odroczył rozprawę w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 399 § 2 k.p.k. – w odniesieniu do tego zagadnienia zob. jednak uwagi zawarte w podrozdziale 9.15;*
- *sprawdzamy, czy akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, czy też subsydiarny. A jeśli ten drugi – wówczas sprawdzamy, czy zachowane zostały warunki do wniesienia tego aktu oskarżenia (czy akt oskarżenia wniesiony został w terminie, czy zachowane zostały wszystkie przesłanki z art. 55 § 1 k.p.k.) pod kątem ewentualnej bezwzględnej przyczyny odwoławczej w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela (zob. podrozdział 6.3.9.).*

3. Następnie czytamy uzasadnienie wyroku i zaznaczamy sobie te kwestie, które naszym zdaniem ustalone zostały w sposób niekorzystny dla oskarżonego, np. sąd dał wiarę świadkowi, który pomawia oskarżonego lub ocenił dokument albo opinię biegłego w sposób dla oskarżonego niekorzystny. Następnie szukamy w uzasadnieniu wyroku wyjaśnienia, z jakiego powodu sąd ustalił kwestionowane przez nas fakty w określony sposób, tj. z jakich konkretnie dowodów

¹¹⁷ Zob. art. 491 § 1 k.p.k. i art. 496 § 3 k.p.k.

¹¹⁸ Ewentualnie, czy możliwa zmiana kwalifikacji prawnej czynu nie wymaga od oskarżonego zmiany taktyki bądź rewizję dotychczas przyjętej linii obrony.

wyprowadził określone wnioski i dlaczego. Robimy tak po to, by ustalić, na czym skupić uwagę pod kątem fragmentaryczności lub dowolności w zakresie oceny zgromadzonego materiału dowodowego bądź pominięcia jakichś dowodów, mimo że naszym zdaniem dowody te podważają ustalony przez sąd stan faktyczny. Podobnie, zapoznajemy się z interpretacją prawa przedstawioną przez sąd w uzasadnieniu po to, by zweryfikować, czy zaprezentowany sposób rozumienia określonych norm prawa karnego jest zgodny z utrwaloną linią orzeczniczą i stanowiskiem doktryny.

4. Po przeczytaniu ww. dokumentów, wiemy już czego sprawa dotyczy i gdzie są elementy, na które musimy zwrócić szczególną uwagę, czytając akta. **Zapoznajemy się zatem po kolei z całością zadania egzaminacyjnego**, zaznaczając sobie te fragmenty, które budzą nasze wątpliwości i będą wymagały dalszej weryfikacji.

Czytanie akt w innej kolejności rodzi ryzyko rozproszenia uwagi na szereg mało istotnych uchybień (np. potencjalnych licznych przypadków obrazu art. 7 k.p.k.), co może spowodować brak czasu na wyczerpujące opisanie kluczowych problemów. Z mojego doświadczenia wynika, że w apelacjach pojawiają się liczne zarzuty, mające całkowicie drugorzędne znaczenie i marginalny wpływ na treść zapadłego orzeczenia, dodatkowo z bardzo wyczerpującym i niekiedy nawet prawidłowym uzasadnieniem. Nierzadko zdającym nie wystarcza jednak czasu na opisanie uchybień istotniejszych, tj. takich, które doprowadziłyby do zmiany wyroku co do istoty lub do jego uchylenia. Tymczasem umiejętność właściwego selekcjonowania problemów i dostrzegania nie wszystkich, ale kluczowych i oczekiwanych przez autorów kasusów egzaminacyjnych błędów sądu I instancji, jest również jednym z kryteriów dokonywanej oceny pracy egzaminacyjnej.

Niezależnie od powyższego, warto sprawdzić akta pod kątem każdej z poszczególnych przesłanek z art. 439 § 1 k.p.k. oraz z art. 17 § 1 k.p.k., ponieważ w zadaniach egzaminacyjnych z reguły pojawia się bezwzględna przyczyna odwoławcza. W ramach samokontroli warto po kolei sprawdzić, czy właściwy sąd orzekł w sprawie oskarżonego, czy skład sędziowski na każdej rozprawie był ten sam, czy mamy komplet znamion, czy czyn przypisany

oskarżonemu nie jest przedawniony, czy złożony został wniosek o ściganie, jeśli ustawodawca wymaga złożenie takiego wniosku itd.

Jeśli coś budzi Waszą wątpliwość, sprawdźcie przepis bądź orzecznictwo raz jeszcze. Nie polegajcie wyłącznie na swojej pamięci, bo ta bywa mylna, a przepisy zmienne ☺.

